



---

## CONTRATOS PARTE ESPECIAL

---

## INTRODUCCIÓN

El contenido del apunte de Contratos Parte Especial dice relación con el estudio particular y pormenorizado de los principales contratos nominados e innominados presentes en nuestro ordenamiento jurídico.

Recordemos que los contratos son actos jurídicos bilaterales o convenciones, que generan derechos y obligaciones. Recordemos también que los actos jurídicos constituyen la manifestación más concreta de la autonomía privada, pues permiten a las personas regular libremente sus propias relaciones jurídicas dentro de los márgenes necesarios para una adecuada convivencia en sociedad. Así, los contratos son una de las principales vías por medio de las cuales las personas establecen relaciones jurídicas de manera voluntaria.

La diversidad de contratos que estudiaremos en este apunte dan cuenta de la variedad de vínculos jurídicos que las personas pueden constituir y, por consiguiente, las variadas formas en las cuales pueden satisfacer sus intereses de manera jurídica. En otras palabras, contratos parte especial es una de las materias más concretas y prácticas del derecho privado. Si nos imaginamos el derecho civil patrimonial como un árbol, contratos parte especial estaría al nivel de sus ramas.

Por su carácter concreto y práctico, los contratos se encuentran reglamentados de manera bastante detallada por el legislador. Un control adecuado de estas materias supone un manejo preciso de las reglas particulares de cada contrato. Recomendamos encarecidamente utilizar el código durante el estudio, pues la literalidad de los términos del legislador es sumamente relevante.

En la misma línea de lo anterior, debemos tener en cuenta que a los contratos les resultan aplicables todas las reglas y principios generales que hemos estudiado hasta ahora. Así, al abordar el estudio de este apunte, conviene tener en mente los contenidos estudiados en los apuntes anteriores, para efectos de lograr captar de manera cabal y plena la forma sistemática en que está construido nuestro derecho civil.

## INDICE

|                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Promesa .....                                                     | 6  |
| 1.1 Concepto .....                                                   | 6  |
| 1.2 Ubicación del contrato de promesa en el CC.....                  | 7  |
| 1.3 Características del contrato de promesa .....                    | 7  |
| 1.4 La promesa unilateral de celebrar un contrato bilateral .....    | 8  |
| 1.5 Diferencias entre la promesa y el contrato de opción .....       | 9  |
| 1.6 Requisitos del contrato de promesa .....                         | 11 |
| 1.7 La lesión enorme en el contrato de promesa .....                 | 16 |
| 1.8 Efectos del contrato de promesa .....                            | 18 |
| 2. Compraventa .....                                                 | 19 |
| 2.1 Generalidades.....                                               | 19 |
| 2.2 Formas del contrato de compraventa .....                         | 20 |
| 2.3 La cosa vendida .....                                            | 23 |
| 2.4 El precio .....                                                  | 26 |
| 2.5 Capacidad para celebrar el contrato de compraventa .....         | 28 |
| 2.6 Modalidades del contrato de compraventa .....                    | 31 |
| 2.7 Efectos del contrato de compraventa .....                        | 32 |
| 2.7.1 Obligaciones del vendedor.....                                 | 32 |
| 2.7.1.1 Obligación de entregar la cosa vendida .....                 | 32 |
| 2.7.1.2 Saneamiento de la cosa vendida .....                         | 38 |
| 2.7.1.2.1 Saneamiento de la evicción .....                           | 39 |
| 2.7.1.2.2 Saneamiento de los vicios redhibitorios .....              | 44 |
| 2.7.2 Obligaciones del comprador.....                                | 47 |
| 2.7.2.1 Obligación de recibir la cosa comprada.....                  | 47 |
| 2.7.2.2 Obligación de pagar el precio .....                          | 48 |
| 2.8 Pactos accesorios al contrato de compraventa .....               | 50 |
| 2.9 De la rescisión de la venta por lesión enorme.....               | 52 |
| 3. Mandato.....                                                      | 55 |
| 3.1 Generalidades.....                                               | 55 |
| 3.2 Clasificación del contrato de mandato .....                      | 56 |
| 3.3 Partes, intereses y capacidad en el mandato .....                | 58 |
| 3.4 Relación entre mandato y representación .....                    | 59 |
| 3.4.1 Mandato sin representación .....                               | 60 |
| 3.4.2 Mandato con representación .....                               | 61 |
| 3.5 Subcontratación en el mandato .....                              | 61 |
| 3.5.1 El mandante autorizó expresamente la delegación.....           | 61 |
| 3.5.2 El mandante nada dice respecto de la delegación .....          | 62 |
| 3.5.3 La delegación ha sido prohibida por el mandante.....           | 64 |
| 3.6 Clases de mandato .....                                          | 64 |
| 3.7 Efectos del contrato de mandato respecto de las partes .....     | 65 |
| 3.7.1 Obligaciones del mandatario .....                              | 65 |
| 3.7.1.1 Obligación de ejecutar el encargo .....                      | 65 |
| 3.7.1.1.1 Casos en que la ley lo autoriza a obrar de otro modo ..... | 66 |
| 3.7.1.1.2 Prohibiciones o limitaciones legales.....                  | 66 |

|                                                                            |     |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|
| 3.7.1.2 Extralimitación del mandatario en sus facultades .....             | 67  |
| 3.7.1.2.1 Resp. del mandatario frente al mandante.....                     | 67  |
| 3.7.1.2.2 Resp. del mandante frente a terceros.....                        | 68  |
| 3.7.1.2.3 Resp. del mandatario frente a terceros .....                     | 69  |
| 3.7.1.3 Obligación de rendir cuenta .....                                  | 69  |
| 3.7.2 Obligaciones del mandante.....                                       | 70  |
| 3.8 Efectos del contrato de mandato respecto de terceros .....             | 72  |
| 3.8.1 Los vicios del consentimiento y el dolo del mandatario .....         | 73  |
| 3.9 Terminación del mandato .....                                          | 74  |
| 3.10 Actos ejecutados después de expirado el mandato .....                 | 78  |
| 4. Cesión de derechos .....                                                | 79  |
| 4.1 Generalidades .....                                                    | 79  |
| 4.2 Cesión de créditos personales .....                                    | 79  |
| 4.2.1 Naturaleza jurídica de la cesión de créditos .....                   | 80  |
| 4.2.2 Formalidades de la cesión .....                                      | 80  |
| 4.2.3 Efectos de la cesión .....                                           | 82  |
| 4.3 Cesión del derecho real de herencia .....                              | 83  |
| 4.3.1 Maneras de efectuar la cesión .....                                  | 84  |
| 4.3.2 Tradición del derecho real de herencia .....                         | 85  |
| 4.3.3 Efectos de la cesión .....                                           | 86  |
| 4.3.4 Responsabilidad en la cesión .....                                   | 86  |
| 4.4 Cesión de derechos litigiosos .....                                    | 86  |
| 4.4.1 Quién puede cederlos .....                                           | 87  |
| 4.4.2 Efectos de la cesión .....                                           | 88  |
| 5. Transacción .....                                                       | 89  |
| 5.1 Generalidades .....                                                    | 89  |
| 5.2 Características .....                                                  | 89  |
| 5.3 Quiénes pueden transigir .....                                         | 90  |
| 5.4 Objeto de la transacción .....                                         | 90  |
| 5.5 Nulidad de la transacción .....                                        | 91  |
| 5.6 Efectos de la transacción .....                                        | 92  |
| Los contratos accesorios .....                                             | 95  |
| 6. Prenda .....                                                            | 97  |
| 6.1 Generalidades .....                                                    | 97  |
| 6.2 Clasificación y características .....                                  | 97  |
| 6.3 Obligaciones susceptibles de garantizarse por medio de la prenda ..... | 98  |
| 6.4 Capacidad de las partes .....                                          | 99  |
| 6.5 Bienes susceptibles de darse en prenda .....                           | 100 |
| 6.6 Efectos del contrato de prenda .....                                   | 101 |
| 6.7 Extinción de la prenda .....                                           | 106 |
| 6.8 Prenda sin desplazamiento .....                                        | 107 |
| 7. Hipoteca .....                                                          | 109 |
| 7.1 Definición. Derecho real de hipoteca y contrato de hipoteca .....      | 109 |
| 7.2 Características del derecho real de hipoteca .....                     | 110 |
| 7.3 Características del contrato de hipoteca .....                         | 111 |
| 7.4 Clases de hipoteca .....                                               | 113 |
| 7.5 Elementos de la hipoteca .....                                         | 114 |

|                                                                       |     |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|
| 7.5.1 Personas que pueden hipotecar .....                             | 114 |
| 7.5.2 Formas del contrato de hipoteca .....                           | 115 |
| 7.5.3 Cosas que pueden hipotecarse .....                              | 115 |
| 7.5.4 La especialidad de la hipoteca .....                            | 117 |
| 7.6 Efectos de la hipoteca .....                                      | 119 |
| 7.6.1 Efectos en relación al inmueble hipotecado .....                | 119 |
| 7.6.2 Efectos con respecto al constituyente .....                     | 120 |
| 7.6.2.1 La clausula de no enajenar en la hipoteca .....               | 120 |
| 7.6.3 Efectos respecto del acreedor hipotecario .....                 | 121 |
| 7.7 Extinción de la hipoteca .....                                    | 125 |
| 8. Fianza .....                                                       | 128 |
| 8.1 Concepto .....                                                    | 128 |
| 8.2 Características .....                                             | 128 |
| 8.3 Clasificaciones de la fianza .....                                | 129 |
| 8.4 Requisitos del contrato de fianza .....                           | 131 |
| 8.5 Personas obligadas a rendir fianza .....                          | 132 |
| 8.6 Calidades que debe reunir el fiador .....                         | 132 |
| 8.7 Efectos de la fianza entre acreedor y fiador .....                | 133 |
| 8.7.1 Antes de que el acreedor reconvenga al fiador .....             | 133 |
| 8.7.2 Después de que el acreedor reconvenga al fiador .....           | 133 |
| 8.8 Efectos de la fianza entre el fiador y el deudor .....            | 136 |
| 8.9 Efectos de la fianza entre los cofiadores .....                   | 139 |
| 8.10 Extinción de la fianza .....                                     | 139 |
| Contratos reales .....                                                | 140 |
| 9. Comodato .....                                                     | 142 |
| 9.1 Generalidades .....                                               | 142 |
| 9.2 Efectos del comodato .....                                        | 142 |
| 9.3 Comodato precario .....                                           | 144 |
| 10. Mutuo .....                                                       | 145 |
| 10.1 Generalidades .....                                              | 145 |
| 10.2 Requisitos del mutuo .....                                       | 146 |
| 10.3 Efectos del contrato de mutuo .....                              | 146 |
| 11. Depósito .....                                                    | 150 |
| 11.1 Generalidades .....                                              | 150 |
| 11.2 Clasificaciones .....                                            | 150 |
| 11.3 Depósito voluntario .....                                        | 150 |
| 11.4 Depósito necesario .....                                         | 152 |
| 11.5 Secuestro .....                                                  | 153 |
| 11.5.1 Secuestro judicial .....                                       | 153 |
| 12. Arrendamiento .....                                               | 155 |
| 12.1 Generalidades .....                                              | 155 |
| 12.2 Características .....                                            | 156 |
| 12.3 Similitud del arrendamiento con otras figuras .....              | 157 |
| 12.4 Arrendamiento de cosas .....                                     | 158 |
| 12.4.1 Efectos del contrato de arrendamiento de cosas .....           | 159 |
| 12.4.2 Extinción del contrato de arrendamiento de cosas .....         | 162 |
| 12.4.3 Normas especiales sobre arrendamiento de predios urbanos ..... | 165 |

|                                                                        |     |
|------------------------------------------------------------------------|-----|
| 12.4.4 Normas especiales sobre arrendamiento de predios rústicos ..... | 167 |
| 12.5 Arrendamiento para la confección de obra material .....           | 168 |
| 12.6 Arrendamiento de servicios .....                                  | 168 |
| 12.7 Contrato de leasing .....                                         | 169 |
| 12.7.1 Efectos del leasing .....                                       | 171 |
| 13. Sociedad .....                                                     | 173 |
| 13.1 Generalidades .....                                               | 173 |
| 13.2 Elementos especiales del contrato de sociedad .....               | 174 |
| 13.3 La personalidad jurídica y la sociedad .....                      | 175 |
| 13.4 Tipos de sociedades .....                                         | 177 |
| 13.5 Sociedad colectiva civil .....                                    | 179 |
| 13.5.1 Disolución de la sociedad .....                                 | 182 |
| 14. Cuasicontratos .....                                               | 184 |
| 14.1 Aspectos generales .....                                          | 184 |
| 14.2 Fundamento: Reparación al enriquecimiento sin causa .....         | 185 |
| 14.3 La agencia oficiosa o gestión de negocios ajenos .....            | 186 |
| 14.3.1 Requisitos .....                                                | 186 |
| 14.3.2 Efectos de la agencia oficiosa .....                            | 187 |
| 14.4 El pago de lo no debido .....                                     | 189 |
| 14.4.1 Requisitos del pago de lo no debido .....                       | 189 |
| 14.4.2 Efectos del pago de lo no debido .....                          | 190 |
| 14.5 La comunidad .....                                                | 191 |
| 14.5.1 Derechos de los comuneros en la comunidad .....                 | 191 |
| 14.5.2 Terminación de la comunidad .....                               | 193 |
| 15. Contratos aleatorios .....                                         | 194 |
| 15.1 Aspectos generales .....                                          | 194 |
| 15.2 El juego y la apuesta .....                                       | 195 |
| 15.3 La renta vitalicia .....                                          | 197 |
| 15.4 El censo vitalicio .....                                          | 199 |
| 16. Contratos modernos .....                                           | 201 |
| 16.1 Aspectos generales .....                                          | 201 |
| 16.2 El factoring .....                                                | 201 |
| 16.3 Contratos de transferencia tecnológica .....                      | 203 |
| 16.4 Contratos de colaboración empresarial .....                       | 205 |
| Anexos .....                                                           | 207 |

## CONTRATOS PARTE ESPECIAL

---

### CAPÍTULO 1. PROMESA

#### 1.1 CONCEPTO.

**Contrato de promesa:** aquel en que dos o más personas se comprometen a celebrar un contrato futuro, en cierto plazo o en el evento de cierta condición, cumpliéndose los demás requisitos legales.

Se distinguen dos contratos:

- 1) Contrato definitivo: el que se celebra cumpliendo con la obligación de hacer originada en el contrato de promesa.
- 2) Contrato preparatorio: aquel del cual nace la obligación de hacer que consiste en celebrar, dentro de un plazo o condición, el contrato definitivo.

Objetivo: generar una obligación de hacer, específicamente una obligación de celebrar en el futuro un acto jurídico, sea unilateral o bilateral.

La promesa tiene una gran importancia práctica. Muchas veces la celebración definitiva de un contrato depende de variadas circunstancias, y en tales situaciones puede ser más favorable para los contratantes no celebrar todavía el contrato. Así, por ejemplo, esperar que se alce un embargo o medida precautoria, o la dictación de una sentencia definitiva, o la necesidad de estudiar prolijamente los títulos de un inmueble, o la obtención de financiamiento, etc.

Recordemos que, en nuestro ordenamiento civil, el proceso de formación del consentimiento no está regulado. Solo el Código de Comercio regula la formación del consentimiento, pero reduciéndolo a la regulación de la oferta y la aceptación. Por esta razón, es importante tener en cuenta que la contratación moderna ha desarrollado prácticas y figuras para que los contratantes puedan reglar las tratativas preliminares, sobre todo en relación a contratos de alta complejidad.

Tales son, por ejemplo, las cartas de intención, los memorándums de entendimiento y las declaraciones o garantías contractuales. Estas figuras corresponden a declaraciones formales de voluntad, por medio de las cuales una (como en las cartas de intención o garantías contractuales) o ambas (como en el caso de los memos) partes formula a la otra declaraciones vinculantes acerca de su intención de que las negociaciones culminen en un contrato, acerca del estado o condición de la o las cosas objeto del contrato que se está negociando, o sobre lo que sea que estimen conveniente. En otras palabras, son figuras intermedias entre la pura negociación y la celebración misma del contrato, por medio del cual las partes pueden cimentar el camino hacia la formación del consentimiento. Por las razones mencionadas más arriba, todas estas figuras corresponden a actos jurídicos innominados en nuestro ordenamiento jurídico.

## 1.2 UBICACIÓN DEL CONTRATO DE PROMESA EN EL CC.

Siendo un contrato típico o nominado, debiera haber estado tratado en la parte del Libro IV donde se encuentran todos los contratos típicos. Pero no es así.

Está tratado en el Art. 1554 CC, en el Título XII del Libro IV, relativo a los efectos de las obligaciones, específicamente la ejecución forzada de la obligación de hacer. No obstante ello, la promesa es un contrato. Y si es una promesa bilateral, le serán aplicables todas las disposiciones propias de este tipo de contratos.

A partir de su ubicación, y del hecho de que el encabezado del art. 1554 CC está regulado en términos negativos, la doctrina tradicionalmente ha entendido que el legislador ha querido regular la promesa de manera restrictiva. Así, se ha entendido que la regla general es que la promesa no produzca efectos obligatorios, a menos que cumpla con los requisitos señalados en la citada norma.

Art. 1554 CC. "La promesa de celebrar un contrato no produce obligación alguna; salvo que concurren las circunstancias siguientes:

1.a Que la promesa conste por escrito;

2.a Que el contrato prometido no sea de aquellos que las leyes declaren ineficaces;

3.a Que la promesa contenga un plazo o condición que fije la época de la celebración del contrato;

4.a Que en ella se especifique de tal manera el contrato prometido, que sólo falten para que sea perfecto, la tradición de la cosa, o las solemnidades que las leyes prescriban.

Concurriendo estas circunstancias habrá lugar a lo prevenido en el artículo precedente."

## 1.3 CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO DE PROMESA.

De acuerdo a la clasificación legal de los contratos:

**1.** Puede ser un **contrato unilateral o bilateral**. Pueden celebrarse promesas unilaterales de contratos unilaterales (Una parte se obliga a celebrar un contrato de prenda), promesas bilaterales de contratos unilaterales (Dos partes se obligan a celebrar un contrato de mutuo), promesas bilaterales de contratos bilaterales (Dos partes se obligan a celebrar un contrato de compraventa) pero se discute la validez de las promesas unilaterales de contratos bilaterales (Una parte se obliga a vender pero la otra no se obliga a comprar).

**2.** Puede ser un **contrato gratuito u oneroso**.

**3.** Si el contrato de promesa es oneroso puede ser **conmutativo o aleatorio**.

**4.** Es un **contrato principal**.

**5.** Es un **contrato solemne**.



Además, podemos agregar:

**1. Es un contrato preparatorio.**

**2. Es un caso en que la modalidad es un elemento de la esencia.**

**3. Es general y de derecho estricto**, simultáneamente. Es un contrato de aplicación general (puede celebrarse promesa de cualquier contrato), pero a su vez es excepcional, pues únicamente será válida la promesa que cumpla los requisitos del Art. 1554 CC.

**4. Tiene por finalidad celebrar otro contrato, por lo tanto, engendra una obligación de hacer, generando una acción que será siempre mueble** (Art. 581 CC).

**5. No admite voluntades tácitas** porque es un **contrato solemne**, ya que debe constar por escrito.

#### **1.4. LA PROMESA UNILATERAL DE CELEBRAR UN CONTRATO BILATERAL.**

**Argumentos a favor de la nulidad (Alessandri, alguna jurisprudencia).**

**1)** No cumple con el Art. 1554 N° 2 CC, porque un contrato en que uno sólo se obligue a vender no produce efecto alguno.

**2)** No se cumple el Art. 1554 N° 4 que exige que en la promesa se especifique de tal modo el contrato prometido que sólo falten para que sea perfecto, la tradición de la cosa o la solemnidades. Así, en el contrato de compraventa, uno de sus requisitos esenciales es el concurso real de las voluntades del vendedor y del comprador. Sin ese requisito, no se concibe la existencia de la compraventa

**3)** En la promesa unilateral de venta queda exclusivamente a voluntad del comprador contraer las obligaciones inherentes a su calidad de tal. Esto significa que queda subordinada una condición meramente potestativa de su sola voluntad, obligación que es nula (Art. 1478 CC).

Respuesta: el posible comprador no contrae obligación alguna que dependa de su mera voluntad, sino que se reserva resolver si compra o no, es decir, la facultad de prestar o no su consentimiento, pero no de cumplir o no la obligación contraída.

**Argumentos a favor de la validez (Claro Solar y la mayor parte de la doctrina actual).**

**1)** Ninguna disposición legal exige que en la promesa ambas partes se obliguen recíprocamente.

**2)** La exigencia del Art. 1554 N° 4 CC no significa que el contrato de promesa haya de tener la misma esencia y naturaleza del contrato prometido.

**3)** Hay numerosas disposiciones que revelan el espíritu de aceptar, en materia de

promesa de compraventa, obligaciones unilaterales. Ej. Pacto de retroventa: es la obligación unilateral que se impone al comprador de vender a su turno la cosa que ha comprado a la misma persona que se la vendió.

Se concluye que la promesa aceptada es un perfecto contrato unilateral que obliga al prometiende. En efecto, debe distinguirse la oferta para celebrar un contrato, de la promesa de celebrar un contrato.

### **1.5 DIFERENCIA ENTRE EL CONTRATO DE PROMESA UNILATERAL DE CELEBRAR UN CONTRATO BILATERAL Y EL CONTRATO DE OPCIÓN.**

**Promesa unilateral de contrato bilateral:** existe una promesa de celebrar un contrato definitivo, en la cual sólo una de las partes resulta obligada, pero el contrato definitivo no existe. Sólo se genera una obligación de hacer.

**Contrato de opción:** el contrato definitivo ya existe, pero en virtud de una cláusula especial, se dejan pendientes sus efectos a la espera de que el destinatario de la opción haga uso de ésta. Una vez que se ejerza la opción, y sin la necesidad de que la contraparte concorra a "re-celebrar" el contrato definitivo, éste producirá todos sus efectos.

- Es un contrato preparatorio y general.
- Si bien es un contrato innominado desde el punto de vista del derecho civil, se encuentra regulado a propósito del Código de Minería, artículo 169.
- En tanto contrato innominado, su naturaleza jurídica se ha discutido en doctrina. Algunos lo asimilan erróneamente a la promesa unilateral. Otros sostienen que consiste en la oferta unilateral de contrato que formula una de las partes a la otra de manera completa, temporal e irrevocable. Se hace a favor de otra parte, la cual se limita a declararla admisible expresa o tácitamente, reservándose libremente la facultad de aceptar dentro del plazo que las partes hayan pactado. También se ha sostenido que es una modalidad de contratación en la cual el contrato definitivo queda perfecto, pero sujeto a la condición suspensiva de que el destinatario de la opción acepte.
- Hay conformidad expresa o tácita del destinatario de esta oferta, quien se guarda la libertad de aceptar en el futuro. Básicamente las preguntas que cabe hacer son dos:

#### **A.- ¿Es un acto jurídico unilateral o es un acto jurídico bilateral?**

- Es un acto jurídico bilateral, puesto que hay un acuerdo de voluntades. Es cierto que hay una manifestación de voluntad, pero que ha sido declarada admisible por la otra parte, por lo que, hay un acuerdo de voluntades en torno a esa oferta. Hay un oferente y hay un destinatario que manifiesta su conformidad, lo que ocurre es que el destinatario se guarda su posibilidad de aceptar el contrato que se le propone. Hay una aceptación porque hay un acuerdo entre el oferente y el receptor de la oferta, lo que constituye una convención.

- Es un contrato porque el oferente asume una obligación, asume la obligación de

no retractarse. Ahora bien, dentro de los contratos es un contrato preparatorio porque prepara la celebración de otro contrato, o bien, prepara el nacimiento de una relación jurídica. Hay quienes sostienen que sería un contrato definitivo en el sentido de que sería un contrato sujeto a una condición suspensiva, la cual es la aceptación de la otra parte. Dentro de los contratos preparatorios es un contrato preparatorio general que permite celebrar el contrato de opción en relación con cualquier contrato: Opción de CV, Opción de Comodato, etc., entonces no se limita sólo para comprar. Por último, es un contrato innominado y atípico, puesto que no se encuentra regulado en el Código Civil. Solo está regulado en materia minera.

**B.- ¿Tiene individualidad en cuanto contrato preparatorio, o bien, estamos simplemente ante un contrato de promesa o contrato de promesa unilateral?**

La primera impresión que se tiene es que es un contrato de promesa unilateral, ya que, pareciera que una parte se obliga a aceptar o no aceptar. Se cree que una de las partes resulta obligada, y la otra no.

- Como contrato de promesa unilateral: Una parte de la doctrina sostenía que era un contrato de esta característica, como el profesor Álvaro Puelma (libro sobre contratos innominados).

- Como especie dentro de los contratos preparatorios: Tiene individualidad propia dentro de los contratos preparatorios, por lo cual, es distinto al contrato de promesa. El profesor Fernando Fueyo analiza largamente el contrato de opción. En esta materia, Fueyo destaca las diferencias:

1.

- La promesa unilateral de celebrar un contrato constituye un contrato en razón del cual, quien resulta obligado, resulta obligado a hacer, es decir, resulta obligado en el futuro a celebrar un nuevo contrato. La otra parte no asume obligación de celebrar ese contrato, pero si esta parte quiere celebrarlo, lo celebra.
- Pero en el contrato de opción, el oferente no tiene que celebrar en el futuro un nuevo contrato, puesto que, el oferente ha resultado obligado en razón del contrato de opción, y no tiene que manifestar nuevamente su voluntad, y si no tiene que manifestar nuevamente su voluntad, quiere decir que no es necesario un nuevo acuerdo de voluntades, porque simplemente cuando el destinatario de la oferta acepta el contrato, se forma el consentimiento. Basta, entonces, la pura aceptación sin compeler al oferente a tener que formar el consentimiento respecto de un nuevo contrato.

2.

- En la promesa unilateral hay dos contratos.
- En el contrato de opción hay un sólo contrato. Esto porque no hay nuevamente un acuerdo de voluntad.

3.

- En la promesa unilateral no es esencial que ésta y el contrato definitivo tengan la misma esencia y naturaleza.
- En el contrato de opción, el contrato queda determinado con todos sus

elementos en la sola oferta, por lo mismo, se dice que es una oferta completa. La oferta del oferente contempla todos los elementos del contrato y no solamente los elementos esenciales, a tal punto que, el optante (destinatario de la oferta) basta con que simplemente acepte, puesto que, ya están incorporados todos los elementos del contrato y no estará viciado.

#### **Utilidad práctica del contrato de opción:**

- Existencia de gastos anteriores al contrato, los que tendría lugar por la necesidad que tienen los nuevos actores de un mercado de tener acceso a información referente al mismo.
- El eventual contratante requiere de tiempo para conocer las diversas alternativas que el mercado le ofrece y sus posibles medios de financiamiento.
- Necesidad de la seguridad que precisa el contratante relativo a que las ofertas enunciadas se mantienen firmes.
- En materia de comercio exterior existiría otra razón en que se sustentaría, la competencia. Lo exportadores acostumbran otorgar opción firme, a plazo, a sus posibles clientes, para efectos de que estos no sean atraídos por las ofertas de otros actores del mercado.

#### **1.6 REQUISITOS DEL CONTRATO DE PROMESA.**

|                                                                |
|----------------------------------------------------------------|
| <b>Art. 1554 N° 1 CC.</b> "Que la promesa conste por escrito;" |
|----------------------------------------------------------------|

Debe cumplirse siempre, aun cuando el contrato prometido sea consensual. Por eso la promesa es **siempre solemne**. Basta un instrumento privado, aunque se prometa la celebración de un contrato que para su validez requiera escritura pública. No exige el legislador que el contrato conste de un solo instrumento. Este requisito elimina la posibilidad de consentimiento tácito.

Especial **discusión** se ha generado respecto a la **promesa de compraventa de bienes raíces**:

I. Las razones esgrimidas en algunos fallos iniciales para concluir que la promesa de venta de bienes raíces debe otorgarse por escritura pública para ser válida, fueron las siguientes:

1. Si es necesaria tal escritura para la venta de los inmuebles, también lo debe ser para el contrato de promesa de venta de esos mismos bienes, pues la disposición del art. 1801 CC, por ser de carácter especial, debe prevalecer sobre la de carácter general, el art. 1554.
2. La promesa de venta es un accesorio del contrato de venta y, en consecuencia, deben aplicársele los preceptos que reglan éste, entre los cuales está el que exige otorgamiento de escritura pública.
3. Si se diere valor legal a una promesa de compraventa de bienes raíces otorgada por documento privado, resultaría que teniendo según el art. 1553 del CC el acreedor el derecho de pedir que se apremie al deudor a la ejecución del hecho convenido, se le obligaría a vender, y esto, sin embargo,

no podría hacerse en virtud de un documento privado.

II, La tendencia mayoritaria de la jurisprudencia, que abarca también los fallos más recientes, concluye, por el contrario que la promesa de celebrar una compraventa de bienes raíces no necesita, para su validez, escritura pública; basta un instrumento privado:

1. El art. 1554 CC exige que la promesa conste por escrito, y “escrito” es todo documento. Si se aceptara que la promesa debe constar por escritura pública, se llegaría a la conclusión de que “escrito” es sinónimo de “escritura pública”, lo que es contrario a la ley.
2. El art. 1801 CC exige escritura pública para la venta de inmuebles, y como las solemnidades son excepcionales y deben aplicarse restrictivamente, no pueden extenderse al contrato de promesa,
3. Aceptar que la promesa de venta de un bien raíz requiere escritura pública, significa aceptar que no existe la debida correspondencia o armonía en un mismo artículo, ya que exigiéndose en el número 1 del art. 1554 CC escritura pública, sería ilógico el número 4 del mismo artículo, que establece que pueden faltar en la promesa las solemnidades del contrato prometido (y la primera de ellas es la escritura pública). Siendo la promesa y el contrato prometido dos convenciones diferentes, el legislador no ha entendido someter a la una a las solemnidades propias del otro.
4. En los casos en los cuales la ley ha querido que la promesa se celebre por escritura pública, así lo ha dispuesto expresamente (Por ejemplo: Art. 1787 CC, donaciones por causa de matrimonio; o en el artículo 1736 Nº 7 CC, en la sociedad conyugal; o en el caso del artículo 1204 CC, referido a la promesa de no disponer de la cuarta de mejoras).

**Art. 1554 Nº 2 CC.** “Que el contrato prometido no sea de aquellos que las leyes declaran ineficaces;”

- **¿Qué debe entenderse por eficacia del contrato?**

Se refiere a que el **contrato prometido no adolezca de vicios de nulidad**. Por eficacia del contrato prometido debe entenderse, en un sentido amplio, que éste produzca efectos jurídicos, que establezca un vínculo de derecho entre los contratantes. La ley niega sus efectos a la obligación de hacer contraída, cuando ella recae sobre un contrato que carecerá de causa o de objeto, o que tendrá un objeto o causa ilícitos.

Esta exigencia es aplicación del principio general de que el objeto de los contratos debe ser lícito. Así, por ejemplo, no podría prometerse la venta de bienes entre padres e hijos no emancipados o entre cónyuges no separados judicialmente; también carece de validez una promesa en que una de las partes se obliga a ejecutar un hecho inmoral o prohibido; o un contrato que contenga una obligación física o moralmente imposible.

- **¿En qué momento debe ser eficaz el contrato?**

El **contrato prometido debe ser eficaz al momento de celebrarse la promesa**. Es necesario que el contrato prometido tenga eficacia, que sea jurídicamente lícito y posible, al momento en que se suscribe la promesa.

**¿Qué ocurre si el contrato prometido fuere válido al tiempo de la promesa pero nulo al momento de exigir la celebración del contrato prometido?** La Corte Suprema, por sentencia de 24 de enero de 2011, declaró que si la compraventa va a ser nula, la promesa de compraventa no produce obligación alguna, rechazando una demanda de cumplimiento del contrato interpuesta por el promitente comprador. En el caso, el contrato prometido no sería eficaz a consecuencia de haberse dictado la Ley Nº 19.253 (Diario Oficial de fecha 5 de octubre de 1993), conocida como “Ley Indígena”, que prohíbe la enajenación de tierras indígenas a personas que no pertenezcan a la etnia del vendedor.

- **La ineficacia del contrato ¿se puede generar por el incumplimiento de requisitos de fondo o de forma?**

Cabe precisar que **la ley se refiere a los contratos ineficaces o nulos por incumplimiento de requisitos de fondo, no de forma**, dado que los últimos perfectamente pueden cumplirse al celebrar el contrato prometido. Por ello, es válida la promesa de compraventa de bienes de incapaces, en la que se omite la autorización judicial, sin perjuicio que esta no puede faltar al celebrar el contrato definitivo. La exigencia del art. 1554 Nº 2 no se refiere a las formalidades necesarias para su validez en atención a la calidad de las personas que en él intervienen, puesto que el Nº 4 de la misma disposición legal autoriza la omisión de tales solemnidades en la promesa. Así ha concluido la mayoría de la jurisprudencia y así también concluye Alessandri. Por lo demás, cuando la ley exige que la formalidad habilitante conste también en el contrato de promesa, lo ha dicho: por ejemplo, en el artículo 1749 CC, respecto de la autorización de la mujer, cuando el marido en régimen de sociedad conyugal, celebra un contrato de promesa de venta de un bien raíz social.

Sin embargo, debe advertirse que algunos fallos han sostenido una posición contraria: Por ejemplo: un fallo de la Corte de Santiago del año 1964, señala que es nulo el contrato de promesa de un bien raíz perteneciente en común a la madre y a sus hijos menores de edad, celebrado por aquélla por sí y en representación legal de los menores, sin autorización judicial.

Por otra parte, a pesar de lo establecido en el art. 1464 Nº 3 CC, en relación con el art. 1810 CC, nada obsta a que pueda celebrarse un contrato de promesa referido a bienes embargados u objeto de medidas precautorias (salvo si fuere la de celebrar actos y contratos sobre una determinada cosa), sin perjuicio que tales embargos o prohibiciones se alcen antes o al momento de celebrar el contrato prometido.

**Art. 1554 N° 3 CC.** "Que la promesa contenga un plazo o condición que fije la época de la celebración del contrato;"

La modalidad es un elemento de la esencia del contrato de promesa. No hay promesas de contratos puras y simples.

**a) Plazo:**

Se ha discutido en la doctrina y en la jurisprudencia la naturaleza jurídica del plazo pactado en el contrato de promesa.

- Para la mayoría de los autores, se trata de un plazo suspensivo, es decir, posterga la exigibilidad de las obligaciones derivadas de la promesa. Vencido el plazo, nace el derecho de exigir el cumplimiento de la obligación de celebrar el contrato prometido. La jurisprudencia no ha sido unánime.
- Algunos fallos han sostenido que el plazo señalado en la promesa de venta para celebrar el contrato es extintivo por su naturaleza, pues, una vez vencido, cesa o se extingue la obligación contraída por el promitente vendedor de ejecutar el contrato prometido. Si el promitente comprador no hizo uso de su derecho a exigir la celebración del contrato dentro del plazo estipulado, el promitente vendedor podrá excepcionarse alegando que caducó el derecho del promitente comprador. Para parte de la doctrina en estos fallos, operaría una causal de caducidad y no de prescripción. En efecto, si ambas partes no dan cumplimiento a una promesa con plazo extintivo y ninguna desarrolla actividades ni persevera en el contrato dentro del término estipulado, el solo transcurso de éste acarrea la ineficacia posterior de la promesa. La promesa deja de producir efectos.
- Otros fallos, han concluido, igual que la doctrina, que estamos ante un plazo suspensivo. En efecto, como se indica en un fallo de la Corte de Santiago de 1964, la intención de los contratantes al establecer en la promesa de venta que "el plazo para la firma del contrato definitivo será el 5 de enero de 1962 no pudo ser otra que indicar el término, vencido el cual las partes estarían en mora, de conformidad con lo señalado en el artículo 1551 N° 1 del Código Civil. Sostener que vencido tal plazo las obligaciones del promitente se extinguen por la caducidad, significa caer en el absurdo de admitir que el demandante no pudo antes ni después de estar vencido el plazo, exigir el cumplimiento de las obligaciones del promitente vendedor; antes no serían éstas exigibles, y después, tampoco, porque habría caducado el plazo. Estos extremos pugnan con la buena fe con que deben ejecutarse los contratos y contradicen la regla del art. 1562 del CC.
- En otro fallo de 1965, de la Corte Suprema, se reitera la idea que estamos ante un plazo suspensivo, al decir: "Expirado el plazo, nace el derecho de exigir el cumplimiento forzado de la obligación, pues no sería jurídico el estimar que, en tal evento, se han extinguido todos los derechos, puesto que



el plazo fijado carecería de objeto y de efectos jurídicos: la parte renuente podría excusarse alegando que está pendiente el plazo hasta la medianoche de su último día, y llegada ella ya no podría exigirse el cumplimiento de la obligación (...) Pendiente el plazo, no hay posibilidad de solicitar el cumplimiento de la obligación. Pero vencido el plazo, el contratante que desea cumplir, puede constituir en mora al otro contratante, haciéndole saber que por su parte está llano a cumplir en forma y tiempo debidos, a fin de que pueda tener lugar lo que previene el artículo 1553 del CC.”

Aunque en la promesa se estipule que el contrato prometido debe celebrarse “a más tardar” en cierta fecha, no estamos ante un plazo fatal y extintivo de derechos. Si se estimara lo contrario, significa que la estipulación del plazo carecería de objeto y de efectos jurídicos. En la práctica, de seguir tal interpretación, nunca sería posible pedir el cumplimiento forzado de una promesa, y el contrato de promesa se convertiría en un acto cuyo cumplimiento quedaría entregado a la mera voluntad de una de las partes, lo que resulta inaceptable.

Distinta es la situación si en la promesa las partes acuerdan que el contrato definitivo debe celebrarse dentro de cierto plazo y que vencido éste, dicha promesa quedará sin efecto. Tal estipulación constituye simplemente un pacto comisorio o una condición resolutoria ordinaria, según los términos en que esté estipulada la cláusula, regida por las reglas que se aplican a tales instituciones.

### **Plazo expreso o tácito.**

Otro aspecto que se ha discutido en la doctrina y jurisprudencia, dice relación con la necesidad de que el plazo sea expreso, o por el contrario, si es admisible un plazo tácito.

Nada obsta a que se estipule un plazo tácito. Como lo señala un fallo del año 1988, no hay inconveniente alguno para estimar que el plazo tácito es válido para los efectos de la promesa de contrato. El plazo tácito es una modalidad que importa certidumbre sobre exigibilidad futura de una obligación ya nacida. Lo tácito no es más que una fórmula sobre medida de tiempo, que indica menor precisión que un plazo expreso, pero no autoriza para calificarse el plazo de impreciso o de vago, mucho menos de ininteligible o inexistente.

Así, por ejemplo, las partes podrían convenir que celebrarán el contrato de compraventa de una máquina trilladora, cuando termine el proceso de cosecha

### **b) Condición.**

Tanto la condición suspensiva como la resolutoria son eficaces.

- Una parte de la doctrina y jurisprudencia sostiene que la condición debe ser determinada, ya que de no ser así, no se determina la época de la celebración (no cumple el Art. 1554 N° 3 CC).



- Otros dan aplicación al plazo de la propiedad fiduciaria para entenderla fallida (5 años).
- Otra parte de la doctrina y jurisprudencia sostiene que no es necesario que la condición sea determinada.

Se puede fijar **un plazo y una condición conjuntamente**. Por ejemplo: las partes pueden estipular que "el contrato prometido se llevará a efecto a más tardar el día 15 de marzo de 2013, una vez que el promitente vendedor obtenga de la Dirección de Obras pertinente, la recepción final de las obras". La expresión "una vez que" implica establecer una exigencia adicional al mero plazo.

**Art. 1554 N° 4 CC.** "Que en ella se especifique de tal manera el contrato prometido, que sólo falten para que sea perfecto, la tradición de la cosa, o las solemnidades que las leyes prescriban."

#### **A. ¿Es posible la promesa de un contrato consensual?**

Algunos autores han sostenido que sólo puede prometerse la celebración de un contrato real o solemne, por lo establecido en el Art. 1554 N° 4 CC. Si el contrato es consensual, el completo acuerdo acerca de sus estipulaciones trae como consecuencia que el contrato quede desde ya perfecto.

Sin embargo, no hay razón de peso para limitar así la norma. Que el contrato se especifique cabalmente no significa que se esté prestando ahora el consentimiento.

#### **B. ¿Significa esto que el contrato debe contener todas y cada una de las cláusulas del contrato definitivo?**

1) Se ha sostenido que es necesario que el contrato prometido esté prácticamente contenido en la promesa, ya que sólo así faltaría, para ser perfecto, la tradición de la cosa o las solemnidades del contrato prometido.

2) La doctrina contraria sostiene que el contrato prometido quede suficientemente especificado si sólo se señalan en la promesa sus elementos esenciales, que permitan distinguirlos de los otros contratos, pudiendo omitirse los elementos de la naturaleza, que la ley los presume, y los meramente accidentales, que se especifican por cláusulas especiales al tiempo de celebrarse el contrato prometido.

- La jurisprudencia ha señalado que la especificación es la necesaria para que no quepa duda en cuanto a la naturaleza del contrato prometido.
- También se ha resuelto que incluso los elementos esenciales de un contrato pueden no quedar especificados en la promesa, con tal que sea posible determinarlos al tiempo de la celebración del contrato definitivo. Ej. Precio de la compraventa.

### **1.7 LA LESIÓN ENORME EN EL CONTRATO DE PROMESA.**

Se ha discutido si es procedente impugnar por lesión enorme el contrato de promesa de compraventa de un inmueble. La discusión se centra en evitar que el

contrato se celebre, considerando que manifiestamente adolecerá de lesión enorme.

Hay dos posturas:

**1. Mayoritaria (jurisprudencia y doctrina en general). No es procedente.**

La compraventa y promesa de compraventa son contratos distintos: el primero genera una obligación de dar y el segundo una de hacer. Los preceptos sobre lesión enorme de los arts. 1888, 1889 y 1896 del CC dicen relación directa y exclusivamente con un contrato de compraventa ya celebrado. No cabe, pues, atacar por dicha lesión un contrato de promesa de venta. No puede excepcionarse el demandado respecto de la obligación que contrajo en la promesa alegando el posible vicio de lesión enorme que podría afectar a la compraventa todavía no celebrada.

La doctrina agrega que parece innegable que la promesa no puede atacarse por lesión enorme, principalmente, porque la acción rescisoria es propia de la compraventa y no puede extenderse a otros contratos por su doble excepcionalidad: constituye una sanción y en nuestro Código, además, específica para contados actos y contratos.

**2. Sería admisible (Planteamiento de Abeliuk).**

Sostiene que al llegar el tiempo de celebrarse el contrato de compraventa prometido, la parte que soportará la lesión enorme al celebrarse el contrato prometido tiene derecho a excepcionarse y por ende a no concurrir a su celebración, arguyendo que no está obligado a ello en virtud de la nulidad de que adolecerá el contrato definitivo. Dos motivos fundamentarían esta conclusión:

a. Sería ilógico permitir que judicialmente se obligue a otorgar el contrato prometido, para que luego el demandado vencido pidiera la rescisión. Se movería inútilmente todo el mecanismo judicial para otorgar un contrato que de todos modos será ineficaz. Lo lógico es que esta ineficacia se plantee y discuta de antemano.

b. El cumplimiento de la promesa no importa sólo otorgar el contrato prometido, sino uno que sea válido y eficaz. Si ello no es ya posible, se produce una imposibilidad jurídica. De esta forma, si la compraventa va a ser nula por cualquier causa (como por ejemplo porque adolecería de lesión enorme) la promesa no produce obligación alguna y debe rechazarse la demanda interpuesta para obtener su cumplimiento.

Sin perjuicio de esto, se debe tener presente lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley Nº 16.742: *"Para los efectos del artículo 1889 del Código Civil, en los contratos de compraventa celebrados en cumplimiento de promesas de sitios que formen parte de un loteo hecho conforme a la Ley General de Construcciones y Urbanización, se entenderá que el justo precio se refiere al tiempo de la celebración del contrato de promesa, cuando dicho precio se haya pagado de acuerdo con las estipulaciones de la promesa"*. Se desprende entonces de este precepto, que **el justo precio se**

**considerará al tiempo de la promesa, pero siempre y cuando dicho precio se hubiere pagado.**

### **1.8. EFECTOS DEL CONTRATO DE PROMESA.**

**Efecto propio:** nacimiento de una obligación de hacer.

- **Si se cumple,** se extingue la promesa y sólo pasa a tener vida el contrato definitivo.
- **Si no se cumple,** podría el acreedor, establecida que sea la existencia de la promesa, solicitar al juez que apremie al contratante negligente para que celebre el contrato, y de negarse éste, dentro del plazo que le señale el tribunal, podrá solicitarse al juez que suscriba dicho contrato por la parte rebelde o que declare resuelto el contrato de promesa y ordene el pago de indemnización de perjuicios, de conformidad al artículo 1553 CC en relación con el art. 1489 CC.

Si el hecho consiste en la suscripción de un documento o en la constitución de una obligación, puede el juez proceder a nombre del deudor, si requerido éste, no lo hace dentro del plazo fijado por el juez (Art. 532 CPC).

Aquí, tiene importancia el título en que consta la promesa. Si consta en un título ejecutivo (escritura pública), podrá solicitarse su cumplimiento de acuerdo a las normas del juicio ejecutivo de obligación de hacer. En caso contrario, deberá prepararse la vía ejecutiva o promoverse previamente una acción ordinaria destinada a declarar la existencia de la obligación de celebrar determinado contrato.

Siendo la obligación que emana del contrato de promesa una obligación de hacer, tiene carácter indivisible. Por tanto, si los deudores son varios, cada uno de ellos puede ser obligado a satisfacer la obligación en el todo. Desde el punto de vista de los acreedores, todos los comuneros, y no sólo uno o algunos de ellos, deben solicitar el cumplimiento del contrato de promesa.

## CAPÍTULO 2. COMPRAVENTA.

### 2.1 GENERALIDADES.

#### 1. Concepto

Art. 1793 CC. "La *compraventa* es un contrato en que una de las partes se obliga a dar una cosa y la otra a pagarla en dinero. Aquélla se dice *vender* y ésta *comprar*. El dinero que el comprador da por la cosa vendida, se llama *precio*."

#### 2. Caracteres

- ❖ **Bilateral:** las partes contratantes se obligan recíprocamente. Las obligaciones de la esencia del contrato son la de dar la cosa y la de pagar el precio.
- ❖ **Oneroso:** cada parte reporta utilidad de la obligación que para con ella se contrae, gravándose recíprocamente.
- ❖ **Generalmente conmutativo:** las prestaciones se miran como equivalentes (Art. 1441 CC). Excepcionalmente es aleatorio: compraventa de las cosas que no existen pero se espera que existan a que se refiere el Art. 1813 CC.  
La compraventa de cosa futura puede ser:
  - Condicional y conmutativa.
  - Pura y simple y aleatoria.
- ❖ **Principal:** subsiste por sí mismo (Art. 1442 CC).
- ❖ **Normalmente consensual:** se perfecciona por el sólo consentimiento de las partes (Art. 1443 CC), salvo las excepciones legales, en las cuales el contrato es solemne.

#### 3. La compraventa es un título traslativo de dominio

De acuerdo a los Arts. 675 y 703 CC, la compraventa es un título traslativo de dominio, esto es, por su naturaleza sirve para transferirlo.

En consecuencia, la compraventa no transfiere el dominio. Esto ocurre con la tradición subsiguiente. Mientras la tradición no se efectúe, comprador y deudor son sólo acreedores.

#### 4. Elementos del contrato de compraventa.

Hay 3 elementos esenciales: consentimiento, cosa y precio.

La formación del consentimiento se rige por las reglas generales. Pero es necesario examinar sobre qué debe recaer el consentimiento y las formas que debe revestir.

La cosa y el precio son el objeto de las obligaciones del vendedor y comprador, respectivamente. Se les aplica la norma del Art. 1460 CC, pero hay reglas particulares.

Además, hay reglas especiales de capacidad.

## **2.2 FORMAS DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA.**

### **1. La regla general**

Art. 1801 inc. 1º CC. "La venta se reputa perfecta desde que las partes han convenido en la cosa y en el precio; salvo las excepciones siguientes."

El consentimiento debe recaer sobre:

**a)** La cosa objeto del contrato. No hay acuerdo sobre la cosa vendida en caso de error:

- sobre la identidad de la cosa (Art. 1453 CC)
- o sobre su sustancia o calidad esencial (Art. 1544 CC)

**b)** El precio. Hay acuerdo cuando el precio en que una parte entiende comprar es el mismo en que la otra entiende vender.

**c)** Venta misma: que una de las partes quiera vender y la otra comprar. Falta el consentimiento cuando hay error sobre la especie del acto o contrato (Art. 1453 CC).

### **2. El consentimiento en las ventas forzadas**

El consentimiento debe manifestarse libre y espontáneamente. Si es resultado de la fuerza, el contrato es nulo.

Pero en las ventas forzadas, el consentimiento no se manifiesta de esta forma. Sin embargo, por el hecho de obligarse, el deudor ha consentido de antemano en las consecuencias de la obligación, entre las cuales está la posibilidad de que el acreedor haga vender bienes para pagarse su crédito, en virtud de la prenda general de los acreedores.

En consecuencia, la venta forzada es una verdadera compraventa.

### **3. Por excepción, la compraventa es solemne**

La compraventa puede estar revestida de solemnidades legales, solemnidades convencionales, o haberse celebrado con arras.

#### **1) SOLEMNIDADES LEGALES:**

**a) ORDINARIAS:** aquellas de que por la ley está revestida la compraventa de cierta clase de bienes. Consisten en el otorgamiento de escritura pública.

La escritura pública es al mismo tiempo:

- requisito para el perfeccionamiento del contrato,
- el único medio de probar la existencia del mismo (Art. 1701 CC).

Art. 1801 inc. 2 CC. La venta de (1) los bienes raíces, (2) servidumbre y (3) censos, y la de una (4) sucesión hereditaria, no se reputan perfectas ante la ley, mientras no se ha otorgado escritura pública.

❖ **Casos en que la ley exige escritura pública para la validez de la venta**

(Art. 1801 inc. 2º CC):

- (1) Compraventa de bienes raíces.
- (2) Compraventa de los derechos de servidumbre y de censo (son bienes raíces porque siempre recaen sobre bienes raíces).
- (3) Compraventa de una sucesión hereditaria.

❖ **Compraventa por intermedio de mandatarios:** no es necesario que el mandato revista las mismas formas que el contrato encomendado al mandatario. El mandato es generalmente consensual (Art. 2123 CC); debe constar por escritura pública sólo cuando la ley lo exige. En consecuencia, no se requiere que el mandato para comprar los bienes del Art. 1801 inc. 2º CC conste por escritura pública. Sin embargo, la doctrina y jurisprudencia estiman generalmente lo contrario.

❖ **La inscripción no es requisito de la compraventa de bienes raíces:** no es solemnidad del contrato, sino la manera de efectuar la tradición.

❖ **Es solemne sólo la venta de inmuebles por su naturaleza:**

- i) Es consensual la compraventa de muebles por anticipación, aunque mientras adhieran al predio son inmuebles por adherencia (Art. 1801 inc. 3º CC en relación al Art. 571 CC).
- ii) Es también consensual la venta de los bienes inmuebles por destinación, pues cuando dejan de estar destinados al uso, cultivo y beneficio del predio, recobran su calidad de inmuebles.

**b) ESPECIALES:** aquellas que la ley exige para la compraventa en atención a las circunstancias particulares en que se celebra o a las personas que intervienen.

- i) Ventas forzadas ante la justicia: se hacen, previa tasación del inmueble y publicación de avisos, en pública subasta, ante el juez (Arts. 485 y ss. CPC). El acta de la venta hace provisoriamente de escritura pública, pero la compraventa debe reducirse a escritura pública, que es suscrita por el rematante y el juez.
- ii) Ventas de bienes pertenecientes a personas incapaces: autorización judicial y subasta pública.

**2) SOLEMNIDADES VOLUNTARIAS:** aquellas que establecen las partes, sea añadiéndolas a las que establece la ley, sea para hacer solemne una compraventa que es naturalmente consensual.

Art. 1802 CC. "Si los contratantes estipularen que la venta de otras cosas que las enumeradas en el inciso 2.º del artículo precedente no se reputa perfecta hasta el otorgamiento de escritura pública o privada, podrá cualquiera de las partes retractarse mientras no se otorgue la escritura o no haya principiado la entrega de la cosa vendida".

Es necesario que las partes estipulen expresamente que el contrato no se reputa perfecto si no se cumple con la solemnidad.

La facultad de retractación se mantiene:

- a) Hasta que se cumpla la solemnidad.
- b) Hasta que haya principiado la entrega: el cumplimiento del contrato es una derogación tácita de la estipulación que hizo solemne el contrato.

### 3) **LAS ARRAS:**

En el párrafo de las formalidades del contrato de compraventa, la ley también se ocupa de las arras.

Para Alessandri, debieron reglamentarse al tratarse de las obligaciones en general, porque podrían utilizarse en cualquier contrato.

Arras: cantidad de dinero u otras cosas muebles que se da:

#### **a) Como garantía de la celebración o ejecución del contrato:**

Art. 1803 CC. "Si se vende con arras, esto es, dando una cosa en prenda de la celebración o ejecución del contrato, se entiende que cada uno de los contratantes podrá retractarse; el que ha dado las arras, perdiéndolas; y el que las ha recibido, restituyéndolas dobladas."

Para una parte de la doctrina, el contrato ya está perfecto y la entrega de estas arras envuelve una condición resolutoria ordinaria, ya que si una de las partes se retracta, el contrato se entiende resuelto, sin que haya incumplimiento de las obligaciones del contrato.

Para otra parte de la doctrina, el contrato con arras se celebra bajo la condición negativa y suspensiva de que las partes no hagan uso de la facultad de retractación (Postura de Alessandri).

Si las partes nada dicen, la retractación puede ejercerse en un plazo de dos meses. Pero se extingue antes si el contrato se reduce a escritura pública o se principia la entrega (Art. 1804 CC).

Pero si bien las partes adquieren por medio de las arras el derecho a retractarse, la ley dispone que si el que se retracta es el que dio las arras, las perderá, y si es el que las recibió, deberá restituir las dobladas.

**b) Como parte del precio o en señal de quedar las partes convenidas:**

Art. 1805 CC. "Si expresamente se dieran arras como parte del precio, o como señal de quedar convenidos los contratantes, quedará perfecta la venta; sin perjuicio de lo prevenido en el artículo 1801, inciso 2º.  
No constando alguna de estas expresiones por escrito, se presumirá de derecho que los contratantes se reservan la facultad de retractarse según los dos artículos precedentes."

En este caso, las arras constituyen un medio de prueba de la celebración del contrato.

Para que las arras se entiendan dadas en este sentido:

- i) Deben las partes estipularlo expresamente.
- ii) Debe constar por escrito.

Si no es así, se entienden dadas en garantía.

• **GASTOS DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA:** son de cargo del vendedor (Art. 1806 CC), porque el legislador supone que están considerados en el precio. Cuando se trata de una escritura de compraventa de un inmueble, conviene entonces estipular que los gastos de escritura serán soportados en partes iguales y los de inscripción serán de cargo del comprador.

Pero la Ley de Timbres y estampillas modifica la regla señalada: el impuesto a la compraventa es de cargo de quien suscribe el documento, a prorrata de sus intereses.

## **2.3. LA COSA VENDIDA.**

### **1. La cosa vendida es requisito esencial de la compraventa**

Si falta la cosa, la obligación del vendedor carece de objeto, lo que priva de causa a la del comprador.

### **2. Requisitos de la cosa vendida**

Además de los propios del objeto de todo acto jurídico (real, comerciable y determinada), la cosa vendida debe:

#### **1) Ser comerciable y enajenable.** (Apropiabilidad y transferibilidad)

Art. 1810 CC. "Pueden venderse todas las cosas corporales o incorporeales, cuya enajenación no esté prohibida por ley.

De acuerdo a lo estudiado en acto jurídico y en bienes, una cosa es comerciable, cuando puede ser objeto de dominio y posesión por parte de los particulares.  
Por regla general, las cosas comerciables son también susceptibles de enajenación,



pero excepcionalmente, puede ocurrir que la cosa, no obstante su carácter comerciable, no pueda transferirse. Tal situación se genera con los derechos personalísimos.

De tal forma, para que una cosa comerciable pueda venderse, deberá también ser enajenable. Sobre el particular, el Art. 1810 dispone que pueden venderse todas las cosas corporales o incorporeales, cuya enajenación no esté prohibida por la ley, y un caso en que la ley limita la facultad de disposición es el caso del Art. 1464 CC.

Recordemos también que para la Tesis Velasco Letelier, el Art. 1810 no se aplicaría a los casos contemplados en los números 3 y 4 del Art. 1464, sino que sólo a los casos de los números 1 y 2 del mismo precepto, pues los primeros corresponderían a normas imperativas de requisito y los últimos a normas prohibitivas. En consecuencia, podría venderse una cosa embargada, por ejemplo, sin autorización del juez ni el consentimiento del acreedor, sin perjuicio que mientras subsista el embargo, no podrá verificarse la tradición, a menos que se otorgue dicha autorización o se preste tal consentimiento.

La compraventa de cosas cuya enajenación está prohibida es nula absolutamente por ilicitud del objeto.

## **2) Ser determinada y singular.**

La determinación puede ser específica o genérica (Art. 1461 inc. 1º CC). Cuando sea genérica, debe determinarse la cantidad. Pero la cantidad puede ser inicialmente incierta, siempre que el mismo contrato fije las reglas para determinarla (debe ser determinable, Art. 1461 inc. 2º CC).

No es válida la venta de una universalidad jurídica. No es posible que una persona venda su patrimonio, pero es válida la venta de todos los bienes de una persona, especificándolos.

Art. 1811 CC. "Es nula la venta de todos los bienes presentes o futuros o de unos y otros, ya se venda el total o una cuota; pero será válida la venta de todas las especies, géneros y cantidades, que se designen por escritura pública, aunque se extienda a cuanto el vendedor posea o espere adquirir, con tal que no comprenda objetos ilícitos.  
Las cosas no comprendidas en esta designación se entenderán que no lo son en la venta: toda estipulación contraria es nula."

## **3) Existir o esperarse que exista.**

No sólo las cosas que existen pueden ser objeto de un acto jurídico, sino las que se espera que existan (Art. 1461 inc. 1º CC). Pueden venderse las cosas presentes y futuras.

Si la cosa no existe ni se espera que exista:

- i. **Si no existe en absoluto** (falta totalmente), no hay ni puede haber compraventa.

Art. 1814 inc. 1º CC. "La venta de una cosa que al tiempo de perfeccionarse el contrato se supone existente y no existe, no produce efecto alguno."

- ii. **Si existe sólo parcialmente.**

Art. 1814 inc. 2º CC. "Si faltaba una parte considerable de ella al tiempo de perfeccionarse el contrato, podrá el comprador a su arbitrio desistir del contrato, o darlo por subsistente, abonando el precio a justa tasación."

La buena o mala fe de las partes (ignorancia o conocimiento de la inexistencia de la cosa) no influye en la validez del contrato. Pero si el vendedor supo que la cosa no existía, debe reparar perjuicios al comprador que lo ignoraba (Art. 1814 inc. final CC).

### **Venta de cosa futura:**

Art. 1813 CC. "(1) La venta de cosas que no existen, pero se espera que existan, se entenderá hecha bajo la condición de existir, (2) salvo que se exprese lo contrario, o que por la naturaleza del contrato aparezca que se compró la suerte."

- En el primer caso la venta es condicional y conmutativa: si la cosa no llega a existir, no hay compraventa.
- En el segundo caso la venta es pura y simple y aleatoria, la inexistencia de la cosa no obsta a que la venta sea perfecta; no afecta a la validez del contrato sino al provecho que las partes reportarán de él.

### **4) No pertenecer al comprador.**

Art. 1816 inc. 1º CC. "La compra de cosa propia no vale: el comprador tendrá derecho a que se le restituya lo que hubiere dado por ella."

La cosa debe ser del vendedor o de un tercero.

## **3. Venta de cosa ajena**

Art. 1815 CC. "La venta de cosa ajena vale, sin perjuicio de los derechos del dueño de la cosa vendida, mientras no se extingan por el lapso de tiempo."

Esto es consecuencia de que la compraventa simplemente genera derechos personales, pero no transfiere el dominio.

Efectos de la venta de cosa ajena:

1) **En relación al dueño de la cosa:** el contrato no le afecta, no contrae ninguna obligación y conserva su derecho de dominio mientras el comprador no lo adquiera por prescripción. Por ello, tiene acción reivindicatoria contra el comprador, si es él quien la posee.

2) **Entre las partes:**

- a) La compraventa y correspondiente tradición no dan al comprador el dominio de la cosa. Sólo le otorga los derechos transferibles que el vendedor tenía sobre la cosa (Art. 682 CC). Pero el comprador adquiere la posesión de la cosa, y podrá ganarla por prescripción (Art. 683 CC).
- b) El vendedor podrá verse en la imposibilidad de entregarla. El comprador tendrá derecho al cumplimiento o resolución del contrato, con indemnización.
- c) Si entregada la cosa, el dueño la reivindica, el vendedor debe sanear la evicción. No tiene este deber si el comprador contrató a sabiendas de que era ajena.

**Ratificación del dueño:**

Art. 1818 CC. "La venta de cosa ajena, ratificada después por el dueño, confiere al comprador los derechos de tal desde la fecha de la venta."

**Adquisición posterior del dominio por el vendedor:**

Art. 1819 CC. "Vendida y entregada a otro una cosa ajena, si el vendedor adquiere después el dominio de ella, se mirará al comprador como verdadero dueño desde la fecha de la tradición.  
Por consiguiente, si el vendedor la vendiere a otra persona después de adquirido el dominio, subsistirá el dominio de ella en el primer comprador."

**2.4 EL PRECIO.**

**1. El precio es esencial en la compraventa**

Si falta el precio, la obligación del comprador carece de objeto, lo que priva de causa a la del vendedor.

**2. Requisitos del precio**

**1) Debe consistir en dinero.**

Es de la esencia de la compraventa, que el precio consista en dinero. Sin embargo, no es esencial que se pague en dinero, porque después de constituida la obligación del comprador de pagar el precio, puede ser novada, acordando las partes que se

pague de otra forma, o pueden las partes acordar que la obligación se cumpla dando en pago un determinado bien (en este último caso, debe pactarse inicialmente que el precio se pagará en dinero efectivo; luego, ante la imposibilidad del comprador de disponer de la suma adeudada, podrá convenirse en que opere la dación en pago. Si se pactare desde un comienzo que el precio será satisfecho con otra cosa, estaríamos ante una permuta). Lo esencial es que al momento de celebrarse el contrato, el precio se fije en dinero.

Puede ocurrir que el precio consista parte en dinero, parte en otra cosa. En este caso, habrá que aplicar el art. 1794 CC, para determinar si hay compraventa o permuta. Si el dinero vale más que la cosa habrá compraventa, y a la inversa, permuta.

Art. 1794 CC. "Cuando el precio consiste parte en dinero y parte en otra cosa, se entenderá permuta si la cosa vale más que el dinero; y venta en el caso contrario."

## **2) Debe ser real o serio.**

Debe existir efectivamente una suma de dinero que se pague a cambio de una cosa. La realidad o seriedad debe existir en relación:

- a) A la voluntad de las partes: que se tenga efectivamente la intención de pagarse y exigirse.
- b) A la cosa vendida: que no exista entre precio y cosa una desproporción tal que el precio resulte puramente ilusorio.

No es necesario que el precio sea justo, es decir, que equivalga al valor de la cosa. El precio vil (que no refleja tal equivalencia) no excluye la existencia del contrato, pues de todos modos es un precio serio. Excepcionalmente, cuando la desproporción genera lesión enorme, influye en la suerte del contrato.

## **3) Debe ser determinado.**

Determinación del precio: señalamiento de la precisa cantidad que el comprador debe pagar por la cosa.

Este requisito es consecuencia de la regla general del Art. 1461 CC sobre el objeto.

Puede determinarse:

**a) Por acuerdo de las partes:** es la forma normal.

Art. 1808 CC. "El precio de la venta debe ser determinado por los contratantes. Podrá hacerse esta determinación por cualesquiera medios o indicaciones que lo fijen.

Si se trata de cosas fungibles y se vende al corriente de plaza, se entenderá el del día de la entrega, a menos de expresarse otra cosa."

**b) Por un tercero:**

Art. 1809 CC. "Podrá asimismo dejarse el precio al arbitrio de un tercero; y si el tercero no lo determinare, podrá hacerlo por él cualquiera otra persona en que se convinieren los contratantes; en caso de no convenirse, no habrá venta."

En este caso, el contrato es condicional, sujeto a la condición de que el tercero determine el precio.

Art. 1809 inc. final CC. "No podrá dejarse el precio al arbitrio de uno de los contratantes." (Condición meramente potestativa de la voluntad del deudor, por lo tanto, nula)

## **2.5 CAPACIDAD PARA CELEBRAR EL CONTRATO DE COMPRAVENTA.**

### **1. Reglas generales**

Para la compraventa, como para todo contrato, la capacidad es la regla general (Arts. 1445 y 1446 CC).

Art. 1795 CC. "Son hábiles para el contrato de venta todas las personas que la ley no declara inhábiles para celebrarlo o para celebrar todo contrato."

Incapacidades:

- 1) Personas afectas a una incapacidad general para contratar (Art. 1447 CC).
- 2) Personas afectas a ciertas incapacidades particulares del contrato de compraventa (prohibiciones, Art. 1447 inc. final CC). Estas son las que interesan.

### **2. Clasificación de las incapacidades**

#### **1) Incapacidades de comprar y vender (incapacidades doble).**

Art. 1796 CC. "Es nulo el contrato de compraventa entre cónyuges no separados judicialmente, y entre el padre o madre y el hijo sujeto a patria potestad".

#### **a) Compraventa entre cónyuges:**

La prohibición afecta incluso a los cónyuges casados bajo el régimen de separación de bienes.

Razones de la prohibición:

- i) La ley prohíbe las donaciones irrevocables entre cónyuges; por una compraventa simulada o a precio vil se puede burlar dicha prohibición.
- ii) Los cónyuges podrían, mediante una venta simulada, sustraer bienes de la persecución de los acreedores.

### **b) Compraventa entre el padre o madre y el hijo:**

Objeto: proteger al hijo, regularmente falto de experiencia, y evitar al padre el conflicto entre el deber de cautelar los intereses del hijo y su propio interés.

i) Rige para la compraventa entre el hijo y padre o madre a cuya patria potestad se encuentra sometido.

ii) Pero es válida si recae sobre bienes que formen parte del peculio profesional del hijo, respecto de cuya administración se le mira como mayor de edad (Art. 251 CC). Pero si se trata de un inmueble, debe ser autorizada por el juez.

## **2) Incapacidades para vender (incapacidades simples).**

Prohibición de los administradores de establecimientos públicos:

Art. 1797 CC. "Se prohíbe a los administradores de establecimientos públicos vender parte alguna de los bienes que administran, y cuya enajenación no está comprendida en sus facultades administrativas ordinarias; salvo el caso de expresa autorización de la autoridad competente".

## **3) Incapacidades para comprar (incapacidades simples).**

### **a) Prohibición a los empleados públicos.**

Art. 1798 CC. "Al empleado público se prohíbe comprar los bienes públicos o particulares que se vendan por su ministerio; (...) aunque la venta se haga en pública subasta."

### **b) Prohibición a los jueces y funcionarios del orden judicial.**

Art. 1798 CC. "(...) y a los jueces, abogados, procuradores o escribanos los bienes en cuyo litigio han intervenido, y que se vendan a consecuencia del litigio; aunque la venta se haga en pública subasta".

Pero el Art. 321 COT amplía la prohibición: "Se prohíbe a todo juez comprar o adquirir a cualquier título para sí, para su cónyuge o para sus hijos las cosas o derechos que se litiguen en los juicios de que él conozca.

Se extiende esta prohibición a las cosas o derechos que han dejado de ser litigiosos, mientras no hayan transcurrido cinco años desde el día en que dejaron de serlo; pero no comprende las adquisiciones hechas a título de sucesión por causa de muerte, si el adquirente tuviere respecto del difunto la calidad de heredero abintestato."

**c) Incapacidad de los tutores y curadores.**

Art. 1799 CC. "No es lícito a los tutores y curadores comprar parte alguna de los bienes de sus pupilos, sino con arreglo a lo prevenido en el título De la administración de los tutores y curadores."

Art. 412 CC. "Por regla general, ningún acto o contrato en que directa o indirectamente tenga interés el tutor o curador, o su cónyuge, o cualquiera de sus ascendientes o descendientes, o de sus hermanos, o de sus consanguíneos o afines hasta el cuarto grado inclusive, o alguno de sus socios de comercio, podrá ejecutarse o celebrarse sino con autorización de los otros tutores o curadores generales, que no estén implicados de la misma manera, o por el juez en subsidio.

Pero ni aun de este modo podrá el tutor o curador comprar bienes raíces del pupilo, o tomarlos en arriendo; y se extiende esta prohibición a su cónyuge, y a sus ascendientes o descendientes."

**d) Incapacidad de los mandatarios, síndicos y albaceas.**

Art. 1800 CC. "Los mandatarios, los síndicos de los concursos, y los albaceas, están sujetos en cuanto a la compra o venta de las cosas que hayan de pasar por sus manos en virtud de estos encargos, a lo dispuesto en el artículo 2144."

i) Mandatarios: Art. 2144 CC. "No podrá el mandatario por sí ni por interpuesta persona, comprar las cosas que el mandante le ha ordenado vender, ni vender de lo suyo al mandante lo que éste le ha ordenado comprar, si no fuere con aprobación expresa del mandante."

Objeto: evitar los abusos que pudiera cometer el mandatario.

ii) Síndicos: Esta mención está obsoleta, en virtud de la ley 20.720, que estableció el nuevo régimen de reorganización y liquidación de empresas y personas, sustituyendo al antiguo régimen concursal. Dicha ley establece un régimen aún más estricto respecto de los veedores y los liquidadores. En tal sentido, estos tienen una prohibición absoluta de adquirir bienes para sí o para terceros en su art. 18 y, en caso de hacerlo, cesarán inmediatamente en su cargo y serán excluidos de las respectivas nóminas.

iii) Albaceas: el Art. 1294 CC les hace aplicables las normas de las guardas. Se rigen por el Art. 412 CC. La regla del mandato no es aplicable porque el albacea nunca podrá obtener la aprobación expresa del causante

## 2.6 MODALIDADES DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA

### 1. Generalidades.

Art. 1807 CC. "La venta puede ser pura y simple, o bajo condición suspensiva o resolutoria. Puede hacerse a plazo para la entrega de la cosa o del precio. Puede tener por objeto dos o más cosas alternativas. Bajo todos estos respectos se rige por las reglas generales de los contratos, en lo que no fueren modificadas por las de este título."

Pero además puede estar sujeta a ciertas modalidades especiales:

### 2. Venta al peso, cuenta o medida.

La venta de cosas que se aprecian según su cantidad puede hacerse:

1) En bloque: no es necesario pesar, contar o medir para llegar a determinar la cosa o el precio.

2) Al peso, cuenta o medida: sí es necesario efectuar alguna de esas operaciones. Pero las consecuencias son distintas si se dirigen a determinar el precio o la cosa:

**a) Se venden ciertas cosas determinadas que deben pesarse, contarse o medirse para determinar el precio:** Art. 1821 inc. 1º CC. "Si se vende una cosa de las que suelen venderse a peso, cuenta o medida, pero señalada de modo que no pueda confundirse con otra porción de la misma cosa, como todo el trigo contenido en cierto granero, la pérdida, deterioro o mejora pertenecerá al comprador, aunque dicha cosa no se haya pesado, contado ni medido; con tal que se haya ajustado el precio."

**b) Se vende una cosa que es preciso contar, pesar o medir para determinarla:** Art. 1821 inc. 2º CC. "Si de las cosas que suelen venderse a peso, cuenta o medida, sólo se vende una parte indeterminada, como diez fanegas de trigo de las contenidas en cierto granero, la pérdida, deterioro o mejora no pertenecerá al comprador, sino después de haberse ajustado el precio y de haberse pesado, contado o medido dicha parte."

La operación de peso, cuenta o medida determina solamente de cargo de quién son los riesgos, pero el contrato se encuentra perfecto.

### 3. Venta a prueba o al gusto



Art. 1823 CC. "Si se estipula que se vende a prueba, se entiende no haber contrato mientras el comprador no declara que le agrada la cosa de que se trata, y la pérdida, deterioro o mejora pertenece entre tanto al vendedor. Sin necesidad de estipulación expresa se entiende hacerse a prueba la venta de todas las cosas que se acostumbra vender de ese modo."

En este caso, el contrato no se perfecciona sino cuando el comprador encuentra la cosa de su agrado.

## **2.7 EFECTOS DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA.**

**Efectos de la compraventa:** derechos y obligaciones que genera para las partes. Obligaciones de la esencia del contrato: dar el vendedor la cosa y pagar el comprador el precio.

Pero existen ciertas obligaciones de la naturaleza, y las partes pueden pactar obligaciones accidentales.

### **2.7.1 OBLIGACIONES DEL VENDEDOR.**

Art. 1824 inc. 1º CC. "Las obligaciones del vendedor se reducen en general a dos: la entrega o tradición, y el saneamiento de la cosa vendida."

#### **2.7.1.1 OBLIGACIÓN DE ENTREGAR LA COSA VENDIDA**

**1) Alcance de la obligación:** ¿Se obliga a hacer dueño al comprador o a procurarle la posesión pacífica y útil de la cosa?

La determinación del alcance de la obligación esencial del vendedor no es una materia pacífica en doctrina. En efecto, el legislador no es del todo consistente en el empleo de ciertas expresiones técnicas a lo largo del título XXIII del libro IV del Código. Así, si en el art. 1793 CC el legislador sostiene que el vendedor se obliga a *dar* una cosa, en el art. 1824 CC se habla de la *entrega o tradición*. Puestas así las cosas, ¿cuál es el contenido de dicha obligación del vendedor?

La posición tradicional en nuestro ordenamiento jurídico, defendida por primera vez por Arturo Alessandri Rodríguez en su memoria de título, es que la obligación principal del vendedor consiste en la entrega de la cosa vendida, la cual se hace por medio de la tradición. No habría obligación de transferir el dominio, sino sólo de procurarle al comprador la posesión pacífica y útil de la cosa. Si bien esta postura ha sido la predominante en nuestro medio, tanto en doctrina como en jurisprudencia, un sector de la doctrina contemporánea (aún minoritario), argumenta que el vendedor sí tendría la obligación de transferir el dominio, doctrina que tuvo recepción por la Corte Suprema en la sentencia causa Rol N°194-2023. En cualquier caso, la obligación del vendedor consiste en hacer la tradición. En otras palabras, la discusión refiere a si la tradición debe, además, transferir el dominio.

Esta discusión no solo reviste un evidente interés teórico y hermenéutico, sino que también tiene importantes consecuencias prácticas, principalmente en cuestiones relativas al incumplimiento. Si se sigue la tesis de Alessandri, el vendedor que no era dueño de la cosa vendida y que, por consiguiente, no ha transferido el dominio, no se encuentra en situación de incumplimiento. Así, el comprador que no se ha hecho dueño, no tendría ninguna acción al respecto. Solo podría hacer valer la garantía del saneamiento de la evicción, y solo en caso de ser demandado judicialmente.

En cambio, si se sigue la tesis de que el vendedor se obliga a transferir el dominio, el vendedor que no ha transferido el dominio sí se encuentra en una situación de incumplimiento. Así, el comprador que no se ha hecho dueño, podría demandar la resolución por incumplimiento según las reglas generales, sin la necesidad de que un tercero turbe su derecho para obtener tutela jurídica.

A continuación, explicaremos los principales argumentos de cada postura:

### **1ª postura, el vendedor no se obliga a transferir el dominio:**

1. El primer argumento de este sector de la doctrina es de carácter histórico. Señalan que la compraventa tiene sus orígenes en el derecho romano clásico. Para los romanos, la compraventa solo funciona como fuente de derechos personales, y el vendedor no se encontraba obligado a traspasar el dominio al comprador, sino solo garantizar su posesión pacífica y útil. Así, siendo fieles con la tradición histórica que dio lugar a nuestro derecho civil, debiésemos entender que este es el alcance de la obligación esencial del vendedor.
2. En segundo lugar, Alessandri invoca como argumento el art. 1815 CC, según el cual la venta de cosa ajena es válida. Si el vendedor estuviera obligado a dar el dominio de la cosa al comprador, entonces solo podría vender aquellas cosas sobre las cuales tuviera un derecho de propiedad, pues sólo respecto a ellas podría cumplir su obligación. Así, si el legislador dispuso que la venta de cosa ajena es válida, es porque no le dio a la obligación principal del vendedor este alcance.
3. En tercer lugar, se invoca el art. 1824 CC, en tanto sostiene que el vendedor está obligado a "la entrega o tradición". Se sostiene que el uso de la conjunción disyuntiva "o" da cuenta de las dos posiciones en las cuales podría encontrarse el vendedor: Si es dueño de la cosa vendida, cumplirá haciendo una verdadera tradición; si no lo es, cumplirá por medio de la mera entrega.

### **2ª postura, sí se obliga a transferir el dominio:**

1. En contra, se ha sostenido que el argumento histórico no es pertinente. En el derecho romano habían buenas razones para que la compraventa no generase la obligación de transferir el dominio, principalmente porque su regulación de los modos de adquirir el dominio era sustancialmente diferente de la nuestra. Luego, ya no existirían los fundamentos sustantivos para una interpretación romanista de la compraventa.

2. Para este sector de la doctrina, de la validez de la venta de cosa ajena no se sigue que el legislador haya dispuesto que el vendedor no está obligado a transferir el dominio. La razón por la cual el legislador permite la compraventa de cosa ajena radica en la dualidad título y modo. Es decir, dado que la compraventa solo da lugar a derechos personales, es perfectamente válido que una persona se obligue respecto a un bien sobre el cual no tiene titularidad alguna. Así, si una persona celebra la compraventa sobre cosa ajena, dicho contrato dará lugar a una obligación válida, y la imposibilidad del vendedor para transferir el dominio dará lugar al incumplimiento de su obligación. No deben confundirse las condiciones para el perfeccionamiento del contrato con las condiciones para el cumplimiento de las obligaciones a que éste da lugar.

3. En cuanto a los argumentos de texto, este sector de la doctrina invoca el art. 1793 CC, para el cual el vendedor se obliga a *dar* una cosa. Dado que las obligaciones de dar son aquellas que consisten en la transferencia del dominio u otro derecho real, debemos entender que el vendedor se obliga a transferir el dominio. También se hace referencia al art. 1837 CC, que establece que la obligación de saneamiento implica “amparar al comprador en el dominio y posesión pacífica de la cosa vendida (...)”. No tendría sentido que el legislador hubiera establecido que el vendedor debe amparar al comprador en el dominio si no existiera la obligación de transferirlo.

4. Adicionalmente, el nuevo derecho de los contratos incorpora la idea de que el propósito práctico de los mismos debe ser considerado como un factor relevante para su conceptualización e interpretación. Así, dado que el propósito práctico de la compraventa es el ser un contrato de intercambio, su finalidad social no se cumple adecuadamente si no entendemos que el comprador está obligado a transferir el dominio.

5. Por otro lado, la tesis de que el vendedor no se obliga a transferir el dominio deja al comprador en una posición injusta, de manera contraria a la buena fe y la equidad. En efecto, según dicha tesis el comprador que no se ha hecho dueño no puede acceder a ningún tipo de tutela judicial sino hasta que un tercero lo turbe en la posesión pacífica de la cosa. Así, el comprador que no se ha hecho dueño debe soportar una situación de incerteza jurídica entre la compra y el plazo para la prescripción adquisitiva, que podría ser interrumpido en cualquier momento por la notificación judicial de la demanda del verdadero dueño. Para esta tesis, en cambio, el comprador que no se ha hecho dueño puede demandar la resolución por incumplimiento, con indemnización de perjuicios.

## 2) Forma de la entrega:

Art. 1824 inc. 2º CC. “La tradición se sujetará a las reglas dadas en el Título VI del Libro II.”

i) Muebles: significando una de las partes a la otra que le transfiere el dominio y figurando la transferencia por alguna de las formas del Art. 684 CC, o por separación en el caso de los muebles por anticipación.

ii) Inmuebles: inscripción del contrato de compraventa en el CBR. Excepciones:

- Servidumbre: sólo por la escritura pública (Art. 689 CC), salvo la de alcantarillado en predios urbanos, que debe inscribirse.
- Minas: inscripción en el Conservador de Minas.

### **3) Obligación de entregar materialmente la cosa:**

La cosa debe ser materialmente puesta a disposición del comprador; no basta con la inscripción. La falta de entrega material autoriza al comprador para reclamarla o para pedir la resolución del contrato.

### **4) Época en que debe efectuarse la entrega:**

Art. 1826 inc. 1º CC, "El vendedor es obligado a entregar la cosa vendida inmediatamente después del contrato o a la época prefijada en él."

La época de la entrega, que no es el resultado de una expresa estipulación, puede resultar de las circunstancias del contrato (plazo tácito).

### **Pero el vendedor tiene derecho de retención sobre la cosa en ciertos casos:**

i) Cuando el comprador no le ha pagado (Art. 1826 inc. 3º CC). Pero no puede retenerla si el comprador está pronto a pagar el precio. El pago debe ser íntegro. Todo esto siempre y cuando no se haya fijado un plazo para el pago.

ii) Cuando el vendedor se vea en peligro de perder el precio como consecuencia de una disminución considerable de la fortuna del comprador (Art. 1826 inc. final CC). Tiene el derecho de retención aun cuando se haya fijado un plazo. Pero cesa si el comprador paga o cauciona el pago.

### **3) Lugar de la entrega:**

Se rige por las reglas generales (Arts. 1587, 1588 y 1589 CC): en el lugar convenido. Si no hay estipulación, y:

- la cosa es una especie, en el lugar donde existía al tiempo del contrato.
- es otra cosa, en el domicilio del deudor al tiempo del contrato.

### **4) Gastos de la entrega:**

Son del deudor (Art. 1571 CC), por lo tanto, son de cargo del vendedor los que demande la entrega de la cosa en el lugar debido, y del comprador los que signifiquen su transporte una vez entregada (Art. 1825 CC).

### **5) Qué comprende la entrega:**

El pago debe hacerse al tenor de la obligación, y el acreedor no puede ser obligado a recibir una cosa distinta (Art. 1569 CC). El vendedor debe entregar **lo que reza el**

**contrato** (Art. 1828 CC). La cosa debe ser entregada con accesorios y frutos:

i) Frutos (Art. 1816 CC):

- Pertenecen al comprador los frutos naturales pendientes al tiempo del contrato.
- \*No debe al vendedor indemnización por los gastos para producirlos (están en el precio).
- \*La venta de un animal comprende la del hijo que lleva en el vientre o que amamanta (Art. 1829 CC).
- Pertenecen al comprador los frutos naturales y civiles que la cosa produzca después del contrato.

Esta regla tiene tres excepciones:

- Las partes han señalado un plazo para la entrega: los frutos pertenecen al vendedor hasta el vencimiento de dicho plazo.
- Las partes han señalado una condición para la entrega: los frutos pertenecen al vendedor hasta el cumplimiento de la condición.
- Las partes han estipulado cláusulas especiales: se rigen por ellas.

ii) Accesorios:

En la venta de una finca se comprenden sus accesorios (Art. 1830 CC), regla que se aplica también a la venta de cosas muebles.

Art. 1828 CC. Expresión "lo que reza el contrato".

Puede prestarse a dificultades determinar qué es "lo que reza el contrato". La determinación de lo que reza el contrato está comprendida en la interpretación del mismo. La determinación de lo pactado en un contrato importa la fijación de un hecho, para cuyo establecimiento es menester recurrir a la intención de los contratantes, que es el elemento esencial e inseparable de él, y que no cae bajo el control del tribunal de casación.

## 6) Riesgos de la cosa vendida:

Art. 1820 primera parte CC. "La pérdida, deterioro o mejora de la especie o cuerpo cierto que se vende, pertenece al comprador, desde el momento de perfeccionarse el contrato, aunque no se haya entregado la cosa;..."

Esto es aplicación de la regla general del Art. 1550 CC.

En consecuencia, la pérdida de la cosa por caso fortuito extingue la obligación del vendedor de entregar la cosa, pero el comprador debe pagar el precio. El deterioro o pérdida parcial también debe ser soportada por el comprador, que debe recibirla como está. Pero se aprovecha de las mejoras.

Esta regla se aplica a la venta de cosas genéricas en bloque, o que deben ser pesadas, contadas o medidas para determinar el precio total.

Excepciones:

**i) Venta sujeta a una condición suspensiva:** la pérdida debe soportarla el vendedor cuando sobreviene pendiente la condición. El comprador no debe pagar el precio. Pero la pérdida parcial o el deterioro pertenecen al comprador. Es necesario que se cumpla la condición; si no se cumple, no hay contrato, y pérdida y deterioro son del frustrado vendedor.

**ii) Venta a peso, cuenta o medida en que las operaciones tienen por objeto determinar la cosa vendida:** la pérdida, deterioro o mejora pertenecen al comprador mientras las operaciones no se verifiquen.

**iii) Venta al gusto:** los riesgos don del comprador desde que expresa que la cosa le agrada.

## **7) Entrega de predios rústicos.**

Art. 1831 inc. 1º CC. "Un predio rústico puede venderse con relación a su cabida o como una especie o cuerpo cierto."

i) En relación a la cabida (Art. 1831 inc. 2º CC):

1. Cuando la cabida se expresa en el contrato,
2. El precio se fija con relación a ella, y
3. Las partes no renuncian a las acciones resultantes de que la cabida real sea diversa.

### Efectos:

Puede plantearse una de dos cuestiones:

1. La cabida real es mayor a la expresada (Art. 1832 inc. 1º CC):

- a. Es poco mayor (el precio del sobrante no excede de la décima parte del precio de la verdadera cabida: el vendedor tiene derecho a que se le aumente proporcionalmente el precio.
- b. Es mucho mayor (el precio del sobrante excede de la décima parte del precio de la verdadera cabida): queda al arbitrio del comprador desistir del contrato o aumentar el precio proporcionalmente.

2. La cabida es menor a la expresada (Art. 1832 inc. 2º CC):

- a. Es poco menor (el precio de la cabida que falta no excede de la décima parte de la cabida declarada): el vendedor debe completar la cabida, y si no fuera posible, disminuir proporcionalmente el precio.
- b. Es mucho menor (el precio de la cabida que falta excede de la décima parte de la cabida declarada): el comprador puede, a su arbitrio, aceptar la disminución del precio o desistir del contrato.

ii) Como especie o cuerpo cierto ("ad corpus", Art. 1832 inc. final):

1. Cuando la cabida no se expresa en el contrato, o
2. Cuando las partes la mencionan, pero expresa o tácitamente declaran que es un

dato puramente ilustrativo.

Efectos:

No plantea ningún problema de cabida. No hay derecho por parte del comprador ni del vendedor para pedir rebaja o aumento del precio sea cual fuere la cabida (Art. 1833 inc. 1º CC). Pero el vendedor debe entregar todo lo que se comprenda en sus deslindes (Art. 1833 inc. 2º CC). Si falta una parte dentro de los deslindes, se siguen las reglas de la venta en relación a la cabida cuando ésta es menor a la expresada.

Art. 1835 CC. "Las reglas dadas en los dos artículos referidos se aplican a cualquier todo o conjunto de efectos o mercaderías." (Arts. 1832 y 1833 CC).

Art. 1834 CC. "Las acciones dadas en los dos artículos precedentes expiran al cabo de un año contado desde la entrega."

Art. 1836 CC. "Además de las acciones dadas en dichos artículos compete a los contratantes la de lesión enorme en su caso."

**8) Consecuencias de la falta de entrega de la cosa:**

Requisitos:

- i) Mora del vendedor.
- ii) Que el comprador haya pagado o esté pronto a pagar el precio, o haya plazo.

Art. 1826 inc. 2º CC. "Si el vendedor por hecho o culpa suya ha retardado la entrega, podrá el comprador a su arbitrio perseverar en el contrato o desistir de él, y en ambos casos con derecho para ser indemnizado de los perjuicios según las reglas generales."

**2.7.1.2. SANEAMIENTO DE LA COSA VENDIDA.**

No basta con la entrega de la cosa. Debe entregarse en condiciones tales que el comprador pueda gozar de ella tranquila y útilmente.

- No tendrá la posesión tranquila cuando se vea turbado en dicha posesión a consecuencia de los derechos que terceros hagan valer sobre la cosa.
- No tendrá la posesión útil si la cosa adolece de defectos que la hacen inadecuada para el objeto que se tuvo en vista.

El recurso para subsanar esta situación es la **acción de saneamiento**.

Art. 1837 CC. "La obligación de saneamiento comprende dos objetos:  
(1) amparar al comprador en el dominio y posesión pacífica de la cosa vendida, y  
(2) responder de los defectos ocultos de ésta, llamados *vicios redhibitorios*."



### **Caracteres de la obligación de saneamiento:**

- a.** Elemento de la naturaleza del contrato de compraventa. Se entiende incorporada en ella sin necesidad de cláusula especial, pero las partes pueden excluirla o limitar su alcance, mediante estipulación expresa. La obligación de entrega, en cambio, es de la esencia de la compraventa.
- b.** Obligaciones de garantía.
- c.** Eventuales. Puede o no hacerse exigible, según acontezcan o no los hechos descritos. Cuando el comprador es turbado en su posesión por actos de un tercero que pretende derechos sobre la cosa, se produce la evicción. Cuando se trata de defectos ocultos de la cosa, que imposibilitan al comprador para sacar provecho de ella, hay vicios redhibitorios.
- d.** Su renuncia no es válida cuando se realiza con dolo.

#### **2.7.1.2.1. SANEAMIENTO DE LA EVICCIÓN.**

❖ **Objeto:** amparar al comprador en el dominio y posesión pacífica de la cosa (Art. 1837 CC). Se desarrolla en 2 etapas:

- i) Defender al comprador contra los terceros que reclaman derechos sobre la cosa.
- ii) Indemnizar al comprador si la evicción, no obstante, se produce.

❖ **Naturaleza** (Art. 1840 CC):

- i) Defender al comprador: obligación de hacer, es indivisible.
- ii) Indemnizarlo: obligación de dar, es divisible.

❖ **Requisitos para que sea exigible:**

- i) Que el comprador se vea expuesto a sufrir evicción de la cosa comprada.
- ii) Que el vendedor sea citado de evicción (Art. 1843 inc. 1º CC).

❖ **Concepto de evicción:**

Art. 1838 CC. "Hay evicción de la cosa comprada, cuando el comprador es privado del todo o parte de ella, por sentencia judicial."

Art. 1839 CC. "El vendedor es obligado a sanear al comprador todas las evicciones que tengan una causa anterior a la venta, salvo en cuanto se haya estipulado lo contrario."

En consecuencia, la evicción es la privación que experimenta el comprador de todo o parte de la cosa comprada, en virtud de una sentencia judicial, por causa anterior a la venta.



❖ **Elementos de la evicción:**

**1) Privación total o parcial:** Ej.

- Será total si la cosa es reivindicada;
- será parcial si sobre ella se reclama un derecho de usufructo o servidumbre.

**2) Sentencia judicial:** supone un proceso y una sentencia que desposea al comprador total o parcialmente de la cosa.

Consecuencias:

- Los reclamos extrajudiciales que hagan los terceros no hacen exigible la obligación de saneamiento. Estos sólo pueden configurar un justo temor de verse expuesto a la evicción, que autoriza para suspender el pago del precio (Art. 1872 CC).
- El abandono voluntario que haga el comprador al tercero no obliga al vendedor al saneamiento. Pero puede producirse evicción sin sentencia judicial: cuando citado el vendedor, acepta la demanda y se allana a la evicción, y el comprador, reconociendo la justicia de la pretensión del tercero, restituye la cosa.
- El vendedor sólo está obligado al saneamiento de las turbaciones de derecho, las cuales se traducen en el ejercicio de una acción en contra del comprador. Las turbaciones de hecho no provienen de una insuficiencia del derecho del vendedor sobre la cosa, por lo que no debe sanearlas.

**3) Causa anterior a la venta:** las evicciones motivadas por causa posterior son ajenas al vendedor. Pero las partes pueden convenir otra cosa.

❖ **Citación de evicción:**

El vendedor, para quedar obligado al saneamiento, debe tener noticia del juicio que amenaza con privar de la cosa al comprador. La falta de citación le exonera totalmente de responsabilidad (Art. 1843 inc. final CC).

- **Forma y oportunidad de la citación:** se rige por las reglas de los Arts. 584, 585 y 586 CPC (Art. 1843 inc. 2º CC):

- 1) Debe solicitarse por el comprador, y para que el juez la ordene, deben acompañarse antecedentes que hagan aceptable la solicitud.
- 2) Debe hacerse antes de la contestación de la demanda.
- 3) Una vez decretada, se paraliza el juicio por 10 días, aumentado por el emplazamiento si el citado vive en otro departamento.
- 4) Si el demandado no hace practicar la citación en ese plazo, el demandante puede pedir que se declare caducado el derecho de

exigirla, o que se le autorice para llevarla a efecto, a costa del demandado.

5) Practicada la citación, los citados disponen del término de emplazamiento para comparecer en juicio. Mientras, se suspende el procedimiento.

- La citación de evicción procede en toda clase de juicios, no sólo en el juicio ordinario.

- **A quién puede citarse:** no sólo al vendedor, sino también a los antecesores de éste (Art. 1841 CC). El comprador adquiere sobre la cosa todos los derechos de sus antecesores, entre ellos, la acción de saneamiento de cada comprador contra su vendedor.

#### ❖ **Desarrollo de la obligación de saneamiento del vendedor citado:**

Una vez citado, pueden presentarse 2 situaciones:

i) El vendedor no comparece: el procedimiento continúa, y el vendedor queda responsable por la evicción que se produzca (Art. 1843 inc. final CC).

Excepción: no queda responsable si la evicción se produce como consecuencia de que el comprador no opuso una excepción suya.

ii) El vendedor comparece: se sigue el juicio con él. El vendedor asume el papel de demandado (Art. 1844 CC). El comprador puede seguir actuando como coadyuvante, y debe intervenir si dispone de excepciones que el vendedor no puede oponer. Si no lo hace, el vendedor no queda responsable de la evicción.

#### ❖ **Actitudes que puede adoptar el vendedor que comparece al juicio:**

i) Allanarse a la evicción: el comprador puede seguir por su cuenta el juicio. Si sobreviene la evicción, el vendedor debe indemnizarle, pero no se incluyen las costas del pleito ni los frutos percibidos durante el juicio, pagados al demandante (Art. 1845 CC).

ii) Asumir la defensa del comprador.

#### ❖ **Obligación de indemnizar al comprador evicto:**

i) Si la sentencia es favorable al comprador: el vendedor habrá cumplido con su obligación de amparar al comprador, quedando eximido de indemnizarlo (Art. 1855 CC).

ii) Si la sentencia es adversa al comprador: se produce la evicción, el vendedor no habrá cumplido su obligación de defenderlo, a la que se sucede la obligación

de indemnizarlo.

❖ **Indemnizaciones:**

**1) Evicción total** (Art. 1847 CC):

- **Restitución del precio**, aunque la cosa al tiempo de la evicción valga menos, salvo que el menor valor provenga de deterioros de que el comprador se haya aprovechado (debe disminuirse el precio, Art. 1848 CC).
- **Costas legales del contrato** que hayan sido satisfechas por el comprador.
- Valor de los **frutos** que el comprador haya sido obligado a restituir al dueño, con la excepción del Art. 1845 CC (vendedor que se allana).
- **Costas del juicio** sufridas por el comprador, con la misma excepción.
- **Aumento de valor que la cosa haya experimentado en poder del comprador:**

1. Por causas naturales o el mero transcurso del tiempo (Art. 1850 CC):

- a. Si el vendedor está de buena fe: no se abona el aumento que excede a la cuarta parte del precio.
- b. Si está de mala fe: se abona el total del aumento.

2. Por mejoras introducidas por el comprador (Art. 1849 CC):

- c. Si el vendedor está de buena fe: debe abonar el aumento de valor resultante de las mejoras necesarias y útiles que no hayan sido abonadas por el que obtuvo la evicción.
- d. Si el vendedor está de mala fe: debe abonar incluso las mejoras voluptuarias.

**2) Evicción parcial:**

**1. Si la parte evicta es de tal magnitud que permita presumir que sin ella no se habría comprado la cosa:** el comprador tiene derecho opcional de pedir la rescisión de la venta o el saneamiento de la evicción (Art. 1852 inc. 4º CC).

Si opta por la rescisión (Art. 1853 CC):

- Debe restituir al vendedor la parte no evicta (se lo considera de buena fe).
- El vendedor le debe restituir el precio, abonar los frutos que el comprador haya debido restituir, y todo otro perjuicio por la evicción.

**2. Si la parte evicta no es de tanta magnitud (Art. 1854 CC):** el comprador sólo tiene derecho para pedir el saneamiento de la evicción parcial.

❖ **Extinción de la acción de saneamiento por evicción:**

Puede ser total, caso en el cual el vendedor queda liberado; o parcial, caso en que su responsabilidad se limita a ciertas prestaciones.

#### Causales de extinción:

##### **i) Renuncia:**

La obligación de saneamiento es de la naturaleza del contrato, por lo que puede renunciarse.

La renuncia es nula si se hace de mala fe por parte del vendedor, es decir, si éste conocía la causa de la evicción y pactó su irresponsabilidad sin darla a conocer al comprador (Art. 1842 CC).

Pero la renuncia es parcial: no exonera al vendedor de la obligación de restituir el precio (Art. 1852 CC). Sólo queda liberado:

1. Si el que compró lo hizo a sabiendas de que la cosa era ajena.
2. Si expresamente tomó sobre sí el peligro de la evicción, especificándolo.

##### **ii) Prescripción:**

1. Obligación de defender al comprador: es imprescriptible.

2. Obligación de indemnizar al comprador: prescribe en 4 años (prestaciones del Art. 1847 CC), pero la restitución del precio prescribe según las reglas generales, es decir, en 5 años (Art. 1856 CC). Se cuenta desde la sentencia de evicción, o desde la restitución de la cosa, si no hay sentencia (vendedor que se allana).

##### **iii) Por disposición de la ley:**

1. Se extingue parcialmente:

- a. En las ventas forzadas, sólo debe restituirse el precio (Art. 1851 CC).
- b. Si el vendedor se allana, y el comprador sigue el juicio, no debe indemnizarse las costas ni los frutos producidos durante el juicio (Art. 1845 CC).

2. Se extingue totalmente:

- a. Si el vendedor no comparece y la cosa es evicta porque el comprador no opuso una excepción suya (Art. 1843 inc. 3º CC).
- b. Si el comprador y el demandante se someten al juicio de árbitros sin consentimiento del vendedor, y la cosa es evicta (Art. 1846 N° 1 CC).
- c. Si el comprador perdió la posesión por su culpa y de ello se siguió la evicción (Art. 1846 N° 2 CC).

### 2.7.1.2.2 SANEAMIENTO DE LOS VICIOS REDHIBITORIOS.

#### ❖ **Objeto:**

Procurar al comprador la posesión útil de la cosa, y entregarla en estado de servir para los fines que determinaron su adquisición. Se incumple esta obligación si la cosa adolece de vicios o defectos que la hacen inútil o aminoran su utilidad.

Art. 1857 CC. "Se llama acción *redhibitoria* la que tiene el comprador para que se rescinda la venta o se rebaje proporcionalmente el precio por los vicios ocultos de la cosa vendida, raíz o mueble, llamados *redhibitorios*."

#### ❖ **Concepto de los vicios redhibitorios:**

La ley no los define, pero señala sus características o requisitos en el Art. 1858 CC. Pero las partes pueden atribuir el carácter de redhibitorios a vicios que no los cumplan (Art. 1863 CC).

1) El vicio debe ser **contemporáneo a la venta** (Art. 1858 N° 1 CC): basta que el vicio exista en germen al momento de la venta, aunque posteriormente se manifieste en toda su gravedad.

2) El vicio debe ser **grave** (Art. 1858 N° 2 CC): debe ser tal que por él la cosa no sirva para su uso natural, o sólo sirva imperfectamente, de modo que se pueda presumir que, conociéndolo, el comprador no la habría comprado o la habría comprado a mucho menos precio.

3) El vicio debe ser **oculto** (Art. 1858 N° 3 CC): que sean desconocidos por el comprador. No es oculto:

1. Cuando el vendedor lo dio a conocer al comprador.
2. Cuando el comprador lego lo ha ignorado por grave negligencia suya.
3. Cuando el comprador experto, en razón de su profesión y oficio, pudo fácilmente conocerlo.

De la lectura de los requisitos que el legislador establece para los vicios redhibitorios, resulta evidente que los vicios redhibitorios se encuentran en la frontera con el incumplimiento en la obligación de entrega por parte del vendedor y con el error en las calidades esenciales de la cosa. Así, la doctrina y la jurisprudencia contemporáneas han tenido que formular criterios para delimitar el campo de aplicación de dichas instituciones, pues sus requisitos y sus consecuencias divergen de manera sustantiva.

En efecto, la entrega de una cosa defectuosa puede entenderse en el sentido de la entrega de una cosa con un vicio grave, en los términos del art. 1858 n°2 CC, o como la entrega de otra cosa distinta a la comprada, en términos que más bien configuran un incumplimiento contractual. Al respecto, la jurisprudencia ha establecido que, para que apliquemos las reglas propias de los vicios redhibitorios, la cosa entregada debe

ser la cosa vendida, según se desprende del art. 1857 CC. Si no lo es, debemos aplicar las reglas generales del incumplimiento contractual.

Para distinguir cuándo un vicio de estas características debe entenderse como vicio redhibitorio, y cuándo debe entenderse como el incumplimiento de la obligación de entregar, cierto sector de la doctrina contemporánea<sup>1</sup> ha propuesto aplicar la distinción entre obligaciones de especie o cuerpo cierto y obligaciones de género. Sostienen que en las obligaciones de género, cualquier caso hipotético de vicios redhibitorios quedaría subsumido bajo la hipótesis del incumplimiento.

En las obligaciones de género, el deudor cumple entregando un individuo del género de una calidad a lo menos mediana, según el art. 1509 CC. Así, si se entrega una cosa defectuosa, en realidad no se ha entregado lo debido, sino otra cosa distinta. En cambio, si la cosa debida es una especie o cuerpo cierto, y ésta contiene defectos que cumplen con los requisitos del art. 1858 CC, entonces sí se configuraría el vicio redhibitorio.

#### ❖ **Vicios redhibitorios y error en las calidades esenciales:**

Como ya dijimos, el ámbito de aplicación del error en las calidades esenciales se encuentra en la frontera con el de los vicios redhibitorios, pudiendo incluso superponerse en algunos casos. En ambos casos, el legislador atiende a una discrepancia entre lo que el contratante se ha representado y le ha motivado a contratar, por un lado, y la materialidad de la cosa sobre la que recae el contrato, por el otro.

No obstante, a pesar de la similitud entre el error en el objeto y los vicios redhibitorios, podemos identificar las siguientes diferencias entre ambas:

- El error es un vicio del consentimiento, por lo que la falta de adecuación entre lo que el sujeto se representa y las cualidades de la cosa radica en su mente. En los vicios redhibitorios, se trata de un vicio objetivo de la cosa, que no sirve por sí misma a su uso natural, sin la necesidad de recurrir a la mente del comprador.
- El error es de aplicación amplia, los vicios redhibitorios solo aplican en la compraventa;
- Los vicios redhibitorios son renunciables anticipadamente, el error jamás puede ser renunciado de forma anticipada;
- El error se enraíza en el fuero interno del sujeto, el vicio redhibitorio depende de los datos objetivos de la cosa;
- El error produce la consunción de la nulidad relativa, mientras que los vicios redhibitorios dan lugar a la acción redhibitoria y la estimatoria.

En último término, la frontera entre ambas instituciones debe analizarse caso a caso. Podrían darse diversas situaciones. Podría ocurrir que concurran solo los requisitos de

---

<sup>1</sup> De la Maza, Íñigo y Vidal, Álvaro. *Aliud pro alio, incumplimiento contractual y vicios redhibitorios en el contrato de compraventa*. Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. 2018.

los vicios redhibitorios o solo los del error, en cuyo caso no hay problema. Podría suceder que concurren ambas instituciones en el mismo caso, como si se compra un caballo bajo la calidad esencial de que sea de carrera y finalmente no lo es, y además tiene una herida que impide su uso natural: en este caso, el actor podrá dirigirse por ambos defectos, pues la causa de pedir en cada caso es distinto.

El caso más complejo es el caso en que ambas instituciones se superponen. Supongamos un candelabro que se cree de plata, pero que en realidad es de estaño. Como dicho material es demasiado frágil, el candelabro se dobla bajo el peso de las velas. En este caso, la calidad esencial de la cosa es diversa de lo que se cree, y ese mismo hecho es un vicio oculto que impide que el candelabro sirva para su uso natural. Así, resultan aplicables las acciones que emanan del error y las que emanan del vicio redhibitorio. Si bien la jurisprudencia no ha sido uniforme y la doctrina no está conteste, la mayoría se inclina por aplicar el principio de especialidad y sostener que debe preferirse la acción redhibitoria.

#### ❖ **Efectos de los vicios redhibitorios (Arts. 1857 y 1860 CC):**

1) **Acción propiamente redhibitoria:** es una acción resolutoria de la compraventa. Los arts. 1857 y 1860 CC hablan de "rescisión", pero en verdad no hay nulidad relativa, sino incumplimiento de la obligación de entrega, y por ende, una hipótesis de resolución del contrato; curiosamente, en los proyectos de CC. previos al definitivo, e incluso en el aprobado, decía "resolución", pero Bello escribió "rescisión" en la corrección final).

2) **Acción estimatoria (acción quanti minoris):** acción para pedir la restitución de una parte del precio, proporcional a la disminución de valor resultante del vicio.

#### ❖ **Situaciones especiales:**

i) No todos los vicios redhibitorios autorizan al comprador para ejercitar alternativamente uno u otro derecho: únicamente le dan esta facultad los vicios que reúnen las calidades indicadas en el N° 2 del art. 1858 CC, esto es, los vicios graves, pues si el vicio no es grave, sólo hay derecho a ejercer la acción estimatoria.

ii) El art. 1861 CC hace más gravosa la responsabilidad del vendedor, cuando conoció los vicios o debió conocerlos en razón de su profesión u oficio (por ejemplo, un agricultor que vende trigo descompuesto o un mecánico que vende un automóvil cuyo motor estaba a punto de fundirse): además de la resolución del contrato o de la rebaja del precio, el comprador puede pedir indemnización de perjuicios. En otras palabras, en contra del vendedor de mala fe, el comprador tiene además acción de indemnización de perjuicios. El fundamento de esta mayor responsabilidad será el dolo negativo en el que incurrió el vendedor.

iii) El art. 1862 CC deja en claro que la pérdida de la cosa vendida no exime de la obligación de sanear los vicios redhibitorios, y si la cosa ha perecido a consecuencia del vicio, no sólo se puede pedir la rebaja del precio, sino también la resolución del

contrato, con indemnización de perjuicios. Aún más, se desprende del artículo 1862 que si la cosa se pierde por culpa del comprador pero a raíz del vicio redhibitorio, igualmente se podrá demandar la rebaja del precio. Así, por ejemplo, el automóvil se incendia a consecuencia de un defecto en su sistema eléctrico, y el comprador no puede impedirlo al circular sin extintor.

❖ **Caso en que el objeto vendido se compone de varias cosas:**

Si sólo una de ellas tiene vicios, sólo procede la acción respecto de ella, y no del conjunto, salvo que aparezca que no se habría comprado el conjunto sin ella (Art. 1864 CC).

❖ **Extinción de la obligación de saneamiento de los vicios redhibitorios:**

**i) Ventas forzadas** (Art. 1865 CC): no hay obligación de saneamiento, pero el vendedor debe de todos modos dar a conocer al comprador la existencia de los vicios que conozca o deba conocer.

**ii) Renuncia:** esta obligación también es de la naturaleza de la compraventa. La renuncia sólo produce efectos si el vendedor está de buena fe (Art. 1859 CC). Está de mala fe cuando conocía los vicios y no los comunicó al comprador.

**iii) Prescripción:**

1. Acción redhibitoria (Art. 1866 CC):

- a. Muebles: 6 meses.
- b. Inmuebles: 1 año.

2. Acción estimatoria (Art. 1869 CC):

- a. Muebles: 1 año. Excepción: si la compra se hace para remitir la cosa a un lugar distante, se amplía de acuerdo al emplazamiento, siempre que en el tiempo intermedio entre la venta y la remesa el comprador haya podido ignorar el vicio sin negligencia de su parte (Art. 1870 CC).
- b. Inmuebles: 18 meses.

Hay que tener presente:

- El plazo se cuenta desde la entrega real de la cosa, pues sólo entonces el comprador puede percatarse de la existencia de los vicios.
- Las partes pueden restringir o ampliar el plazo de prescripción de la acción redhibitoria.
- La acción de indemnización prescribe según las reglas generales.

## **2.7.2. OBLIGACIONES DEL COMPRADOR.**

### **2.7.2.1 OBLIGACIÓN DE RECIBIR LA COSA COMPRADA.**



**a) En qué consiste:** en hacerse cargo de la cosa, tomando posesión de ella. La manera práctica de cumplir variará según la naturaleza de la cosa. La recepción, al igual que la entrega, puede ser simbólica.

**b) Mora en recibir (Art. 1827 CC):**

- i) El comprador debe abonar al vendedor los perjuicios que sean consecuencia de la mora (incluido el gasto de alquiler de almacenes, graneros, los gastos de cuidadores, etc.).
- ii) El vendedor queda liberado del cuidado ordinario de la cosa, respondiendo sólo por su culpa grave o dolo.
- iii) El vendedor puede pedir el cumplimiento o la resolución del contrato (Art. 1489 CC).

#### **2.7.2.2 OBLIGACIÓN DE PAGAR EL PRECIO.**

Art. 1871 CC. "La principal obligación del comprador es la de pagar el precio convenido."

Es obligación de la esencia del contrato.

**1) Lugar y época del pago (Art. 1872 CC):**

- i) Si las partes han expresado su voluntad, el pago debe hacerse en la época y lugar convenidos (reglas generales).
- ii) Si nada han dicho, el pago debe hacerse en el momento y lugar de la entrega. En consecuencia, fijado un plazo o lugar para la entrega, rigen también para el pago del precio.

**2) Derecho del comprador para suspender el pago del precio (Art. 1872 inc. 2º CC):**

Tiene este derecho cuando se ve expuesto a perder la cosa. Son dos las causas que lo justifican:

- i) Que sea turbado en la posesión de la cosa.
- ii) Que pruebe que existe contra la cosa una acción real de que el vendedor no le dio noticia antes de celebrarse el contrato.

Pero el comprador no queda facultado para retener el precio en su poder, sino que debe ser depositado en virtud de una autorización judicial. El juez puede autorizarlo para conservarlo él mismo.

El depósito cesa:

- Por la cesación de la turbación.
- Por el otorgamiento, por parte del vendedor, de una caución que asegure las resultas del juicio.

**3) Consecuencias de la falta de pago del precio (Arts. 1489 y 1873 CC):** la mora del comprador da derecho al vendedor para exigir el cumplimiento forzado o la resolución del contrato. El comprador no está en mora cuando el vendedor no ha entregado la cosa o no está llano a entregarla.

Efectos de la resolución:

i) **Entre las partes:** tienen derecho a que se las restituya al estado anterior a la celebración del contrato:

1. Prestaciones a que tiene derecho el vendedor:

- a. Que se le restituya la cosa.
- b. Que se le restituyan los frutos que el comprador hubiere percibido mientras tuvo la cosa en su poder, en proporción al saldo insoluto del precio (todos los frutos si no se pagó nada, Art. 1875 inc. 1º CC). Esto es una excepción a la regla general de la resolución.
- c. Si se dieron arras, tiene derecho para retenerlas, o exigir las dobladas (Art. 1875 inc. 1º CC).
- d. Que el comprador le indemnice los deterioros de la cosa, para lo cual se lo considera de mala fe, a menos que pruebe haber sufrido, sin culpa de su parte, menoscabos tan grandes en su fortuna que le fue imposible cumplir (Art. 1875 inc. 3º CC).

2. Prestaciones a que tiene derecho el comprador:

- a. Que se le restituya la parte del precio que pagó (Art. 1875 inc. 2º CC).
- b. Que se le abonen las mejoras, para lo cual se le considera poseedor de mala fe, con la misma salvedad de la letra d. anterior.

ii) **Respecto de terceros:** se aplican las reglas generales de los Arts. 1490 y 1491 CC, es decir, la resolución no afecta a terceros de buena fe (Art. 1876 inc. 1º CC).

**4) Declaración en la escritura de haberse pagado el precio:** tiene importancia en relación con el ejercicio de la acción resolutoria.

Art. 1876 inc. 2º CC. "Si en la escritura de venta se expresa haberse pagado el precio, no se admitirá prueba alguna en contrario sino la de nulidad o falsificación de la escritura, y sólo en virtud de esta prueba habrá acción contra terceros poseedores."

En consecuencia, la declaración hace indudable la buena fe de los terceros, y no se admite prueba directa de que es inexacta la aseveración de haberse pagado el precio.

Esta disposición no rige para la acción del vendedor respecto del comprador, pues es una medida de protección a los terceros.

**5) Cláusula de no transferirse el dominio sino por el pago del precio.**

Art. 1874 CC. "La cláusula de no transferirse el dominio sino en virtud de la paga del precio, no producirá otro efecto que el de la demanda alternativa enunciada en el artículo precedente; y pagando el comprador el precio, subsistirán en todo caso las enajenaciones que hubiere hecho de la cosa o los derechos que hubiere constituido sobre ella en el tiempo intermedio."

El dominio, pese a la estipulación se transfiere al comprador. Pero la falta de pago del precio da al vendedor el derecho de pedir el cumplimiento o la resolución. El comprador adquiere el dominio, expuesto a resolverse.

Esto contradice al Art. 680 CC, que señala que la tradición transfiere el dominio de la cosa vendida, aunque no se haya pagado el precio, a menos que el vendedor se haya reservado el dominio hasta el pago.

## **2.8. PACTOS ACCESORIOS DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA.**

Art. 1887 CC. "Pueden agregarse al contrato de venta cualesquiera otros pactos accesorios lícitos; y se regirán por las reglas generales de los contratos."

El CC reglamenta 3 pactos.

### **1. Pacto comisorio**

Pacto comisorio: condición resolutoria de no cumplirse lo pactado, expresamente estipulado. Puede ser:

- 1) Simple: mismos efectos de la condición resolutoria tácita.
- 2) Calificado: no se resuelve de pleno derecho. El deudor puede enervar la acción en un plazo de 24 horas a contar de la notificación de la demanda.

### **2. Pacto de retroventa.**

#### **1) Concepto.**

Art. 1881 CC. "Por el *pacto de retroventa* el vendedor se reserva la facultad de recobrar la cosa vendida, reembolsando al comprador la cantidad determinada que se estipulare, o en defecto de esta estipulación lo que le haya costado la compra."

Importa una condición resolutoria del contrato de compraventa: el contrato está expuesto a desaparecer por el hecho futuro e incierto consistente en que el vendedor haga valer su opción de recobrar la cosa vendida. Es una condición meramente potestativa.

#### **2) Ventajas e inconvenientes.**

- 1) Es un eficaz medio de procurarse dinero el propietario de una cosa de la que no desea desprenderse definitivamente.
- 2) Presenta para el vendedor una ventaja sobre otras garantías, como la hipoteca: puede conseguir una mayor cantidad de dinero, ya que el acreedor que presta con garantía hipotecaria tiene en cuenta los gastos del cobro del crédito.
- 3) El comprador puede hacer suya la cosa por el sólo hecho de que el vendedor deje pasar el plazo sin efectuar el reembolso.

4) Sus inconvenientes derivan de que a menudo sirve para encubrir un pacto comisorio que la ley prohíbe. En el hecho, la estipulación puede tener por objeto permitir al prestamista hacerse pago de su crédito con la cosa dada en garantía.

### **3) Requisitos:**

- 1) Que el vendedor se reserve la facultad de recomprar la cosa vendida. La reserva debe estipularse en el mismo contrato de compraventa. La estipulación posterior importaría una promesa de compraventa.
- 2) El vendedor debe reembolsar al comprador el precio estipulado, y a falta de estipulación, el mismo precio de la venta.
- 3) Es indispensable que se conceda al vendedor un plazo para ejercitar su derecho, que no puede pasar de 4 años desde la fecha del contrato (Art. 1885 CC).

### **4) Condiciones para ejercitar el derecho que emana del pacto de retroventa.**

- 1) Que el vendedor haga valer judicialmente su derecho: si las partes se avienen a ejecutar la retroventa, no hay problema, pero si el comprador se resiste, el vendedor debe acudir a la justicia.
- 2) Que en el acto de ejercerlo ponga el precio a disposición del comprador.
- 3) Que el derecho se haga valer en tiempo oportuno: dentro del plazo convenido.
- 4) Que se dé el correspondiente aviso al comprador, con la debida anticipación (6 meses para inmuebles, 15 días para muebles). Esto no se aplica si la cosa produce frutos de tiempo en tiempo, mediante trabajos e inversiones; es justo que la restitución no pueda reclamarse sino después de obtenidos los frutos de su esfuerzo (Art. 1885 inc. 2º CC).

### **5) Efectos:**

1) Si el vendedor no ejercitó el derecho en tiempo oportuno: falla la condición resolutoria del contrato de compraventa. Caducan los derechos del vendedor; los del comprador se consolidan.

2) Si el vendedor ejercita su acción oportunamente: se cumple la condición resolutoria, se resuelve el contrato y se vuelve al estado anterior.

#### **i) Efectos entre las partes:**

1. El comprador debe restituir la cosa, con sus accesorios (Art. 1883 inc. 1º CC).
2. El comprador debe indemnizar al vendedor por los deterioros de la cosa imputables a su hecho o culpa (Art. 1883 inc. 2º CC).
3. El vendedor debe pagar al comprador las mejoras necesarias de la cosa (Art. 1884 inc. final CC).

ii) Efectos respecto de terceros: se rigen por las reglas generales de los Arts. 1490 y 1491 CC (Art. 1882 CC).

**6) El derecho que nace del pacto de retroventa es intransferible:** no puede cederse (Art. 1884 CC), pero podría transmitirse por causa de muerte.

### 3. Pacto de retracto.

#### 1) Concepto:

Es aquel en que las partes convienen que se resolverá la venta si, en un plazo determinado, se presenta un nuevo comprador que ofrezca al vendedor condiciones más ventajosas que el comprador primitivo.

Art. 1886 inc. 1º CC. "Si se pacta que presentándose dentro de cierto tiempo (que no podrá pasar de un año), persona que mejore la compra se resuelva el contrato, se cumplirá lo pactado; a menos que el comprador o la persona a quien éste hubiere enajenado la cosa, se allane a mejorar en los mismos términos la compra."

2) **Efectos:** los mismos del pacto de retroventa (Art. 1886 incs. 2º y final CC).

### 2.9 DE LA RESCISIÓN DE LA VENTA POR LESIÓN ENORME.

#### 1. Concepto y fundamento.

Lesión: perjuicio pecuniario que las partes sufren como consecuencia de la falta de equivalencia de las prestaciones recíprocas de un contrato conmutativo.

La compraventa es, en buena medida, una especulación. Pero un grave desequilibrio en las prestaciones no ha podido ser consentido sino bajo el imperio de una presión a la que el contratante no ha sido capaz de resistir (imperiosa necesidad de dinero). Este desequilibrio debe ser de gran entidad para que se justifique la rescisión: debe ser enorme.

#### 2. Requisitos de la rescisión por lesión enorme.

##### 1) Que la venta sea susceptible de rescindirse por lesión enorme:

La compraventa puede rescindirse por lesión enorme (Art. 1888 CC), pero no todas las compraventas:

- a) No procede en la venta de bienes muebles (Art. 1891 CC).
- b) Tampoco en las ventas hechas por el ministerio de la justicia (Art. 1891 CC).
- c) Ni tampoco en la venta de minas.

##### 2) Que la lesión sea enorme:

Art. 1889 CC. "El vendedor sufre lesión enorme, cuando el precio que recibe es inferior a la mitad del justo precio de la cosa que vende; y el comprador a su vez sufre lesión enorme, cuando el justo precio de la cosa que compra es inferior a la mitad del precio que paga por ella.  
El justo precio se refiere al tiempo del contrato."

El justo precio carece de definición legal. No obstante, la doctrina estima que este consiste en el precio de mercado del bien respectivo.

### **3) Que la cosa no haya perecido en el poder del comprador:**

Art. 1893 inc. 1º CC. "Perdida la cosa en poder del comprador no habrá derecho por una ni por otra parte para la rescisión del contrato."

Esto ocurre porque pronunciada la rescisión, deberá restituirse la cosa, lo que será imposible si la cosa ha perecido.

### **4) Que el comprador no haya enajenado la cosa:**

Art. 1893 inc. 2º CC. "Lo mismo será si el comprador hubiere enajenado la cosa; salvo que la haya vendido por más de lo que había pagado por ella; pues en tal caso podrá el primer vendedor reclamar este exceso, pero sólo hasta concurrencia del justo valor de la cosa, con deducción de una décima parte."

### **5) Que la acción se entable en tiempo oportuno (prescripción de la acción):**

Art. 1896 CC. "La acción rescisoria por lesión enorme expira en cuatro años contados desde la fecha del contrato."

Como es de corto tiempo, corre contra toda clase de personas (Art. 2524 CC).

## **3. Irrenunciabilidad de la acción rescisoria.**

Art. 1892 CC. "Si se estipulare que no podrá intentarse la acción rescisoria por lesión enorme, no valdrá la estipulación; y si por parte del vendedor se expresare la intención de donar el exceso, se tendrá esta cláusula por no escrita."

## **4. Efectos de la rescisión por lesión enorme.**

Sus efectos son los propios de la nulidad: queda sin efecto el contrato, el vendedor recobra la cosa, y el comprador recobra el precio.

Pero tiene una modalidad: como la rescisión se funda en la desproporción de las prestaciones, si se restablece el equilibrio, ya no hay perjuicio para las partes.

- Si la víctima es el vendedor, el comprador puede hacer subsistir el contrato completando el justo precio;
- Si la víctima es el comprador, el vendedor puede hacer lo mismo restituyendo el exceso.

### 1) Efectos si el demandado opta por evitar la rescisión:

Pronunciada la rescisión, nace para los contratantes el derecho para enervar el fallo:

Art. 1890 inc. 1º CC. "El comprador contra quien se pronuncia la rescisión, podrá a su arbitrio consentir en ella, o completar el justo precio con deducción de una décima parte; y el vendedor en el mismo caso, podrá a su arbitrio consentir en la rescisión, o restituir el exceso del precio recibido sobre el justo precio aumentado en una décima parte."

- 1) La facultad del demandado puede ejercerla a su arbitrio. El demandante sólo puede pedir la rescisión.
- 2) La opción del demandado nace una vez fallado el pleito y declarada la nulidad.
- 3) La ley fija la cantidad que debe pagar el demandado para evitar la rescisión. No debe llegarse al exacto justo precio, sino al justo precio reducido o aumentado en una décima parte, según el caso.

Art. 1890 inc. 2º CC. "No se deberán intereses o frutos sino desde la fecha de la demanda, ni podrá pedirse cosa alguna en razón de las expensas que haya ocasionado el contrato."

### 2) Efectos si el demandado consiente en la rescisión:

1. **Restitución de la cosa.** El vendedor debe restituir la cosa y el comprador el precio, con intereses y frutos, pero sólo desde la demanda.
2. **Expensas del contrato.** Las partes no están obligadas a pagar las expensas del contrato.
3. **Deterioros.**

Art. 1894 CC. "El vendedor no podrá pedir cosa alguna en razón de los deterioros que haya sufrido la cosa; excepto en cuanto el comprador se hubiere aprovechado de ellos."

4. **Terceros adquirentes.** La rescisión no afecta a terceros adquirentes. Si la cosa fue enajenada por el comprador, no hay derecho a rescisión.

5. **Terceros en cuyo favor el comprador constituyó un derecho real.** No afecta tampoco a los terceros en cuyo favor el comprador haya constituido un derecho real. Estos derechos no se extinguen de pleno derecho por la rescisión.

Art. 1895 CC. "El comprador que se halle en el caso de restituir la cosa, deberá previamente purificarla de las hipotecas u otros derechos reales que haya constituido en ella."

## CAPÍTULO 3 MANDATO.

### 3.1. GENERALIDADES

#### 1. Concepto de mandato.

Art. 2116 inc. 1º CC. "El *mandato* es un contrato en que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera".

#### 2. Elementos que se desprenden de la definición legal

**1) Confianza en la gestión de los negocios:** Aquí interviene un elemento subjetivo del mandante (contrato intuitu personae). De ello se desprenden algunas consecuencias:

- a) Intransmisibilidad. Las obligaciones del mandatario no se transmiten.
- b) Muerte del mandatario. Por muerte del mandatario se pone fin al contrato de mandato.
- c) Facultad de revocación. Normalmente existe la facultad del mandante de revocar el mandato.
- d) Error en la persona. El error en la persona es causal de nulidad de este contrato.

**2) La gestión de uno o más negocios:** El objeto del mandato es que el encargo constituye en definitiva la ejecución de un acto jurídico. Sin embargo, la expresión "gestión de negocios" permite diversas acepciones:

a) Acepción amplia: implica la ejecución de actos de cualquier naturaleza, sean jurídicos o materiales. Esta postura es rechazada porque cuando la ley ha querido que el mandatario realice hechos materiales, lo ha autorizado expresamente.

b) Acepción restringida: sólo implica la ejecución de actos jurídicos. Esta postura no es coincidente con la expresión "negocio". "Gestión de negocios" implica la idea de administrar un negocio ajeno, o sea gobernar, regir, cuidar y dar término a una operación de interés económico, para lo cual puede ser necesaria la ejecución de actos jurídicos.

c) Posición ecléctica: "gestión de negocios" indica la ejecución de un asunto que tenga atinencia en la creación, mantenimiento, transferencia o extinción de relaciones jurídicas. Este asunto puede ser estrictamente jurídico o de orden económico del cual se derive la ejecución de actos jurídicos.

Asuntos que pueden ser objeto del mandato:

- i) Conservación de un patrimonio (Art. 2132 CC).
- ii) Ejecución de cualquier negocio de índole económica para el mandante (Art. 2147)



- iii) Administración de una industria. (Art. 2132 parte final CC).
- iv) Realización de cualquier acto jurídico.

**3) Por cuenta y riesgo de la primera:** Es una característica esencial de este contrato, que no puede faltar. Esto no necesariamente importa que en el mandato sea esencial la representación. El mandatario siempre actúa por cuenta y riesgo del mandante, aún cuando actúe a su propio nombre. Esto significa que, aunque las consecuencias jurídicas del acto no se radiquen directamente en el patrimonio del mandante, será siempre él quien se aproveche de los beneficios y soporte las pérdidas económicas del negocio encomendado, como si el negocio lo hubiese realizado personalmente.

### 3.2. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO DE MANDATO.

#### **1. Bilateral.**

Genera derechos y obligaciones para ambas partes. Aunque el mandato sea gratuito (aunque el mandatario no reciba remuneración), el mandante igualmente contrae obligación: proveer fondos para la recta ejecución del mandato (Art. 2158 Nº 1 CC). Si el mandante no la cumple, el mandatario puede desistirse (Art. 2159 CC).

Por excepción puede ser unilateral, cuando por estipulación expresa de las partes, o por la naturaleza misma del contrato, el mandante no es obligado a pagar remuneración ni a proveer al mandatario de lo necesario para la ejecución del encargo. En todo caso, en este evento, se trataría al menos en doctrina de un contrato sinalagmático imperfecto.

#### **2. Naturalmente oneroso.**

La remuneración es de la naturaleza del mandato.

Art. 2117 CC. "El mandato puede ser gratuito o remunerado."

La remuneración (llamada *honorario*) es determinada por convención de las partes, antes o después del contrato, por la ley, la costumbre, o el juez." (Caso de costumbre según ley)

A propósito de la graduación de la culpa, el CC se aparta del Art. 1547 CC. Conforme al Art. 2129 CC, el mandatario responde hasta de culpa leve en cumplimiento del encargo, sin atender al carácter gratuito u oneroso del mandato, más que para agravar esta responsabilidad si es remunerado. Por el contrario, si el mandatario ha repugnado el encargo o se ha visto forzado a aceptarlo, será menos estricta su responsabilidad.

En cuanto al mandante, rige la regla general del Art. 1547 CC: si el mandato es gratuito, responderá hasta de la culpa levísima, limitándose a la culpa leve cuando sea remunerado.

### **3. Normalmente conmutativo.**

Normalmente el beneficio se mira como equivalente. Existe una relación entre la remuneración estipulada, la actividad desplegada por el mandatario para la ejecución del encargo y la utilidad que el mandante obtiene de la gestión realizada.

Es importante la relación entre la remuneración y el servicio, pues la remuneración se debe siempre, sin consideración a que el negocio haya tenido o no éxito, salvo que el fracaso se deba a culpa del mandatario (Art. 2158 inc. final CC).

Sin embargo, podrá ser aleatorio en determinados casos, como en cuando el mandatario sujeta sus honorarios a la resultados de la gestión (pacto de cuota litis).

### **4. Es principal.**

### **5. Normalmente consensual.**

El Art. 2123 CC establece la forma como puede hacerse el encargo: puede ser verbal, por escrito, mediante escritura pública o de cualquier modo inteligible.

- También constituye encargo de mandato la aquiescencia tácita por parte del mandante respecto de que otra persona le gestione un negocio.
- El silencio del mandante constituye aceptación cuando el mandatario da principio a la gestión con conocimiento y sin reclamo de él. Para los efectos de la prueba, rige la limitación de la prueba testimonial (Arts. 1708 y 1709 CC).

La aceptación del mandatario se perfecciona conforme a reglas generales (Art. 2124 CC): la aceptación puede ser expresa o tácita. La ley califica de aceptación del mandato cualquier ejecución que se haga del mismo.

El Art. 2125 CC establece un caso relevante de silencio circunstanciado que constituye aceptación del mandato: caso en que el encargo se efectúa a persona que por su profesión u oficio se encarga de negocio ajeno.

#### Requisitos:

- 1) Que la persona, por su profesión u oficio, normalmente gestione negocios ajenos.
- 2) Que el mandante se encuentre ausente.
- 3) Que haya transcurrido un tiempo razonable sin que el destinatario se excuse.

#### **Excepciones al consensualismo en el mandato:**

**1) Mandato para contraer matrimonio:** debe otorgarse por escritura pública y designarse expresamente a los contrayentes.

**2) Mandato judicial:** debe efectuarse (Art. 6º CPC):

- i. Mediante escritura pública, o
- ii. Mediante acta extendida ante el juez y suscrita por todos los otorgantes,

- o
- iii. Mediante declaración escrita del mandante, autorizada por el secretario del tribunal.

**3) Mandato que otorga la mujer para los efectos de enajenar bienes raíces sociales** (Art. 1749 inc. 7° CC): debe constar por escrito o por escritura pública si el acto requiere de esa solemnidad.

**4) Mandato para enajenar bienes raíces que el marido está obligado a restituir en especie** (Art. 1754 inc. 2° parte final CC): requiere escritura pública.

**¿El mandato, para los efectos de realizar un acto solemne, debe a su turno ser solemne?**

- La jurisprudencia, en torno a los bienes raíces, se inclinó por exigir la solemnidad del acto a ser realizado, por lo tanto para efectos de vender bienes raíces se exigía escritura pública.

Razones:

- 1) El poder o mandato es el único instrumento en que el comprador o vendedor manifiesta su consentimiento.
- 2) El Art. 2123 CC, que establece la regla del consensualismo, señala entre sus excepciones, el caso en que el mandato deba constar por escritura pública.

- Hoy en día parece que no cabe la menor duda de que no es necesaria la celebración del mandato solemne para realizar un acto solemne. El mandante que encomienda la compra o venta de algún bien no manifiesta en manera alguna el consentimiento necesario para que se perfeccione esa compraventa. El mandatario que en cumplimiento del encargo celebra el contrato, manifiesta su propio consentimiento y no el del mandante. Esta es la solución doctrinaria ampliamente aceptada. Sin embargo, esta solución en la práctica bancaria no es aceptada.

### **3.3. PARTES, INTERESES Y CAPACIDAD EN EL MANDATO.**

#### **❖ Partes.**

- 1. Mandante o comitente:** persona natural o jurídica que confiere el encargo.
- 2. Mandatario, apoderado o procurador:** persona que acepta el encargo.

#### **❖ Intereses.**

La gestión del negocio puede interesar a:

- Al mandante,
- Al mandante y al mandatario,
- A un tercero,
- o a un tercero y a ambos conjuntamente (Art. 2120 CC).

**a) Si el negocio interesa a un tercero,** el mandante puede actuar con autorización del tercero o sin ella. En el primer caso, habrá un verdadero mandato. En el segundo, se produce entre ambos el cuasicontrato de agencia oficiosa.

**b) Si el negocio interesa sólo al mandatario,** no hay mandato, sino un mero consejo que no produce obligación alguna (Art. 2119 CC); salvo que se haya dado maliciosamente, pues en tal caso da lugar a la indemnización de perjuicios.

**c) Si el que propone a otro la gestión de un negocio ajeno no lo hace con la intención de obligarse como mandante,** no hay mandato sino que una simple recomendación de negocios ajenos (Art. 2121 CC).

#### ❖ Pluralidad de mandatarios.

Pueden ser muchos, que obren individualmente o de consuno. La ley no ha establecido responsabilidad solidaria entre mandatarios (salvo la comisión mercantil); sin perjuicio de que se pacte (Art. 2127 CC).

#### ❖ Capacidad de los contratantes.

**1) Capacidad del mandante:** se aplican las reglas generales. Debe tener una doble capacidad:

- de celebrar el contrato de mandato
- y de ejecutar por sí mismo el acto o contrato que por el mandato encomienda. Si el mandante no está autorizado para ejecutar por sí mismo el contrato que encomienda, el mandato es nulo por ilicitud del objeto.

**2) Capacidad del mandatario:** hay una regla especial en el Art. 2128 CC: si es menor adulto, sus actos no lo obligan frente a mandante y terceros, sino de conformidad a las reglas generales (de acuerdo al Art. 1688 CC), pero sí obligan al mandante y terceros.

### 3.4. RELACIÓN ENTRE MANDATO Y REPRESENTACIÓN.

La representación es autónoma e independiente del contrato de mandato; de manera que puede existir independientemente de otra relación jurídica o unida a una relación contractual determinada.

Mandato y representación son cosas absolutamente distintas:

#### **1. Naturaleza jurídica:**

- El mandato es un acto jurídico; un contrato.
- La representación es una modalidad de los actos jurídicos.

## 2. Origen:

- El mandato tiene su origen en una convención;
- La representación puede tener su origen en la convención, en la ley o en una sentencia judicial. Ni aun en el caso de que el origen de la representación sea la convención, necesariamente es mandato.

## 3. Relación:

- Puede existir mandato y no existir representación (Art. 2151 CC). La representación es un elemento de la naturaleza del mandato y no de la esencia del mismo.

### 3.4.1. MANDATO SIN REPRESENTACIÓN.

Los derechos y obligaciones se radican en el patrimonio del mandatario. ¿Qué pasa con los derechos y obligaciones que nacen del contrato celebrado por el mandatario? Nace la **obligación para el mandatario de traspasar los derechos y obligaciones al mandante.**

No es el mismo el estatuto aplicable al traspaso de los derechos que al traspaso de las obligaciones, ya que al tercero contratante no le empece ni puede oponerse a que los derechos le sean traspasados al mandante, pero si le empece el traspaso de la deuda, porque importa un cambio de deudor.

#### 1) Traspaso de créditos y demás derechos:

El mandatario tiene la obligación de rendir cuenta de su gestión al mandante. La rendición de cuenta será el título necesario para el traspaso de los derechos. Hay que distinguir:

**a) Derechos Reales:** para transferirlos al mandante, el mandatario requiere de un título traslativo de dominio y de un modo de adquirir.

- El título es el propio contrato de mandato que, para estos efectos, se materializa en una escritura pública de rendición de cuenta<sup>2</sup>;
- el modo de adquirir es la tradición del derecho.

Una vez ejecutado el encargo, nace para el mandatario la obligación de entregar al mandante las cosas que ha adquirido por cuenta y riesgo de éste. Es una obligación de dar (Arts. 2153 y 2157 CC) que impone al mandatario la de entregar las cosas. Por tanto, el mandatario que transfiere al mandante cosas adquiridas, paga lo que debe.

**b) Derechos Personales o Créditos:** se efectuará la tradición de los mismos, según la naturaleza del título:

---

<sup>2</sup> Para algunos, resulta discutible si el título para el traspaso es la escritura de rendición de cuentas o el mandato mismo.

- 1) Cesión de créditos, si son nominativos (Art. 1901 y ss. CC).
- 2) Endoso, si son a la orden.
- 3) Entrega material del documento si son al portador.

Siempre se tiene como antecedente o título el propio mandato, que se materializa a través de la rendición de cuenta.

## **2) Traspaso de las deudas u obligaciones:**

La posición jurídica del deudor no puede ser cedida unilateralmente por éste, toda vez que al acreedor no le es irrelevante la persona contra la cual deberá dirigirse para cobrar su crédito. Por esa razón, el traspaso de las deudas u obligaciones se hará por medio de la novación, y será necesario distinguir si el acreedor consiente o no consiente en el cambio.

**a) Si no hay aquiescencia del acreedor:** el mandatario no quedará liberado de las obligaciones y seguirá siendo obligado. El mandante, en el supuesto de haber aceptado el traspaso de las deudas, será obligado a favor del tercero acreedor en calidad de deudor solidario o subsidiario (fiador).

En todo caso, en virtud del mandato, el mandante debe proporcionar al mandatario los fondos necesarios para cumplir las obligaciones contraídas por cuenta y riesgo de él.

**b) Si existe aquiescencia por parte del acreedor:** el acreedor consiente expresamente en dar por libre el mandatario (primitivo deudor), aceptando en su reemplazo al mandante. Se produce novación por cambio de deudor.

### **3.4.2. MANDATO CON REPRESENTACIÓN.**

Se producen los efectos propios de esta modalidad: los derechos y obligaciones nacidos en el contrato celebrado por el mandatario se radican en el patrimonio del mandante.

Como es una modalidad del acto, que quien la invoca debe probar su existencia.

### **3.5. SUBCONTRATACIÓN EN EL MANDATO.**

¿Puede o no el mandatario delegar el mandato que se le ha conferido?

En principio, la delegación está permitida, a menos que exista prohibición expresa por parte del mandante (Art. 2135 CC).

Para establecer las relaciones, entre mandante, mandatario y delegado, debemos distinguir:

#### **3.5.1. EL MANDANTE AUTORIZÓ EXPRESAMENTE LA DELEGACIÓN:**

Dos situaciones:

##### **1) Si la autorización fue genérica (sin designación de personas):**

- El mandatario es responsable en cuanto debe designar, necesariamente como delegado, a una persona solvente y capaz (Art. 2135 inc. 2º CC).
- Es un caso de responsabilidad objetiva sin culpa: el mandatario responde de los hechos del delegado como si fueran propios.
- Su culpa está en no haber elegido una persona solvente y capaz, aún cuando en los hechos del delegado no haya culpa del mandatario.

## **2) Si la autorización fue a persona determinada:**

- Nos encontramos con un nuevo contrato de mandato entre mandante y delegado.
- La verdad es que cuando se ha autorizado delegar en persona determinada, el mandatario se encuentra frente a una obligación alternativa que consiste:
  - a) En ejecutar él mismo el encargo, o
  - b) En delegar el encargo a un tercero.

### **3.5.2 EL MANDANTE NADA DICE RESPECTO DE LA DELEGACIÓN.**

No la ha autorizado ni la ha prohibido.

El mandatario puede delegar el encargo sino se le ha prohibido (Art. 2135 CC). La facultad de delegar es de la naturaleza del mandato.

## **1) Relaciones entre mandante y mandatario:**

- Frente al mandante, el mandatario es responsable por la inexecución del encargo y por el incumplimiento de cualquier otra obligación contraída por el mandato.
- El mandatario responderá de los hechos del delegado como de los suyos propios (Art. 2135 inc. 1º CC). Es una responsabilidad objetiva (sin culpa); sólo puede eximirse probando la inculpabilidad del propio delegado (caso fortuito o fuerza mayor)

## **2) Relaciones entre el mandante y el delegado:**

Hay que distinguir:

### **a) El mandatario contrata la delegación a nombre propio:**

- El mandato entre mandante y mandatario es ajeno al delegado.
- El mandante carece de acción en contra del delegado y el delegado es responsable exclusivamente frente al mandatario.
- El Art. 2138 CC faculta al mandante para ejercer contra el delegado las acciones del mandatario, pero eso no significa que tenga acción personal directa en contra del delegado, sino que el derecho a subrogarse en los derechos del mandatario (acción subrogatoria u oblicua del Art. 2466 CC).

### **b) El mandatario contrata la delegación a nombre del mandante:**

- Obliga al mandante para con el delegado y viceversa, por aplicación de los Arts. 2151 y 1448 CC.

- El mandatario celebra un contrato de mandato con el delegado, como cualquier otro a que está facultado por el mandato.
- El mandante tiene acción directa contra el delegado, y el delegado es responsable directamente al mandante.
- Todo lo cual supone que la delegación haya sido efectuada dentro de los límites del mandato; si fue fuera de dichos límites, el mandante no puede ser obligado (Art 2160 CC).

### 3) Relaciones entre el mandatario y el delegado:

**a) Si el mandatario delegó a su propio nombre:** se produce entre mandatario y el delegado un nuevo mandato;

**b) Si el mandatario delegó a nombre del mandante:** obliga a éste para con el delegado y no se obliga personalmente, siempre que actúe dentro de los límites de su mandato. El mandatario conserva su carácter de representante del mandante y en tal calidad el delegado le responde del cumplimiento de sus obligaciones.

### 4) Relaciones entre el mandante y los terceros:

Art. 2136 CC. "La delegación (a) no autorizada o (b) no ratificada expresa o tácitamente por el mandante no da derecho a terceros contra el mandante por los actos del delegado".

Tres posiciones en relación a la posibilidad de que el delegado represente al mandante frente a terceros:

**a)** Se requiere que el mandatario tenga facultad expresa de delegar.

**b)** Es necesario que haya mediado autorización del mandante o bien ratificación expresa o tácita de la delegación.

**c)** Haciendo una interpretación armónica de las disposiciones:

- La frase "delegación no autorizada" debe entenderse en el sentido de la "delegación prohibida". Esto concuerda con el Art. 2135 CC que autoriza al mandatario para delegar, de manera que al hacerlo obra dentro de sus facultades.
- Al delegar el encargo, se delegan las facultades para ejecutarlo, entre las que se cuenta la de contratar a nombre del mandante.
- Si admitimos que los actos del delegado no obligan al mandante frente a terceros, tendríamos que concluir que en tal caso los terceros no tienen acción personal derivada del contrato que celebran:
  - i. no pueden dirigirse contra el mandante;
  - ii. Tampoco pueden dirigirse contra el delegado porque no actúa a nombre propio; y
  - iii. Tampoco pueden dirigirse contra el mandatario, pues el delegado no obró a nombre del mandatario sino a nombre del mandante.



### 3.5.3 LA DELEGACIÓN HA SIDO PROHIBIDA POR EL MANDANTE:

- Si el mandatario delega, contraviene la prohibición (obligación de no hacer): que se resuelve en la de indemnizar perjuicios, y si es posible, deshacer lo hecho (Art. 1555 CC).
- En todo caso, el mandante podrá ejercer contra el delegado las acciones del mandatario por aplicación del Art. 2138 CC (acción subrogatoria).
- El mandatario queda personalmente responsable al delegado si no le dio suficiente conocimiento de sus poderes o se obligó personalmente a obtener la ratificación del mandante (Art. 2154 CC)

### 3.6. CLASES DE MANDATO.

#### **1. Mandato civil, comercial y judicial.**

- 1) Comercial:** el negocio cometido sea un acto de comercio (Art. 233 y ss. CCom.)
- 2) Judicial:** consiste en la comparecencia en juicio a nombre de otro.
- 3) Civil:** el negocio cometido sea un acto civil (todos los que no sean mercantiles o judiciales).

#### **2. Mandato general y especial (Art. 2130 CC).**

- 1) General:** se da para todos los negocios del mandante, o con una o más excepciones determinadas.
- 2) Especial:** comprende uno más negocios especialmente determinados.

#### **3. Definido e Indefinido.**

- 1) Indefinido:** se lo concibe en términos generales sin precisar poderes o facultades.
- 2) Definido:** se contemplan las atribuciones del mandatario. Distintos aspectos:
  - a) Facultades del mandatario:** Se plantea el problema en el mandato indefinido, que es resuelto por el Art. 2132 CC que los limita a los actos de administración, requiriendo poder especial para los actos que no lo sean.
    - En caso de que se lo faculte a obrar como mejor le pareciere no lo autoriza a alterar la sustancia del mandato, ni actuar en actos que exigen poderes especiales, Art. 2133 CC.
    - La cláusula de libre administración sólo faculta a ejecutar los actos que las leyes designan como autorizados por dicha cláusula, inc. 2 CC.
  - b) Concepto del acto de administración:** Administrar es adoptar las medidas

de carácter material o jurídico tendientes a conservar los bienes, incrementarlos y obtener las ventajas que pueden procurar. Algo puede deducirse del tenor del Art. 391 C. Com. El Art. 2132 CC señala algunos actos a modo de ejemplo.

De ellos se desprende que los actos de administración comprenden actos de conservación (impedir pérdida o menoscabo). Pueden ser de conservación material (reparar un edificio) o jurídica (interrumpir prescripción).

Además abarcan los actos tendientes a obtener de los bienes administrativos el provecho que están llamados ordinariamente a brindar.

No se incluyen los actos de disposición, que son los que alteran la composición del patrimonio. Si se venden frutos es de administración, pero si se vende el bien no lo es. Se concluye que los actos de disposición deben ser del giro ordinario del negocio para que sean actos de administración, ello se refleja en los Art. 387 y 397 del C. Com.

**c) Actos que requieren un poder especial:** Art. 2132 inc. 2 CC dice que para todos los actos que salgan del límite del mandato se requiere de poder especial o expreso. Pero hay casos en que se requiere por orden de la ley:

i) Poder para transigir, Art. 2448 CC.

ii) Art. 7 CPC nombra una serie de facultades que lo requieren.

**d) Facultades especiales que el CC reglamenta:**

i) Art 2141 CC la facultad de transigir no comprende la de comprometerse y viceversa.

ii) Art 2142 CC la facultad de vender comprende la de recibir el precio (si es que la facultad de vender no se comprende en el giro ordinario).

### **3.7. EFECTOS DEL CONTRATO DE MANDATO RESPECTO DE LAS PARTES:**

Los efectos del contrato de mandato son los derechos y obligaciones que emanan del mismo, tanto respecto del mandante como respecto del mandatario.

#### **3.7.1. OBLIGACIONES DEL MANDATARIO.**

Las obligaciones del mandatario son dos: i) la obligación de ejecutar el encargo y la obligación de rendir cuentas.

##### **3.7.1.1. OBLIGACIÓN DE EJECUTAR EL ENCARGO:**

Su naturaleza jurídica corresponde a la de una obligación de hacer.

El mandatario debe ceñirse rigurosamente a los términos del mandato, fuera de los casos en que las leyes lo autoricen para obrar de otro modo (Art. 2131 CC). Esto se refiere no solo a los fines encomendados por el mandante, sino también a los medios propuestos por el mismo. (Art. 2134 inc. 1º CC).

### **3.7.1.1.1. CASOS EN QUE LA LEY LO AUTORIZA A OBRAR DE OTRO MODO:**

- 1) Art. 2134 inc. 2º CC: se podrán emplear medios equivalentes a los ordenados por el mandante, cuando sea necesario y se obtuviere completamente de este modo el objeto del mandato.
- 2) Art. 2150 incs. 1º y 2º CC: el mandatario que se halle en la imposibilidad de obrar con arreglo a las instrucciones, no está obligado a constituirse en agente oficioso; pero debe tomar las providencias conservativas. Si no fuere posible dejar de obrar sin comprometer gravemente al mandante, actuará del modo que más se acerque a sus instrucciones y que más convenga al negocio.
- 3) Art. 2150 inc. 3º CC: compete al mandatario probar la fuerza mayor o el caso fortuito que le imposibilite de llevar a efecto las órdenes del mandante.
- 4) Art. 2148 CC: sus facultades se interpretan con mayor latitud cuando no está en situación de poder consultar al mandante.
- 5) Art. 2149 CC: debe abstenerse de ejecutar el mandato si ello es manifiestamente pernicioso al mandante.
- 6) Art. 2147 CC: caso en que puede realizar el negocio con mayor beneficio o menor gravamen.

### **3.7.1.1.2. PROHIBICIONES O LIMITACIONES LEGALES:**

Los Arts. 2144 a 2147 CC contemplan conflictos de intereses entre el mandante y el mandatario.

Art. 2144 CC: El mandatario:

- No puede comprar para sí las cosas que el mandante le ha ordenado vender;
- No puede vender de lo suyo al mandante lo que éste le ha ordenado comprar.
- Las prohibiciones no son absolutas sin embargo, porque el mandante puede autorizar dichos actos. Lo anterior implica que la facultad para autocontratar, requiere de expresa autorización.

Art. 2145 CC:

- No puede el mandatario tomar para sí el dinero que el mandante le encargó colocar o prestar a interés.
- Puede sin embargo el mandatario prestar de su dinero al mandante cuando éste le encargó obtenerlo, pero siempre que lo haga al mismo interés designado por el mandante o a falta de éste, al interés corriente.

Art. 2146 CC:

- No puede el mandatario colocar a interés dineros del mandante, sin autorización expresa de éste. Si contaba con dicha autorización para colocar el dinero a un determinado interés y lo coloca a un interés superior, el exceso no pertenecerá al mandatario sino que al mandante, salvo si el mandante lo hubiere autorizado para apropiarse del exceso.

Art. 2147 CC:

- Si el mandatario ejecuta el mandato con mayor beneficio o menor gravamen que los designados por el mandante, se prohíbe al mandatario apropiarse lo que exceda al beneficio o disminuya el gravamen designado en el mandato.

### **3.7.1.2. EXTRALIMITACIÓN DEL MANDATARIO EN SUS FACULTADES:**

Si el mandatario se extralimita incurre en responsabilidad frente a su mandante, pero también puede incurrir en responsabilidad frente a terceros, pues éstos quedarán privados de obtener del mandante el cumplimiento de las obligaciones contraídas a su nombre.

Determinar si el mandatario se extralimitó en sus facultades es una cuestión de hecho privativa de los jueces del fondo (no es susceptible de casación). Hay que distinguir:

#### **3.7.1.2.1 RESPONSABILIDAD DEL MANDATARIO FRENTE AL MANDANTE:**

Art. 2154 CC: Responsabilidad de carácter contractual para con el mandante, pues ha infringido la obligación de ceñirse rigurosamente a los términos del mandato (Art. 2131 CC). Por lo tanto, deben cumplirse los requisitos propios de la responsabilidad contractual (incumplimiento del contrato, culpa o dolo, daño, relación de causalidad, no concurra una causal de exención de responsabilidad y mora del deudor).

Los perjuicios que sufra el mandante normalmente consistirán en lo que sea obligado a cumplir por los actos y contratos celebrados por el mandatario fuera de sus poderes. Si el mandante no resulta obligado en favor de terceros, y sin embargo ratifica expresa o tácitamente los contratos celebrados por el mandatario, debe entenderse que renuncia a la acción de perjuicios que pudo intentar en contra de éste.

¿De quién es el peso de la prueba? De conformidad al art. 1698, si el mandante acredita la existencia del mandato, será el mandatario quien deberá acreditar que ha ejecutado el encargo en la forma convenida.

**1. Si por una necesidad imperiosa, el mandatario se sale de los límites:** cesa su responsabilidad para con el mandante y se convierte en un agente oficioso (Art. 2122 CC), pero él deberá acreditar esta circunstancia imperiosa. El mandatario tiene acción contra el mandante para que le reembolse las expensas útiles y necesarias y no es responsable por la infracción, salvo que el negocio haya sido mal administrado (Art. 2290 CC), en cuyo caso la responsabilidad emana de la agencia oficiosa y no de la infracción del contrato de mandato.

**2. Si el mandatario se excede culpablemente:** tendrá responsabilidad por perjuicios frente al mandante, y no tendrá acción en contra del mandante para demandar

las prestaciones que se le deban, salvo que pruebe que la gestión ha sido verdaderamente útil al mandante y que esa utilidad exista al tiempo de la demanda. En este caso, se aplica el Art. 2291 CC, pues, en definitiva, el mandatario actúa como en la hipótesis del agente oficioso que administra contra la expresa prohibición del interesado.

### **3.7.1.2.2. RESPONSABILIDAD DEL MANDANTE FRENTE A LOS TERCEROS:**

**1. Si el mandatario ha actuado a su propio nombre:** el mandante es ajeno a las relaciones derivadas de ese contrato. Es indiferente, para los terceros, que el mandatario haya o no excedido de sus facultades. Los terceros deben dirigirse contra el mandatario, quien es personalmente obligado.

**2. Si el mandatario ha actuado a nombre del mandante (con representación):** por regla general, el mandante no será obligado respecto de los terceros (Art. 2160 CC a contrario sensu). Se trata de un caso de inoponibilidad por falta de concurrencia de voluntad (el mandante no ha consentido en obligarse, ni ha sido legítimamente representado).

Si el mandante ratifica lo obrado por el mandatario, quedará obligado como si el mandatario hubiese actuado legítimamente (Art. 2160 inc. 2º CC). Por tanto, los actos celebrados por el mandatario no son nulos absolutamente por falta de consentimiento; si así fuese, no podrían ratificarse, sino que obligarían al mandante mientras no se declara la nulidad.

Ratificación del mandante: acto jurídico unilateral, en virtud del cual una persona acepta como suyas las declaraciones de voluntad hechas en su nombre por otra persona que carecía de poder suficiente.

Para la validez de la ratificación no es necesaria la aceptación del tercero ni la del mandatario.

La ratificación puede ser:

- a. Tácita: ejecución de actos que sólo podrían ejecutarse en virtud del contrato. El simple conocimiento del acto no basta. No requiere de formalidad alguna.
- b. Expresa: que debe reunir las formalidades del acto que ratifica.

- En cualquier caso, la ratificación opera con efecto retroactivo.
- La ratificación es irrevocable, pues crea derechos en favor de terceros contratantes.
- El mandante no tiene plazo para ratificar, puede hacerlo en cualquier tiempo. Los terceros pueden romper esta inercia demandando al mandante, quien en el plazo de contestación, deberá ratificar o alegar inoponibilidad.

### **3.7.1.2.3 RESPONSABILIDAD DEL MANDATARIO FRENTE A TERCEROS:**

La regla general es la irresponsabilidad del mandatario frente a terceros (Art. 2154 CC). Excepciones:

#### **1. Cuando el mandatario no ha dado suficiente conocimiento de sus poderes:**

En este caso, la responsabilidad del mandatario no emana de la infracción del contrato celebrado con el tercero, pues él no entiende obligarse personalmente, sino a su mandante. En consecuencia, su responsabilidad es de carácter delictual o cuasidelictual, pues habrá dolo o culpa al dejar en ignorancia a los terceros o al inducirlos a contratar en base a una condición jurídica distinta a la que ostenta.

Si el mandatario ha dado suficiente conocimiento, los terceros contratan bajo su cuenta y riesgo, pues saben que el contrato queda subordinado a la ratificación del mandante.

Son los terceros quienes deberán acreditar que el mandatario no les dio suficiente noticia de sus poderes.

#### **2. Cuando el mandatario se ha obligado personalmente:**

Esta expresión permite entender dos cosas:

- a. El mandatario ha contratado en su propio nombre. Esta hipótesis debe descartarse, porque la norma se refiere al caso en que el mandatario actúa a nombre del mandante.
- b. El mandatario contrata a nombre del mandante, pero se ha constituido en deudor solidario o subsidiario, o ha prometido por sí la ratificación del mandante (promesa de hecho ajeno). Esta es la hipótesis correcta.

### **3.7.1.3. OBLIGACIÓN DE RENDIR CUENTA:**

Obligación de la naturaleza del mandato. Es obligado a ella sea que haya obrado a su propio nombre o en representación de su mandante (Art. 2155 inc. 1º CC).

Objeto:

**1. Poner en conocimiento del mandante la forma en que se ha llevado a cabo la gestión y sus resultados.**

**2. Restituir al mandante lo que ha recibido el mandatario con ocasión de la ejecución,** sea del propio mandante o de terceros, aún cuando lo pagado por éstos no se deba al mandante (Art. 2157 CC). Además, el mandatario es responsable de lo que ha dejado de recibir por su culpa.

El mandante tiene acción reivindicatoria contra el mandatario para obtener la restitución de las cosas que le pertenecen y que el mandatario ha recibido del mandante o de terceros a nombre del mandante.

**3. Si el mandatario ha actuado a su propio nombre, la rendición de cuenta importa también la cesión de los derechos y el traspaso de las deudas.**

- La cuenta debe comprender los intereses corrientes de los dineros del mandante que el mandatario haya empleado en utilidad propia (Art. 2156 CC).
- Las partidas importantes de la cuenta deben ser documentadas (Art. 2155 inc. 2º CC). El mandante puede relevar al mandatario de la obligación de rendir cuenta documentada, y en este caso, el mandatario podrá acreditar la verdad de las partidas por todos los medios de prueba.
- El mandante puede relevar al mandatario de la obligación de rendir cuenta; pero esto debe ser acreditado por el mandatario, ya que la obligación de rendir cuenta es de la naturaleza del mandato. Esta liberación no produce otro efecto que el de alterar el onus probandi, pues no exonera al mandatario de los cargos que contra él justifique el mandante.
- La acción de rendición de cuentas es personal, transmisible y prescribe según las reglas generales, esto es, 5 años contados desde que la obligación se hizo exigible (3 años como ejecutiva si consta de título ejecutivo).
- El mandatario puede oponer a esta acción dos excepciones:
  - Prescripción extintiva de la acción de rendición de cuenta; y
  - Prescripción adquisitiva de las cosas adquiridas a su propio nombre (no a nombre del mandante, pues en ese caso reconoce dominio ajeno).
- La aprobación de las cuentas dada por el mandante determina irrevocablemente los saldos a favor o en contra de éste. No puede volver a discutirse, salvo que haya habido dolo del mandatario, a menos que el mandante condone expresamente el dolo contenido en ella.
- Procedimiento para el juicio de cuentas: Art. 227 N° 3 COT (juicio de cuenta es de arbitraje forzoso) y Arts. 693 y ss. CPC (para que se declare la obligación de rendir cuenta. Una vez rendida, y en caso de mediar objeción del mandante, se genera el juicio de cuentas para lo cual deberá designarse un árbitro).

**3.7.2 OBLIGACIONES DEL MANDANTE.**

Están en el Art. 2158 CC. Ninguna es de la esencia del mandato. Además, las partes pueden estipular otras obligaciones para el mandante.

**1. Cumplimiento de las obligaciones contraídas por el mandatario.**

Debe cumplir con las obligaciones que contraiga el mandatario, a su nombre, dentro de los límites del mandato, Art 2160 inc. 1 CC. Requiere dos condiciones:

1) El mandatario debe obrar a nombre del mandante: El art 2160 CC es concluyente ("a su nombre"), en concordancia con el Art. 1448 CC. Conforme al Art. 2151 CC en caso de que obre a nombre propio no obliga al mandante respecto de terceros, pero

en las relaciones con el mandante, se reputará haber obrado a nombre de éste, por lo que debe rendir cuentas y puede exigirle que le ceda las acciones contra terceros.

2) El mandatario debe obrar dentro de los límites del mandato: Si lo excede carece de poder y no obliga al mandante, pero el mandante se puede obligar por una ratificación, Art. 2160 inc. 2. Es tácita la ratificación cuando ejecuta actos que importen su propósito de apropiarse de lo hecho por el mandatario.

En caso de que se extralimite no obliga al mandante. El mandatario en principio no se obligaría por el Art 2154 CC, y para que responda debe ocurrir una de las hipótesis:

- i) Responde si ha asumido la responsabilidad frente a terceros, Art. 2154 Nº 2 CC.
- ii) No dar a conocer a terceros debidamente sus poderes, por lo que induce a éstos a creer que los límites del mandato no eran sobrepasados, Art 2154 Nº 1 CC.

En algunos casos el mandatario se convierte en agente oficioso:

- 1) Si ejecuta de buena fe un mandato nulo (ignora que el mandato es nulo).
- 2) Si excede los límites del mandato por imperiosa necesidad, Art. 2122 CC.

En caso de que haya una ejecución parcial del mandato no obliga al mandante sino en cuanto el cumplimiento del encargo le reportare beneficio, Art. 2161 CC. Además el mandatario debe indemnizar los perjuicios por la ejecución parcial.

## **2. Provisión de lo necesario para cumplir el mandato.**

Art 2158 Nº1 CC. El mandatario no está obligado a emplear recursos propios en el cumplimiento del encargo. Si faltan los fondos, puede desistirse del encargo. Art. 2159 CC.

Esta obligación es muy importante en la letra de cambio, según el Art. 648 C. Com que dice que el librador está obligado a poner en manos del librado antes del vencimiento los fondos destinados al pago de la cantidad librada. También el girador de un cheque debe proveer de fondos al librado, Art. 22 de Ley de Cuentas Corrientes Bancarias.

## **3. Obligación de indemnizar al mandatario**

El mandatario debe quedar indemne de los resultados del desempeño del mandato.

La indemnización comprende:

- i) Gastos razonables causados por la ejecución del mandato, Art. 2158 Nº 2 CC.
- ii) Reintegro de anticipaciones de dinero con intereses corrientes, Art. 2158 Nº 4 CC.
- iii) Pérdidas en que haya incurrido sin culpa y por causa del mandato, Art. 2158 Nº 5 CC.



#### **4. Obligación de remunerar al mandatario.**

Está obligado a remunerar la cantidad acordada, o sino la usual, Art. 2158 Nº 3 CC. En caso de desacuerdo lo soluciona el juez. No puede renunciar a pagar honorarios, gastos y anticipos o perjuicios a pretexto de que no resulto exitosa la gestión, salvo que se le pruebe culpa. Ello porque el mandatario no se obliga al éxito, sino a poner todo de su parte (buen padre de familia).

#### **5. Situación del mandante que incumple sus obligaciones.**

En caso de que el mandante incumpla sus obligaciones, el mandatario se entiende autorizado para excusarse del desempeño del encargo. Art. 2159 CC.

Por otro lado, el mandatario dispone de un derecho legal de retención respecto de los bienes que se le hayan entregado por cuenta del mandante, para asegurar el cumplimiento de las prestaciones que éste le deba. Art. 2162.

### **3.8. EFECTOS DEL CONTRATO DE MANDATO RESPECTO DE TERCEROS.**

#### **1. Mandatario que contrata a nombre propio.**

No obliga respecto de terceros al mandante (Art. 2151 CC). Pero una vez finalizada su gestión, debe traspasar a su mandante los créditos y derechos adquiridos y las deudas contraídas por la ejecución del mandato.

#### **2. Mandatario que contrata a nombre de su mandante.**

Opera la representación (Art. 1448 CC). Obliga al mandante frente a terceros, y no se obliga personalmente.

La representación es una modalidad: no se presume, debe acreditarse por quien la invoca. Los terceros deben probar, también, que el mandatario ha contratado dentro de los límites del mandato, pues sólo así queda obligado el mandante (la prueba de las obligaciones incumbe al que las alega). Los actos celebrados sin poder o en defecto del poder de representación son inoponibles al mandante. El riesgo de esta extralimitación recae en los terceros, quienes deben corroborar la existencia y el alcance del poder de representación (art 2160 CC).

Ahora, bien puede suceder que un tercero de buena fe contrate bajo la creencia errónea de que el aparente mandatario es, efectivamente, el mandatario de la persona con la cual se desea contratar. Como correctivo a esta situación, y como forma de proteger las apariencias y la buena fe, se establece la doctrina de los poderes aparentes. Si bien esta figura se encuentra regulada en el art. 2173 CC a propósito de los efectos del mandato que expira por causas desconocidas al mandante, cierta doctrina ha planteado una aplicación por analogía de dicha figura a situaciones como la descrita.

Así, si las circunstancias objetivas del caso permiten afirmar la apariencia del mandato, y un tercero de buena fe, con justa causa de error contrata persuadido por esta apariencia, podría alegar la existencia de los poderes aparentes para que el contrato le sea oponible al mandante. Es necesario hacer presente que la expansión analógica de la doctrina de los poderes aparentes es discutida en doctrina. Si bien se justifica en la protección de la buena fe de los terceros y de las apariencias, en contra puede decirse que desvirtúa la finalidad de la regla general del art. 2160 CC, a saber, que los contratantes sean diligentes al revisar los poderes de la contraparte.

### **3.8.1. LOS VICIOS DEL CONSENTIMIENTO Y EL DOLO DEL MANDATARIO**

- Vicio de la voluntad recayó en la voluntad del mandatario: Se ha resuelto que el mandante puede intentar la acción de nulidad por los vicios que hayan afectado la voluntad del mandatario (regla especial en la tradición, Art. 678 CC).

- Vicio de la voluntad recayó en la voluntad del tercero: Si los vicios han recaído en la voluntad del tercero, no hay duda que éste tiene acción de nulidad. Ello es categórico tratándose del error y la fuerza, pues vician el consentimiento con independencia de quién provenga.

El problema se plantea con el dolo, pues él vicia el consentimiento sólo cuando es obra de una de las partes. El dolo cometido por el mandatario, ¿es oponible al mandante?

1) Primera tesis: como el mandante no participó en la maquinación fraudulenta, el dolo del mandatario (que es personalísimo) no le puede ser oponible. El tercero sólo tiene :

- Acción de perjuicios contra el mandatario, por el total de los perjuicios,
- Y contra el mandante que se ha aprovechado de él y hasta concurrencia del provecho.

2) Segunda tesis (correcta): el dolo del mandatario es oponible al mandante porque el dolo ha sido obra de una de las partes (quien presta su consentimiento es el mandatario y no el mandante), aún cuando los efectos del mismo se radiquen en el mandante. El mandante se hace cargo de todos los derechos y acciones que emanan directa e inmediatamente del contrato.

Pero esto no quiere decir que el dolo del mandatario se traspase al mandante, pues según la jurisprudencia, el dolo es una actitud personalísima. El tercero podrá:

- Accionar de nulidad en contra del mandante,
- Dirigir la acción de perjuicios, pero deberá dirigirla en contra del mandatario. Esto, por cuanto el mandante, por regla general, no es responsable de los delitos y cuasidelitos cometidos por el mandatario en el desempeño de su cometido.
- El mandante responde de su propio dolo y del provecho que reporta del dolo del mandatario (Art. 2316 inc. final CC).

### **La responsabilidad del mandante por culpa o dolo del mandatario en el incumplimiento de una obligación contractual.**

Hipótesis: existe un contrato que liga válidamente a mandante y a un tercero; el cumplimiento del mandato ha sido encomendado al mandatario; el incumplimiento es imputable a dolo o culpa del mandatario; y el tercero contratante ha sufrido perjuicio.

El mandante es responsable de los perjuicios que se deriven del incumplimiento, aunque sea imputable al mandatario. En materia de responsabilidad contractual, en el hecho o culpa del deudor se comprende el de las personas por quienes fueren responsables (Arts. 1590 y 1679 CC).

El mandante no puede eximirse de responsabilidad alegando su falta de culpa. Debe probar también que el incumplimiento no ha sido imputable a su mandatario.

### **3.9 TERMINACIÓN DEL MANDATO.**

Además de las causales de extinción generales que puedan ser aplicables al mandato (pago, novación, resciliación, transacción, nulidad o caso fortuito), el Art. 2163 CC reglamenta causales especiales de extinción del mandato:

#### **1. DESEMPEÑO DEL NEGOCIO PARA EL CUAL FUE CONSTITUIDO (Art. 2163 N° 1 CC).**

Una vez ejecutado el negocio termina el mandato. Pero pueden quedar subsistentes obligaciones ya generadas, como las de rendir cuenta y pagar la remuneración. Estas obligaciones se extinguirán por el pago.

Esta causal sólo es aplicable a los mandatos especiales. Los mandatos generales para la administración de los bienes del mandante no se agotan, aún cuando se destruyan todos los bienes, pues jurídicamente su patrimonio subsiste.

#### **2. EXPIRACIÓN DEL TÉRMINO O EVENTO DE LA CONDICIÓN (Art. 2163 N° 2 CC).**

El mandato puede estar sujeto a un plazo o condición; cumplidos los cuales el contrato termina o se resuelve (pero la resolución no opera con efecto retroactivo). A todo evento, el mandato siempre estará sujeto a un plazo indeterminado: la muerte del mandante o mandatario.

#### **3. LA REVOCACIÓN DEL MANDANTE (Art. 2163 N° 3 CC).**

El mandante puede revocar el mandato a su arbitrio (Art. 2165 CC), lo que implica que, por regla general, no necesita explicar sus razones ni justificar una falta del mandatario.

El mandatario tiene esta facultad aunque el mandato sea remunerado. Si el mandatario ya ha dado comienzo a la gestión, los tribunales deberán regular los honorarios proporcionalmente a los servicios prestados.

La revocación pone término al mandato desde que el mandatario toma conocimiento de ella (Art. 2165 CC). Respecto de terceros, sólo produce efecto desde que éstos la conocieron.

### **1) La irrevocabilidad del mandato:**

La facultad de revocar es de la naturaleza del mandato.

Conforme al Art. 241 CCom (norma aplicable a todo mandato), el comitente (mandante) no puede revocar a su arbitrio la comisión aceptada, cuando su ejecución interesa al comisionista (mandatario) o a terceros.

Asimismo, es lícito el pacto por el cual mandante y mandatario convienen en que el primero no podrá revocar el encargo (Art. 12 CC). La ley, en determinadas ocasiones, ha prohibido expresamente el pacto de irrevocabilidad, de donde se sigue que la regla general es su licitud.

Sin embargo, se ha estimado ilícito el pacto de irrevocabilidad estipulado en un mandato general de administración de bienes, pues ello establecer una especie de incapacidad relativa.

Una vez pactada la irrevocabilidad, el mandante no puede prohibir a los terceros que contraten con el mandatario. Además, el mandante debe abstenerse de ejecutar por sí mismo el negocio, y si de hecho lo hace, quedará responsable de los perjuicios que irroque al mandatario (responsabilidad contractual).

### **2) Formas de la revocación (Art. 2164 CC).**

a) Expresa: de palabra o por escrito; siempre que se haga en términos explícitos.

b) Tácita: el mandante encarga el mismo negocio a otra persona (basta el encargo, no es necesaria la aceptación).

Si el primer mandato es general y el segundo especial, subsiste el primero en los negocios no comprendidos en el segundo. En la situación inversa, se ha resuelto el segundo mandato deja sin efecto al primero, pues se entiende que comprende el negocio anteriormente encomendado.

También es tácita cuando aparezca claramente y de cualquier modo la intención de poner término al mandato.

La revocación no está sujeta a formalidad alguna, ni aún cuando el mandato conste en escritura pública; salvo que el mandato deba constituirse en forma solemne por ley; en cuyo caso debe revocarse de igual manera.

### **3) Efectos de la revocación:**

Para que surta efecto respecto del mandatario, debe ponerse en su conocimiento. Puede hacerse por cualquier medio de comunicación. Basta que el mandatario sepa que sus poderes han sido revocados, aunque se entere por terceras personas.

Es el mandante quien tiene que acreditar que el mandatario tomó conocimiento, para lo cual puede servirse de todos los medios que le franquea la ley.

#### **a) Efectos de la revocación respecto del mandatario:**

- Desde que toma conocimiento de ella, cesa en sus funciones y debe abstenerse de seguir actuando, salvo en lo estrictamente necesario para evitar un

daño.

- Si el mandatario, sabedor de la revocación, contrata con terceros, deberá indemnizar al mandante de los perjuicios que esa contravención le haya ocasionado (Art. 2173 inc. 2º CC.)
- Si el mandatario, luego de la revocación, contrata a su propio nombre, pero por cuenta del mandante, no obliga al mandante con terceros ni tiene derecho a que el mandante le pague reembolsos, etc., salvo que la gestión hubiese sido útil al mandante y existiera la utilidad al tiempo de la demanda, en cuyo caso tiene acción contra el mandante hasta concurrencia del provecho (regla del Art. 2291 CC).

b) **Efectos de la revocación respecto de terceros:**

Es inoponible a los terceros de buena fe (aquellos que ignoran la revocación al tiempo en que contrataron con el mandatario). Para ellos, el mandato subsiste: lo que celebre el mandatario con ellos, obliga al mandante.

La buena fe se presume; incumbe al mandante acreditar que los terceros conocían de la revocación. Pero si el mandante notifica la revocación al público mediante avisos, o no pareciera probable la ignorancia del tercero, podrá el juez en su prudencia absolverlo (Art. 2173 inc. final CC).

Si los terceros contrataron de mala fe no tiene acción contra el mandante ni contra el mandatario.

**4. LA RENUNCIA DEL MANDATARIO (Art. 2163 N° 4 CC).**

El mandatario puede renunciar antes de dar comienzo a la gestión (Art. 2124 CC) o durante ella, sin perjuicio de continuar atendiendo los negocios del mandante por un tiempo razonable para que éste pueda encargárselo a un tercero o asumirlo personalmente. El mandatario no está obligado a justificar su renuncia ni a formularla en determinado tiempo.

**1) La irrenunciabilidad del mandato:**

Es lícito el pacto de irrenunciabilidad; salvo los casos en que la renuncia esté expresamente prohibida. Si pactada la irrenunciabilidad, el mandatario renuncia, la renuncia no produce efectos y se hace responsable de los perjuicios que se produzcan al mandante (responsabilidad contractual).

**2) Forma de la renuncia:**

La renuncia debe comunicarse siempre al mandante.  
Renuncia del mandato judicial: Art. 10 CPC.

**3) Efectos de la renuncia:**

Pone fin al mandato una vez vencido el tiempo razonable para que el mandante pueda hacerse cargo de los negocios (Art. 2167 CC).

En cuanto a los terceros, la renuncia no es oponible sino desde que han tomado

conocimiento de ella (Art. 2173 CC).

## **5. MUERTE DEL MANDANTE (Art. 2163 N° 5 CC).**

Produce efecto desde que el mandatario toma conocimiento (Art. 2168 CC). Mientras éste lo ignore, rige la regla del Art. 2173 inc. 1º CC.

### **1) Casos en que no obstante la muerte del mandante subsiste el mandato:**

- 1) Mandato destinado a ejecutarse después de la muerte del mandante (Art. 2169)
- 2) Mandato judicial (Art. 396 COT).
- 3) Comisión mercantil (Art. 240 CCom).
- 4) Cuando la suspensión de funciones pueda ocasionar perjuicio a los herederos del mandante (Art. 2168 CC).

### **2) Efectos de la muerte del mandante:**

Por regla general, pone término al mandato desde que el mandatario toma conocimiento de ella; pero los contratos celebrados por el mandatario, sabedor o ignorante de la muerte, con terceros de buena fe obligan a los herederos del mandante (Art. 2173 CC).

## **6. MUERTE DEL MANDATARIO (Art. 2163 N° 5 CC).**

Pone fin al mandato (Art. 2170 CC) salvo estipulación de continuar el mandato con los herederos del mandatario.

Si existen varios mandatarios que deban obrar conjuntamente, la muerte de uno de ellos pone término al mandato respecto de todos (Art. 2172 CC).

## **7. INSOLVENCIA DEL MANDANTE O MANDATARIO (Art. 2163 N° 6 CC).**

Si el mandante adquiere la calidad de deudor en un procedimiento concursal de liquidación, queda inhibido de administrar libremente sus bienes, por lo que tampoco podrá hacerlo por medio de mandatario.

Misma situación ocurre respecto del mandatario, dada la relación de confianza que este contrato supone.

## **8. INTERDICCIÓN DE MANDANTE O MANDATARIO (Art. 2163 N° 7 CC).**

Quien ha sido declarado interdicto, ha sido privado de la administración de sus bienes, por lo que cesa el mandato de pleno derecho.

## **9. CESACIÓN DE LAS FUNCIONES DEL MANDANTE, SI EL MANDATO HA SIDO DADO EN EJERCICIO DE ELLAS (Art. 2163 N° 9 CC).**

Ej. Mandato otorgado por el padre o madre en ejercicio de la patria potestad. Lo mismo sucede con el resto de los representantes legales.

### **3.10 ACTOS EJECUTADOS POR EL MANDATARIO DESPUÉS DE EXPIRADO EL MANDATO.**

Los actos ejecutados por el mandatario después de la expiración del mandato le son inoponibles al mandante. Como ya lo anticipamos más arriba, el legislador establece ciertas excepciones, que se fundan en la protección de la buena fe de los terceros y en la protección a las apariencias. Es la denominada teoría de los poderes aparentes, expresamente consagrada en el artículo 2173 CC:

1) Si el mandatario (y los terceros) ignoran que ha terminado el mandato, sus actos obligan al mandante, Art. 2173 inc. 1 CC. El mandatario y los terceros deben estar de buena fe.

2) Si los terceros ignoraban la terminación y el mandatario no, igual se obliga en mandante. La buena o mala fe del mandatario es indiferente para con los terceros, sólo importa para las relaciones con el mandante, ya que tiene derecho a demandar al mandatario de mala fe, inc. 2 CC. Se puede absolver al mandante si la extinción se notificó por periódicos y en los casos en que parece improbable que ignoren la extinción, inc. 3 CC.

Art. 2173 CC. En general, todas las veces que el mandato expira por una causa ignorada del mandatario, lo que éste haya hecho en ejecución del mandato será válido y dará derecho a terceros de buena fe contra el mandante.

Quedará asimismo obligado el mandante, como si subsistiera el mandato, a lo que el mandatario sabedor de la causa que lo haya hecho expirar, hubiere pactado con terceros de buena fe; pero tendrá derecho a que el mandatario le indemnice.

Cuando el hecho que ha dado causa a la expiración del mandato hubiere sido notificado al público por periódicos, y en todos los casos en que no pareciere probable la ignorancia del tercero, podrá el juez en su prudencia absolver al mandante.

## CAPÍTULO 4. CESIÓN DE DERECHOS.

### 4.1. GENERALIDADES.

Las cosas incorpóreas, en su manifestación de derechos reales y personales pueden ser objeto de enajenación o transferencias (excepto los derechos personalísimos)

La cesión de los derechos reales sigue las reglas de todos los contratos, con excepción del derecho real de herencia, para el cual el Código Civil ha establecido normas especiales.

- Tratándose de los derechos personales, la ley también ha dispuesto normas particulares en los Arts. 1901 a 1908 CC, bajo el título “De los créditos personales”.
- Los Arts. 1909 y 1910 CC regulan la cesión del derecho real de herencia.
- Los Arts. 1911 a 1914 CC se refieren a los derechos litigiosos.

### 4.2. CESIÓN DE CRÉDITOS PERSONALES.

#### **1. Concepto de créditos personales.**

Los créditos son necesariamente personales. El legislador ha querido significar créditos “nominativos”.

#### **2. Clasificación de los créditos.**

**a) Créditos nominativos:** aquellos en que se indica con toda precisión la persona del acreedor y no son pagaderos sino a la persona precisamente designada. La cesión de estos créditos es la única regida por el CC.

**b) Créditos a la orden:** aquellos en que al nombre de la persona del titular se antepone la expresión “a la orden” u otra equivalente, y son pagaderos a la persona designada o a quien ésta ordene o designe. Su cesión se verifica mediante el endoso (Art. 164 CCom).

**c) Créditos al portador:** aquellos en que no se designa a la persona del acreedor, o llevan la expresión “al portador”. Se ceden por la mera tradición manual (Art. 164 CCom).

#### **3. Concepto de cesión de créditos:**

**Cesión de créditos:** es la convención por la cual un acreedor cede voluntariamente sus derechos contra el deudor a un tercero que llega a ser acreedor en lugar de aquél. El enajenante toma el nombre de **cedente**, el adquirente del crédito es el **cesionario**, y el deudor contra el cual existe el crédito que constituye el objeto del traspaso, se llama **deudor cedido**.



#### 4.2.1. NATURALEZA JURÍDICA DE LA CESIÓN DE CRÉDITOS.

Se plantea en la doctrina si la cesión de créditos es un contrato o la manera de hacer la tradición de los derechos personales.

- Se sostenía por algunos que la cesión de derechos personales no era otra cosa que un contrato de compraventa de cosas incorporales. Tal es el concepto que de la cesión de derechos tiene el CC italiano.
- En nuestra legislación, sin embargo, y así se sostiene unánimemente hoy en día por la doctrina, la cesión de derechos personales no es un contrato, sino la manera de efectuar la tradición de los derechos personales. No es un contrato generador de obligaciones, sino la manera de cumplir o consumir el contrato, la manera en que se transfiere el dominio sobre un derecho. Tal naturaleza jurídica concuerda con el concepto precedentemente indicado.

En definitiva, su ubicación sugiere que es un contrato pero su examen lleva a la conclusión de que es la tradición de los derechos personales:

- a) El Art. 1901 CC señala la forma en que se perfecciona entre cedente y cesionario, a cualquier título que se haga. Es decir, la cesión requiere un título.
- b) El Art. 1907 CC regula la responsabilidad que contrae el cedente en la cesión a título oneroso. Misma conclusión.
- c) El Art. 1901 CC reproduce casi literalmente la regla del Art. 699 CC.

#### 4.2.2. FORMALIDADES DE LA CESIÓN.

##### **a) Partes que intervienen:**

En toda cesión de créditos, intervienen tres personas:

- **El cedente:** que es el acreedor, titular del derecho personal y que lo transfiere a otro.
- **El cesionario:** que es la persona que adquiere el derecho cedido y pasa a ocupar el lugar del acreedor.
- **El deudor:** sujeto pasivo del derecho cedido, que queda obligado en favor del cesionario.

Si en la cesión intervienen tres personas, hay que analizar la manera como se perfecciona respecto de todos ellos. En la cesión de créditos hay dos etapas: la primera se desarrolla entre el cedente y el cesionario y tiende a dejar perfeccionada entre ellos la cesión; la segunda etapa se desarrolla con el deudor, y tiende a ponerlo en conocimiento de que la persona del acreedor ha cambiado.

##### **b) Perfeccionamiento de la cesión entre las partes:**

El sólo acuerdo no es suficiente. La cesión no tiene efecto entre cedente y cesionario

sino en virtud de la entrega del título (Art. 1901 CC).

Al efectuarse la tradición, debe anotarse en el título entregado el traspaso del derecho, designando al cesionario y bajo la firma del cedente (Art. 1903 CC).

En ciertos casos, el crédito cedido no consta en un instrumento que pueda traspasarse. En tal hipótesis, debe especificarse el crédito en la escritura de cesión, sirviendo la misma escritura de título que deberá entregarse al cesionario.

### **c) Perfeccionamiento de la cesión respecto del deudor y terceros:**

Realizada la entrega real o simbólica del título por el cedente al cesionario, queda perfeccionada la transferencia del dominio del crédito, y radicado éste en manos del cesionario. Concluye con esto la primera etapa de la cesión de créditos. Pero hay otro que tiene intereses comprometidos, el deudor. Este puede no tener conocimiento del acto que ha mediado entre el cedente y el cesionario; pero dado que es él quien va a efectuar el pago, es de absoluta necesidad que se le ponga en conocimiento de la cesión. A este propósito responden los Arts. 1902 a 1905 CC.

Conforme al art. 1902, para que la cesión produzca efectos respecto del deudor y terceros, es necesario que se le notifique al primero o la acepte.

La omisión de esta notificación o aceptación no invalida la tradición entre el cedente y el cesionario, pero respecto del deudor y los terceros, el crédito se reputa subsistir en manos del cedente, con las consecuencias del Art. 1905 CC: el deudor podrá pagar al cedente, y los acreedores del último podrán embargar el crédito.

El perfeccionamiento puede ser de 2 formas:

#### **1) Notificación del deudor:**

- a) La notificación debe ser judicial y efectuarse personalmente.
- b) La iniciativa de la notificación corresponde al cesionario.
- c) Debe practicarse cumpliendo los requisitos generales de toda notificación personal, y además debe hacerse con exhibición del título, que lleve anotado el traspaso (Art. 1903 CC).

#### **2) Aceptación del deudor:** puede ser expresa o tácita.

El art. 1904 CC se refiere a la aceptación tácita, señalando que la aceptación podrá consistir en un hecho que la suponga, como la litis contestación con el cesionario, un principio de pago al cesionario, etc.

Sobre la aceptación, cabe tener presente:

- Si la aceptación no consta en el instrumento público o privado, sino que se presta verbalmente, regirán las limitaciones a la prueba de testigos contempladas en los Arts. 1708 y 1709 CC.
- Si la aceptación se da por instrumento privado, eventualmente deberá pedirse en juicio que el deudor lo reconozca o que se mande tener por reconocido, conforme al Art. 346 del CPC.

- En cuanto a la fecha del documento privado en que conste la aceptación: adquirirá ante terceros el carácter de "fecha cierta" conforme a lo dispuesto en el Art. 1703 CC.

Cabe indicar que **el deudor no puede oponerse a la cesión**: Art. 1636 CC, respecto de la novación. Aún cuando el deudor no consienta o se oponga a la cesión, queda obligado para con el cesionario. Estamos ante lo que se denomina delegación imperfecta. Para un solo efecto tiene importancia que la cesión haya sido aceptada por el deudor, y es en materia de compensación. Si la cesión le ha sido notificada y la ha aceptado sin reservas, el deudor no puede oponer en compensación al cesionario, los créditos que antes de la cesión hubiera podido oponer al cedente. Pero si al tiempo de la cesión formula reservas, podrá oponer todos los créditos que tenga contra el cedente (Art. 1659 inc. 1 CC). Igual ocurre, si no medió aceptación, es decir, si el deudor fue notificado de la cesión (Art. 1659 inc. 2 CC).

#### 4.2.3. EFECTOS DE LA CESIÓN.

##### **a) Extensión de la cesión:**

Art. 1906 CC. "La cesión de un crédito comprende sus fianzas, privilegios e hipotecas; pero no traspasa las excepciones personales del cedente."

De conformidad al Art. 1906 CC, el crédito pasa al cesionario en las mismas condiciones que lo tenía el cedente. Por excepción, no pasan al cesionario las excepciones personales del cedente, en lo que se diferencia la cesión de derechos con la subrogación, con una salvedad: la única excepción personal que pasa al cesionario es la nulidad relativa (Art. 1684 CC).

- En cuando a la excepción de compensación, como ya advertíamos:

Art. 1659 CC. "El deudor que acepta sin reserva alguna la cesión que el acreedor haya hecho de sus derechos a un tercero, no podrá oponer en compensación al cesionario los créditos que antes de la aceptación hubiera podido oponer al cedente.

Si la cesión no ha sido aceptada, podrá el deudor oponer al cesionario todos los créditos que antes de notificársele la cesión haya adquirido contra el cedente, aun cuando no hubieren llegado a ser exigibles sino después de la notificación".

## **b) Responsabilidad del cedente:**

Art. 1907 CC. "El que cede un crédito a título oneroso, se hace responsable de su existencia al tiempo de la cesión, esto es, de que verdaderamente le pertenecía en ese tiempo; pero no se hace responsable de la solvencia del deudor, si no se compromete expresamente a ello; ni en tal caso se entenderá que se hace responsable de la solvencia futura, sino sólo de la presente, salvo que se comprenda expresamente la primera; ni se extenderá la responsabilidad sino hasta concurrencia del precio o emolumento que hubiere reportado de la cesión, a menos que expresamente se haya estipulado otra cosa."

La cesión tiene que efectuarse en virtud de un título, ya sea oneroso o gratuito.

- Si la cesión es a título gratuito, el cedente no contrae responsabilidad alguna, ya que se trata de un acto de mera liberalidad de su parte.
- Si la cesión es a título oneroso, el cedente responde del saneamiento de la evicción conforme a las reglas generales. La obligación de sanear que tiene el cedente, puede desaparecer o modificarse por pacto entre las partes.
  - La regla general es que el cedente sólo responde de la existencia del crédito, pero no de la solvencia del deudor, a menos que así, lo convengan las partes, en cuyo caso el cedente responde de que el crédito sea pagado.
  - Si el cedente responde de la solvencia del deudor, se entiende que se trata de la solvencia al tiempo de la cesión, y no de la solvencia futura, a menos de estipulación en contrario, caso en el cual el cedente se constituye en una especie de fiador del deudor. Pero en este caso, si el deudor cae en insolvencia, el cedente no responde sino hasta concurrencia de lo que recibió por el crédito, a menos que se hubiere pactado otra cosa.

## **4.3 CESIÓN DEL DERECHO REAL DE HERENCIA.**

La regla general es que el derecho real de herencia sea adquirido por el modo de adquirir el dominio sucesión por causa de muerte. No obstante, también es posible adquirirlo por tradición. La cesión del derecho de herencia es la vía jurídica para adquirir el derecho real de herencia por tradición.

### **1. Concepto.**

**Cesión del derecho real de herencia:** es la cesión o transferencia a título oneroso que el heredero hace del todo o parte de su derecho de herencia a otra persona.

### **2. Presupuesto necesario de la cesión.**

La herencia es un derecho real que abarca la totalidad de los derechos y obligaciones transmisibles del causante o una parte o cuota de ellos, según estemos ante un heredero universal o ante herederos de cuotas. Es por tanto un derecho universal, y al igual que el patrimonio, forma un todo independiente de los elementos que lo componen. No está formado por los bienes del causante, sino que es un todo abstracto, independiente de sus componentes.

Para que pueda haber cesión del derecho de herencia, es necesario, como presupuesto, que la sucesión esté abierta. De acuerdo al Art. 955 inc. 1 CC, la sucesión de una persona se abre al momento de su muerte, en su último domicilio. Se denomina delación de una asignación hereditaria el actual llamamiento de la ley para aceptarla o repudiarla.

De no concurrir tal presupuesto básico, la cesión adolecería de objeto ilícito (Art. 1463 CC), y por lo tanto, sería susceptible de declararse nula (nulidad absoluta). Recordemos que lo anterior tiene una excepción, en lo que se refiere a la cuarta de mejoras (Art. 1204 CC).

#### **4.3.1 MANERAS DE EFECTUAR LA CESIÓN.**

**a) Especificando los bienes comprendidos.**

**b) Sin especificarlos.**

Los Arts. 1909 y 1910 CC sólo se aplican en la segunda hipótesis.

- En el primer caso, hay en realidad una verdadera compraventa o permuta, que se rigen por las reglas generales. Por tanto, al hacerse la partición, si resulta que al cesionario no se le adjudica el bien que adquirió específicamente, el cedente tendrá las responsabilidades propias de los contratos mencionados, cuando no se cumple con la obligación de entregar.
- Cuando lo que se cede es una cosa incorporal que se denomina "derecho de herencia", lo que se cede es el derecho del heredero a participar en la distribución de los bienes del difunto. Ello explica el Art. 1909 CC, en cuanto el cedente sólo responde de su calidad de heredero o legatario. El objeto de la cesión del derecho de herencia es una universalidad o la cuota que al cedente corresponde en el conjunto de bienes que comprenden el haber hereditario; los bienes individualmente determinados, no son objeto de esa cesión.

**La cesión puede hacerse a título gratuito u oneroso.**

En el primer caso, estamos ante una donación que queda por completo sometida a las reglas generales que rigen ese contrato, en conformidad a las cuales el cedente no tiene ninguna responsabilidad. La cesión del derecho de herencia propiamente tal, es la cesión a título oneroso, única regida por los Arts. 1909 y 1910 CC.

Debe tenerse en cuenta que lo que se cede en la cesión del derecho de herencia, no es la calidad de heredero o legatario, puesto que tales calidades dependen de las relaciones de familia, si la herencia es intestada, o del testamento, si se trata de

una herencia testamentaria; lo que se cede, son las consecuencias patrimoniales que resultan de la calidad de heredero.

A su vez, como en el caso de la cesión de créditos, la cesión del derecho real de herencia es la tradición o enajenación de este mismo derecho, y no el contrato, ya que este es el antecedente en virtud del cual una de las partes se obliga a transferir este derecho a otra, obligación que se cumple verificando la cesión.

La cesión del derecho real de herencia a título oneroso debe tener un título que le sirva de antecedente jurídico. Este título o contrato debe constar por escritura pública, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 1801 CC.

#### **4.3.2. TRADICIÓN DEL DERECHO REAL DE HERENCIA.**

Se ha debatido si la cesión requiere ser inscrita en el Registro Conservatorio, especialmente si la herencia sobre la que recae el derecho cedido, está compuesta por inmuebles.

La jurisprudencia y la mayoría de la doctrina, estiman que no es necesario practicar inscripción para que se entienda verificada la tradición. Argumentos:

- En el CC., no se encuentra disposición alguna que exija la inscripción, y no podría invocarse para tal efecto el Art. 686 CC, porque en él no se menciona el derecho de herencia, siendo tal norma excepcional y por ende de interpretación restrictiva;
- Para que pueda hacerse la tradición mediante la inscripción en el Registro Conservatorio, es necesario que el título se refiera a inmuebles determinados, lo que no puede acontecer tratándose de la cesión del derecho real de herencia, que necesariamente recae sobre bienes indeterminados, es una universalidad jurídica, independiente de las cosas que la componen.

La Corte Suprema ha resuelto que la tradición del derecho real de herencia no requiere inscripción, aunque en la herencia haya inmuebles, y que basta con cualquier acto que signifique ejercicio del derecho por parte del cesionario, como por ejemplo, que solicite la posesión efectiva, que provoque el juicio de partición, que participe en la misma, etc.

#### **Críticas:**

- 1) Sustraer a la herencia de la clasificación de mueble o inmueble es metafísica.
- 2) Si la ley no ha señalado forma especial, la tradición debe hacerse de acuerdo a los bienes que la integran.
- 3) La doctrina aceptada importa negar la necesidad de una tradición, pues en nada se parece, por Ej. la petición de posesión efectiva con la tradición.
- 4) La falta de inscripción crea una solución de continuidad contraria al propósito del legislador.
- 5) La sustracción de los inmuebles al régimen normal deja sin efecto las medidas que adopta la ley para proteger a los incapaces.

#### **4.3.3 EFECTOS DE LA CESIÓN.**

El cesionario adquiere todos los derechos y contrae todas las responsabilidades del cedente como consecuencia de que pase a ocupar el lugar jurídico que tenía el cedente (Art. 1910 CC):

- 1) El cedente debe al cesionario todos los elementos activos de la sucesión: debe hacerle entrega de los bienes.
- 2) Debe igualmente los frutos que haya percibido, los créditos que haya cobrado, los precios recibidos por la enajenación de bienes, etc.
- 3) El cesionario debe reembolsar los costos necesarios y prudentiales que haya hecho el cedente en razón de la herencia.
- 4) El cesionario beneficia del derecho de acrecer.
- 5) El cesionario puede:
  - Solicitar la posesión efectiva,
  - Solicitar la partición de bienes,
  - Intervenir en la partición,
  - Ejercitar las acciones de petición de herencia y reforma de testamento.

#### **4.3.4 RESPONSABILIDAD EN LA CESIÓN.**

##### **a) Responsabilidad del cedente:**

Art. 1909 CC. "El que cede a título oneroso un derecho de herencia o legado sin especificar los efectos de que se compone, no se hace responsable sino de su calidad de heredero o de legatario."

Si la cesión es a título gratuito, no hay responsabilidad del cedente.

##### **b) Responsabilidad del cesionario ante terceros:**

El cesionario se hace responsable del pasivo ante el cedente. Pero ante terceros, el cedente continúa siendo responsable, teniendo acción de reembolso contra el cesionario. Los acreedores pueden de todos modos accionar contra el cesionario (lo aceptan como deudor).

#### **4.4 CESIÓN DE DERECHOS LITIGIOSOS.**

##### **1. Concepto del derecho litigioso**

**Derechos litigiosos:** aquellos derechos que son objeto de una controversia judicial, cuya existencia es discutida en juicio (Art. 1911 inc. 2º CC). Dos condiciones:

- a) Debe deducirse una demanda sobre el derecho.
- b) Debe notificarse judicialmente la demanda. La notificación marca el momento a partir del cual el derecho es litigioso.
- c) Debe litigarse sobre la existencia de un derecho. Que este derecho esté en discusión. Por eso, se ha resuelto que no es litigioso el derecho que se ejercita en un juicio ejecutivo para obtener el cumplimiento forzado de una obligación.

Importante: **No confundir con las cosas litigiosas**, según el Art. 1464 N<sup>o</sup> 4 del CC y las disposiciones del CPC, son de aquellas especies sobre cuya propiedad se litiga, y en cuya enajenación hay objeto ilícito si se ha dictado prohibición de enajenar por el tribunal competente, prohibición que debe haberse inscrito, en el caso de los inmuebles, en el Registro Conservatorio.

La cesión no tiene por objeto el derecho mismo, sino la pretensión de obtener una determinada ventaja, que el cedente cree conseguir en un litigio. **La cesión versa sobre la expectativa de ganancia o pérdida (carácter aleatorio).**

#### 4.4.1. QUIÉN PUEDE CEDERLOS.

##### **Sólo el demandante en juicio.**

Como demandado, no puede ceder derechos litigiosos que, por regla general, sólo pertenecen al demandante, conforme se desprende de los Arts. 1912 y 1913 CC.

- El Art. 1912 CC considera indiferente que el derecho lo persiga el cedente o el cesionario, y el que persigue un derecho es el actor.
- Por su parte, el Art. 1913 CC dispone que el deudor no será obligado a pagar al cesionario sino el valor de lo que éste haya dado por el derecho cedido con los intereses desde la fecha en que se haya notificado la cesión al deudor, y siendo en todo juicio el deudor el demandado, carecería de aplicación el beneficio de retracto que dicha norma establece en términos generales si aquél pudiera ceder derechos litigiosos.

Argumentos para afirmar que sólo puede ceder derechos litigiosos el demandante:

- a) El art. 1912 se refiere al que persigue el derecho, vale decir, al demandante;
- b) El demandado goza del derecho de rescate (art. 1913), de lo que se desprende que el demandante es el cedente de los derechos litigiosos.

##### **1. Forma de la cesión.**

El CC no la establece. En la práctica, se entiende hecha por el hecho de apersonarse el cesionario al juicio, acompañando el título de la cesión. Para que la cesión produzca efecto respecto del deudor, debe ser notificado.

##### **2. Título de la cesión.**

Puede hacerse a diversos títulos, incluso a título gratuito (Art. 1912 y 1913 CC).



#### **4.4.2. EFECTOS DE LA CESIÓN.**

##### **a) Entre cedente y cesionario:**

1) El cedente se desprende de los derechos que le correspondían como demandante, y el cesionario los adquiere. Pero el juicio puede proseguirlo cualquiera (Art. 1912 CC).

2) No debe el cedente al cesionario ninguna garantía por la suerte del juicio (Art. 1911 CC).

##### **b) Respecto del demandado. Derecho de rescate o retracto litigioso:**

**Derecho de rescate:** facultad del demandado de liberarse de la prestación a que ha sido condenado en el juicio, reembolsando al cesionario lo que éste hubiera pagado al cedente como precio de la cesión.

###### **1) Requisitos:**

- i) La cesión debe haber sido a título oneroso (Art. 1913 inc. 1º CC).
- ii) Debe ser invocado en el plazo perentorio del Art. 1914 CC: 9 días desde la notificación del decreto en que se manda ejecutar la sentencia.

###### **2) Casos en que no procede:**

- i) Cesiones gratuitas.
- ii) Cesiones por el ministerio de la justicia.
- iii) Cesiones que van comprendidas en la enajenación de una cosa de que el derecho litigioso forma parte.
- iv) Cesiones que se hacen entre coherederos o copropietarios de un derecho común a ambos.
- v) Cesiones que se hacen a un acreedor en pago de lo que le debe el cedente.
- vi) Cesiones que se hacen al que goza de un inmueble como poseedor de buena fe, usufructuario o arrendatario, cuando el derecho cedido es necesario para el goce tranquilo y seguro del inmueble.

## CAPÍTULO 5. TRANSACCIÓN

### 5.1. GENERALIDADES

#### 1. Concepto.

Art. 2446 inc. 1º CC. "La *transacción* es un contrato en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente, o precaven un litigio eventual."

#### 2. Elementos constitutivos.

La transacción es un contrato y no exclusivamente un modo de extinguir las obligaciones. Lo mismo ocurre respecto de la novación que es simultáneamente un contrato y un modo de extinguir las obligaciones.

La transacción debe reunir por un lado los requisitos comunes de todo contrato, y por el otro, debe cumplir con dos elementos o requisitos que le son propios.

Debería contener los siguientes elementos:

##### **a) Existencia de un derecho dudoso:**

Debe tratarse de un derecho actualmente controvertido o susceptible de serlo. Por ello, no es transacción la renuncia de un derecho que no se disputa (Art. 2446 inc. 2 CC), y es nula la transacción si el litigio ya ha terminado por sentencia firme (Art. 2455 CC).

El carácter de dudoso de un derecho es puramente subjetivo (lo que estimen las partes).

##### **b) Mutuas concesiones o sacrificios:**

Esto no implica que las partes renuncien por partes iguales a sus pretensiones, sino que cada una de ellas renuncie aunque sea a una porción de ellas. De aquí que se señale que la transacción podría definirse, con más precisión como un acto en que las partes, sacrificando parte de sus pretensiones, ponen fin a un litigio pendiente o precaven un litigio eventual. Por tal razón, no es transacción el simple desistimiento del demandante, sin perjuicio, la aceptación que por su parte manifieste el demandado. En definitiva, la ausencia de mutuas concesiones o recíprocos sacrificios, implica la renuncia de un derecho o la remisión de una deuda, es decir, es un modo de extinguir las obligaciones, una convención que no es un contrato.

### 5.2. CARACTERÍSTICAS.

1. Es un **contrato bilateral**, como consecuencia de las recíprocas concesiones.

2. Es un **contrato oneroso**.

3. Es **conmutativo o aleatorio**, dependiendo de las prestaciones a que se obliguen las partes.

4. Es **consensual**: grava a ambas partes, la una en beneficio de la otra

Otras características:

1. **Puede o no ser titulo traslativo de dominio**: Art. 703 inciso final CC. Si la transacción se limita a reconocer o declarar derechos preexistentes, no forma nuevo título, pero en cuanto transfiere la propiedad de un objeto no disputado, constituye un título nuevo.

2. **Contrato intuitu personae**: por lo tanto, puede anularse por error en la persona, a pesar de ser oneroso, lo que constituye una excepción a la regla general del Art. 1455 CC.

### 5.3. QUIÉNES PUEDEN TRANSIGIR.

Art. 2447 CC. "No puede transigir sino la persona capaz de disponer de los objetos comprendidos en la transacción."

La transacción es siempre un acto de disposición, lleva a una enajenación. Esto es muy claro cuando recae en un objeto no disputado transfiriéndose su propiedad; pero también habrá un acto de disposición al declarar un derecho preexistente, ya que tal acto implica siempre la renuncia a lo menos parcial de un derecho.

De ahí que la ley disponga que no puede transigir sino la persona capaz de disponer de los objetos comprendidos en la transacción (Art. 2447 CC).

#### Poder para transigir.

Art. 2448 CC. "Todo mandatario necesitará de poder especial para transigir. En este poder se especificarán los bienes, derechos y acciones sobre que se quiera transigir."

En cuanto al mandatario, sea judicial o no, requiere poder especial para transigir, debiendo especificarse en el poder extrajudicial los bienes, derechos y acciones sobre que se quiera transigir (Arts. 2448; 2132 y 2141 del Código Civil y Art. 8 Código de Procedimiento Civil). No es necesaria tal singularización en el poder judicial, pues los derechos y acciones han quedado suficientemente explicitados en los principales escritos del juicio.

### 5.4. OBJETO DE LA TRANSACCIÓN.

Si el Art. 2447 CC establece que para transigir debe poseerse la capacidad de disponer de los bienes incluidos en la transacción, concluimos que pueden ser objeto de transacción todos los bienes susceptibles de disponerse, es decir, aquellos

bienes comerciables (aunque la transacción podría recaer sobre derechos que no son enajenables, pero si comerciables, como los alimentos).

No obstante, las reglas generales sobre la materia, explícitamente la ley ha determinado prohibiciones o derechos que no pueden ser objeto de transacción.

**1. No se puede transigir sobre las acciones penales que nacen de un delito:** Art. 2449 CC. Expresamente permite la ley, en cambio, transigir sobre la acción civil proveniente de un delito, cuya finalidad es obtener una indemnización de perjuicios; lo anterior está en armonía con el principio general del Art. 12 CC y en el hecho de que tratándose de la acción penal, toda la sociedad tiene interés en la imposición de la pena al delincuente.

**2. No se puede transigir sobre los alimentos futuros de las personas a quienes se deben por ley:** Art. 2451 CC. Esta norma no establece una prohibición absoluta porque la transacción es posible, aprobada por la justicia. Esto es concordante con los Art. 334 CC y 335 CC. De lo expuesto y de lo que establece el Art. 336, se desprende que pueden ser objeto valido de una transacción las pensiones alimenticias atrasadas. Igualmente, pueden ser transigidas las pensiones alimenticias dispuestas voluntariamente por testamento o por donación entre vivos, respecto de las cuales deberá estarse a la voluntad del testador o donante, en cuanto hayan podido disponer libremente de lo suyo (Arts. 2451 y 337 CC)

**3. No se puede transigir sobre el estado civil:** Art. 2450 CC. Ello porque las disposiciones que lo reglan, son de orden público. Se previene por los autores que son susceptibles de transacción las consecuencias pecuniarias de un determinado estado civil

**4. No se puede transigir sobre los derechos ajenos o inexistentes:** Art. 2452Cc. Cabe precisar, en lo referido a los derechos ajenos, que la transacción no es "nula", sino inoponible al titular de los derechos.

## **5.5 NULIDAD DE LA TRANSACCIÓN.**

A la transacción como contrato le son aplicables todas las normas generales que se refieren a la nulidad de los actos jurídicos. Pero el legislador estableció algunas disposiciones expresas, relativas al error, el dolo y la fuerza.

**1.** Art. 2453 CC. "Es nula en todas sus partes la **transacción obtenida (...) por dolo o violencia.**"

**2.** Art. 2457 CC. "El **error acerca de la identidad del objeto** sobre que se quiere transigir anula la transacción."

**3.** Art. 2458 CC. "El **error de cálculo no anula la transacción**, sólo da derecho a que se rectifique el cálculo."

**4.** Art. 2456 incs. 1º y 2º CC. "La transacción se presume haberse aceptado por consideración a la persona con quien se transige."

**Si se cree pues transigir con una persona y se transige con otra, podrá rescindirse la transacción."**

**5.** Art. 2454 CC. "Es nula en todas sus partes la **transacción celebrada en consideración a un título nulo**, a menos que las partes hayan tratado expresamente sobre la nulidad del título." Título: acto del que emana el derecho sobre el cual se transige. Es otra hipótesis de error.

**6.** Art. 2453 CC. "Es nula en todas sus partes la **transacción obtenida por títulos falsificados**,...". Título: documento en que consta el derecho que se transige. También es una hipótesis de error.

**7.** Art. 2455 CC. "Es **nula asimismo la transacción, si, al tiempo de celebrarse, estuviere ya terminado el litigio por sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada**, y de que las partes o alguna de ellas no haya tenido conocimiento al tiempo de transigir." Nuevamente error.

Si ambas partes conocían la existencia del fallo, la transacción no es nula, pero no hay transacción, sino, por Ej., una renuncia.

**8.** Art. 2459 incs. 1º y 2º CC. "Si constare por títulos auténticos que **una de las partes no tenía derecho alguno al objeto sobre que se ha transigido**, y estos títulos al tiempo de la transacción eran desconocidos de la parte cuyos derechos favorecen, podrá la transacción rescindirse; salvo que no haya recaído sobre un objeto en particular, sino sobre toda la controversia entre las partes, habiendo varios objetos de desavenencia entre ellas.

En este caso el descubrimiento posterior de títulos desconocidos no sería causa de rescisión, sino en cuanto hubiesen sido extraviados u ocultados dolosamente por la parte contraria."

## **5.6 EFECTOS DE LA TRANSACCIÓN.**

### **a) Relatividad de los efectos en cuanto a las partes:**

Art. 2461 CC. "La transacción no surte efecto sino entre los contratantes. Si son muchos los principales interesados en el negocio sobre el cual se transige, la transacción consentida por el uno de ellos no perjudica ni aprovecha a los otros; salvos, empero, los efectos de la novación en el caso de solidaridad."

Art. 2456 inc. 3º CC. "De la misma manera, si se transige con el poseedor aparente de un derecho, no puede alegarse esta transacción contra la persona a quien verdaderamente compete el derecho."

Principio general: como todo contrato, produce efecto solo entre las partes, Art. 2461CC.

Dos consecuencias se derivan expresamente de este principio:

1. Si son muchos los interesados en el asunto sobre el cual se transige, la transacción

consentida por uno de ellos no perjudica ni aprovecha a los otros. Esta norma tiene especial importancia en el caso de la solidaridad, y para determinar su alcance, hay que hacer algunas distinciones:

1º Efectos de la transacción consentida por un codeudor solidario, sin que haya novación: por regla general, cuando una obligación solidaria se extingue por uno de los codeudores, se extingue también respecto de los demás; tal constante, que se da respecto a cualquier medio de extinguir las obligaciones, se altera en la transacción, por tratarse de un contrato intuitu personae. Por ello, si la transacción es consentida por uno de los codeudores solidarios, no se extiende a los otros, a menos que dicha transacción envuelva una novación de la obligación solidaria.

2º Efectos de la transacción consentida por un codeudor solidario cuando aquélla envuelve novación: si la transacción con uno de los codeudores envuelve una novación, los otros codeudores se liberan de la obligación (tiene concordancia con los artículos 1519 y 1645 CC).

2. Si se transige con el poseedor aparente de un derecho, “no puede alegarse esta transacción contra la persona a quien verdaderamente compete el derecho”, Art. 2456 inciso 3 CC.

**b) Relatividad de los efectos de la transacción en cuanto al objeto:** se limitan a los derechos sobre que se ha transigido, contemplando el CC dos consecuencias:

1. Art. 2462 CC, norma interpretativa que restringe la extensión de la transacción.
2. Art. 2464 CC, cuando se adquiere el objeto posteriormente por un nuevo título.

Art. 2462 CC. “Si la transacción recae sobre uno o más objetos específicos, la renuncia general de todo derecho, acción o pretensión deberá sólo entenderse de los derechos, acciones o pretensiones relativas al objeto u objetos sobre que se transige.”

Art. 2464 CC. “Si una de las partes ha renunciado el derecho que le correspondía por un título y después adquiere otro título sobre el mismo objeto, la transacción no la priva del derecho posteriormente adquirido.”

**c) La transacción produce el efecto de cosa juzgada:** Art. 2460 CC.

Art. 2460 CC. “La transacción produce el efecto de cosa juzgada en última instancia; pero podrá impetrarse la declaración de nulidad o la rescisión, en conformidad a los artículos precedentes.”

Por ello se dice que es un equivalente jurisdiccional, sustituye a la sentencia judicial. Dos diferencias con la sentencia judicial:

1. La transacción como contrato debe atacarse por vía de nulidad. La sentencia a través de recursos.
2. La sentencia siempre es un título ejecutivo. La transacción es título

ejecutivo sólo si consta en escritura pública.

**d) Estipulación de una cláusula penal:**

Art. 2463 CC. "Si se ha estipulado una pena contra el que deja de ejecutar la transacción, habrá lugar a la pena, sin perjuicio de llevarse a efecto la transacción en todas sus partes."

Esto es una excepción a la regla general del Art. 1537 CC, según la cual no se puede acumular la pena compensatoria con el cumplimiento de la obligación principal.

## LOS CONTRATOS ACCESORIOS

La garantía que tiene un acreedor para los efectos de hacer valer su crédito se consagra en el mal denominado Derecho de Prenda General, mediante el cual el deudor afecta su patrimonio al cumplimiento de una obligación Art. 2465 CC. Este derecho de prenda general se fundamenta en la idea de patrimonio universalidad.

Art. 2465 CC. Toda obligación personal da al acreedor el derecho de perseguir su ejecución sobre todos los bienes raíces o muebles del deudor, sean presentes o futuros, exceptuándose solamente los no embargables, designados en el artículo 1618.

Suele este Derecho de Prenda General ser insuficiente ya sea por:

- la exigua cantidad de bienes que componen esta universalidad jurídica,
- ya sea por el hecho de que este derecho de prenda general del acreedor no impide la circunstancia que los bienes salgan del patrimonio del deudor.

En conclusión, en muchos de los casos los acreedores necesitan o eventualmente pueden necesitar que se les asegure adicionalmente el cumplimiento de la obligación, lo que se suele lograr mediante la celebración de los Contratos Accesorios.

**Contratos Accesorios:** (Art. 1442 C.C.) Aquel que tiene por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación principal, de manera que no puede subsistir sin ella.

Es necesario concordar esto con la disposición del Art. 46 CC que define lo que es Caución.

Art. 46 CC. Caución significa generalmente cualquiera obligación que se contrae para la seguridad de otra obligación propia o ajena. Son especies de caución la Fianza, la Hipoteca y la Prenda.

En consecuencia tenemos 2 términos que tienen relación de género a especie:

**a. Garantía** (término genérico) Cualquier mecanismo que tenga por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación, sea propia o ajena. Por ejemplo, el derecho de prenda general que es una garantía para el cumplimiento de una obligación. El derecho legal de retención también es una garantía, pero no es una caución.

**b. Caución** (es la especie). Las cauciones pueden ser reales o personales:

- (1) Cauciones Reales: se caracterizan por que se afectan determinados bienes al cumplimiento de una obligación (Res = Cosa). Suelen ser más restringidas que las personales, ya que en esta última generalmente se



comprometen patrimonios completos. Pero también suelen ser más eficaces (Ej. hipoteca, prenda, anticresis).

(2) Cauciones Personales: aseguran el cumplimiento de una obligación generalmente mediante la incorporación de un tercer patrimonio al cumplimiento de una obligación. Por ejemplo, la solidaridad pasiva y la fianza.

- Esto es generalmente ya que hay casos en que es el propio deudor el que otorga una caución personal; por ejemplo, la Cláusula Penal. Esta es una caución en la que el propio deudor como seguridad de que va a cumplir la obligación avalúa anticipada y contractualmente los perjuicios que su posible incumplimiento pueda causarle al acreedor.
- En consecuencia, en las cauciones personales no se toman en cuenta bienes determinados que posea el que garantiza la obligación, sino que su solvencia, y en cierto modo, la confianza que merezca al acreedor.

## CAPÍTULO 6. PRENDA

### 6.1. GENERALIDADES.

#### 1. Acepciones de la palabra prenda.

La palabra prenda como tal tiene a lo menos 4 acepciones:

1. Designa un contrato definido en el Art. 2384
2. Se puede referir a la cosa empeñada. Art 2384 CC.
3. Se puede referir al Derecho
4. Se refiere a un privilegio dentro de la prelación de créditos. Art. 2474 inc. 3º C.C.

#### 2. Definición legal y doctrinaria del contrato de prenda.

Art. 2384 CC. "Por el *contrato de empeño o prenda* se entrega una cosa mueble a un acreedor para la seguridad de su crédito.  
La cosa entregada se llama prenda.  
El acreedor que la tiene se llama acreedor prendario".

**Definición doctrinaria:** "Contrato en que se entrega una cosa mueble a un acreedor para seguridad de su crédito, otorgándole la facultad de perseguir la cosa empeñada, retenerla en ciertos caso, y pagarse preferentemente con el producto de su realización, si el deudor no cumple la obligación garantizada".

### 6.2. CLASIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS.

**1. Es un contrato real o solemne:** Es real en la prenda civil pues se perfecciona por la entrega de la cosa empeñada (Art. 2386); y solemne en las prendas especiales. Nunca es consensual.

**2. Es un contrato unilateral** dado que como casi todos los contratos reales queda obligado el que recibe la cosa es decir el acreedor. Pero puede ser un contrato sinalagmático imperfecto.

#### 3. Puede ser oneroso o gratuito.

- Será oneroso, normalmente, cuando la garantía la otorga el propio deudor (en tal caso, el acreedor obtiene una seguridad para su crédito y al deudor le es posible la obtención del crédito).
- Será gratuito, en cambio, si la prenda la constituye un tercero.

En relación a esto el problema de la culpa y el de la acción pauliana se resuelven expresamente en este contrato, por lo que la distinción entre oneroso y gratuito carece en verdad de importancia práctica.

- En cuanto a la culpa: el acreedor responde de la culpa leve. Art. 2394 CC.
- En cuanto a la acción pauliana: El Art. 2468 N° 1 establece que pueden rescindirse los contratos onerosos y las hipotecas, prendas y anticresis, por lo tanto la distinción entre contrato gratuito u oneroso en materias de prenda

carece de importancia ya que para los efectos prácticos de su aplicación hay norma expresa que resuelve el conflicto.

**4. Es un contrato accesorio.** Art. 2385 CC que dispone que el contrato de prenda supone siempre una obligación principal a la que accede (Art. 46)

Otras características:

**1.** Constituye un **título de mera tenencia** (en la prenda civil). Art. 2395.

**2.** En cuanto derecho: es un **derecho real; mueble; constituye un privilegio de segunda clase y es indivisible.**

**3. Indivisibilidad de la prenda.** Comprende 2 Aspectos:

1) Dentro de las excepciones a la divisibilidad, el C.C. en el artículo 1526 N° 1 (aspecto objetivo de la indivisibilidad) señala que la acción prendaria se dirige contra aquel de los co-deudores que tenga (o posea dice el CC) la cosa empeñada. Por lo tanto se dirige la acción contra quién tenga la cosa empeñada. De esta manera, si la cosa empeñada se adjudica a uno de los herederos del deudor, ejercitando la acción prendaria, el acreedor podrá perseguir el total de la deuda y el heredero no podría alegar que de ésta sólo le corresponde una parte a prorrata de su cuota hereditaria.

2) La prenda integralmente se encuentra afecta al pago total del crédito. Art. 2396 CC. Esto significa, por ejemplo, que si entrego en prenda algún bien divisible (por ejemplo, 100 acciones de Cemento Melón) para garantizar una deuda no se puede pedir la restitución de ninguna acción, mientras no se pague el total de lo adeudado, y no importando el monto del saldo de precio que garantice la deuda.

El artículo 2405 se pone en el caso en que uno de los herederos del deudor haya pagado su parte de la deuda, y aun cuando la prenda sea de una cosa divisible, le niega el derecho a pedir la restitución de la parte de la prenda que a él le corresponda, mientras los otros herederos por su parte no hayan pagado su cuota en la deuda. También contempla el caso inverso: una vez fallecido el acreedor, no puede el heredero que ha sido satisfecho en su parte del crédito remitir la prenda, mientras no hayan sido pagados todos los demás herederos.

### **6.3 OBLIGACIONES QUE SON SUSCEPTIBLES DE GARANTIZARSE MEDIANTE EL CONTRATO DE PRENDA CIVIL.**

Regla General: en principio cualquier obligación puede garantizarse mediante un contrato de prenda.

1. Pueden ser obligaciones de dar, hacer o no hacer.

2. Se puede garantizar la obligación principal o una obligación accesorio, por lo tanto se puede garantizar la obligación de un fiador mediante la prenda.

3. Se pueden garantizar obligaciones civiles o naturales.
4. Las obligaciones que nacen de cualquier fuente de las obligaciones.

¿Se puede garantizar mediante la prenda civil obligaciones futuras? Pareciera que no, básicamente por las siguientes razones:

- a. Porque en la hipoteca y en la fianza se acepta expresamente que estos contratos garanticen obligaciones futuras, cuestión que no ocurre en la prenda.
- b. El Art. 2385 C.C. es demasiado categórico al disponer que el contrato de prenda supone "siempre" una obligación principal a la que accede y una obligación futura no es una obligación existente e incluso puede llegar a no existir.
- c. En la prenda civil el deudor pierde la tenencia de la cosa por lo tanto queda privado del uso y goce de la cosa, cuestión que no parece razonable frente a una obligación que no se sabe si va existir o no, es decir, una obligación futura.

Por lo tanto, en el caso de la prenda civil resulta de dudosa validez la cláusula de garantía general prendaria, (es decir entregar prenda por todas las obligaciones presentes y futuras), lo que es, no obstante, aceptado en la hipoteca y en la mayoría de las prendas especiales.

Lo anterior es sin perjuicio de la prenda tácita a que se refiere el artículo 2401 del CC y que desarrollaremos más adelante.

#### **6.4 CAPACIDAD DE LAS PARTES.**

**El constituyente debe tener facultad de disposición y capacidad de ejercicio.** El Art. 2387 CC dispone que no se puede empeñar una cosa si no por persona que tenga facultad de enajenarla, pues la prenda es un principio de enajenación de la cosa. Se produce, sin embargo, un problema en relación a la prenda sobre cosa ajena. Art. 2390 y 2391. Como la prenda sobre cosa ajena vale, sin perjuicio de los derechos del dueño, la facultad de enajenación a que se refiere el art. 2387 no significa que sea dueño de la cosa, sino que tiene capacidad de disposición.

**El acreedor sólo debe tener capacidad de ejercicio y no facultad de disposición,** ya que el mismo (el acreedor) no está disponiendo de la cosa.

Se puede dar en prenda una cosa personalmente o mediando representación legal o convencional. En este caso es perfectamente aplicable por analogía el Art. 2143 C.C. referido al mandato, según el cual la facultad de vender no comprende la de hipotecar ni viceversa. (Lo mismo habría que decir de la facultad de empeñar).

En el caso de las representaciones legales existen restricciones para los efectos de la constitución de la prenda. Así, por ejemplo, el tutor tiene las restricciones establecidas en el Art. 393 CC respecto del empeño de los muebles preciosos o con valor de afección del pupilo y para darlos en prenda necesita que el juez lo autorice.

## **6.5 BIENES SUSCEPTIBLES DE DARSE EN PRENDA.**

**1)** La prenda recae sobre todos los bienes muebles excepto las naves o aeronaves de más de 50 toneladas de registro.

**2)** Pueden ser bienes muebles por naturaleza o por anticipación.

**3)** Pueden ser corporales o incorporeales.

**4)** En algunas prendas especiales, la ley tipifica los bienes muebles que pueden ser objeto de esos contratos.

Como estos bienes muebles deben ser entregados para la constitución de la prenda, no es posible la prenda sobre bienes futuros.

**5)** Pueden ser dados en prenda los derechos personales. Art. 2389. En tal caso, para la eficacia de la prenda es necesario que el acreedor notifique este hecho al deudor del crédito, prohibiéndole que lo pague en otras manos.

**6)** En cuanto a la prenda sobre derechos reales muebles. El C.C. nada dice, pero no existen razones para prohibirla.

**7)** Se estima que puede darse en prenda el dinero, aplicándole las mismas reglas que al depositario (Art. 2395 CC en relación con los Art. 2220 y 2221 CC).

**8)** La cosa dada en prenda debe ser comerciable.

**9)** Se puede dar en prenda una cosa ajena. Art 2390 CC el que dispone expresamente que puede darse en prenda una cosa que no propia y en tal caso subsiste el contrato mientras el dueño no la reclame, salvo que el acreedor sepa haber sido hurtada, robada o perdida, en cuyo caso se aplica la norma del comodato relativo a la suspensión de la restitución del art. 2183.

Por lo tanto puede darse en prenda una cosa ajena, sin perjuicio de los derechos del dueño (pues para el dueño la prenda es res inter alios acta) y consiste que si el dueño reclama la cosa dada en prenda (mediante acción reivindicatoria) y se verifica la restitución, conforme a los Art. 2390 y 2391 C.C. el acreedor podrá pedir:

- Que se le otorgue otra prenda de igual o mayor calidad.
- Que se le de otra garantía adecuada.
- Estimar la deuda como de plazo vencido, existiendo plazo pendiente para el pago (caso de caducidad legal del plazo).
- 

Manuel Somarriva es de la idea que cuando la prenda ha sido constituida por un tercero, estos derechos que el art. 2391 otorga al acreedor sólo podrían ejercitarse contra el deudor y no contra el tercero. Ello, habida consideración de que el 3ºno tiene interés en la deuda y se ha obligado en forma gratuita. Pero si éste ha otorgado la garantía mediante una remuneración que le ha pagado el deudor, y resulta que la cosa era ajena, el deudor podría repetir contra el tercero.

Cabe hacer presente que en la prenda de cosa ajena, el acreedor puede adquirir el derecho por prescripción: Art. 670 inc. 2º y Art. 2.498 inc. 2º.

### **¿Cómo debe hacerse la entrega?**

Respecto de la entrega de la cosa dada en prenda, ésta debe ser real y no ficticia. Es decir, debe pasar la tenencia de la cosa a manos del acreedor por dos razones:

- Por razón de publicidad, para que los terceros se enteren que existe sobre la cosa mueble entregada al acreedor un derecho real.
- Porque el C.C. reglamenta latamente los deberes de cuidado y restitución del acreedor, cosa imposible frente a una entrega ficta.

Respecto de la entrega se ha discutido si es posible que la entrega se efectúe a un 3º elegido de común acuerdo por las partes y no al acreedor, y se ha fallado que esto es posible. El C. de Comercio lo autoriza expresamente y no se ve razón para prohibirla en materia civil.

## **6.6 EFECTOS DEL CONTRATO DE PRENDA.**

### **A) DERECHOS DEL ACREEDOR.**

- 1.- Derecho de Retención.
- 2.- Derecho de Venta.
- 3.- Derecho de Pago Preferente.
- 4.- Derecho de Persecución
- 5.- Reembolso e Indemnizaciones

#### **1. DERECHO DE RETENCIÓN.**

Es la facultad del acreedor para retener la prenda (conservar la tenencia de la cosa empeñada) hasta el pago total de la obligación. (Art. 2396).

Esta situación, sin embargo, no obsta a que el deudor pueda pedir el reemplazo de una prenda por otra, lo cual constituye una excepción a los efectos obligatorios de los contratos entre partes (1545). El deudor será oído en términos del reemplazo de la prenda.

El derecho de retención no autoriza al acreedor para usar la cosa. Sin embargo, el Art. 2395 dispone que las obligaciones, respecto del no uso de la prenda, son las mismas que tiene el depositario. En consecuencia, podrá usar la prenda en los mismos términos del depositario (Art. 220-2221). También constituye una excepción al no uso de la cosa por parte del acreedor prendario la norma del art. 2403, en cuanto le permite al acreedor imputar al pago de la deuda los frutos que haya producido la cosa empeñada.

El derecho legal de retención, entonces, subsiste mientras no se pague íntegramente la deuda caucionada con la prenda, sin perjuicio de lo que establece el

inciso 2º y 3º del art. 2396.

Art. 2396 CC. El deudor no podrá reclamar la restitución de la prenda en todo o parte, mientras no haya pagado la totalidad de la deuda en capital e intereses, los gastos necesarios en que haya incurrido el acreedor para la conservación de la prenda, y los perjuicios que le hubiere ocasionado la tenencia.  
Con todo, si el deudor pidiera que se le permita reemplazar la prenda por otra sin perjuicio del acreedor, será oído.  
Y si el acreedor abusa de ella, perderá su derecho de prenda, y el deudor podrá pedir la restitución inmediata de la cosa empeñada.

De esta manera, una vez satisfecho el crédito, el acreedor debe restituir la prenda. Esta es la regla general que sufre una importante excepción con lo que la doctrina denomina la prenda tácita y que consagra el art. 2401 del C.C.

### **Prenda Tácita. Art. 2401 CC.**

En este caso, la prenda se prolonga más allá de la extinción de la obligación primitivamente caucionada.

Supone la existencia de otras obligaciones distintas entre acreedor y deudor, de manera que cumpliéndose los requisitos de este artículo, la prenda subsiste por disposición legal.

Art. 2401 CC. Satisfecho el crédito en todas sus partes, deberá restituirse la prenda. Pero podrá el acreedor retenerla si tuviere contra el mismo deudor otros créditos, con tal que reúnan los requisitos siguientes:

1. Que sean ciertos y líquidos;
2. Que se hayan contraído después que la obligación para la cual se ha constituido la prenda;
3. Que se hayan hecho exigibles antes del pago de la obligación anterior.

Los requisitos para que opere la prenda tácita son:

- 1) La relación crediticia debe ser entre el deudor y el acreedor prendario.
- 2) Deben ser créditos nuevos (no cesiones ni subrogaciones, porque sería sencillo transformar créditos valistas en créditos privilegiados).
- 3) Que estos créditos sean ciertos y líquidos y exigibles antes del pago de la obligación anterior.
- 4) El acreedor no debe haber perdido la tenencia de la prenda. (Art. 2393)
- 5) Que la cosa no haya sido comprada por un tercero (Art.2404 inciso final).

La prenda tácita es un caso de apariencia jurídica calificada, en la cual, la ley privilegia el hecho de existir nuevos créditos entre acreedor y deudor, dándoseles el carácter, por el solo ministerio de la ley, de créditos garantizados mediante el derecho real de prenda.

Constituye un caso de prenda legal y no es una simple retención de la cosa. Es un

nuevo derecho de prenda (Art. 2402), aunque no un nuevo contrato de prenda. Así, la fuente de este derecho es la ley y no la convención.

## **2. DERECHO DE VENTA.**

Si la obligación principal no es cumplida por el deudor, el acreedor puede solicitar la realización de la prenda en la forma prevenida por la ley (venta en pública subasta).

Art. 2397 CC. El acreedor prendario tendrá derecho de pedir que la prenda del deudor moroso se venda en pública subasta para que con el producido se le pague; o que, a falta de postura admisible, sea apreciada por peritos y se le adjudique en pago, hasta concurrencia de su crédito; sin que valga estipulación alguna en contrario, y sin perjuicio de su derecho para perseguir la obligación principal por otros medios.

- Tampoco podrá estipularse que el acreedor tenga la facultad de disponer de la prenda o de apropiársela por otros medios que los aquí señalados.
- El principio más relevante de este derecho es que el deudor no puede pagarse con la cosa dada en prenda. Es nula, de nulidad absoluta, la estipulación de que en caso de incumplimiento de la obligación el acreedor se quedará con la cosa o se la apropiará por otros medios que los señalados por la ley. En consecuencia, el pacto comisorio está prohibido (Art. 2397 inc. final)
- Sin perjuicio de ello, y de conformidad al art. 2398, el acreedor puede concurrir como postor a la pública subasta.
- El D.L.776 regula la realización de la prenda, que se caracteriza por:
  - La pública subasta
  - El hecho de que la prenda se saca a remate sin mínimo de postura.
- El derecho de venta no excluye el derecho de prenda general, lo que fluye del art. 2397 que establece que el acreedor puede perseguir la obligación principal por otros medios.

### **Imputación del pago:**

El Art. 2402 establece los mecanismos de imputación al crédito:

- 1) Intereses y costos
- 2) Al capital
- 3) Según las reglas de la imputación al pago si es más de una obligación.

## **3. DERECHO DE PREFERENCIA.**

Dice relación con la prelación de créditos, y está contemplada en el Art. 2474 en su número N°3 (crédito de segunda clase)



El privilegio del acreedor prendario es especial porque él se hace efectivo en el bien dado en garantía, pero no en el resto del patrimonio del deudor. De aquí resulta que si parte del crédito queda sin pagarse con el producto de la realización de la prenda, el saldo insoluto no goza de preferencia y debe ser considerado como un crédito valista (de quinta clase)

En principio no debería existir contradicción entre la prenda y la hipoteca. Bajo la sola vigencia del C.C. nunca hubo conflicto; pero sí con las prendas especiales en torno al derecho de preferencia, porque la característica fundamental de casi todas las prendas especiales (menos la mercantil), es que son prendas sin desplazamiento y, en consecuencia, se pueden dar en prenda y quedar en poder del deudor y por esta característica llegar a ser inmueble.

#### **4. DERECHO DE PERSECUCIÓN.**

Deriva del carácter de derecho real de la prenda. El acreedor que ha perdido la tenencia de la cosa empeñada, tiene acción para recobrarla de manos de quien la tenga, incluso el deudor. Art. 2393. Es una acción de reivindicación del derecho real de prenda. (Art. 891 CC)

Art. 2393 CC. Si el acreedor pierde la tenencia de la prenda, tendrá acción para recobrarla, contra toda persona en cuyo poder se halle, sin exceptuar al deudor que la ha constituido.

Pero el deudor podrá retener la prenda pagando la totalidad de la deuda para cuya seguridad fue constituida.

Efectuándose este pago, no podrá el acreedor reclamarla, alegando otros créditos, aunque reúnan los requisitos enumerados en el artículo 2401.

La excepción a este derecho es que el deudor pague íntegramente la obligación caucionada con la prenda, en cuyo caso, el acreedor no tiene posibilidad de recuperarla.

#### **5. DERECHO DE REEMBOLSO E INDEMNIZACIÓN.**

El acreedor tiene derecho a que le paguen los gastos necesarios por conservación de la cosa, y a la indemnización de perjuicios que le haya acarreado la tenencia de la cosa (Art. 2396).

### **B) OBLIGACIONES DEL ACREEDOR.**

#### **1. No usar la cosa en los términos del Art. 2395.**

Art. 2395 CC. El acreedor no puede servirse de la prenda, sin el consentimiento del deudor. Bajo este respecto sus obligaciones son las mismas que las del mero depositario.

**2. Cuidar y conservar la cosa como un buen padre de familia.** Responde de la culpa leve.

Art. 2394 CC. El acreedor es obligado a guardar y conservar la prenda como buen padre de familia, y responde de los deterioros que la prenda haya sufrido por su hecho o culpa.

**3. Restituir la cosa una vez satisfecho el crédito** (Arts. 2396, 2401 inc.1º y 2403), con todos los aumentos que haya recibido.

**C) DERECHOS DEL CONSTITUYENTE.**

**1. DERECHO A QUE SE LE RESTITUYA LA COSA.**

Tiene derecho a exigir la restitución de la prenda una vez satisfecho el crédito. Para estos efectos, goza de la acción prendaria, que es de carácter personal, pero si además es dueño de la cosa dada en prenda, tendrá acción reivindicatoria.

**2. DERECHO A GRAVAR O ENAJENAR LA COSA EMPEÑADA.**

Art. 2404 CC. Si el deudor vendiere la cosa empeñada, el comprador tendrá derecho para pedir al acreedor su entrega, pagando y consignando el importe de la deuda por la cual se contrajo expresamente el empeño.  
Se concede igual derecho a la persona a quien el deudor hubiere conferido un título oneroso para el goce o tenencia de la prenda.

En ninguno de estos casos podrá el primer acreedor excusarse de la restitución, alegando otros créditos, aun con los requisitos enumerados en el artículo 2401.

**3. DERECHO A CONCURRIR A LA SUBASTA EN QUE SE LICITE LA PRENDA.**

Art. 2398 CC. A la licitación de la prenda que se subasta podrán ser admitidos el acreedor y el deudor.

**4. DERECHO DE RECLAMAR LA RESTITUCIÓN INMEDIATA DE LA PRENDA EN CASO DE ABUSO.**

Art. 2396 inc. 3º CC. Y si el acreedor abusa de ella, perderá su derecho de prenda, y el deudor podrá pedir la restitución inmediata de la cosa empeñada.

## **5. DERECHO DE SUSTITUIR LA PRENDA.**

Art. 2396 inc. 2º CC. Con todo, si el deudor pidiera que se le permita reemplazar la prenda por otra sin perjuicio del acreedor, será oído.

## **6. DERECHO DE PAGAR LA DEUDA Y RESCATAR LA PRENDA.**

Art. 2399 CC. Mientras no se ha consumado la venta o la adjudicación prevenidas en el artículo 2397, podrá el deudor pagar la deuda, con tal que sea completo el pago y se incluyan en él los gastos que la venta o la adjudicación hubieren ya ocasionado.

## **7. DERECHO A SER INDEMNIZADO POR LOS DETERIOROS A LA COSA EMPEÑADA QUE PROVENGAN DEL HECHO O CULPA DEL ACREEDOR.**

Art. 2394 CC. El acreedor es obligado a guardar y conservar la prenda como buen padre de familia, y responde de los deterioros que la prenda haya sufrido por su hecho o culpa.

### **D) OBLIGACIONES DEL DEUDOR.**

Hemos dicho que la prenda es un contrato unilateral, por cuanto sólo genera obligaciones para el acreedor, principalmente, la de restituir la cosa empeñada. Sin embargo, puede surgir para el deudor la obligación de pagar los gastos y perjuicios que la tenencia de la cosa haya podido ocasionar al acreedor.

### **6.7. EXTINCIÓN DE LA PRENDA.**

**POR VÍA CONSECUCIONAL O INDIRECTA:** Sigue la suerte de la obligación principal, según la regla general de la accesoriedad. Así, por ejemplo,

- el pago de la obligación principal extingue la prenda.
- Lo mismo sucede con la prescripción de la obligación principal (Art. 2516).
- La prenda se extingue por la novación de la obligación a que accede (Arts. 1642 y 1643), etc.

**POR VÍA DIRECTA:** Se extingue la prenda sin necesidad de extinción ni de modificación de la obligación principal en los casos señalados por el Art. 2406 CC.

**1. Por destrucción de la cosa empeñada.**

**2. Por confusión** (el acreedor de la cosa empeñada se hace dueño de ella)

3. Por la **resolución del derecho del constituyente.**

4. **Si el deudor pierde el dominio de la cosa por el evento de una resolución** se extingue la prenda, sin perjuicio de los derechos del acreedor de buena fe de exigir otra caución competente o el cumplimiento de la obligación, aún cuando exista plazo pendiente para el pago (se aplica el Art. 2391)

5. Además de estas causales, debe agregarse el **abuso de la prenda por el acreedor.** Art. 2392 inc. 3º.

## **6.8. PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO.**

### **1. Concepto y cuestiones generales**

Con fecha 5 de junio de 2007, en virtud de la ley 20.190, entre otras cosas, se regula la figura de la Prenda sin Desplazamiento y se crea el Registro de Prenda sin Desplazamiento. El artículo 1º de las normas que reglan esta figura establece lo siguiente:

Art. 1º El contrato de prenda sin desplazamiento tiene por objeto constituir una garantía sobre una o varias cosas corporales o incorporeales muebles, para caucionar obligaciones propias o de terceros, conservando el constituyente la tenencia y uso del bien constituido en prenda.

En lo no previsto por la presente ley, se aplicarán las disposiciones del contrato de prenda del Código Civil.

Puede constituirse este tipo de prenda sobre todo tipo de cosas corporales e incorporeales, presentes o futuras, siempre y cuando sean cosas muebles.

Por medio de la prenda sin desplazamiento pueden caucionarse cualquier clase de obligaciones, presentes o futuras, propias o ajenas, estén o no determinadas a la fecha del contrato.

La utilidad de este tipo de prenda es que el deudor no pierde la tenencia de la cosa pignorada, pudiendo usar y gozar de ella. Como contrapartida, el legislador la estableció como contrato solemne, para darle publicidad a la existencia de la caución.

### **2. La prenda sin desplazamiento es un contrato solemne**

La prenda sin desplazamiento es un contrato solemne. Por lo tanto, el contrato mismo, su modificación o su alzamiento, deben realizarse por alguna de las siguientes maneras:

a) Por escritura pública.

b) Por instrumento privado, en cuyo caso las firmas de los concurrentes deben ser autorizadas por un notario, y el instrumento debe ser protocolizado en el registro del mismo notario que autorizó.

La sola suscripción del contrato de prenda sin desplazamiento no otorga al acreedor prendario el derecho real de prenda. El derecho real de prenda se adquiere por medio de la tradición, la cual se realiza por medio de su inscripción

en el Registro de Prendas sin Desplazamiento.

Dentro del plazo de tres días hábiles desde la suscripción de la escritura pública, o desde su fecha de protocolización en el caso de los instrumentos privados, el notario deberá enviar una copia autorizada del instrumento respectivo, para su inscripción en el Registro de Prendas sin Desplazamiento.

El derecho real de prenda se adquirirá, probará y conservará por la inscripción del contrato de prenda en el Registro de Prendas sin Desplazamiento. La prenda sólo será oponible a terceros a partir de esa fecha.

Si se trata de bienes sujetos a inscripción obligatoria en algún otro registro, como el caso de los vehículos motorizados, la prenda será inoponible a terceros mientras no se anote una referencia del contrato de prenda al margen de la inscripción correspondiente.

### **3. Efectos**

El acreedor prendario tendrá derecho a pagarse preferentemente con el producto de la venta forzada de la cosa pignorada con la preferencia establecida en el art. 2474 del Código Civil, es decir, una preferencia de segunda clase. En caso de haber dos o más prendas constituidas sobre el mismo bien, los acreedores respectivos se preferirán según el orden de la inscripción en el Registro de Prendas sin Desplazamiento.

El constituyente o el deudor prendario, en caso de que fueren distintos, conservarán la tenencia, uso y goce de la cosa dada en prenda, siendo de su cargo los gastos de custodia y conservación. No obstante lo anterior, las partes podrán pactar que la especie dada en prenda deba mantenerse en un lugar determinado, o que la cosa dada en prenda solo pueda utilizarse de una manera específica. En este caso, el deudor prendario debe estarse a lo señalado en el contrato y, si contraviene dichas estipulaciones, al acreedor podrá exigir la realización inmediata de la prenda.

Los deberes y responsabilidades del constituyente o del deudor en relación con la conservación de la cosa dada en prenda serán los del depositario.

### **4. Alzamiento**

Una vez que la deuda caucionada con la prenda se haya extinguido íntegramente, ya sea por el pago o por cualquier otro medio, el deudor podrá exigir al acreedor prendario que proceda al alzamiento de la prenda. Dicho alzamiento deberá hacerse de manera solemne, por medio de escritura pública o de escritura privada autorizada ante notario y protocolizada por el mismo. El deudor tendrá un plazo de 45 días para proceder al alzamiento.

## CAPÍTULO 7. HIPOTECA

### 7.1 DEFINICIÓN. DERECHO REAL DE HIPOTECA Y CONTRATO DE HIPOTECA.

Debe distinguirse el **contrato de hipoteca**, del **derecho real de hipoteca**. Nuestro CC define al **derecho real de hipoteca**.

Art. 2407 CC. "La *hipoteca* es un derecho de prenda, constituido sobre inmuebles que no dejan por eso de permanecer en poder del deudor."

Esta definición es deficiente:

- No apunta a lo fundamental, sino que la compara con la prenda.
- Olvida que la hipoteca es un derecho real
- Olvida el hecho que puede tener carácter contractual y legal (hipoteca legal), etc., por lo tanto no es una definición satisfactoria.
- Habla de deudor, cuando la parte es el constituyente que podrá ser el deudor o un tercero.

**Concepto doctrinario de derecho real de hipoteca:** (1) derecho real que grava un inmueble, (2) que no deja de permanecer en poder del constituyente, (3) para asegurar el cumplimiento de una obligación principal, (4) otorgando al acreedor el derecho de perseguir la finca en manos de quienquiera que la posea y de pagarse preferentemente con el producto de la realización.

Esta definición caracteriza a la hipoteca como un derecho y prescinde de su carácter contractual pues hay casos en que puede existir como derecho sin que haya contrato. Es el caso de la hipoteca legal contemplada en el art. 662 del CPC relativa a la adjudicación de bienes raíces en la partición (cuando a un comunero en la partición se le adjudica un bien raíz, se entiende constituida hipoteca sobre él para garantizar los alcances que resulten en su contra).

La hipoteca necesita como todo derecho real (Art. 577 CC) para su nacimiento que opere un modo de adquirir el dominio, típicamente la tradición (aunque también podría operar la prescripción o la sucesión por causa de muerte). Por lo tanto, deberá existir un título que le anteceda, es decir, un contrato que coloque a la persona en la obligación de transferir el derecho de hipoteca: **Contrato hipotecario**.

**Concepto doctrinario de contrato hipotecario:** aquel en que el deudor o un tercero se obliga con respecto al acreedor a darle el derecho de hipoteca sobre un inmueble de su propiedad.

- El título en la tradición de los derechos reales puede ser la compraventa, la permuta, la donación, etc. No se ve inconveniente para que se apliquen los mismos títulos que en los demás derechos reales, sin embargo, en la práctica no son estas las formas como se genera; de ordinario el deudor se limita a constituir el gravamen a favor del acreedor. Por eso, el contrato hipotecario es sui generis y su único rol es servir de antecedente al nacimiento del

derecho real de hipoteca.

- El contrato hipotecario se puede celebrar entre acreedor y deudor o entre el acreedor y un tercero extraño.

## **7.2 CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO REAL DE HIPOTECA.**

### **1. Es un derecho real.**

- Está en la enumeración del Art. 577 CC. Consecuencia de este carácter es el derecho de persecución que tiene el acreedor hipotecario.
- Pero es distinto a otros derechos reales, pues no hay una relación directa con la cosa.
- Es un derecho real que recae sobre otro derecho real. Se traduce en la facultad del acreedor para vender la cosa y pagarse con el producto.

### **2. Es un derecho inmueble.**

Se ejerce sobre un inmueble (Art. 580 CC). Tiene este carácter cualquiera sea la naturaleza del crédito garantizado.

La regla no es absoluta: se puede hipotecar naves, que son muebles (Art. 825 CCom).

### **3. Es un derecho accesorio.**

Está destinado a asegurar el cumplimiento de una obligación principal. La consecuencia es que la hipoteca se extingue por la extinción de la obligación principal, y pasa con el crédito a los sucesores del acreedor. Puede garantizar toda clase de obligaciones.

Sin embargo, hay casos en que la hipoteca es relativamente independiente de la obligación principal:

1) La hipoteca puede garantizar obligaciones futuras. Art. 2413 inc. final. "Podrá asimismo otorgarse en cualquier tiempo antes o después de los contratos a que acceda, y correrá desde que se inscriba."

2) La persona que hipoteca un bien propio en garantía de una deuda ajena no se obliga personalmente, a menos que así se estipule expresamente. En este caso, las acciones personal y real se separan, deben ejercerse contra personas distintas.

3) Aunque la obligación principal se extinga por novación, las partes pueden convenir la reserva de la hipoteca para la nueva obligación.

### **4. La finca permanece en poder del deudor.**

Esta es una ventaja para el deudor, pues conserva la facultad de gozar y disponer de ella.

## 5. Genera una preferencia.

El Art. 2470 CC la señala entre las causas de preferencia; el Art. 2477 CC la menciona entre los créditos de tercera clase.

## 6. Es indivisible.

Art. 2408 CC. "La hipoteca es indivisible.

En consecuencia, cada una de las cosas hipotecadas a una deuda y cada parte de ellas son obligadas al pago de toda la deuda y de cada parte de ella."

1) Si son varios los deudores, el acreedor puede dirigirse en contra de quien posea, en todo o en parte la finca (Art. 1526 N° 1 CC). Si se divide la finca, cada parte queda gravada con el total de la deuda.

2) La extinción parcial del crédito no libera proporcionalmente al inmueble hipotecado (Art. 1526 N° 1 CC).

## 7.3. CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO DE HIPOTECA.

**1. Es un contrato unilateral:** Sólo resulta obligado el constituyente –sea este el deudor o un tercero- La obligación consiste en transferir al acreedor el derecho real de hipoteca, quien por su parte no contrae obligación alguna.

Sin embargo, no es de la esencia el carácter unilateral de la hipoteca, bien puede ser bilateral, lo que sucederá cuando el acreedor contraiga obligaciones. Ej. Se estipula que pagará al tercero una remuneración a cambio de que éste acceda a constituir el gravamen.

Por otro lado, en el caso de las hipotecas otorgadas en favor de proveedores de servicios financieros, tales como los bancos y demás casas de crédito, reguladas por la ley 19.496 de protección a los consumidores, la ley 20.855, publicada durante el año 2015 incluyó una modificación legal que resulta necesario tener en cuenta. El nuevo artículo 17 D) de la mencionada ley establece que, una vez extinguido íntegramente el o los créditos caucionados por la hipoteca, el prestador del servicio financiero estará obligado, a su cargo y costo, otorgar la escritura pública de alzamiento y a ingresarla al Registro del Conservador respectivo para su inscripción.

**2. Es un contrato gratuito:** sólo tiene por objeto la utilidad de una de las partes, sufriendo la otra el gravamen. La utilidad es para el acreedor que obtiene seguridad de su crédito y no soportada gravamen alguno.

**3. Es un contrato accesorio:** supone la existencia de una obligación principal cuyo cumplimiento está garantizando. Esto no es obstáculo para que la hipoteca se otorgue antes del contrato a que accede (Art. 2413). Lo importante es que, extinguida la obligación principal, se extingue el contrato accesorio.

**4. Es un contrato solemne:** Las solemnidades se establecen en los Arts. 2409 y 2410 CC.



Art. 2409 CC. La hipoteca deberá otorgarse por escritura pública.

Podrá ser una misma la escritura pública de la hipoteca, y la del contrato a que accede.

Art. 2410 CC. La hipoteca deberá además ser inscrita en el Registro Conservatorio; sin este requisito no tendrá valor alguno; ni se contará su fecha sino desde la inscripción.

Dos opiniones:

1) Ambas solemnidades son necesarias.

2) Sólo es necesaria la escritura pública.

- La inscripción en el CBR es la tradición del derecho real de hipoteca y no es solemnidad. Mientras esta no se verifica el contrato puede ser perfecto, es decir, produce derechos y obligaciones entre las partes pero no transfiere ningún derecho real, ni tiene respecto de terceros existencia alguna.

- Basta la escritura pública para que el acreedor pueda exigir que se le haga la tradición del derecho porque el contrato se encuentra perfecto, o bien, el acreedor podría solicitar la resolución del contrato para obtener la restitución de lo pagado.

Disposiciones legales que confirman esta postura (inscripción no es solemnidad, sino la forma de realizar la tradición del derecho real de hipoteca):

1) Art. 2411 CC: Los contratos hipotecarios celebrados en país extranjero darán hipoteca sobre bienes situados en Chile, con tal que se inscriban en el competente Registro. Por lo tanto, el legislador reconoce la existencia del contrato hipotecario antes de efectuarse la inscripción.

2) Art. 2419 CC. Que refiriéndose a la hipoteca de bienes futuros da derecho al acreedor de hacerla inscribir sobre los inmuebles que el deudor adquiera en lo sucesivo y a medida que los adquiera, por lo tanto, entre las partes, por el otorgamiento de la escritura pública ha nacido un vínculo jurídico.

Otros argumentos:

3) Así se señala en el Mensaje del CC respecto de los derechos reales.

4) Así lo corroboran las consecuencias prácticas. Ej. Después de constituida la hipoteca, pero antes de inscribirla, el constituyente enajena el bien. El acreedor no queda burlado porque tiene derecho a que se le haga la tradición del derecho real.

Posible argumento contra la teoría.

Art. 2410 CC. La hipoteca deberá además ser inscrita en el Registro Conservatorio; sin este requisito no tendrá valor alguno; ni se contará su fecha sino desde la inscripción.

El error de los intérpretes es creer que esta disposición se refiere al contrato hipotecario, cuando en realidad se ocupa del derecho real de hipoteca, para cuya existencia no hay duda que se requiere la inscripción porque ella representa la tradición del derecho.

Además esto se confirma porque los Art. 2407 y 2408 CC se refieren a la hipoteca como derecho, no como contrato.

#### **7.4. CLASES DE HIPOTECA.**

Otras legislaciones reglamentan 3 clases de hipoteca: legal, judicial y convencional. En el CC sólo se contempla la hipoteca convencional.

En nuestro ordenamiento jurídico encontramos algunos casos de hipoteca legal:

##### **a) Hipoteca legal del Código de Procedimiento Civil.**

Está establecida en el Código de Procedimiento Civil, arts. 660 y 662. Opera en la partición de bienes. El art. 660 CPC dispone que salvo acuerdo unánime de los interesados, todo comunero que reciba en adjudicación bienes por un valor que exceda del 80% de lo que le corresponde, deberá pagar el exceso al contado. A su vez, el art. 662 establece que en las adjudicaciones de inmuebles que se hagan a los comuneros a raíz del juicio de partición, se entenderá constituida hipoteca sobre las propiedades adjudicadas para asegurar el pago de los alcances que resultan en contra de los adjudicatarios, salvo que se pague de contado el exceso al que se refiere el art. 660. De esta manera los requisitos de la hipoteca legal son los siguientes:

1. Debe adjudicarse un bien raíz;
2. El valor de la adjudicación debe exceder del 80% del haber probable del adjudicatario;
3. Que el adjudicatario no pague el exceso de contado.

De esta manera, por ejemplo al realizarse la partición, se le adjudica a Juan un inmueble avaluado en \$ 90.000.000.- Ahora bien, ocurre que la cuota de Juan ascendía a \$ 100.000.000.- En este caso, el valor del inmueble excede del 80% del haber probable del adjudicatario, de manera que se entiende hipotecado, en favor del resto de los comuneros. ¿Por qué, podríamos preguntarnos, queda hipotecado el inmueble, si ocurre que de todas maneras éste no excede la cuota total de Juan? La respuesta la encontramos en la expresión "haber probable". En efecto, pues bien podría ocurrir que con posterioridad a la adjudicación aparezcan obligaciones del causante de las que no se tenía noticia, y por ende, disminuir la cuota de cada uno de los comuneros.

Características de esta hipoteca legal:

1. Es especial, recae sobre el inmueble adjudicado;
2. Es determinada, cauciona el alcance que resulta en contra del adjudicatario.
3. Es pública, requiere inscripción en el Registro respectivo del Conservador de Bienes Raíces. Señala el art. 662 que el Conservador, conjuntamente con inscribir el título de la adjudicación, inscribirá a la vez la hipoteca por el valor de los alcances.

#### **b) Hipoteca legal del Código de Aguas.**

Conforme a lo dispuesto en el Código de Aguas, quienes sean comuneros en comunidades de aguas, deben concurrir a los gastos de mantención de la comunidad, a prorrata de sus derechos (art. 212 N° 3). Agrega el citado Código que los derechos de aprovechamiento de aguas quedarán gravados de pleno derecho, con preferencia a toda prenda, hipoteca u otro gravamen constituido sobre ellos, en garantía de las cuotas de contribución para los gastos que fijan las juntas y directorios. Los adquirentes a cualquier título de estos derechos, responderán solidariamente con su antecesor de las cuotas insolutas al tiempo de la adquisición (art. 214). Finalmente, el art. 258 del Código de Aguas, establece que las disposiciones citadas, referidas a las comunidades de aguas, son aplicables también a las asociaciones de canalistas.

#### **c) Hipoteca legal en las normas de la Ley N° 20.720, "Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas".**

En las normas del capítulo IV de la citada Ley, tratándose de la venta de los bienes del deudor como "unidad económica", establece la Ley una hipótesis de hipoteca legal, cuando el adquirente de los bienes no pague el precio al contado o contrajere cualquiera otra obligación a consecuencia de la venta, a menos que la Junta de Acreedores dispusiere otra cosa. Dispone el precepto: "Artículo 221.- Trámites posteriores. La venta como unidad económica deberá constar en escritura pública en la que se indicarán los hechos y/o requisitos que acrediten el cumplimiento de las disposiciones anteriores. Dicha escritura será aprobada por el tribunal, el cual ordenará el alzamiento y cancelación de todos los gravámenes y prohibiciones que pesen sobre los bienes que integran la unidad económica. / Los bienes que integran la unidad económica se entenderán constituidos en hipoteca o prenda sin desplazamiento, según su naturaleza, por el sólo ministerio de la ley, para caucionar los saldos insolutos de precio y cualquiera otra obligación que el adquirente haya asumido como consecuencia de la adquisición, salvo que la Junta de Acreedores, al pronunciarse sobre las bases respectivas, hubiese excluido expresamente determinados bienes de tales gravámenes"

### **7.5 ELEMENTOS DE LA HIPOTECA.**

#### **7.5.1 PERSONAS QUE PUEDEN HIPOTECAR.**

|                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art. 2414 inc. 1º CC. "No podrá constituir hipoteca sobre sus bienes, sino la persona que sea capaz de enajenarlos, y con los requisitos necesarios para su enajenación." |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

La ley requiere capacidad de enajenar porque la hipoteca compromete seriamente el crédito del futuro constituyente.

Los incapaces no pueden constituir hipoteca por sí mismos, sino con sujeción a las formalidades que señala la ley:

1) Inmuebles del hijo: no pueden hipotecarse sin autorización judicial, aunque

pertenezcan a su peculio profesional (Art. 254 CC).

2) Inmuebles de los pupilos: no pueden hipotecarse sin previo decreto judicial, expedido por causa de utilidad o necesidad manifiesta (Art. 393 CC).

3) Inmuebles de la mujer casada bajo sociedad conyugal: se requiere voluntad de la mujer, específica, otorgada por escritura pública o interviniendo de expresasmente de cualquier modo en el acto (Art. 1754 CC). No procede autorización del juez en caso de negativa de la mujer.

### 7.5.2. FORMAS DEL CONTRATO DE HIPOTECA.

Enunciaciones de la inscripción del derecho real de hipoteca:

La ley no regula las enunciaciones de la escritura pública, sino las de la inscripción (Art. 2432 CC). Pero la inscripción se hace con los datos que suministra el título.

- 1) Individualización de las partes y sus representantes.
- 2) Fecha, naturaleza y archivo en que se encuentra el contrato a que accede la hipoteca. Mismos datos de la hipoteca, si se constituye en acto separado.
- 3) Situación de la finca y sus linderos.
- 4) Suma determinada a que se extiende la hipoteca, si las partes la limitan a una cantidad.
- 5) Fecha de la inscripción y firma del Conservador.

Sólo la omisión de esta última siempre anula la inscripción. Las demás la anulan sólo cuando por medio de ella o los contratos citados en ella no se pueda conocer los datos que faltan (Art. 2433 CC).

### 7.5.3. COSAS QUE PUEDEN HIPOTECARSE.

Art. 2418 inc. 1º CC. "La hipoteca no podrá tener lugar sino sobre bienes raíces que se posean en propiedad o usufructo, o sobre naves."

También son hipotecables las pertenencias mineras.

#### **1) INMUEBLES QUE SE POSEEN EN PROPIEDAD.**

Puede hipotecarse cualquier clase de propiedad: absoluta o fiduciaria, plena o nuda.

**a) Hipoteca de la propiedad fiduciaria:** los bienes se asimilan a los de los pupilos, sujetándose a sus formalidades, y con audiencia de las personas que tienen derecho a impetrar medidas conservativas (entre ellas, el fideicomisario, Art. 761 CC). Si no se cumplen, el fideicomisario no está obligado a reconocer la hipoteca (Art. 757 CC).

**b) Hipoteca de la nuda propiedad:** una vez extinguido el usufructo, la hipoteca afecta a la propiedad plena ("aumento" de la cosa hipotecada).

## **2) INMUEBLES QUE SE POSEEN EN USUFRUCTO.**

Lo que se puede hipotecar es el derecho de usufructo. No así el de uso y habitación.

La hipoteca recae sobre el derecho mismo, no sobre los frutos (Art. 2423 CC). El usufructuario conserva el derecho de percibirlos, y una vez incorporados a su patrimonio, constituyen la prenda general de sus acreedores.

La hipoteca del usufructo se extingue con la muerte del usufructuario y, en general, por las causas que ponen fin al usufructo. Pero el usufructo hipotecario no puede renunciarse en perjuicio de los acreedores (Art. 803 CC).

## **3) HIPOTECA DE NAVES (ART. 868 CCOM).**

Sólo pueden hipotecarse las naves mayores (más de 50 toneladas), siempre que se encuentren inscritas en el Registro de Matrícula.

Debe otorgarse por escritura pública e inscribirse.

## **4) HIPOTECA DE CONCESIÓN MINERA.**

Debe constituirse sobre la concesión cuyo título esté inscrito. Afecta también a los inmuebles accesorios de la concesión. Pero no se extiende a los frutos percibidos ni a las sustancias minerales separadas del suelo (Art. 2423 CC).

## **5) HIPOTECA DE BIENES FUTUROS.**

Como la inscripción es impracticable, sólo da al acreedor el derecho de recabar la inscripción sobre los bienes que el constituyente vaya adquiriendo, a medida que se produzca la adquisición (Art. 2419 CC).

## **6) HIPOTECA DE CUOTA.**

El comunero puede, antes de la división, hipotecar su cuota.

- Pero efectuada la división, la hipoteca afecta a los bienes hipotecables que se le adjudiquen.
- Si no se le adjudica ninguno, caduca la hipoteca (Art. 2417 CC). Esto es consecuencia del efecto declarativo de la adjudicación.
- Pero puede subsistir la hipoteca sobre bienes adjudicados a otros comuneros, si éstos consienten por escritura pública, subinscrita al margen de la inscripción hipotecaria.

## **7) HIPOTECA DE BIENES EN QUE SE TIENE UN DERECHO EVENTUAL, LIMITADO O RESCINDIBLE.**

En este caso, la hipoteca tiene los mismos caracteres que el derecho del constituyente sobre el bien gravado.

Sin embargo, si el derecho está limitado por una condición resolutoria, la resolución del mismo no extingue la hipoteca sino de acuerdo al Art. 1491 CC: sólo en perjuicio del acreedor hipotecario de mala fe.

La hipoteca constituida por el donatario cuya donación es resuelta, rescindida o revocada, se sujeta a reglas especiales.

### **8) HIPOTECA DE COSA AJENA.**

Aunque se decida que es válida, es forzoso concluir que no da al acreedor el derecho de hipoteca. La tradición no da al adquirente un derecho que el tradente no tenía. 2 opiniones:

I. La exigencia de que el constituyente sea dueño se desprende de varias disposiciones (Ej. Art. 2414 CC: "sus bienes").

II. Pero hay varias razones para decir que es válida la hipoteca de cosa ajena:

- 1) No puede decirse que el Art. 2414 CC contenga la prohibición de hipotecar cosas ajenas.
- 2) La tradición hecha por quien no es dueño no es nula; solamente no transfiere el derecho de que se trata.
- 3) No hay razón para adoptar, respecto de la hipoteca, una solución distinta a la de la prenda (Art. 2390 CC).
- 4) El derecho de hipoteca se adquiere por prescripción (Art. 2498 CC). No se concibe esta adquisición sino justamente cuando se constituye por quien no es dueño. Si el contrato fuera nulo, sería título injusto, y jamás procedería la prescripción ordinaria.
- 5) Si consideramos nula la hipoteca, no podría validarse por la adquisición posterior del dominio o la ratificación del dueño. Esto sería contradictorio con el Art. 2417 CC (relativo al comunero), que establece que la hipoteca constituida por quien no es dueño (comunero que no se adjudica el bien) puede subsistir si el dueño la ratifica (comunero que sí se adjudica el bien).

### **7.5.4. LA ESPECIALIDAD DE LA HIPOTECA.**

#### **1. ESPECIALIDAD DE LA HIPOTECA EN RELACIÓN CON EL BIEN HIPOTECADO.**

La especialidad de la hipoteca consiste en una doble especificación:

- bienes gravados con la hipoteca
- naturaleza y monto de los créditos garantizados.

En cuanto al bien, debe indicarse precisamente el inmueble gravado.

En nuestra legislación no existen hipotecas generales.

#### **2. OBLIGACIONES SUSCEPTIBLES DE CAUCIONARSE CON HIPOTECA.**

Todas las obligaciones son susceptibles de garantizarse con hipoteca, cualquiera sea su origen: civil o natural, presente o futuras.

#### **3. ESPECIALIDAD DE LA HIPOTECA EN RELACIÓN CON EL CRÉDITO HIPOTECARIO.**

Debe determinarse la naturaleza y el monto de la obligación garantizada. Esto

permite que el deudor conozca cabalmente el alcance de su obligación, y que los terceros conozcan exactamente la medida en que se encuentra comprometido el crédito del deudor.

#### **4. ¿PUEDE CONSTITUIRSE HIPOTECA EN GARANTÍA DE UNA OBLIGACIÓN DE MONTO INDETERMINADO?**

Si bien este punto es discutible, en tanto pugna con la especialidad de la hipoteca, debe concluirse que sí es posible constituir hipoteca en garantía de una obligación de monto indeterminado. Podemos señalar los siguientes argumentos:

- a) El art. 2427 CC, frente a la pérdida o deterioro de la finca, en términos de no ser suficiente para la seguridad de la deuda, faculta al acreedor para impetrar providencias conservativas "si la deuda fuere ilíquida, condicional o *indeterminada*".
- b) El art. 2431 CC, a propósito del límite del monto caucionado por la hipoteca, señala que la hipoteca no se extenderá a "más del duplo de del importe conocido o *presunto* de la obligación principal"
- c) El art. 2432 CC no señala el monto de la obligación principal dentro de los requisitos de la inscripción, sino solo el monto al cual se extiende la hipoteca.
- d) En numerosos casos, el monto de la obligación caucionada es necesariamente indeterminado.

En la práctica, un ejemplo concreto de hipoteca en garantía de una obligación de monto indeterminado cuya validez ha sido aceptada por la jurisprudencia es la hipoteca que garantiza una cuenta corriente y los sobregiros que se puedan efectuar en ella.

#### **5. LÍMITE LEGAL DE LA HIPOTECA.**

La indeterminación del monto atenta contra la especialidad de la hipoteca. Por eso, si no se fija un límite al monto de la hipoteca, la ley fija uno: el doble del monto conocido o presunto de la obligación principal (Art. 2431 CC). "Conocido o presunto" importa aceptar que el monto de la deuda puede ser determinado o indeterminado.

#### **6. CLÁUSULA DE GARANTÍA GENERAL HIPOTECARIA.**

La cláusula de garantía general hipotecaria es una cláusula muy frecuente en la práctica bancaria. Por medio de dicha cláusula se constituye hipoteca para garantizar determinadas obligaciones y, además, todas las obligaciones futuras que se contraigan entre el deudor y el acreedor. Así, por medio de la cláusula de garantía general hipotecaria se caucionan obligaciones futuras y de monto indeterminado.

Estas dos características han generado bastante discusión doctrinaria y jurisprudencial acerca de la validez de este tipo de cláusulas. Si bien la posición doctrinaria y jurisprudencial imperante apunta a reconocer su validez, vale la pena revisar algunos de los argumentos que se han esgrimido en su contra.

- a) La cláusula de garantía general hipotecaria sería nula por pugnar con el principio de accesoriedad de la hipoteca, en tanto cauciona obligaciones futuras. No obstante, como vimos más arriba, la accesoriedad de la hipoteca no obsta a la hipoteca en favor



de obligaciones futuras (art. 2413 CC). El principio de accesoriedad más bien se refiere a la extinción de la hipoteca por la extinción de la obligación principal.

b) La cláusula sería nula por atentar contra la publicidad de la hipoteca y, en particular, contra el requisito del art. 2432 nº2 CC. El sistema registral en relación con la hipoteca tiene por fundamento que cualquier persona pueda conocer la existencia de este tipo de gravámenes en relación con la propiedad raíz. Así, este tipo de cláusulas podría dar lugar a fraudes u otro tipo de abusos en contra de los demás acreedores. No obstante, se concluye que esta exigencia debe cumplirse sólo cuando ello sea posible, lo cual no sería el caso en las hipotecas sobre obligaciones futuras, las cuales son válidas según el art. 2413 CC.

c) La cláusula sería nula por indeterminación del objeto del contrato. En la cláusula de garantía general hipotecaria no individualiza las obligaciones caucionadas, ni tampoco da reglas que sirvan para determinar su monto, por lo cual el contrato adolecería de falta de objeto, en razón de su indeterminación. Este argumento se refuta, pues confunde el objeto del contrato hipotecario con el objeto del derecho real de hipoteca. Dado que el objeto del contrato hipotecario es la obligación de transferir el derecho real de hipoteca, la indeterminación de la obligación caucionada no quiere decir, en ningún caso, indeterminación del contrato hipotecario.

## **7.6 EFECTOS DE LA HIPOTECA.**

### **7.6.1 EFECTOS EN RELACIÓN AL INMUEBLE HIPOTECADO.**

Cosas a que se extiende la hipoteca:

**1) Inmuebles por destinación (Art. 2420 CC):** los alcanza aunque nada se exprese en el contrato, y aunque la inscripción no los mencione. Afecta incluso a los que se adquieren después de la constitución de la hipoteca, pero deja de afectarles desde que se enajenan.

**2) Aumentos y mejoras (Art. 2421 CC):** forman parte del inmueble, es lógico que los afecte. Comprende todo lo que incrementa la cosa, sea por causas naturales o a consecuencia de la industria humana.

**3) Rentas de arrendamiento del bien hipotecado (Art. 2422 CC):** lo que no significa que el acreedor tenga derecho a percibir las, sino que sobre ellas tiene la misma preferencia que respecto del inmueble, lo que le servirá cuando sean embargadas.

**4) Indemnizaciones debidas por los aseguradores (Art. 2422 CC):** se produce una subrogación real. La cosa materia del seguro es subrogada por la indemnización para efectos de ejercer sobre ella la hipoteca (Art. 555 CCom).

**5) Precio de la expropiación del inmueble (Art. 924 CPC).**



### **7.6.2 EFECTOS CON RESPECTO AL CONSTITUYENTE.**

Restricciones impuestas al dueño de la finca:

#### **a) Limitaciones a la facultad de disposición:**

En términos generales, conserva la facultad de disposición, en cuanto no perjudique el derecho del acreedor.

Art. 2415 CC. "El dueño de los bienes gravados con hipoteca podrá siempre enajenarlos o hipotecarlos, no obstante cualquiera estipulación en contrario."

- La enajenación no afecta al acreedor, porque puede perseguir la cosa.
- La hipoteca tampoco, porque la hipoteca antigua prefiere a la nueva.

¿Qué pasa con el resto de los derechos reales? En principio, menoscaban la garantía y perjudican al acreedor. Pero por otro lado, nadie puede transferir más derechos que los que tiene: si su dominio está limitado, los derechos que constituyan deben sujetarse a la misma limitación.

El Art. 1368 CC resuelve la situación en el caso del testador que constituye usufructo sobre un bien hipotecado: el usufructo no afecta al acreedor hipotecario. Pero la hipoteca sí afecta al usufructuario: debe pagar la deuda y se subroga en ella.

#### **b) Limitaciones a las facultades de uso y goce:**

El constituyente conserva dichas facultades, pero no le es lícito ejercerlas en forma arbitraria y perjudicial para el acreedor.

Art. 2427 CC. "Si la finca se perdiere o deteriorare en términos de no ser suficiente para la seguridad de la deuda, tendrá derecho el acreedor:

- a que se mejore la hipoteca,
- se le dé otra seguridad equivalente;
- y en defecto de ambas cosas, podrá demandar el pago inmediato de la deuda líquida, aunque esté pendiente el plazo, o implorar las providencias conservativas que el caso admita, si la deuda fuere ilíquida, condicional o indeterminada."

Es indiferente que la pérdida o deterioro se produzca por caso fortuito o por culpa del dueño.

#### **7.6.2.1 LA CLÁUSULA DE NO ENAJENAR EN EL CONTRATO HIPOTECARIO**

Las cláusulas de no enajenar son una práctica frecuente en los contratos hipotecarios, por lo que ameritan un análisis particular.

Art. 2415 CC. "El dueño de los bienes gravados con hipoteca podrá siempre enajenarlos o hipotecarlos, no obstante cualquiera estipulación en contrario."

Lo primero que hay que constatar es que la disposición referida no contiene una prohibición expresa a las cláusulas de no enajenar. Se limita a señalar que, aunque se haya pactado lo contrario, el dueño de los bienes hipotecados podrá siempre enajenarlos o hipotecarlos, aunque se hubiere pactado lo contrario.

En este sentido, si bien resulta un problema discutible, es posible concluir que las cláusulas de no enajenar en los contratos hipotecarios son válidas, en la medida en que cumplan con los requisitos de amparar un interés legítimo, y de estar limitadas en el tiempo. Ahora bien, aunque admitamos que dichas cláusulas son válidas, la norma citada dispone claramente que el dueño de la finca podrá enajenarlo de todas formas.

Por consiguiente, la celebración de una cláusula de no enajenar válida se traducirá en la constitución de una obligación de no hacer. Luego, esta obligación de no hacer no impide que el dueño, efectivamente, enajene. Pero este acto de enajenación, en la medida en que contraviene una obligación de no hacer, producirá los efectos que prevé la ley, según las reglas generales del art. 1555 CC.

Adicionalmente, en la práctica bancaria, es muy frecuente que este tipo de cláusulas se establezcan en el marco de contratos de 'mutuo hipotecario', es decir, hipotecas constituidas para asegurar la restitución de una suma de dinero. En estos casos, la cláusula de no enajenar sin autorización del banco suele vincularse con una cláusula de aceleración, en virtud de la cual la contravención de la cláusula de no enajenar tiene por efecto la exigibilidad inmediata del total de la obligación, aún cuando haya habido plazos pendientes.

### 7.6.3 EFECTOS RESPECTO DEL ACREEDOR HIPOTECARIO.

Le confiere 3 derechos:

#### **1) DERECHO DE VENTA:**

##### **1. Concepto.**

Es el derecho que tiene el acreedor de hacer vender la cosa hipotecada para pagarse con el producto (Art. 2424 CC en relación al Art. 2397 CC).

Art. 2424 CC. "El acreedor hipotecario tiene para hacerse pagar sobre las cosas hipotecadas los mismos derechos que el acreedor prendario sobre la prenda."

Derecho principal: se saque a remate la cosa hipotecada para que con el producido de la subasta pueda pagarse el acreedor.

Derecho subsidiario: (supone el ejercicio del derecho principal) para adjudicarse el bien hipotecado a falta de posturas admisibles y previa tasación de peritos.

## **2. Forma de realización de la finca hipotecada.**

Se sujeta a las reglas generales que rigen la realización de inmuebles en el juicio ejecutivo. Se vende:

- previa tasación (Art. 486 CPC),
- en pública subasta
- ante el juez que conoce el juicio o el del lugar en que se encuentre el bien (Art. 485 CPC).

El remate se realiza el día que fije el juez, previa publicación de avisos (4) en un diario de la comuna o capital de provincia o región (Arts. 488 y 489 CPC).

## **3. Derecho del acreedor hipotecario de adjudicarse la finca.**

No se aplica el Art. 2397 CC relativo al acreedor prendario, pues a falta de postores, el acreedor puede pedir:

- que la finca se saque nuevamente a remate, con rebaja del mínimo,
- o se le adjudique por los 2/3 de la tasación (Art. 499 CC).

## **4. Prohibición del pacto comisorio.**

Por aplicación del Art. 2397 CC. Este pacto comisorio es la estipulación que autoriza al acreedor para apropiarse o realizar la finca en forma diversa a la prevista por la ley, y está prohibido.

## **5. La hipoteca no excluye el derecho de prenda general del acreedor (Art. 2425 CC).**

El acreedor puede perseguir el cumplimiento de la obligación en otros bienes del deudor. Pero obviamente no tiene sobre ellos la preferencia que le confiere la hipoteca. Por lo tanto, la acción hipotecaria deja a salvo la acción personal en virtud de la cual el acreedor puede perseguir los otros bienes del deudor. El acreedor hipotecario es titular de 2 acciones:

**1. Personal:** que emana del vínculo jurídico cuya obligación se está garantizando. Permite al acreedor perseguir los bienes que el deudor no ha dado en garantía.

Art. 2425 CC. El ejercicio de la acción hipotecaria no perjudica a la acción personal del acreedor para hacerse pagar sobre los bienes del deudor que no le han sido hipotecados; pero aquélla no comunica a ésta el derecho de preferencia que corresponde a la primera.

**2. Real:** que deriva de la hipoteca. Mientras el inmueble hipotecado está en poder del deudor personal, ambas acciones se confunden; pero en cambio ellas se diferencian nítidamente cuando el bien dado en garantía pasa a manos de un tercero, porque entonces contra éste sólo se puede ejercitar la acción real, y contra el deudor, únicamente la acción personal.

Por lo tanto, al no existir incompatibilidad es perfectamente posible que al mismo

tiempo el acreedor entable la real contra el tercer poseedor y la personal contra el deudor.

## **2) DERECHO DE PERSECUCIÓN:**

### **1. Concepto.**

Art. 2428 inc. 1º CC. "La hipoteca da al acreedor el derecho de perseguir la finca hipotecada, sea quien fuere el que la posea, y a cualquier título que la haya adquirido."

Por ser la hipoteca un derecho real, la acción hipotecaria puede dirigirse contra el actual propietario. Es decir, la hipoteca afecta a terceros poseedores.

#### Justificación del derecho de persecución:

- El acreedor es titular de un derecho real.
- El Art. 2415 CC faculta al dueño del inmueble hipotecado para enajenarlo sin que valga estipulación en contrario.

### **2. Terceros poseedores.**

(1) Toda persona que detenta, a un título no precario, la finca gravada con hipoteca, (2) sin que se haya obligado personalmente al pago de la obligación garantizada.

#### **i) Adquirente de la finca gravada con hipoteca (Art. 2429 CC):**

1. Para quedar obligado como tercer poseedor, debe ser adquirente a título singular. Si lo es a título universal, es también deudor personal, a no ser que se trate del heredero beneficiario que no es continuador de la persona del causante, o del heredero que ha pagado su cuota en las deudas hereditarias y a quien se adjudica el inmueble.
2. En cuanto al legatario: hay que indagar si el testador quiso o no gravarle con la deuda garantizada con la hipoteca.

**ii) Constituyente de hipoteca sobre un bien propio en garantía de una deuda ajena (Arts. 2414 y 2430 CC):** no hay acción personal contra él, a menos que se haya obligado personalmente en forma expresa. Si además de hipotecar un bien suyo, se constituye fiador, estamos frente a una fianza hipotecaria.

### **3. Acción de desposeimiento.**

Es la acción hipotecaria dirigida contra el tercer poseedor.

- Si **se persigue al deudor personal, y se dispone de título ejecutivo**, se cobra ejecutivamente la obligación principal, se embarga y realiza la finca y se paga con el producto.

- Si **no se dispone de título ejecutivo**, debe declararse previamente la existencia de la obligación.

Pero si se persigue al tercer poseedor, deben realizarse algunas gestiones preliminares:

**i) Notificación previa del poseedor (Art. 758 CPC).**

**ii) En la notificación se le señala un plazo de 10 días para que adopte una de 3 actitudes:**

1. Pagar la deuda: se subroga en los derechos del acreedor (Art. 2429 inc. 2º CC).
2. Abandonar la finca: desde ese momento cesa su responsabilidad (Art. 2426 CC).  
Este abandono no importa el abandono del dominio ni de la posesión:
  - a. Puede recobrarla mientras no se haya consumado la adjudicación, pagando la deuda.
  - b. Si el producto de la realización excede el monto de la deuda, el saldo pertenece al tercer poseedor.
3. No hacer nada: se procede al desposeimiento (Art. 759 CPC), que se somete a juicio ejecutivo cuando consten en título ejecutivo la obligación y la hipoteca.

\*\*\*El tercer poseedor que abandona la finca o es desposeído debe ser indemnizado por el deudor personal (Art. 2429 inc. 3º CC).

#### **4. No hay derecho de persecución.**

1. Contra el tercero que adquirió la finca hipotecada en pública subasta, ordenada por el juez (Art. 2428 CC).
2. Contra el adquirente de la finca a consecuencia de una expropiación por causa de utilidad pública: debe perseguirse el precio (Art. 924 CPC).

### **3) DERECHO DE PREFERENCIA:**

#### **1. Carácter de la preferencia.**

- 1) Es un crédito de tercera clase (Art. 2477 CC).
- 2) Es especial: recae solamente sobre la finca. Si es insuficiente, el saldo pasa a la quinta clase.
- 3) Pasa contra terceros.

#### **2. A qué se extiende la preferencia.**

La preferencia se hace efectiva sobre el producto de la realización de la finca. Se extiende:

- i) A la indemnización del seguro.
- ii) Al valor de la expropiación de la finca.
- iii) A las rentas de arrendamiento, y
- iv) en general a todos los bienes a que se extiende la hipoteca.

### **3. Pluralidad de hipotecas.**

Prefieren en el orden de sus fechas (Art. 2477 inc. 2º CC). La fecha es la de la correspondiente inscripción. Las de la misma fecha prefieren en el orden de las inscripciones (de acuerdo a su anotación en el Repertorio).

### **4. Posposición de la hipoteca.**

Acto por el cual el acreedor hipotecario consiente en que prefiera a la suya una hipoteca constituida con posterioridad.

### **5. Oportunidad del acreedor hipotecario para alegar su preferencia.**

- 1. En el juicio ejecutivo que le inicie al deudor o al tercer poseedor.
- 2. En el concurso de hipotecarios que se abra a la finca hipotecada en conformidad a lo dispuesto en el artículo 2477.
- 3. En el procedimiento concursal de reorganización o liquidación respectivo.
- 4. Iniciando una tercería de prelación si el inmueble lo hubiere embargado otro acreedor.

### **6. Créditos que se pagan con antelación a los hipotecarios o que concurren con ellos.**

- 1. Los acreedores hipotecarios deben soportar la prioridad para el pago del saldo de los créditos de 1º clase que no se hubieren alcanzado a pagar con los otros bienes del deudor.
- 2. Los inmuebles por destinación que existan en la finca hipotecada, pueden ser dados en prenda agraria o industrial sin el consentimiento del acreedor hipotecario, y en los bienes empeñados los acreedores prendarios gozan de preferencia sobre el bien hipotecado.

## **7.7. EXTINCIÓN DE LA HIPOTECA.**

### **POR VÍA DE CONSECUENCIA.**

Se extingue la hipoteca cada vez que se extinga, por los modos generales de extinguirse las obligaciones, la obligación principal (Art. 2434 inc. 1º CC).

### **POR VÍA PRINCIPAL**

#### **1) RESOLUCIÓN DEL DERECHO DEL CONSTITUYENTE (Art. 2434 inc. 2º CC):**

la hipoteca de una cosa en que se tiene un derecho eventual, limitado o rescindible se entiende hecha con las condiciones o limitaciones del derecho (Art. 2416 CC).

**2) EVENTO DE LA CONDICIÓN RESOLUTORIA (Art. 2434 inc. 2º CC) O LLEGADA DEL PLAZO (Art. 2434 inc. 3º CC):** caso en que la hipoteca misma está sujeta a plazo o condición.

**3) PRÓRROGA DEL PLAZO (Art. 1649 CC):** extingue la hipoteca constituida por terceros, salvo que el dueño del bien acceda a la ampliación.

**4) CONFUSIÓN:** la ley no lo dice, pero es obvio que se extingue por la confusión de las calidades de dueño de la finca y acreedor hipotecario (la ley lo señala respecto de la prenda, Art. 2406 CC). Pero puede darse la situación curiosa de que una persona sea acreedor hipotecario de su propia finca (caso de subrogación del Art. 1610 N° 2 CC).

**5) EXPROPIACIÓN POR CAUSA DE UTILIDAD PÚBLICA (Art. 924 CPC):** el acreedor debe hacer valer su derecho sobre el precio, pues subroga al bien expropiado.

**6) CANCELACIÓN DEL ACREEDOR (Art. 2434 inc. 3º CC):** el acreedor renuncia por escritura pública, que debe anotarse al margen de la inscripción hipotecaria.

**7) PURGA DE LA HIPOTECA (Art. 2428 CC):** Esta es la situación que contempla el inciso 2º del art. 2428. Conforme a esta norma, el acreedor hipotecario no puede perseguir la finca hipotecada contra el tercero que la haya adquirido en pública subasta ordenada por el juez.

Art. 2428 CC. La hipoteca da al acreedor el derecho de perseguir la finca hipotecada, sea quien fuere el que la posea, y a cualquier título que la haya adquirido.

Sin embargo, esta disposición no tendrá lugar contra el tercero que haya adquirido la finca hipotecada en pública subasta, ordenada por el juez.

Mas para que esta excepción surta efecto a favor del tercero deberá hacerse la subasta con citación personal, en el término de emplazamiento, de los acreedores que tengan constituidas hipotecas sobre la misma finca; los cuales serán cubiertos sobre el precio del remate en el orden que corresponda.

El juez entre tanto hará consignar el dinero.

**Requisitos para que opere la purga de la hipoteca:**

- 1) Que se trate de una pública subasta ordenada por el juez.
- 2) Que los acreedores hipotecarios sean citados (notificación personal).
- 3) Que el remate se efectúe transcurrido el término de emplazamiento a contar de la última citación al acreedor hipotecario.

4) Que se consigne el dinero del remate a la orden del tribunal.  
Consecuencias:

- **Si el producto del remate no alcanza a cubrir el monto de los créditos y el monto garantizado por la hipoteca**, ésta desaparece y el juez mandará a cancelar las inscripciones hipotecarias.

- **El acreedor que no ha sido citado conserva su hipoteca**, de manera que podrá perseguirla de manos del adjudicatario en la subasta. En este caso, el que compró el inmueble en la subasta se subroga en los derechos de los acreedores que se pagaron con el precio del remate. Esto significa, que el acreedor hipotecario omitido **no mejora de grado por este hecho**, sino que queda en el mismo lugar o posición que tenía al efectuarse el primer remate, ya que el lugar de los acreedores hipotecarios que se pagaron con el precio de la subasta para a ocuparlo el tercero adquirente, en virtud de la subrogación del N° 2 del art. 1610.

**Derechos que conforme al CPC tiene el acreedor hipotecario de grado preferente:**

El Art. 492 del C.P.C. complementó el art. 2428, permitiendo al acreedor hipotecario de grado preferente optar entre:

- Pagarse con el producto del remate o
- Conservar su hipoteca.

Si el acreedor hipotecario de grado preferente, transcurrido el término de emplazamiento, nada dice, se entiende que opta por pagarse con el producto del remate.

**Requisitos:**

- a) Debe tratarse de un acreedor hipotecario de grado preferente al acreedor hipotecario que solicita el remate. (Aunque también es aplicable cuando el remate es provocado por un acreedor sin ningún derecho preferente)
- b) Debe existir plazo pendiente para el pago de su crédito.



## CAPÍTULO 8. FIANZA

### 8.1 CONCEPTO.

Art. 2335 inc. 1 CC. "La *fianza* es una obligación accesoria, en virtud de la cual una o más personas responden de una obligación ajena, comprometiéndose para con el acreedor a cumplirla en todo o parte, si el deudor principal no la cumple."

Críticas a la definición: No es una "obligación", sino un contrato accesorio. Es siempre un contrato.

**Contrato de fianza**: aquel por el cual una persona, llamada fiador, se obliga personalmente hacia el acreedor de otra, llamada deudor principal, a cumplir la obligación de éste en caso que él no la cumpla por sí mismo.

Por lo tanto, las partes del contrato son:

- Fiador.
- Acreedor del deudor principal.
- El deudor principal no interviene. El eventual entendimiento del deudor principal con el fiador antes de la celebración del contrato de fianza está fuera del esquema de este contrato. No altera la bilateralidad jurídica que envuelve.

### 8.2 CARACTERÍSTICAS.

**1. Es un contrato unilateral.** Quien se obliga es el fiador para con el acreedor. El deudor es extraño al contrato. Sería bilateral si el acreedor se obliga a pagar una remuneración, pero en ese caso degenera en otro contrato (seguro).

**2. Es un contrato gratuito.** Se obliga el fiador en beneficio del acreedor, el gravamen lo soporta exclusivamente el fiador. Pero el fiador puede pactar con el deudor una remuneración (Art. 2341 CC), lo que no altera su naturaleza, porque el deudor es extraño al contrato.

Pese a su carácter gratuito, el fiador responde de la culpa leve (Art. 2351 CC).

**3. Es un contrato accesorio.** Su finalidad es procurar al acreedor una garantía, y supone necesariamente una obligación principal.

Consecuencias de su carácter accesorio:

1. Extinguida la obligación principal, se extingue la fianza (Art. 2381 CC). Excepción: en caso de nulidad por relativa incapacidad del deudor principal (Art. 2354 CC), pues en este caso se afianza una obligación natural.

2. El fiador puede oponer al acreedor todas las excepciones que derivan de la naturaleza de la obligación principal.

3. La obligación del fiador no puede ser más gravosa que la del deudor principal (Arts. 2343 y 2344 CC). Esto se refiere a:

- la cuantía,
- al tiempo,
- al lugar,
- a la condición, al modo
- y a la pena.

La fianza que excede a la obligación del deudor debe reducirse a los términos de la obligación principal. Sin embargo, el fiador puede obligarse en términos más eficaces. Ej. Con una hipoteca, aunque la obligación principal no la tenga.

Además, el fiador puede tener un subfiador (Art. 2335 inc. 2º CC). Respecto de él, el fiador es considerado como deudor principal.

**4. Es un contrato consensual.** Pero suele ser solemne:

1. Fianza que deben rendir tutores y curadores: por escritura pública.
2. Fianza mercantil: por escrito.
3. Aval: firma en el anverso de la letra o pagaré.
4. Fianza que se rinde para garantizar la libertad condicional: escritura pública o acta firmada ante el juez.

**5. La fianza puede ser pactada de manera pura y simple o con modalidades** (art. 2340 CC). Además, las modalidades de la obligación principal pasan a la fianza.

### 8.3 CLASIFICACIONES DE LA FIANZA.

#### **1. En cuanto al origen de la obligación del deudor principal de rendir fianza:**

- 1) **Fianza legal:** Ej. Poseedor provisorio, tutor y curador, usufructuario.
- 2) **Fianza judicial:** Ej. Propietario fiduciario, dueño de la obra ruinosa, albacea. El juez debe apoyarse en texto expreso de la ley.
- 3) **Fianza convencional.**

En general, la legal y la judicial se sujetan a las mismas normas de la convencional (Art. 2336 inc. 3º CC). Diferencias:

- i) Si es legal o judicial, puede ser sustituida por una prenda o hipoteca, aun contra la voluntad del acreedor (Art. 2337 CC).
- ii) Cuando es judicial, el fiador no tiene beneficio de excusión (Art. 2358 N° 4 CC).

#### **2. En atención a la obligación del fiador:**

- 1) **Fianza simple:** Como consecuencia de la obligación personal que emana del contrato de fianza, todos los bienes del fiador son obligados indistintamente al cumplimiento.
- 2) **Fianza hipotecaria o prendaria:** el fiador, además, constituye una prenda o hipoteca. En este caso, si el acreedor ejercita la acción real:

- i) El fiador no puede oponer el beneficio de excusión.
- ii) Tampoco el beneficio de división, por la indivisibilidad de la prenda o hipoteca.

### 3. En cuanto a la determinación de la obligación del fiador:

- 1) **Fianza limitada:** se determinan las obligaciones concretas que toma sobre sí o se limita el monto.
- 2) **Fianza ilimitada:** no se determinan obligaciones ni monto. De todos modos tiene un límite: la obligación principal, comprendiendo todos sus accesorios: capital, intereses y costas.

### 4. Fianza simple y solidaria:

- 1) **Fianza simple.** El fiador se obliga según las reglas generales.
- 2) **Fianza solidaria:** La fianza solidaria es una figura que se genera cuando, habiendo varios fiadores respecto a la misma obligación principal, estos se obligan solidariamente entre sí. La fianza solidaria tiene las siguientes particularidades:
  - Frente al acreedor, los fiadores solidarios son mirados como fiadores. En tal sentido, son deudores subsidiarios, y cuentan con el beneficio de excusión.
  - Sin embargo, en la medida en que los fiadores se han obligado de manera solidaria, están privados del beneficio de división (art. 2367 CC). Por consiguiente, pueden ser demandados por el total.

Por otro lado, la figura del fiador solidario no debe ser confundida con la del fiador y codeudor solidario. Esta última figura se genera cuando una persona celebra el contrato principal en calidad de codeudor solidario y, adicionalmente, como fiador, combinando ambas cauciones en un solo sujeto pasivo. En este caso, tanto la doctrina como la jurisprudencia han entendido que las relaciones entre el acreedor y el fiador y codeudor solidario deben regirse por las reglas de la solidaridad, por lo que el fiador y codeudor solidario debe entenderse como un deudor directo, careciendo tanto del beneficio de división como del de excusión. No obstante, en la medida en que se ha obligado como fiador, dicho codeudor solidario no tiene interés en la obligación, con las consecuencias que establece el art. 1522 CC.

|                            | <b>Codeudor solidario</b>                                 | <b>Fiador y codeudor solidario</b>                          | <b>Fiador solidario</b>                                                 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contrato</b>            | Celebró un contrato principal pactando solidaridad.       | Celebró contrato principal pactando solidaridad y fianza    | Celebró contrato de fianza pactando solidaridad con los demás fiadores. |
| <b>Carácter como parte</b> | Codeudor solidario <b>con</b> interés en la obligación, a | Codeudor solidario <b>sin</b> interés en la obligación, sin | Fiador que goza del beneficio de excusión, pero no el de división (art. |

|                                             |                                                                                 |                                                                                    |                                                                                                  |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | menos que logre acreditar lo contrario.                                         | necesidad de ofrecer prueba adicional.                                             | 2367 CC)                                                                                         |
| <b>Obligación y contribución a la deuda</b> | Directamente obligado a la obligación principal y <u>contribuye</u> a la deuda. | Directamente obligado a la obligación principal y <u>no contribuye</u> a la deuda. | Obligado de manera subsidiaria respecto al deudor principal, pero por el total del monto pactado |

## 8.4. REQUISITOS DEL CONTRATO DE FIANZA.

### **1. Consentimiento.**

Es un contrato consensual.

- El consentimiento del fiador debe ser expreso: la fianza no se presume (Art. 2347 CC).
- Pero el consentimiento del acreedor puede ser tácito.

### **2. Capacidad del fiador.**

Debe ser capaz de obligarse como tal (Art. 2350 CC).

1. Pupilo:

- Debe mediar autorización judicial.
- Debe otorgarse la fianza en favor del cónyuge, descendientes o ascendientes.
- Debe invocarse una causa urgente y grave.

2. Hijo sujeto a patria potestad: debe ser autorizado o ratificado por el padre o madre, los cuales quedan obligados directamente, y el hijo se obliga sólo en cuanto le beneficia (lo que no suele ocurrir, porque la fianza es gratuita).

3. Mujer casada en sociedad conyugal: necesita autorización de marido o del juez en subsidio, sin la cual obliga sólo los bienes a los que se refieren los Arts. 150, 166 y 167 CC. El marido también requiere autorización de la mujer, sin la cual obliga sólo sus bienes propios.

4. Cónyuges casados en régimen de participación en los gananciales: requieren el consentimiento del otro cónyuge.

### **3. Objeto de la fianza.**

La obligación del fiador será siempre de dar una suma de dinero. Si la obligación principal es de hacer o no hacer, se garantiza únicamente el pago de la indemnización de los perjuicios que produce el incumplimiento (Art. 2343 inc. 3º CC).

### **4. Causa de la fianza.**

Se puede decir que en la fianza gratuita, la causa es la liberalidad del fiador; en la

remunerada, la causa es la remuneración. Esto nos lleva a que la causa debe buscarse en sus relaciones con el deudor principal, lo que es curioso porque el deudor es ajeno al contrato.

### **5. Existencia de una obligación principal.**

1. La obligación puede ser civil o natural. Si es natural, el fiador no goza del beneficio de excusión ni del beneficio de reembolso.

2. Puede ser pura y simple o sujeta a modalidad. Las modalidades de la obligación principal se comunican a la fianza.

3. Puede ser obligación presente o futura. La fianza otorgada con anterioridad a la constitución de la obligación principal otorga al fiador la facultad de retractarse mientras no llegue a existir (Art. 2329 CC), con la limitación de que debe dar aviso de su retractación (si no lo hace, queda responsable ante el acreedor y los terceros de buena fe).

### **8.5 PERSONAS OBLIGADAS A RENDIR FIANZA.**

1. El deudor que lo ha estipulado (Art. 2348 N° 1 CC).
2. El deudor cuyas facultades disminuyan en términos de poner en peligro manifiesto el cumplimiento de su obligación (Art. 2348 N° 2 CC).
3. El deudor de quien haya motivo de temer que se ausente del territorio del Estado con ánimo de establecerse en otra parte, mientras no deje bienes suficientes para la seguridad de sus obligaciones (Art. 2348 N° 3 CC).
4. El deudor cuyo fiador se torna insolvente (Art. 2349 CC).

### **8.6 CALIDADES QUE DEBE REUNIR EL FIADOR (ART. 2350 CC).**

#### **1. Capacidad.**

**2. Solvencia:** debe tener bienes suficientes para hacer efectiva la fianza. Para determinar la solvencia, sólo se consideran los bienes raíces, salvo en materia comercial o si la fianza es módica. Se excluyen algunos bienes raíces:

1. Los situados fuera del territorio del Estado.
2. Los sujetos a hipotecas gravosas.
3. Los sujetos a condiciones resolutorias.
4. Los embargados.
5. Los litigiosos.
6. Los que están en peligro por encontrarse el fiador recargado de deudas.

**3. Domicilio:** debe tener o señalar domicilio dentro del territorio jurisdiccional de la respectiva Corte de Apelaciones (la del lugar del pago).

## **8.7 EFECTOS DE LA FIANZA ENTRE ACREEDOR Y FIADOR.**

### **8.7.1 ANTES DE QUE EL ACREEDOR RECONVENGA AL FIADOR.**

#### **1. FACULTAD DEL FIADOR DE ANTICIPARSE A PAGAR LA DEUDA (Art. 2353 CC)**

Puede hacerlo en todos los casos en que podía anticiparse el deudor principal (obligación a plazo establecido en beneficio del deudor). Pero si paga antes, debe esperar que se cumpla el plazo para ejercitar contra el deudor el reembolso (Art. 2373 CC).

El fiador debe dar aviso al deudor antes de pagar. Si no lo hace (Art. 2377 CC):

- 1) El deudor puede oponerle todas las excepciones que no pudo oponer al acreedor.
- 2) El fiador pierde el derecho a reembolso si el deudor paga la deuda ignorando que el fiador pagó.

#### **2. FACULTAD DEL FIADOR DE EXIGIR QUE SE PROCEDA CONTRA EL DEUDOR (Art. 2356 CC)**

Puede ejercerla cuando la obligación se hace exigible. Si el acreedor no procede contra el deudor, el fiador no se hace responsable por la insolvencia del deudor principal sobrevinida durante el retardo.

### **8.7.2 DESPUÉS DE QUE EL ACREEDOR RECONVENGA AL FIADOR. (DEFENSAS DEL FIADOR).**

#### **1. BENEFICIO DE EXCUSIÓN:**

##### **1) Concepto:**

Art. 2357 CC. "El fiador reconvenido goza del *beneficio de excusión*, en virtud del cual podrá exigir que antes de proceder contra él se persiga la deuda en los bienes del deudor principal, y en las hipotecas o prendas prestadas por éste para la seguridad de la misma deuda."

El beneficio de excusión es facultativo para el fiador.

##### **2) Casos en que el acreedor es obligado a practicar la excusión:**

- a. Cuando así se haya estipulado expresamente
- b. Cuando el fiador no se haya obligado a pagar sino lo que el acreedor no pueda obtener del deudor (Art. 2365 inc. 2º CC).

##### **3) Requisitos del beneficio de excusión:**

- a. **Que el fiador no esté privado del beneficio.** No goza del beneficio de excusión (Art. 2358 CC):

- Nº 1. El fiador que lo ha renunciado expresamente.
- Nº 2. El fiador que se ha obligado solidariamente.
- Nº 3. El fiador de una obligación natural.
- Nº 4. El fiador en la fianza judicial.

**b. Que se oponga en tiempo oportuno (Art. 2358 Nº 5 CC):** luego de que el fiador haya sido requerido,

- En el término para contestar la demanda en el juicio ordinario (excepción dilatoria)
- En el escrito de oposición a la ejecución en el juicio ejecutivo.

**c. Que el fiador señale al acreedor bienes del deudor para perseguir el cumplimiento de la obligación (Art. 2358 Nº 6 CC).** No se tomarán en cuenta (Art. 2359 CC):

- Nº 1. Los bienes existentes fuera del territorio del Estado.
  - Nº 2. Los bienes embargados y litigiosos, o los créditos de dudoso o difícil cobro.
  - Nº 3. Los bienes cuyo dominio está sujeto a condición resolutoria.
  - Nº 4. Los bienes hipotecados a favor de deudas preferentes.
- No es necesario que los bienes sean bastantes para obtener un pago total (Art. 2364 CC), pero sí suficientemente importantes para obtener un resultado apreciable y serio.

**4) Costos de la excusión:** el acreedor tiene derecho para que el fiador se los anticipe (Art. 2361 inc. 1º CC), pero esto no es requisito del beneficio.

**5) El beneficio de excusión procede una vez (Art. 2363 CC):** el fiador no puede pretender, a pretexto de que la excusión no produjo resultado o los bienes fueron insuficientes, señalar otros bienes del deudor, excepto que los bienes hayan sido posteriormente adquiridos.

**6) Beneficio de excusión en las obligaciones solidarias:** el fiador de uno de los codeudores solidarios puede señalar también los bienes de los demás (Art. 2362 CC).

**7) Beneficio de excusión del subfiador (Art. 2366 CC):** tiene este beneficio respecto del fiador y del deudor principal.

**8) Efectos del beneficio de excusión:**

1. Suspende la entrada a juicio (excepción dilatoria).
2. El acreedor queda obligado a practicar la excusión. El fiador se libera hasta concurrencia del valor de los bienes que señaló y que el acreedor, por negligencia suya, dejó escapar (Art. 2365 inc. 1º CC).
3. Si los bienes señalados no son suficientes, el acreedor debe resignarse a recibir un pago parcial. Sólo puede perseguir al fiador por el saldo insoluto (Art.

2364 CC).

## **2. BENEFICIO DE DIVISIÓN**

### **1) Concepto:**

Art. 2367 inc. 1 CC. "Si hubiere dos o más fiadores de una misma deuda, que no se hayan obligado solidariamente al pago, se entenderá dividida la deuda entre ellos por partes iguales, y no podrá el acreedor exigir a ninguno sino la cuota que le quepa."

Es una excepción perentoria.

### **2) Requisitos:**

- a. Que los fiadores no se hayan obligado solidariamente.
- b. Que los fiadores lo sean de un mismo deudor y de una misma deuda (Art. 2368 CC).

### **3) Forma de la división:**

- a. Regla general: por partes iguales.
- b. Excepciones:
  1. La división se hace entre los deudores solventes (Art. 2367 inc. 2º CC).
  2. Cuando alguno de los fiadores haya limitado su responsabilidad a una determinada suma (Art. 2367 inc. final CC).

## **3. EXCEPCIÓN DE SUBROGACIÓN**

De acuerdo al Art. 1610 N° 3 CC, el fiador se subroga en los derechos del acreedor a quién paga. De esta manera, quien se obliga como fiador se obliga teniendo en cuenta que, en caso de que se vea constreñido a pagar por el deudor principal, podrá repetir en contra del mismo, quedando indemne en su patrimonio. Luego, debemos hacernos la siguiente pregunta: ¿qué ocurre si el acreedor, por hecho o culpa suya, ha perdido total o parcialmente las acciones que tenía contra el deudor, o ha puesto al fiador en la situación de no poder subrogarse? Previendo esta eventual problemática, el legislador ha establecido la excepción de subrogación.

Art. 2355 CC. "Cuando el acreedor ha puesto al fiador en el caso de no poder subrogarse en sus acciones contra el deudor principal o contra los otros fiadores, el fiador tendrá derecho para que se le rebaje de la demanda del acreedor todo lo que dicho fiador hubiera podido obtener del deudor principal o de los otros fiadores por medio de la subrogación legal"



Art. 2381 CC. La fianza se extingue, en todo o parte, por los mismos medios que las otras obligaciones según las reglas generales, y además:

2º En cuanto el acreedor por hecho o culpa suya ha perdido las acciones en que el fiador tenía el derecho de subrogarse”

Para que proceda la excepción de subrogación, es esencial que la pérdida de las acciones del acreedor se deba a su hecho o culpa, y que el fiador haga valer la excepción. Este beneficio no opera de pleno derecho.

Los efectos posibles de la excepción de subrogación son dos:

i) La extinción de la fianza, cuando las acciones perdidas por culpa del acreedor son tales que, de haber subsistido, hubieran permitido que el fiador se reembolsare íntegramente con lo pagado al acreedor.

ii) La disminución de la responsabilidad del fiador, cuando las acciones en que se podría haber subrogado solo le habrían permitido un reembolso parcial respecto de lo pagado.

#### 4. EXCEPCIONES REALES Y PERSONALES

Art. 2354 CC. “El fiador puede oponer al acreedor cualesquiera excepciones reales, como las de dolo, violencia o cosa juzgada; pero no las personales del deudor, como su incapacidad de obligarse, cesión de bienes, o el derecho que tenga de no ser privado de lo necesario para subsistir. Son excepciones reales las inherentes a la obligación principal.”

i) En cuanto a la fuerza o dolo: en verdad son personales, pero el fiador puede oponer la excepción de nulidad fundada en ellas.

ii) La cosa juzgada compete a quien la ha obtenido en juicio y a todos quienes, según la ley, aprovecha el fallo.

#### 8.8. EFECTOS DE LA FIANZA ENTRE EL FIADOR Y EL DEUDOR.

##### 1. EFECTOS ANTERIORES AL PAGO

##### 1) Derechos del fiador (Art. 2369 inc. 1º CC):

- i) Derecho a que el deudor obtenga que se le releve de la fianza.
- ii) Derecho a que el deudor le caucione las resultas de la fianza (contrafianza).
- iii) Derecho a que el deudor consigne medios suficientes para efectuar el pago.

##### 2) Circunstancias que lo autorizan para ejercerlos (Art. 2369 CC):

1. Cuando el deudor principal disipa o aventura temerariamente sus bienes (Nº 1)
2. Cuando el deudor se obligó a obtener el relevo dentro de cierto plazo, que se ha cumplido (Nº 2).
3. Cuando se ha cumplido la condición o vencido el plazo, haciéndose exigible la obligación (Nº 3).

4. Cuando han transcurrido 5 años desde el otorgamiento de la fianza (Nº 4).

Excepciones:

- a. Si la fianza se constituyó por un tiempo determinado más largo.
- b. Si se contrajo para asegurar obligaciones que no están destinadas a extinguirse en un tiempo determinado.

5. Cuando haya temor fundado de que el deudor principal se fugue, no dejando bienes suficientes para el pago (Nº 5).

**3) Aviso mutuo de fiador y deudor antes de pagar:**

i) **Si el deudor paga sin dar aviso**, es responsable ante el fiador por lo que éste pague de nuevo, pero tiene acción contra el acreedor por el pago indebido (Art. 2367 CC).

ii) **Si el fiador paga sin dar aviso:**

- a. No tiene recurso alguno contra el deudor que pague a su vez, pero puede reclamar el pago indebido contra el acreedor.
- b. El deudor puede oponerle las excepciones que, por la precipitación del fiador, no pudo oponer al acreedor.

**2. ACCIÓN DE REEMBOLSO**

**1) Concepto:** es la acción que pertenece al fiador, por derecho propio, emanada del contrato de fianza. La tiene aunque el deudor haya ignorado la fianza (Art. 2370 CC).

**2) Extensión:** permite al fiador quedar totalmente indemne de las consecuencias de la fianza:

1. El deudor debe reembolsar lo que el fiador haya pagado por él (Art. 2370 CC): capital e intereses.
2. Tiene derecho a que se le paguen los correspondientes intereses.
3. Comprende gastos, tanto aquellos que el fiador haya debido pagar al acreedor ocasionados por la persecución del deudor, como los que le ocasione al fiador la demanda del acreedor. Se limita a los gastos prudentes.
4. Tiene derecho a que se le paguen los perjuicios sufridos.

**3) Requisitos:**

**1. Que el fiador no se encuentre privado de la acción.** Está privado de la acción (Art. 2375 CC):

- a. Fiador de una obligación natural (Nº 1).
- b. Fiador que se obligó contra la voluntad del deudor, pero tiene la acción si se extingue la deuda (Nº 2, excepción nominal).
- c. Fiador que paga sin dar aviso al deudor, y este paga igualmente (Nº 3).

**2. Que haya pagado la deuda:** se extiende a los modos de extinguir equivalentes al pago (Art. 2374 CC).

**3. Que el pago haya sido útil:** que haya extinguido la obligación.

**4. Que se entable en tiempo oportuno:** después del pago, por lo general puede ser inmediatamente. Excepción: cuando la obligación principal no es exigible (Art. 2373 CC). La acción prescribe en 5 años desde el pago o desde que se hizo exigible, en su caso.

**4) Contra quien puede entablarse:** contra el deudor. Si son varios:

1. Obligación simplemente conjunta: a cada uno por su cuota.
2. Obligación solidaria (Art. 2372 CC):
  - a. Si los afianzó a todos: puede pedir el total a cualquiera.
  - b. Si afianzó a uno: puede pedir el total a ese.

### **3. ACCIÓN SUBROGATORIA**

**1) Concepto:** de acuerdo al Art. 1610 N° 3 CC, se opera la subrogación legal en favor del que paga una deuda ajena a la que está obligado subsidiariamente. Tiene la ventaja de gozar de las garantías que tenía el acreedor, pero tiene alcance más restringido que la de reembolso (no incluye intereses, gastos ni perjuicios).

**2) Casos en que no tiene la acción:**

- a. Fiador de una obligación natural.
- b. Fiador que pagó sin dar aviso al deudor, que a su vez paga.

**3) Contra quién se dirige la acción:** deudor principal, codeudores solidarios o cofiadores.

**4) Acción del fiador contra su mandante:** el que se obliga por encargo de un tercero, dispone de una tercera acción, contra el tercero por cuyo encargo se constituyó fiador (Art. 2371 CC).

### **8.9 EFECTOS DE LA FIANZA ENTRE LOS COFIADORES.**

La deuda se divide entre ellos, de pleno derecho, en partes iguales, salvo en caso de insolvencia de un cofiador, o cuando se ha limitado la responsabilidad a una suma determinada.

El cofiador que paga más de lo que corresponde se subroga por el exceso en los derechos del acreedor contra los cofiadores (Art. 2378 CC). En cuanto a su cuota, puede obtener el reintegro del deudor principal.

Los cofiadores pueden oponerse, entre sí, las excepciones reales y las suyas personales (Art. 2379 CC).

## **8.10 EXTINCIÓN DE LA FIANZA.**

### **POR VÍA CONSECUCIONAL:**

De acuerdo al Art. 2381 N° 3 CC, la fianza se extingue por la extinción de la obligación principal. Sólo la nulidad por relativa incapacidad del deudor deja subsistente la fianza.

### **POR VÍA PRINCIPAL:**

**1. De acuerdo al Art. 2381 CC, se extingue por los mismos medios que las otras obligaciones, según las reglas generales.** Precisiones:

- i. La dación en pago extingue irrevocablemente la fianza, aunque después sobrevenga evicción el objeto (Art. 2382 CC).
- ii. Se extingue por confusión de las calidades de acreedor y fiador, o de deudor y fiador (Art. 2383 CC).

**2. Modos peculiares (Art. 2381 CC):**

- i. Relevos de la fianza, en todo o parte, concedido por el acreedor (N° 1).
- ii. Cuando el acreedor, por hecho o culpa suya, ha perdido las acciones en que el fiador tenía derecho a subrogarse (N° 2).

## CONTRATOS REALES

---

### 1. Clasificación del contrato según su perfeccionamiento.

Del artículo 1443 del Código Civil se desprende que los contratos, desde el punto de vista de su perfeccionamiento, pueden clasificarse en contratos consensuales, solemnes o reales.

Art. 1443 CC. "El contrato es **real** cuando, para que sea perfecto, es necesaria la tradición de la cosa a que se refiere; es **solemne**, cuando está sujeto a la observancia de ciertas formalidades especiales, de manera que sin ellas no produce ningún efecto civil; y es **consensual**, cuando se perfecciona por el solo consentimiento".

Son contratos reales aquellos para cuya formación se exige la entrega de la cosa sobre la que versa el acto jurídico. Sin entrega no hay contrato. No hay que confundir esta entrega, que integra la fase del nacimiento del contrato con la entrega que integra la fase del cumplimiento del contrato.

### 2. Elemento característico de los contratos reales.

Lo que caracteriza esencialmente al contrato real es la imprescindible entrega con la cual nace el contrato y, quien entrega la cosa, se constituye en acreedor de la típica obligación restitutoria que nace en estos casos. Quien recibe la cosa es el deudor de esta obligación

Tratándose del depósito, del comodato, de la prenda civil y de la anticresis, la entrega efectuada constituye al que la recibe en mero tenedor, por la cual queda obligado a restituir la misma especie. Por el contrario, en el caso del mutuo, quien recibe la cosa se transforma en poseedor y/o dueño puesto que el mutuo constituye un título traslativo de dominio, y el mutuuario queda obligado a restituir otro tanto del mismo género y calidad.

### 3. Crítica al art. 1443 CC.

De lo señalado se puede deducir que la redacción utilizada por el artículo 1443 del Código Civil no es del todo precisa (al decir que "El contrato es real cuando, para que sea perfecto, es necesaria la tradición de la cosa a que se refiere"), pues la entrega de la cosa no siempre constituirá tradición sino tan sólo tratándose del mutuo.

### 4. Debate doctrinario.

El contrato real es de origen romano y actualmente se ha discutido la mantención

de la categoría como tal. Se ha propuesto transformar los contratos reales, que son unilaterales, en contratos consensuales bilaterales. Así, la entrega dejaría de estar integrada a la fase del nacimiento del contrato para pasar a integrar la fase del cumplimiento del contrato. De este modo, el dueño o comodante o mutuante quedaría obligado a entregar la cosa tan pronto haya accedido a su entrega con el comodatario o mutuuario, esto es, una vez que se ha formado el consentimiento.

Nuestra legislación ha hecho eco de esta corriente a propósito del mutuo cuando constituye una operación de crédito de dinero (artículo 1º de la Ley 18.010), reglándolo como contrato consensual bilateral.

Por otra parte y desde otro punto de vista, puede discutirse la posición anterior pues, siendo los contratos reales esencialmente gratuitos, no reportan en principio beneficio alguno para el que entrega la cosa sino tan sólo para el usuario. Si el contrato es consensual, el dueño no podría abstenerse a entregar la cosa puesto que ha quedado obligado por el mero hecho de otorgar su consentimiento y se verá privado del uso de la cosa que es de su dominio aún cuando ya no desee beneficiar a su contraparte con el préstamo. Por otra parte, si el contrato es real, el dueño siempre podrá retractarse y no entregar la cosa, naciendo el contrato pues, cuando la cosa haya sido entregada.

## CAPÍTULO 9. COMODATO

### 9.1. GENERALIDADES

#### 1. Concepto.

Art. 2174 inc. 1º CC. "El *comodato* o *préstamo de uso* es un contrato en que una de las partes entrega a la otra gratuitamente una especie, mueble o raíz, para que haga uso de ella, y con cargo de restituir la misma especie después de terminado el uso."

#### 2. Características

**1. Unilateral.** Sólo el comodatario se obliga: a restituir la cosa. La entrega de la cosa no es obligación sino forma de perfeccionarse del contrato.

**2. Gratuito.** Es de la esencia del comodato.

**3. Principal.**

**4. Real:** Art. 2174 inc. 2º CC. "Este contrato no se perfecciona sino por la tradición de la cosa."

**5. Título de mera tenencia:** el comodante conserva el dominio y la posesión de la cosa.

#### 3. Cosas que pueden ser objeto de comodato.

Deben ser cosas no fungibles, porque debe restituirse la misma. Puede ser mueble o raíz.

El comodato sobre cosa ajena es válido pero inoponible al dueño, que puede reclamar la cosa. El comodatario no tiene acción contra el comodante (Art. 2188 CC).

#### 4. Prueba del comodato.

El comodato puede probarse por cualquier medio. No rigen las limitaciones a la prueba testimonial (Art. 2175 CC).

### 9.2. EFECTOS DEL COMODATO.

#### 1. OBLIGACIONES DEL COMODATARIO:

**1) Conservar la cosa:** Responde de culpa levísima (Art. 2178 CC) aunque puede responder de otra clase de culpa (Art. 2179 CC). No es responsable de deterioro cuando:

- i) Proviene de la naturaleza de la cosa o de su uso legítimo.
- ii) Proviene del caso fortuito. Excepciones (Art. 2178 CC):
  - a. Cuando se hace expresamente cargo del caso fortuito.
  - b. Cuando el caso fortuito ha sobrevenido por culpa suya.
  - c. Cuando ha empleado indebidamente la cosa o se ha constituido en mora de restituir.

d. Cuando en un accidente prefiere salvar las cosas propias que la prestada.

## **2) Usar la cosa en los términos convenidos o según su uso ordinario.**

### **3) Restituir la cosa prestada:**

En la época estipulada o después de haber hecho su uso convenido.

El comodante excepcionalmente puede reclamar anticipadamente la restitución:

- i) Si muere el comodatario.
- ii) Si le sobreviene una necesidad imprevista y urgente de la cosa.
- iii) Si el comodatario hace uso indebido de la cosa.

El comodatario puede negarse a restituir:

1. Para la seguridad de las indemnizaciones que le deban (derecho legal de retención, Art. 2193 CC).
2. Cuando la cosa se embargue en su poder por orden judicial (Art. 2183 CC).
3. Caso que la cosa haya sido hurtada, perdida o robada, el comodatario debe denunciarlo a su propietario, sino le avisa se hace responsable de los perjuicios (Art. 2183 CC).
4. Armas ofensivas u otras cosas de las cuales se sepa se trata de hacer un uso criminal, deberá ponerlas en disposición del juez (Art. 2184 CC).
5. Cuando el comodante ha perdido la razón y carece de curador (Art. 2184 CC).
6. Cuando el comodatario descubre que era el verdadero dueño de la cosa (Art. 2185 CC).

La restitución debe hacerse al comodante o a la persona que tenga derecho a recibirla. Si la cosa la prestó un incapaz, con permiso de su representante, se le puede devolver al incapaz (Art. 2181 CC).

El comodante goza de dos acciones para exigir la restitución:

- La acción de restitución propia del comodato, que es un acción personal y, por lo mismo, sólo puede entablarse e contra del comodatario.
- La acción reivindicatoria (siempre que el comodante sea el dueño de la cosa prestada), que es una acción real y, por lo mismo, puede ejercerla en contra de cualquier persona. Cuando la cosa haya salido del poder del comodatario y haya pasado a terceras personas, la acción reivindicatoria será la única acción que podrá ejercer el comodante.

Finalmente, cabe señalar que si los comodatarios son muchos y al ser la obligación de restituir una obligación indivisible (artículo 1526 No. 2), la cosa podrá reclamarse en manos de aquel de los comodatarios que la detente.

## **2. OBLIGACIONES DEL COMODANTE:**

**1) Pagar las expensas de conservación de la cosa:** si han sido de carácter extraordinario y, además, necesarias y urgentes (Art. 2191 CC).



**2) Indemnizar perjuicios que le haya causado al comodatario la mala calidad o condición de la cosa, la que debe reunir las siguientes condiciones**

(Art. 2193 CC):

1. Que haya sido conocida esta calidad y no declarada por el comodante.
2. Que sea de tal naturaleza que fuera probable que ocasionare perjuicios.
3. Que el comodatario con mediano cuidado no haya podido conocerlo o precaver los perjuicios.

**9.3. COMODATO PRECARIO.**

Constituye precario:

- El comodante puede en cualquier tiempo recobrar la cosa (Art. 2194 CC).
- También cuando no se presta la cosa para un servicio particular ni se fija un tiempo para la restitución (Art. 2195 inc. 1º CC).
- También constituye precario el goce gratuito de cosa ajena sin ningún título que lo legitime, tolerado por el dueño o que se verifica por ignorancia del dueño (Art. 2195 inc. 2º CC)<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> Esta figura se analiza en detalle en el apunte de bienes.

## CAPÍTULO 10. MUTUO

### 10.1 GENERALIDADES.

#### 1. Concepto.

Art. 2196 CC: "El *mutuo o préstamo de consumo* es un contrato en que una de las partes entrega a la otra cierta cantidad de cosas fungibles con cargo de restituir otras tantas del mismo género y calidad".

#### 2. Partes.

Las partes que intervienen se denominan mutuante y mutuario.

#### 3. Características.

**1. Es un contrato unilateral:** pues impone tan sólo obligaciones al mutuario. El mutuario se obliga a restituir tantas cosas del mismo género y calidad de las que recibió en préstamo. El mutuante no contrae obligación alguna.

**2. Es un contrato naturalmente gratuito** según las normas del Código Civil, pero es un contrato naturalmente oneroso cuando constituye una operación de crédito de dinero. Para el Código Civil, la obligación de pagar intereses en el mutuo puede pactarse, pero requiere de estipulación expresa.

Si nada se dice, el mutuo no devengará intereses.

Cuando el mutuo constituye una operación de crédito de dinero, entran a regir las normas de la Ley 18.010, y del artículo 12 de la misma se desprende que el mutuo es un contrato naturalmente oneroso: si nada se dice se deberán los intereses corrientes.<sup>4</sup>

**3. Es un contrato principal.**

**4. Es un contrato real:** pues se perfecciona por la entrega de la cosa por el mutante al mutuario.

En el caso del mutuo, la entrega constituye tradición.

Art. 2197 CC. "No se perfecciona el contrato de mutuo sino por la tradición, y la tradición transfiere dominio".

La tradición puede verificarse por cualquiera de los modos señalados en el artículo 684.

A este respecto, cabe señalar que cuando el mutuo constituye una operación de crédito de dinero, el contrato podría ser consensual (artículo 1º de la Ley 18.010).

---

<sup>4</sup> Ver anexo al final.

**5. El mutuo constituye un título traslativo de dominio:** el mutante se desprende del dominio de la cosa prestada y el mutuuario se hace dueño de la misma. Por lo mismo, la entrega necesaria para que el contrato se perfeccione importa en el caso del mutuo una verdadera tradición que transfiere el dominio (artículo 2197).

## **10.2 REQUISITOS DEL MUTUO.**

### **1. Cosas susceptibles de darse en mutuo.**

Debe tratarse de cosas FUNGIBLES, que son aquellas que presentan una relación de equivalencia con otras de su mismo género por lo que poseen el mismo valor liberatorio.

Dado que el mutuuario debe restituir otras tantas cosas de igual género y calidad, es lógico que una cosa, para ser susceptible de ser dada en mutuo, deba poder reemplazarse libremente con otra cosa.

### **2. Calidades de las partes en el mutuo.**

El mutuante debe ser capaz de enajenar y dueño de las cosas dadas en mutuo.

- Si el mutuante es incapaz de enajenar, el contrato adolecerá de un vicio de nulidad.
- Y si no es dueño, el mutuo no transferirá el dominio de las cosas, conservando el dominio el verdadero dueño.

Art. 2202 CC "si hubiere prestado el que no tenía derecho de enajenar, se podrán reivindicar las especies, mientras conste su identidad".

Desaparecida la identidad, se hace imposible el ejercicio de la acción reivindicatoria y se aplicará la norma prevista en el artículo 2202 inciso 2º.

El mutuuario debe ser capaz de obligarse, so pena de nulidad del contrato de mutuo.

## **10.3 EFECTOS DEL CONTRATO DE MUTUO.**

### **1. OBLIGACIONES DEL MUTUARIO.**

El mutuuario asume la única obligación de restituir otras tantas cosas de igual género y calidad. Para determinar la forma en que debe efectuarse la restitución, es preciso distinguir si las cosas dadas en mutuo consisten en dinero o en otras cosas fungibles:

#### **1. Mutuo de dinero:**

Se aplican las normas de la Ley 18.010 y no las del Código Civil.

Antiguamente, se aplicaba el artículo 2199 del Código Civil que disponía que debía restituirse la misma suma prestada (criterio nominalista del Código). Dicha regla fue derogada en 1974 por el D.L. 455 que reguló hasta 1981 las operaciones de crédito

de dinero.

Actualmente rige la Ley 18.010 de 27 de Junio de 1981, y la restitución de la cantidad prestada se rige por las siguientes reglas:

Artículo 1º: "Son operaciones de crédito de dinero aquellas por las cuales una de las partes entrega o se obliga a entregar una cantidad de dinero y la otra a pagarla en un momento distinto a aquel en que se celebra la convención." Como dice la norma citada, una de las partes entrega o se obliga a entregar una cantidad de dinero, con lo cual se desprende que el contrato podría ser real o consensual.

Artículo 12: "La gratuidad no se presume en las operaciones de crédito de dinero. Salvo disposiciones de la ley o pacto en contrario, ellas devengan intereses corrientes, calculados sobre el capital o sobre capital reajustado, en su caso". El interés corriente se encuentra regulado por el art. 6º de la misma ley: "interés corriente es el interés promedio cobrado por los Bancos y las sociedades financieras establecidos en Chile en las operaciones que realicen en el país".

Artículo 2º: en las operaciones de crédito de dinero no reajustables, constituye interés toda suma que recibe o tiene derecho a recibir el acreedor, a cualquier título, por sobre el capital.

En las operaciones de crédito de dinero reajustables, constituye interés toda suma que recibe o tiene derecho a recibir el acreedor, a cualquier título, por sobre el capital reajustado.

Artículo 3º: puede pactarse cualquier forma de reajuste (desde 1989 pues antes sólo podía pactarse en UF).

Artículo 6º inciso final: define el máximo interés convencional. Dice la norma que "No podrá estipularse un interés que exceda el producto del capital respectivo y la cifra mayor entre: 1) 1,5 veces la tasa de interés corriente que rija al momento de la convención, según determine la Superintendencia para cada tipo de operación de crédito de dinero, y 2) la tasa de interés corriente que rija al momento de la convención incrementada en 2 puntos porcentuales anuales, ya sea que se pacte tasa fija o variable. Este límite de interés se denomina interés máximo convencional."

Artículo 11: sólo pueden pactarse intereses en dinero. Además, la norma establece que los intereses se devengan por día.

## **2. Mutuo de cosas fungibles distintas de dinero:**

Rigen las normas del Código Civil.

Según el artículo 2198, deben restituirse igual cantidad de cosas de igual género y calidad. Si no es posible, deberá pagarse lo que valgan las cosas al tiempo en que deba hacerse el pago (se paga su equivalente en dinero).

### **Época en que debe hacerse la restitución:**

La obligación del mutuario es siempre una obligación a plazo. Siempre ha de mediar un tiempo entre la entrega y la restitución.

El tiempo de restitución puede ser fijado por la convención de las partes o por la ley:

- Si se trata de cosas fungibles que no sean dinero (aplicándose en consecuencia las reglas del Código Civil): la restitución debe hacerse en la época estipulada. Si no se hubiere fijado un término, en ningún caso podrá exigirse la restitución dentro de los diez días subsiguientes a la entrega (artículo 2200).  
Finalmente, si se hubiere pactado que el mutuario pague cuando le sea posible, podrá el juez, atendidas las circunstancias, fijar un término (artículo 2201).
- Si se trata de dinero (aplicándose en consecuencia las reglas de la Ley 18.010): la restitución debe hacerse en la época estipulada. Si no se hubiere fijado un término, sólo podrá exigirse el pago después de diez días contados desde la entrega, salvo que se trate de documentos u obligaciones a la vista o pagaderos a su presentación (artículo 13).
- El retardo en el cumplimiento da lugar a la sanción prevista en el artículo 16.
- **¿Puede anticiparse el pago?** Según el artículo 2204 es posible siempre que no se hayan pactado intereses. Ello, por cuanto si se ha pactado interés, el plazo en el mutuo es un beneficio establecido en favor de ambas partes.
- El interés se define como "el provecho o remuneración que obtiene el mutuante como precio del capital entregado al mutuario". Son, jurídicamente, frutos civiles de la cosa prestada (artículo 647) y se devengan según el tiempo que se haya pactado el préstamo. De este modo, si se anticipa el pago, la cantidad de intereses será menor y, por lo mismo, la anticipación perjudicaría los intereses del mutuante.

Ahora bien, la anticipación en el pago para la Ley 18.010 es un derecho irrenunciable del mutuario, pero debe efectuarse en los términos señalados en el artículo 10 Ley 18.010.

Hay que distinguir:

- En las operaciones de crédito de dinero no reajustables debe pagar el capital nominal más todos los intereses del capital estipulado hasta el final del plazo, es decir como si hubiera corrido todo el plazo.
- En las operaciones de crédito de dinero reajustables debe pagarse todo el capital reajustado hasta el día del pago efectivo más los intereses estipulados que corren hasta el final del plazo o por todo el término pactado.

El anatocismo es el interés de los intereses. En otras palabras, los intereses se capitalizan o agregan al capital para producir, a su turno, nuevos intereses.

Antiguamente, el artículo 2210 del Código Civil lo prohibía. Hoy, dicha norma fue derogada por la Ley 18.010: el artículo 9° lo permite expresamente y señala la forma en que debe hacerse. (Tiene la limitante que la capitalización de estos intereses debe producirse en términos que no sean inferiores a 30 días (solo se puede capitalizar cada 30 días)).

## **2. OBLIGACIONES DEL MUTUANTE.**

En principio, el mutuante no queda sujeto a obligación alguna. Eventualmente, podría verse obligado a indemnizar al mutuario si se producen daños por la mala calidad de las cosas dadas en mutuo (artículo 2203, el cual se remite al artículo 2192 dentro de las reglas del comodato).

## CAPÍTULO 11. DEPÓSITO

### 11.1 GENERALIDADES

#### 1. Concepto.

Art. 2211 CC. "Llámase en general *depósito* el contrato en que se confía una cosa corporal a una persona que se encarga de guardarla y de restituirla en especie."

#### 2. Características

1. **Unilateral:** sólo se obliga el depositario, a restituir la cosa.

2. **Real:** Art. 2212 CC. "El contrato se perfecciona por la entrega que el depositante hace de la cosa al depositario."

### 11.2 CLASIFICACIONES.

#### a) Depósito propiamente tal:

- 1) Voluntario.
- 2) Necesario.

#### b) Secuestro:

- 1) Convencional.
- 2) Judicial.

### 11.3 DEPÓSITO VOLUNTARIO.

#### 1. Concepto.

Art. 2215 CC. "El *depósito propiamente dicho* es un contrato en que una de las partes entrega a la otra una cosa corporal y mueble para que la guarde y la restituya en especie a voluntad del depositante."

#### 2. Objeto del depósito.

Debe ser un bien corporal y mueble.

#### 3. Capacidad (Art. 2218 CC):

Se requiere la capacidad general pero:

1) Si el depositante es incapaz, el contrato adolece de nulidad pero ésta sólo aprovecha a éste. El depositario contrae válidamente las obligaciones de tal.

**2) Si el depositario es incapaz, el depositante puede:**

- i. Reclamar la cosa depositada mientras esté en poder del depositario.
- ii. Si el depositario la enajenó, sólo tiene acción en su contra en cuanto se hubiese hecho más rico.
- iii. Reivindicarla de terceros poseedores.

**4. Error en el depósito voluntario.**

Sólo produce consecuencias el error del depositario acerca del depositante, o el descubrimiento de que la cosa acarrea peligro, permiten restituir inmediatamente el depósito (Art. 2216 CC).

**5. Prueba en el depósito voluntario.**

Si la cosa es de un valor mayor a 2 UT deberá constar por escrito, la omisión hace inadmisibles la prueba testimonial y será creído el depositario (Art. 2217 CC).

**6. Obligaciones del depositario.**

**1) Guardar la cosa:**

1. Es responsable de culpa grave o lata. Será responsable de culpa leve si se ha ofrecido espontáneamente y si tiene interés personal en el depósito. Responderá de culpa levísima sólo con estipulación expresa (Art. 2222 CC).
2. El depositario no tiene derecho a usar la cosa sin el consentimiento del depositante (Art. 2220 CC). El permiso puede ser expreso o presunto.
3. Debe respetar los sellos y cerraduras del bulto que la contiene. Si se rompen con culpa, se estará a la declaración del depositante acerca de la cantidad y calidad de la cosa depositada; si se rompen sin culpa, debe probarse (Arts. 2223 y 2224 CC).
4. El depositario no podrá violar el secreto de un depósito de confianza, ni podrá ser obligado a revelarlo (Art. 2225 CC).

**2) Restituir el depósito:**

**1. Forma de la restitución:**

- a. Debe restituirse en su idéntica individualidad, en especie, aunque sea genérica o fungible (Art. 2228 CC).
- b. Debe restituirse con sus accesorios, acciones y frutos (Art. 2229 CC).
- c. El depositario paga los gastos de transporte (Art. 2232 CC).
- d. No responde el depositario por el caso fortuito, pero si por esto recibe un precio, debe restituirlo al depositante (Art. 2230 CC).
- e. La obligación de restituir pasa a los herederos (Art. 2231 CC).

**2. Tiempo de la restitución:**

- A voluntad del depositante, cuando éste la reclame.
- Si se estipula un plazo, éste obliga sólo al depositario, quien no puede restituir antes (Art. 2226 CC).
- Vencido el plazo o cuando la cosa peligre o le cause perjuicios, el depositario



podrá exigir al depositante que disponga de la cosa (Art. 2227 CC).

1. Demás aspectos de la restitución: se rigen por las normas del comodato.

❖ En el depósito irregular, el depositario debe restituir otras del mismo género y calidad. Si se trata de dinero, y no se entrega con precauciones que hagan imposible tomarlo, se presume que el depositario puede usarlo (Art. 2221 CC).

## **7. Obligaciones del depositante.**

Puede resultar obligado a pagar los gastos de conservación y los perjuicios (Art. 2235 CC). Para garantizar el pago de estas obligaciones, el depositario tiene derecho de retención.

### **11.4 DEPÓSITO NECESARIO.**

#### **1. Concepto.**

Art. 2236 CC. "El depósito propiamente dicho se llama *necesario*, cuando la elección de depositario no depende de la libre voluntad del depositante, como en el caso de un incendio, ruina, saqueo, u otra calamidad semejante."

La elección está impuesta por las circunstancias.

#### **2. Peculiaridades**

Está sujeto a las mismas reglas del voluntario, pero hay reglas especiales (Art. 2240 CC):

- 1) La premura con la que se hace imposibilita al demandante para procurarse una prueba escrita, por lo que no se aplican las limitaciones de la prueba testimonial (Art. 2237 CC).
- 2) La responsabilidad del depositario se extiende hasta la culpa leve (Art. 2239 CC).

#### **3. Depósito necesario del que se hace cargo un incapaz.**

La precipitación impide al depositante cerciorarse de la capacidad. Por esto, constituye un cuasicontrato que obliga al depositario sin la autorización de su representante legal (Art. 2238 CC).

#### **4. Depósito de efectos en hoteles y posadas.**

Se asimila al depósito necesario (Art. 2241 CC).

### **11.5 SECUESTRO.**

#### **1. Concepto.**

Art. 2249 CC. "El *secuestro* es el depósito de una cosa que se disputan dos o más individuos, en manos de otro que debe restituirla al que obtenga una decisión a su favor.  
El depositario se llama *secuestre*."

#### **2. Clases de secuestro (Art. 2252 CC).**

- 1) Convencional: se constituye por acuerdo de voluntad de las personas que disputan el objeto litigioso.
- 2) Secuestro judicial: se constituye por decreto del juez.

#### **3. Diferencias entre secuestro y depósito.**

1. Objeto del depósito.
  - El depósito recae sobre muebles,
  - el secuestro puede recaer sobre muebles e inmuebles (Art. 2251 CC).
  -
2. Restitución.
  - En el depósito, el depositario restituye a voluntad del depositante.
  - El secuestre no puede restituir la cosa mientras no recaiga sentencia de adjudicación o por voluntad unánime de las partes si fuese convencional (Art. 2256 CC).
3. A quién se restituye.
  - El depositario debe restituir al depositante o a quien tenga derecho a recibir en su nombre.
  - Dictada la sentencia, el secuestre debe restituir al adjudicatario (Art. 2257 CC).

#### **4. Derechos y facultades del secuestre.**

- 1) En caso de perder la tenencia, puede reclamarla contra toda persona (Art. 2254 CC).
- 2) El secuestre de un inmueble tiene relativamente a su administración las facultades y deberes de un mandatario y debe dar cuenta (Art. 2255 CC).

### **11.5.1 SECUESTRO JUDICIAL.**

El demandante, en cualquier estado del juicio, aún cuando no esté contestada la demanda, puede solicitar el secuestro de la cosa que es objeto de la demanda, para asegurar el resultado de la acción (Art. 290 CPC). Procede cuando:

- a)** Se reivindica una cosa corporal mueble y hubiere motivo de temer que se pierda o deteriore en manos del poseedor.

**b)** Se entablan acciones con relación a una cosa mueble determinada y existan motivos de temer que se pierda en manos del tenedor.

- El secuestro judicial recae sólo sobre muebles.
- El secuestre tiene la administración de los bienes secuestrados y podrá venderlos con autorización judicial si son susceptibles de deterioro o su conservación es difícil.
- Cesado el cargo de secuestre deberá rendir cuenta.
- El secuestre tiene derecho a remuneración que fijará el juez.

## CAPÍTULO 12 ARRENDAMIENTO

### 12.1. GENERALIDADES

Se encuentra regulado en los artículos 1915 y siguientes del Código Civil. Es una de las figuras más reglamentadas del Código y de las que tiene mayor aplicación práctica. También se encuentra regulada por leyes especiales:

- Ley 18.101, sobre arrendamiento de predios urbanos.
- D.L. 993, sobre arrendamiento de predios rústicos.

#### 1. Concepto

Art. 1915 CC "El *arrendamiento* es un contrato en las dos partes se obligan recíprocamente, la una a conceder el goce de una cosa o a ejecutar una obra o prestar un servicio, y la otra a pagar por este goce, obra o servicio un precio determinado."

Del anterior concepto se desprende que existen 3 categorías de arrendamiento:

- de cosas
- de servicios
- de confección de obra material

A su vez, el arrendamiento de cosas puede ser de inmuebles o muebles, y si es de inmuebles, de predios rústicos o urbanos. De estas tres especies de arrendamiento se ocupa el Título XXVI del Libro IV del Código Civil.

#### 2. Partes que intervienen

1. Arrendador: proporciona el goce.
2. Arrendatario: a quien se le confiere el goce pagando un precio. Tratándose del arrendamiento de:
  - Predios urbanos se le denomina "inquilino"
  - Predios rústicos "colono" o "aparcero"
  - y si se paga la renta con parte de los frutos que la cosa produce, se denomina "colono aparcero".

#### 3. Requisitos esenciales

1. **Consentimiento:** lo señala la doctrina
2. Que una de las partes se obligue a **proporcionar el goce temporal** de una cosa, a ejecutar una obra o a prestar un servicio.
3. Que el arrendatario se obligue a **pagar un precio** por esta cosa, obra o servicio. En materia de arriendo el precio se denomina "renta".

## 12.2 CARACTERÍSTICAS.

**1. Es un contrato bilateral**

**2. Oneroso**

**3. Conmutativo**

**4. Principal**

**5. Nominado**

**6. Principal**

**7. De tracto sucesivo:** implica que las obligaciones se van renovando y cumpliendo y extinguiendo sucesivamente en forma periódica. Como consecuencia de lo anterior se deriva que en el arrendamiento no existe resolución sino TERMINACIÓN, no cabe la teoría de los riesgos pereciendo la cosa para su dueño, puede operar la teoría de la imprevisión (que jamás puede darse en los contratos de ejecución instantánea).

**8. Título de mera tenencia:** por el contrato de arrendamiento el arrendatario se constituye en mero tenedor, pues el arrendador sigue siendo el propietario y poseedor. El arrendatario reconoce el dominio ajeno por lo cual no lo habilita para adquirir la cosa por prescripción.

**9. El arrendamiento constituye un acto de administración y no de disposición:** pues no implica enajenación. Por ello, dentro de las facultades propias de un mandatario con poder general, se encuentra la de arrendar un bien del mandante (Cabrá dentro de la enumeración del artículo 2132). No obstante ser el arrendamiento un acto de administración, hay ocasiones en que el arrendamiento dura mucho tiempo y constituye un principio de enajenación (aunque por cierto no lo es!). El legislador, luego, establece trabas para arrendar por largo tiempo bienes de personas incapaces y de bienes de la sociedad conyugal (artículos 256, 407, 1749). Son normas prohibitivas que se establecen en consideración al estado o calidad de las partes, por lo que su contravención normalmente acarrearía nulidad relativa. No obstante, el legislador ha previsto para estos casos una sanción especial: la inoponibilidad del contrato en el exceso del tiempo.

**10. Es un contrato consensual,** aún cuando recaiga sobre bienes raíces: no obstante, se le aplica las limitaciones sobre la admisibilidad de la prueba testimonial (arts. 1708 y 1709). Por otra parte, puede resultar conveniente reducirlo a escritura pública e inscribirlo en el Conservador de Bienes Raíces para los efectos de lo dispuesto por el art. 1962. También las partes pueden estipular la escrituración como una formalidad o solemnidad convencional (art. 1921).

### 12.3 SIMILITUD DEL ARRENDAMIENTO CON OTRAS FIGURAS.

1. Usufructo
2. Comodato
3. Compraventa
4. Mandato

#### **1. Usufructo:**

En ambos, usufrutuario y arrendatario tienen el goce de la cosa, pero el usufructo constituye un derecho real de goce y el arrendamiento un derecho personal de goce. Por otra parte, el usufructo puede tener su origen de muchas formas y no sólo de la voluntad de las partes (testamento, prescripción, sentencia judicial, la ley). El arrendamiento sólo tiene su origen en la voluntad común de las partes que lo acuerdan.

- Semejanzas: ambas constituyen un derecho de goce.
- Diferencias: en cuanto a la naturaleza del derecho de goce (derecho real o personal) y en cuanto a su origen o fuente.

#### **2. Comodato:**

- Semejanzas: En ambos, el arrendatario y comodatario tiene el uso y goce y ambos constituyen derechos personales.
- Diferencias: el comodato es esencialmente gratuito, es unilateral y es un contrato real (se perfecciona por la entrega de la cosa). Por otra parte, el arrendamiento es oneroso, bilateral y consensual.

#### **3. Compraventa:**

- Semejanzas: Ambos, arrendador y vendedor están obligados a entregar la cosa (son contratos consensuales), están obligados a pagar el precio el arrendatario y comprador, y ambos contratos son bilaterales, consensuales, onerosos, conmutativos, principales y nominados.
- Diferencias: la compraventa constituye un título traslativo de dominio (transforma al comprador en dueño o al menos en poseedor) y el arrendamiento constituye un título de mera tenencia.

El arrendamiento, después de la compraventa es el segundo contrato de importancia práctica, pues existe un interés social comprometido y por ello se ha dado la figura del dirigismo contractual en el arrendamiento.

#### 4. Mandato:

- Puede existir similitud entre el mandato y el arrendamiento de servicios inmateriales. Es más, existen normas comunes que se le aplican a ambos contratos en virtud de lo dispuesto por el Art. 2012 CC.
- Pero la diferencia está dada principalmente en el objeto de uno y otro porque el mandato recae sobre la realización de actos jurídicos y puede envolver la noción de representación. El arrendamiento de servicios inmateriales jamás dice relación con actos jurídicos y nada tiene que ver con la representación.

#### 12.4 ARRENDAMIENTO DE COSAS.

Está regulado de los artículos 1916 y siguientes del CC y se define como aquel contrato en virtud del cual una de las partes denominada arrendador proporciona a otra denominada arrendatario el goce de una cosa, quien paga por ella un precio determinado. Es ésta una de las materias donde el legislador se remite a la costumbre.

Sus elementos constitutivos esenciales son el precio o renta que se paga por el goce, el consentimiento y la cosa cuyo goce se otorga.

De acuerdo a las reglas generales, la cosa debe ser real, determinada y susceptible de darse en arrendamiento: el arrendamiento puede recaer sobre todo tipo de cosas corporales e incorporeales, salvo que la ley lo prohíba o que se trate de derechos personalísimos (uso, habitación, etc.) Luego, puede arrendarse un derecho real o un derecho personal. Si puede venderse un derecho, bien puede ser arrendado. Por otra parte y al igual que en la compraventa, también puede arrendarse una cosa ajena sin perjuicio de los derechos del dueño. Si el dueño alega su derecho se da una especie de evicción (lo dice expresamente el art. 1916 inc. 2º).

El art. 1916 trata de las cosas susceptibles de arrendarse y debe tratarse de cosas que puedan usarse sin consumirse (relacionar con usufructo y cuasiusufructo). Es de la esencia del contrato de arrendamiento que el arrendatario restituya la cosa al arrendador al terminar el contrato.

Respecto del precio (art. 1917) que se denomina "renta", éste puede estipularse en dinero o en frutos.

- Si el precio se estipula en frutos se da una aparcería o mediería (arrendamiento de predios rústicos), en el cual se estipula que el precio se paga con una cantidad de frutos o con una cuota o proporción de ellos.
- El precio se estipula igual que en la compraventa: por acuerdo de las partes o por la determinación de un tercero (artículo 1918 en relación a artículos 1808 y 1809).

### 12.4.1 EFECTOS DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE COSAS.

#### **A) OBLIGACIONES DEL ARRENDADOR.**

La obligación principal es la de **proporcionar el goce pacífico de la cosa arrendada**. Esta obligación se descompone en tres obligaciones específicas (art. 1924):

##### **1. OBLIGACIÓN DE ENTREGAR LA COSA AL ARRENDATARIO**

Es la obligación principal y es de la esencia del contrato de arrendamiento. Las otras dos obligaciones son de la naturaleza del contrato.

Constituye simple entrega y no tradición, pues el arrendamiento es un título de mera tenencia y no traslativo de dominio.

La entrega se hace según lo dispone el art. 1920 (según las formas de tradición, pero ello sólo es aplicable a las cosas muebles y no inmuebles pues no es necesario efectuar la inscripción para que haya entrega).

Si no se entrega la cosa, el artículo 1925 repite la idea del art. 1489 CC: hay cumplimiento forzado o resolución. En este caso hay resolución y no terminación pues el contrato aún no empezado a cumplirse y puede dejarse sin efecto.

##### **2. OBLIGACIÓN DE MANTENER LA COSA EN UN ESTADO ÚTIL**

De manera que sirva para el fin que ha sido arrendado.

Durante el arrendamiento, el arrendador debe efectuar todas las reparaciones necesarias.

Aquí es importante referirse a las mejoras que pueden hacerse en la cosa arrendada:

- **Necesarias:** aquellas que sin las cuales la cosa se destruye o desaparece o bien no sirve para el objeto a que se le destina. corresponden al arrendador, como los arreglos de cañerías, por goteras, etc. (art. 1927). Se excepcionan las locativas que son un tipo de mejoras necesarias pero corresponden al arrendatario. Ver art. 1935.
- **Útiles:** el arrendador no está obligado a reembolsar los gastos por la mejoras útiles introducidas a la cosa arrendada salvo que así lo hubiesen pactado (art. 1936).
- **Voluptuarias:** jamás se reembolsan.
- **Locativas (art. 1940):** son aquellas que por la costumbre del lugar corresponden al arrendatario y que en general son motivadas por la culpa, hecho o descuido del mismo arrendatario o de las personas que viven a su cargo. (ej.: vidrios rotos).

En algunos casos excepcionales las mejoras locativas corresponden al arrendador:



cuando provienen del caso fortuito o de la mala calidad de la cosa arrendada (1927).

En todos aquellos casos en que el arrendador deba al arrendatario indemnizaciones por mejoras introducidas a la cosa, la ley concede al arrendatario el derecho legal de retención de la cosa a fin de asegurar el pago de dichos gastos (art. 1937).

### **3. OBLIGACIÓN DE LIBERAR AL ARRENDATARIO DE MOLESTIAS O EMBARAZOS DE LA COSA ARRENDADA**

El arrendador no puede efectuar arreglos o modificaciones que perturben al arrendatario salvo que sean indispensables (Ej. arreglo del techo), pero:

- El arrendatario tendrá derecho a que se rebaje la renta en forma proporcional a las perturbaciones.
- Si las reparaciones recaen sobre parte importante de la cosa el arrendatario puede dar por terminado el contrato. (1928).

Si las perturbaciones derivan de actos o hechos de terceros, es preciso distinguir:

- Perturbaciones de hecho: (1930 inc. 1º) el arrendatario la perseguirá a su propio nombre.
- Perturbaciones de derecho: (1930 inc. 2º). Los artículos 1930 y 1931 contemplan un verdadero saneamiento de la evicción en el contrato de arrendamiento.
- Si la turbación sólo imposibilita parcialmente el goce de la cosa, el arrendatario puede pedir rebaja de la renta para el tiempo restante.
- Si la turbación es total puede pedir la terminación del contrato con indemnización de perjuicios en caso que el arrendador hubiere conocido la causa al tiempo del contrato. Si no la conocía, sólo debe el daño emergente y no el lucro cesante.

El arrendador también responde por los vicios que tenga la cosa y que impidan darle a la misma el uso para el cual fue arrendada (arts. 1932, 1933 y 1934).

- Si los vicios son anteriores al contrato pero no conocidos por el arrendador, el arrendatario tiene derecho a pedir la terminación del contrato y a que se le indemnice sólo el daño emergente.
- Si los vicios eran conocidos por el arrendador, éste estará además obligado a indemnizar el lucro cesante.

Si la imposibilidad en cuanto al goce que producen estos vicios es sólo parcial, el juez decidirá si ha de ponerse fin al arrendamiento o sólo conceder una rebaja de la renta.

## **B) OBLIGACIONES DEL ARRENDATARIO.**

### **1. OBLIGACIÓN DE PAGAR LA RENTA**

Es la obligación principal del contrato y resulta esencial a él dado que si esta obligación no existiere, ya no estaríamos en presencia de un contrato de arrendamiento sino que frente a un contrato de comodato.

El pago de la renta debe hacerse según cualquiera de las siguientes formas (art. 1944):

1. En la forma convenida en el contrato.
2. Si no se ha convenido, debe hacerse conforme a la costumbre del lugar.
3. A falta de costumbre, la regla es que la renta en un arrendamiento de un predio urbano se paga mese a mes y tratándose de un predio rústico, se paga por años. Un dato curioso a propósito de los predios rústicos es que el legislador en el artículo 1983 rechaza abiertamente la teoría de la imprevisión, esto es, la revisión del contrato por cambios en las circunstancias posteriores a la celebración del mismo y que hagan excesivamente onerosa la prestación del arrendatario. Se exceptúa el caso de la mediería o aparcería, esto es, aquella clase de arriendo de predio rústico en que la renta se paga con los frutos de la cosecha (art. 1983 inc. 2º).

El no pago de la renta faculta al arrendador para solicitar la terminación del contrato: cuando se pide la terminación por esta causa, la ley exige que se notifique dos veces al arrendatario y por eso se habla de la primera y de la segunda reconvención de pago. Esta doble reconvención, contemplada en el artículo 1977 es sólo aplicable a los predios urbanos. Aparece consignada más adelante en el artículo 10 de la Ley 18.101.

Finalmente, cabe decir que es perfectamente posible incorporar al contrato de arriendo un pacto comisorio por no pago de la renta.

### **2. OBLIGACIÓN DE USAR LA COSA ARRENDADA DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS CONVENIDOS EN EL CONTRATO (ARTÍCULO 1938)**

Si el contrato nada dice, se entiende que la cosa debe usarse según la costumbre del lugar o uso corriente o a aquel a que la cosa está naturalmente destinada. Consecuentemente con esta idea, el artículo 1973 establece la posibilidad de pedir la terminación del arrendamiento cuando la cosa se destina a fines ilícitos.

### **3. OBLIGACIÓN DE USAR Y GOZAR LA COSA COMO UN BUEN PADRE DE FAMILIA (ARTÍCULOS 1939 Y 1941)**

O sea, el arrendatario responde de culpa leve. Y no sólo de la culpa propia sino también de la de su familia, huéspedes y dependientes que vivan con él.

#### **4. OBLIGACIÓN DE EJECUTAR EN LA COSA LAS LLAMADAS MEJORAS O REPARACIONES LOCATIVAS (ARTÍCULO 1940)**

Ya nos referimos a ellas cuando examinamos la obligación del arrendador de mantener la cosa en un estado útil de modo que sirva para el fin para el cual fue arrendada.

El único caso en que el arrendatario no está obligado a efectuar dichas reparaciones corresponde a aquel cuando provengan del caso fortuito o fuerza mayor, o de la mala calidad de la cosa arrendada (artículo 1927 inc. 2º).

#### **5. OBLIGACIÓN DE RESTITUIR LA COSA AL TÉRMINO DEL CONTRATO**

Desde el momento en que el arrendatario es un mero tenedor de la cosa arrendada, tiene la obligación fundamental de restituir la cosa al término del contrato. Es una obligación de la esencia del contrato de arrendamiento.

Según el artículo 1947, la cosa debe restituirse en el estado en que le fue entregada, tomando en consideración el deterioro causado por el uso y goce legítimos de la cosa.

Si no constare el estado en el cual fue entregada la cosa, se entenderá que la misma ha sido recibida por el arrendatario en un regular estado de conservación. Respecto de la obligación que tiene el arrendatario de restituir la cosa arrendada, cabe recordar que la ley concede al arrendatario el derecho legal de retención (el cual debe ser judicialmente declarado para producir sus efectos) si el arrendador no le ha pagado las indemnizaciones que le deba (artículo 1937).

Cabe señalar que el artículo 1942 concede el mismo derecho al arrendador sobre los frutos existente en la cosa arrendada y demás objetos con que el arrendatario la haya amoblado, guarnecido o provisto, en caso que el arrendatario no cumpla con su obligación de pagar la renta.

#### **12.4.2. EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE COSAS.**

El arrendamiento expira por las causas generales en que expira todo contrato y por las especiales previstas en el artículo 1950 CC:

##### **i) Por la destrucción total de la cosa arrendada:**

La razón de esta causal es obvia pues la destrucción de la cosa ocasiona la falta de objeto para la obligación del arrendador y, en consecuencia, falta de causa para la obligación del arrendatario de pagar la renta.

La destrucción debe ser total: si fuera parcial, el arrendatario quedaría sometido a la decisión del juez, el cual debe determinar si atendidas las circunstancias ha de ponerse término al contrato o concederse una rebaja en el valor de la renta (artículo 1932).

La destrucción total de la cosa arrendada pone término al contrato sea que se produzca por caso fortuito o por culpa del arrendador (esto es, por el mal estado o la mala calidad de la cosa arrendada). Lo que sí varía en un caso o en el otro será la indemnización a que estaría obligado a pagar el arrendador.

**ii) Por la extinción del derecho del arrendador:**

Para determinar los efectos que se producen, es preciso distinguir si el derecho del arrendador se extingue por su hecho o culpa, o sin culpa:

- **Si se extingue sin culpa del arrendador:** como lo sería, por ejemplo, el caso en que el arrendador era propietario fiduciario, usufructuario o había pendiente alguna condición resolutoria (no la condición resolutoria tácita porque en dicho caso sería con culpa del arrendador) y se resuelve el derecho del arrendador.

La regla general es que el arrendador no responde por ello frente al arrendatario, salvo en el caso que al momento de celebrar el contrato de arrendamiento el arrendador se hubiere hecho pasar por propietario absoluto. En dicho caso, tendría que indemnizar al arrendatario (artículos 1958 y 1959).

- **Si se extingue por culpa del arrendador:** sea porque el arrendador vende la cosa arrendada o la pierde por no haber pagado el precio de la venta y opera la condición resolutoria tácita, la regla general será que el arrendador deberá indemnizar al arrendatario en todos aquellos casos en que la persona que le sucede en el derecho no esté obligada a respetar el arriendo (artículo 1961).

- La regla general es que el sucesor NO estará obligado a respetar el arriendo (por el principio del efecto relativo de los contratos), salvo en los casos del artículo 1962.

Por consiguiente, si la persona que sucede al arrendador está obligada a respetar el arriendo, no existirá responsabilidad del arrendador respecto del arrendatario porque el contrato subsiste y no se le ha causado al arrendatario perjuicio alguno.

- Están obligados a respetar el arriendo aquellos que caen en algunos de los casos que taxativamente señala el artículo 1962:

- i. Todo aquel a quien se transfiere el derecho del arrendador por un título no lucrativo (o a título gratuito)

- ii. Todo aquel a quien se transfiere el derecho del arrendador, a título oneroso, si el arrendamiento ha sido contraído por escritura pública; exceptuados los acreedores hipotecarios.

- iii. Los acreedores hipotecarios, si el arrendamiento ha sido otorgado por escritura pública inscrita el Registro del Conservador antes de la inscripción hipotecaria.

¿El tercero que adquiere la propiedad arrendada en remate provocado por el acreedor hipotecario queda obligado por el No. 2 o por el No. 3 del artículo 1962?

La distinción tiene importancia porque el contrato podría estar reducido a escritura pública pero no inscrita. En dicho caso, se aplicaría el No. 2.

Es importante tener presente que el artículo 1962 NO se aplica al arrendamiento de predios rústicos. El artículo 10 del D.L. 993 establece que el nuevo adquirente SIEMPRE estará obligado a respetar el contrato de arriendo, sea cual sea el título de la adquisición, esto es, a título gratuito u oneroso.

¿Se aplicaría el artículo 1962 al verdadero dueño que recupera la posesión de la cosa mediante el ejercicio de la acción reivindicatoria?

- No, porque a él le es inoponible el contrato de arrendamiento.
- Algunos han dicho que el artículo 1962 presentaría la particularidad de transformar el derecho personal de goce que resulta del contrato de arriendo al arrendatario en un derecho real pues podría oponerse a terceros.

Hay dos situaciones en las que el derecho del arrendador sobre la cosa arrendada puede verse afectado sin que por ello termine el contrato de arriendo:

- Artículo 1965: si un acreedor del arrendador traba embargo sobre la cosa arrendada, tiene derecho éste acreedor a substituirse en los derechos del arrendador haciendo subsistir el contrato (acción oblicua o subrogatoria, artículo 2466 inc. 2º).  
Por su parte, si es el arrendatario el que cae en insolvencia, tampoco necesariamente se pone fin al contrato (artículo 1968).
- Finalmente, también se extingue el derecho del arrendador y se pone término al contrato de arrendamiento cuando el bien arrendado es expropiado por causa de utilidad pública (artículo 1960).

### **iii) Por el vencimiento del tiempo estipulado para la duración del contrato:**

El arrendamiento es un contrato por esencia temporal, necesariamente ha de tener un fin, pero su duración puede ser determinada o indeterminada.

- Cuando el contrato tiene una duración determinada, sea que se haya pactado así en forma expresa por las partes, por aplicación de la costumbre o por la naturaleza misma de la cosa arrendada, el contrato se extingue por el vencimiento del lapso: no es necesario pedir el desahucio del contrato según el artículo 1954 y sólo corresponde demandar su restitución.

- Ahora bien, si el arrendamiento no se ha estipulado por un plazo determinado, el contrato debe terminar por **desahucio**, que es "el aviso anticipado que da el arrendador o arrendatario de su deseo de poner término al arrendamiento".

- Este desahucio puede ser judicial o extrajudicial, aunque en materia de arrendamiento de predio urbanos la Ley 18.101 dispone que el arrendador sólo podrá poner término al contrato mediante desahucio judicial (artículo 3º Ley 18.101).

- Los plazos del desahucio en un arrendamiento de predio urbano serán examinados más adelante al estudiar el arrendamiento de predios urbanos.

En los demás casos, el desahucio se regula en los plazos y de la forma señalada en el artículo 1951.

Finalmente, cabe señalar que la regla general es que si el contrato termina por la llegada del plazo o por desahucio, el hecho que el arrendatario siga en poder de la cosa arrendada con la aquiescencia del arrendador NO significa que el contrato se prorrogue, SALVO que (artículo 1956):

- i. Se trate de un bien raíz,
- ii. Que el inmueble siga en poder del arrendatario y éste haya pagado un período posterior de pago con el consentimiento del arrendador,
- iii. Que por cualquier razón las partes hayan manifestado su intención inequívoca de perseverar en el contrato.

El contrato se entiende prorrogado por tres meses, sin perjuicio de que al término de éstos se prorrogue de la misma manera.

Y tratándose de predios rústicos, el contrato se entiende prorrogado por el tiempo necesario para la próxima recolección de frutos.

Esta es la llamada reconducción tácita.

Según el artículo 1957, cuando el contrato se renueva de esta manera, caducan las fianzas e hipotecas que estuvieren constituidas por terceros.

#### **iv) Por sentencia judicial:**

Ello ocurre generalmente en caso de **(1)** nulidad o rescisión según las reglas generales y **(2)** cuando se pide la terminación del contrato por incumplimiento de las obligaciones que emanan del contrato, **(3)** o la resolución cuando el contrato aún no ha empezado a cumplirse.

Si el arrendamiento termina por culpa del arrendatario, cabrá además pedir indemnización de perjuicios y, normalmente, se pide el pago de la renta hasta el día en que hubiere cesado o podido cesar el contrato.

#### **12.4.3. NORMAS ESPECIALES SOBRE ARRENDAMIENTO DE PREDIOS URBANOS.**

La Ley 18.101 contiene una normativa de carácter especial que rige el contrato de arrendamiento de los bienes raíces urbanos. Supletoriamente, en lo no previsto por dicha Ley, se aplican las disposiciones del Código Civil.

La Ley 18.101 fue dictada en 1982 y derogó al antiguo D.L. 964 de 1975. Sin embargo, el D.L. mantiene su eficacia para todos aquellos celebrados bajo su vigencia (artículo 22 Ley Sobre el Efecto Retroactivo de las Leyes).

#### **Ámbito de aplicación.**

Se aplica a todos los bienes raíces comprendidos dentro del radio urbano respectivo y a los que se encuentren fuera del territorio urbano siempre que su superficie no exceda de una hectárea (artículo 1º Ley 18.101).

La Ley no se aplica a los inmuebles señalados en el artículo 2º:

- 1) Predios de cabida superior a una hectárea y que tengan aptitud agrícola, ganadera o forestal, o estén destinados a ese tipo de explotación.
- 2) Inmuebles fiscales.
- 3) Viviendas que se arrienden por temporadas no superiores a tres meses, por períodos continuos o discontinuos, siempre que lo sean amobladas y para fines de descanso o turismo.

- 4) Hoteles, residenciales y establecimientos similares en las relaciones derivadas del hospedaje.
- 5) Estacionamientos de automóviles y vehículos.

El procedimiento judicial que se aplica en esta materia es un procedimiento sumario, con algunas reglas especiales.

### **PARTICULARIDADES DE LA LEY 18.101 y MODIFICACIONES DE LA LEY 19.866**

Los derechos que confiere la ley a los arrendatarios son IRRENUNCIABLES (artículo 19).

Si bien el contrato sigue siendo consensual, la escrituración se hace necesaria por vía de prueba ya que **la ley dispone que en los contratos verbales se presumirá que la renta será aquella que señale el arrendatario** (artículo 20).

Es una situación similar y análoga a la del artículo 8° del Código del Trabajo.

- Es una presunción simplemente legal.
- El desahucio dado por el arrendador debe ser SIEMPRE judicial.
- La restitución también debe ser pedida judicialmente.
- Bajo la vigencia del antiguo D.L. 964, para pedir el desahucio, el arrendador debía dar un "motivo plausible". La Ley 18.101 suprime esta exigencia, bastando que el arrendador ponga en conocimiento del arrendatario su deseo de poner fin al contrato.

Como puede observarse, en el contrato de arrendamiento siempre van implícitos intereses que pueden variar según las perspectiva buscada por la administración de turno.

**La ley 19.866, modificando la Ley 18.101, dispone plazos especiales de desahucio:**

Tratándose de los contratos pactados mes a mes y de los de duración indefinida, el plazo de desahucio será de **dos meses** contados desde la notificación, la que podrá ser realizada de forma judicial o por un notario de forma personal.

- A los **dos meses anteriores** se adiciona **un mes** por cada año completo que se hubiese ocupado el inmueble con un plazo máximo de **SEIS** meses.

Respecto de los contratos de plazo fijo, no corresponde pedir el desahucio sino la restitución del inmueble. Lo que pone fin al contrato en estos casos es la llegada del plazo y NO el desahucio, sin perjuicio de que en los contratos de plazo fijo que no exceden de un año el artículo 4° concede un plazo de **dos meses** de espera u aviso.

La Ley no dijo que ocurría con los contratos de plazo fijo superior a un año. Al no haber plazos de desahucio aplicables se concluye que sólo habrá que pedir la restitución judicial.

Bastaría con entablar la demanda anticipadamente al vencimiento del plazo para pedir la restitución en el tiempo convenido.



#### **12.4.4 NORMAS ESPECIALES SOBRE ARRENDAMIENTO DE PREDIOS RÚSTICOS**

El contrato de arrendamiento de predios rústicos puede revestir diferentes modalidades según la naturaleza del precio:

- Si el precio se paga en dinero hay simplemente un contrato de arrendamiento de predio rústico y el arrendatario se llama "colono".
- Si el precio se paga en frutos naturales de la cosa, pero estipulándose un cantidad fija de los mismos, la situación es la misma que la anterior.
- Si el precio consiste en una CUOTA de los frutos naturales de cada cosecha, el contrato se llama "aparcería" y el arrendatario se llama "colono aparcerero". Esta última categoría de contrato participa de las características del contrato de sociedad e incluso de contrato de trabajo, y por ello el D.L. 993 lo ha regulado minuciosamente.

El D.L. 993 se dictó el 1975, derogando las disposiciones atinentes a esta materia contenidas en la Ley de Reforma Agraria. El D.L. 993 contempla normas sobre arrendamiento de predios rústicos, medierías o aparcerías y otras formas de explotación de predios rústicos por terceros.

##### **A. Arrendamiento de Predios Rústicos:**

Es un contrato solemne (es una modificación introducida por la Ley 18.985 de 28 de Junio de 1990, reforma tributaria). Debe pactarse por escritura pública o por escritura privada en presencia de dos testigos mayores de dieciocho años.

- Está prohibido subarrendar todo o parte del predio sin autorización previa y por escrito del propietario.
- El arrendatario debe cumplir todas las disposiciones tendientes a proteger los recursos naturales existentes dentro del predio objeto del contrato.
- Si el arrendador transfiere el inmueble arrendado, el nuevo propietario estará obligado a mantener los términos del contrato salvo acuerdo en contrario con el arrendatario (c.f. artículo 1962).

##### **B. Medierías y Aparcerías:**

"Se entenderá por contrato de mediería o aparecería aquel en que una parte se obliga a aportar el uso de una determinada superficie de terreno y la otra el trabajo para realizar cultivos determinados, con el objeto de repartirse los frutos o productos que resulten, obligándose, ambas partes, además, a aportar los elementos necesarios para la adecuada explotación de los terrenos, a concurrir en los gastos de producción, a realizar en forma conjunta la realización de la explotación y a participar en los riesgos de la misma" (artículo 12 D.L. 993).

##### **Partes:**

1. Cedente: quien confiere el uso.



2. Mediero: quien se obliga a trabajarla.

Si nada se dice expresamente, se entiende que el producto que se obtenga se dividirá en partes iguales.

### **12.5 ARRENDAMIENTO PARA LA CONFECCIÓN DE OBRA MATERIAL**

De la definición general que da el artículo 1915, se desprende que el arrendamiento puede tener por objeto la ejecución de una obra que una de las partes ha de efectuar en beneficio de la otra.

El contrato se llama arrendamiento de obra o contrato de confección de una obra material.

**Concepto de arrendamiento para la confección de obra material.** "Es aquel por el cual una persona, llamada artífice, se obliga mediante cierto precio a ejecutar una obra material".

#### **Partes que intervienen.**

1. Arrendador: es el artífice, quien se obliga a ejecutar la obra.
2. Arrendatario: quien encarga la obra.

Es una figura que presenta semejanzas con el contrato de mandato y de trabajo.

- Las semejanzas con el contrato de trabajo son bastante obvias porque éste bien puede tener por objeto la ejecución de una obra material. La diferencia está en el vínculo de subordinación y dependencia que caracteriza al contrato de trabajo.
- En el contrato de ejecución de obra, el artífice puede ejecutar la obra del modo que mejor parezca.
- La importancia de esta distinción es enorme por las normas que se aplican en un caso o en otro.
- Ahora bien, el contrato de confección de obra puede constituirse en un contrato de venta o en uno de arrendamiento según quien se la parte que suministra la materia de que se compone la obra:
  - a) Será venta, en consecuencia, si el artífice suministra los materiales. Sería una venta al gusto o a prueba, o sea, condicional (que no se encuentra perfecta hasta que quien encarga la obra da su aceptación).
  - b) Será arrendamiento cuando quien encarga la obra es quien suministra los materiales.

Si ambas partes suministran los materiales, para determinar la naturaleza del contrato se atiende a quien suministró la materia principal.

Este contrato se regula por las reglas generales del contrato de arrendamiento y de las especiales contenidas en el párrafo 8º del Título XXVI del Libro IV del Código Civil.

### **12.6 ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS**

De la definición del artículo 1915 CC también podemos desprender que el contrato de arrendamiento puede tener por objeto servicios que una de las partes se obliga a

prestar a otra a cambio de una cantidad de dinero.

Nuestro Código regula tres tipos de arrendamiento de servicios:

- 1) Inmateriales, donde predomina el esfuerzo intelectual por sobre el físico.
  - 2) Criados domésticos
  - 3) Transporte
- A la época de dictación del Código Civil no existía regulación especial del contrato de trabajo. Éste se regula por primera vez a partir de 1924. Hasta esa fecha se aplicaban por analogía las normas de arrendamiento sobre criados domésticos.
  - Las normas sobre arrendamiento sobre criados domésticos fueron derogadas por el Código del Trabajo.
  - El arrendamiento de transporte constituye un acto de comercio y se encuentra minuciosamente reglamentado en el Código de Comercio que distingue entre el transporte terrestre y el transporte marítimo. A falta de disposición expresa del Código de Comercio se aplican las normas del Código Civil (artículo 2021).
  - El arrendamiento de servicios inmateriales es aquel en el cual predomina el esfuerzo intelectual por sobre el físico. La diferencia con el contrato de trabajo va a estar dada según existan o no vínculos de subordinación y dependencia entre las partes.

Puede revestir tres modalidades:

- 1) Realización de una obra aislada. La ley les aplica las reglas de la confección de una obra material (artículo 2006).
- 2) Realización de una larga serie de actos que se desarrollan en un período de tiempo más o menos largo. Respecto de cada una de las obras parciales se aplican las reglas de la confección de una obra material (artículo 2008) y por las demás normas de los artículos 2009, 2010 y 2011.
- 3) Servicios prestados por profesionales. Se rigen en primer término por las reglas del mandato, y en lo no previsto por las reglas del arrendamiento de servicios inmateriales (artículos 2012 y 2118).

En realidad, en cuanto a la calificación jurídica de los servicios de profesionales, como los de un médico o de un ingeniero, éstos constituyen arrendamiento de servicios pues existe mandato cuando va envuelta la facultad de representar a otra persona o al menos de actuar por otra persona. No obstante ello, igualmente se regirán en primer lugar por las reglas del mandato y en segundo lugar por las reglas del arrendamiento de servicios inmateriales.

## **12.7 CONTRATO DE LEASING**

Es una figura relativamente reciente en nuestro país. Es un contrato de carácter innominado o atípico que hizo su aparición en Estados Unidos en los años '50 para ser difundido rápidamente en Europa, con un gran auge en Francia donde incluso obtuvo reglamentación legal a mediados de los '60.

**Contrato de leasing: (1)** Forma de arrendamiento en que una sociedad especializada adquiere, a petición de su cliente, determinados bienes (2) que le entrega a éste en arrendamiento mediante el pago de una renta y (3) la opción, del arrendatario, al vencimiento del plazo, de continuar con el contrato en nuevas

condiciones o de adquirir el dominio de dichos bienes.

El nacimiento y auge de esta figura se vinculan fundamentalmente a la actividad comercial e industrial, ya que los empresarios necesitan renovar sus bienes de capital, sus maquinarias y equipos de trabajo. A eso se suma la rapidez de los avances tecnológicos que producen una rápida obsolescencia de dichos equipos.

El leasing es una fórmula alternativa de financiamiento flexible y rápida que tiene la gran ventaja de no implicar una inversión inicial por parte del usuario. Es una buena alternativa que puede ser más ventajosa que pedir un crédito financiero.

**OPERACIÓN:** Consta de tres etapas:

i) El industrial o usuario identifica al bien que requiere y solicita a la sociedad de leasing que lo adquiera para entregárselo en arriendo por un período determinado.

ii) La sociedad de leasing adquiere el bien y lo entrega en arriendo al usuario por un período determinado, irrevocable por parte del arrendatario, durante el cual éste paga una renta que se fija en función del valor del bien y con el objeto de irlo amortizando.

iii) Al concluir el plazo estipulado, el usuario puede optar libremente terminar el contrato y restituir el bien arrendado o bien ejercer su derecho de opción consistente en prorrogar el arrendamiento en nuevas condiciones o adquirir el dominio del bien por un valor residual ya determinado (o determinable) en el contrato inicial.

Como puede apreciarse, el contrato de leasing excede con mucho a un simple arrendamiento. Es bastante más complejo. No obstante, es un hecho que en base a la estructura de un contrato de arrendamiento se logra en definitiva el financiamiento de una operación para la cual no se contaba con capital, con la expectativa que al cabo de un cierto período en que el usuario amortice el valor del bien arrendado pueda optar por adquirirlo para sí.

Es un contrato bilateral, oneroso, conmutativo, principal, consensual, innominado, de tracto sucesivo, sujeto a un plazo irrevocable por parte del arrendatario, durante el cual éste está obligado a usar y gozar el bien dado en arriendo. Sólo al vencimiento de dicho plazo puede ejercer su derecho de opción.

**PARTES:**

i) Arrendatario o usuario: es quien obtiene el goce de la cosa y quien se compromete a pagar una renta por ello, teniendo el derecho de optar al fin del arrendamiento entre prorrogarlo o adquirir el dominio de la cosa, pagando como precio el valor residual determinado previamente.

ii) Sociedad de Leasing o arrendador: quien adquiere el bien y lo entrega en arriendo al usuario por un período determinado a cambio de un precio y obligándose a respetar el derecho del arrendatario a optar en los términos ya señalados.

iii) Proveedor: normalmente no es parte en el contrato y si lo llega a ser su participación será marginal e irrelevante para la existencia del contrato.

En el hecho, aparece para llevar a cabo la mantención de los equipos y en el caso que el arrendador le ceda sus derechos al usuario en contra del proveedor por posibles vicios de la cosa.

Este es el clásico leasing financiero en que la sociedad especializada adquiere el bien que le solicita su cliente para luego arrendárselo con opción de compra.

Hay también otros tipos de leasing, como el leasing operativo o renting, que se diferencian del leasing financiero justamente en la obligación de adquirir previamente el bien.

- En el leasing operativo, la sociedad de leasing puede cumplir los dos roles: el de proveedor y el de arrendador.
- El renting, por su parte, presupone la existencia de los bienes en poder de la sociedad.

La diferencia en cada tipo de leasing dependerá del tipo de bienes: si éstos son de gran circulación y por ende la sociedad de leasing tendrá una mayor posibilidad de darlos y volverlos a dar en arriendo.

### **12.7.1 EFECTOS DEL LEASING**

#### **A) OBLIGACIONES DEL ARRENDATARIO.**

- 1) Elección del objeto.**
- 2) Pagar la renta** (la que se determina tomando en cuenta el valor del bien y su vida útil).
- 3) Asumir las obligaciones transferidas por la sociedad de leasing, como mantener la cosa en buen estado** (que es una obligación típica de cualquier arrendador).
- 4) Contratar seguros.**
- 5) Restituir el bien vencido el plazo, salvo que opte por prorrogar el contrato en nuevas condiciones o comprarlo para sí por el valor residual ya establecido en el contrato.**

#### **B) OBLIGACIONES DEL ARRENDADOR O SOCIEDAD DE LEASING.**

- 1) Adquirir el bien seleccionado por el arrendatario.**
- 2) Entregar el bien:** lo normal es que aquí el arrendador tiende a desaparecer en esta etapa, dejando ligados al usuario y proveedor directamente.
- 3) Asegurar el uso y goce del bien:** que normalmente son obligaciones que se transfieren al proveedor.
- 4) Respetar el derecho de opción del arrendatario.**

El derecho de opción del arrendatario consiste en las tres alternativas que fluyen al fin del plazo irrevocable:

- 1) Restituir el bien.

- 2) Prorrogar el contrato en nuevas condiciones: dado que con el pago de la renta durante el período anterior el bien ya se ha amortizado en parte y sólo queda un valor residual del mismo, la nueva renta se pactará por un valor inferior.
- 3) Comprar el bien por el valor residual que puede haberse establecido de antemano: lo cual es lo más aconsejable.

Es posible que en algunos contratos de leasing no exista la posibilidad de restituir el bien dado que el artículo puede ser muy específico y, por lo mismo, de difícil colocación en el mercado. Aquí ya no habrá una opción para el usuario sino que una obligación alternativa:

- 1) Comprar el bien para sí.
- 2) Prorrogar el contrato.

### **NATURALEZA JURÍDICA DEL LEASING**

Al tratarse de una figura contractual atípica y compleja, ha habido gran discusión acerca de su naturaleza jurídica.

Mayoritariamente se estima que se trata de un contrato de arrendamiento con una opción unilateral de compra.

La idea de OPCIÓN da a entender la facultad concedida a determinada persona por un cierto tiempo de obtener una determinada prestación o de ejercitar un determinado derecho con preferencia a cualquier otro.

En otras palabras, una persona se obliga para con otra a otorgarle una determinada prestación quedado para ésta la facultad de aceptarla o rechazarla.

No es lo mismo que una promesa en que se genera la obligación de celebrar un nuevo contrato. En la opción no se requiere de un nuevo contrato porque el ofrecimiento se mantiene hasta la sola aceptación del oferente.

### **INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO**

Frente al incumplimiento de cualquier obligación del arrendatario, procederá la terminación del contrato o su cumplimiento forzado más indemnización de perjuicios.

### **TERMINACIÓN DEL CONTRATO**

Puede terminar por vía normal o anormal:

**Vía normal:** llegada del plazo

**Vía anormal:**

- 1) Voluntario
- 2) Involuntario: que puede ser la destrucción de la cosa, sea culpable o por caso fortuito.

## CAPÍTULO 13. SOCIEDAD

### 13.1 GENERALIDADES

#### 1. Concepto.

Art. 2053 CC. La sociedad o compañía es un contrato en que dos o más personas estipulan poner algo en común con la mira de repartir entre sí los beneficios que de ello provengan.

La sociedad forma una persona jurídica, distinta de los socios individualmente considerados.

La característica conceptual de este contrato es la existencia de 2 o más personas (no existe sociedad unipersonal en Chile) que se juntan con mira de poner algo en común y repartirse los beneficios. La idea central es reunir capital y aunar los esfuerzos para alcanzar determinados objetos lícitos.

La sociedad puede tener por objeto cualquier actividad. La única limitación es que no puede tener un objeto o causa ilícita. Las sociedades que tuvieren objeto o causa ilícita (por ejemplo, una sociedad constituida para la trata de blancas o para el tráfico de drogas) son nulas y no puede ser consideradas ni siquiera como una sociedad de hecho.

Quedan sujetas a la normativa criminal. (2057 inc. final)

#### 2. Características.

**1. Es un contrato y a la vez forma una persona jurídica distinta de las personas que la componen.** Art 2053 Incº 2 CC.

**2. Es un contrato plurilateral o de organización** en donde las voluntades van en un mismo sentido que es el sentido de que la sociedad obtenga beneficios.

**3. El contrato de sociedad civil es consensual, por lo tanto basta el mero acuerdo de voluntades.** ("las partes estipulan poner algo en común"). Sin embargo la consensualidad en el contrato social es excepcional ya que la única sociedad que es consensual es la sociedad colectiva civil y todas las restantes sociedades son solemnes.

**4. Es un contrato intuitu personae:** La sociedad colectiva civil termina por la muerte de uno de los socios, puesto que es una sociedad de personas y no una sociedad de capitales que no se disuelven por la muerte de algún socio. Además, el error en la persona del socio vicia el consentimiento y ninguno de los consocios puede ceder sus derechos sin el consentimiento de los otros.

**5. Por regla general, la sociedad goza de personalidad jurídica.** La atribución de personalidad jurídica a las sociedades implica el reconocimiento de la calidad de sujeto de derecho, obligaciones y responsabilidades y, por ende, constituye un

centro de imputación de normas diferenciado de sus miembros. Esto trae como consecuencias:

- a. Autonomía patrimonial del ente personificado: Tiene un patrimonio propio. (Art 2096 CC)
- b. Tiene un nombre
- c. Tiene un domicilio
- d. Tiene una voluntad distinta a la de los socios individualmente considerados. (Art. 2054 CC establece la forma en que se genera la voluntad de los socios en la sociedad colectiva civil)
- e. Responsabilidad en forma diferenciada de la de sus miembros y representantes.

### **13.2 ELEMENTOS ESPECIALES DEL CONTRATO DE SOCIEDAD.**

#### **1. EL APOORTE**

Sin este elemento no existe la sociedad. ("poner algo en común"). Art. 2.055 inc. 1º y 2082. Por regla general, la utilidad que corresponda a cada socio se distribuye en proporción a sus aportes.

El conjunto de los aportes constituye el llamado Capital Social, que a su turno es una deuda de la sociedad para con los socios.

El aporte debe ser susceptible de apreciación pecuniaria y debe ser a título singular (2056).

Los aportes pueden ser de distintas clases:

- Aporte en dinero
- Aporte en especie (en dominio o usufructo)
- Aporte en trabajo (socio industrial)
- Aporte en servicio

Si el aporte es el trabajo, este aporte es avaluado de común acuerdo y a falta de acuerdo es avaluado por el juez.

#### **2. LOS BENEFICIOS**

La característica de la sociedad en términos de que ha sido constituida o pactada para producir utilidades y repartirla entre los socios es lo que la diferencia de las personas jurídicas sin fines de lucro; por ejemplo, las fundaciones.

El beneficio no es moral; sino claramente pecuniario (en dinero). (Art. 2055 inc. 2º y 3º)

Los beneficios solo se podrán determinar al momento de la disolución de la sociedad.

Los beneficios se reparten:

- a. Conforme a lo pactado (2066)
- b. También puede dejarse entregado al arbitrio de un 3º (2067)
- c. Si nada se estipula se reparte a prorrata de los aportes. Art. 2068 CC. (Ley en silencio de la voluntad de las partes)
- d. Respecto del socio industrial o que aporta trabajo, su participación la fija el juez a falta de estipulación expresa. (2069)

### **3. LAS PÉRDIDAS**

Se distribuyen:

- a. Conforme a lo señalado en el pacto social o se deja entregado al arbitrio de un 3º (2066 y 2067).
- b. A falta de estipulación expresa a prorrata de los aportes. (Art. 2068 CC.)
- c. Si nada se estipula respecto del socio industrial, éste solo pierde el trabajo. (2069)

Respecto de los beneficios y pérdidas se debe entender respecto de todos los negocios de la sociedad y no de cada negocio en particular. Art 2070 CC.

### **4. INTENCIÓN DE FORMAR SOCIEDAD**

Se trata de un elemento importante y se denomina "Affectio Societatis" que tiene como cosa característica que las partes deben encontrarse en un pie de igualdad en términos psicológicos destinados a cooperar en la formación de una empresa.

No hay sociedad cuando se hace formalmente un esquema social con un trabajador que seguirá siendo tal. No debe haber vínculo de subordinación ya que en tal caso nos encontraríamos frente a un contrato de trabajo.

### **13.3 LA PERSONALIDAD JURÍDICA Y LA SOCIEDAD.**

El ser humano tiende a agruparse; la primera agrupación es la familia; la última agrupación, en cambio, es el Estado.

Pero entre la familia y el Estado existen una serie de grupos intermedios (asociaciones) en dinámica y recíproca interacción.

Estos grupos intermedios, sean que se encuentren organizados jurídicamente o no, ostentan un conjunto de reglas o normas de conducta que sus miembros deben seguir y que determina la relación de pertenencia al grupo.

Este carácter asociativo del ser humano, del que no es posible prescindir, trajo consigo el establecimiento o reconocimiento - según la tesis que se adopte en cuanto a la naturaleza jurídica de los derechos fundamentales -, del llamado derecho de asociación. Ello supone que el Estado establezca una regulación jurídica heterónoma de las asociaciones intermedias bajo cuyo amparo puedan surgir grupos "formales" o de "derecho". De esta forma, todos los Estados modernos prevén una normativa legal que permite varias posibilidades de organización jurídica para un "grupo intermedio".

Sin embargo, como lo advierte Cabanellas, la personalidad jurídica de las sociedades no responde a una necesidad lógica, sino más bien práctica, en razón de funciones de imputación. Es posible organizar jurídicamente sociedades sin que las mismas tengan personalidad jurídica, como sucede con las sociedades accidentales o en participación. En éstas, las funciones de imputación que en las restantes sociedades cumple la personalidad jurídica de la sociedad, se ven reemplazada por la personalidad del socio gestor. Dicho de otro modo, el socio gestor presta su



personalidad a los fines de la organización y funcionamiento de la sociedad.

La personalidad jurídica es pues únicamente un atributo predicable de ciertas organizaciones sociales. Y su razón de ser trasciende la idea de la simple separación de patrimonios entre la sociedad y los socios individualmente considerados. Dicho de otro modo, la separación patrimonial es una consecuencia de la atribución de personalidad jurídica, pero no es la razón de ser de dicha atribución. La razón de ser de la personalidad jurídica se traduce en funciones prácticas de imputación al ente colectivo de ciertas situaciones jurídicas de sus miembros o integrantes.

Resulta así, pues, que la personalidad jurídica se justifica por su función práctica, pudiendo descomponerse en dos elementos, a saber: a) la imputación que el orden jurídico le hace a un ente colectivo de un conjunto de actos, derechos y responsabilidades; y b) la aplicación de a esta entidad colectiva de todas las normas del ordenamiento jurídico, con total independencia de su sustrato personal, exclusivamente sobre la base de las características propias de la persona jurídica.

En nuestro Derecho, la Constitución Política de 1980 reconoce, ya en su artículo primero, la existencia inevitable de los grupos intermedios, garantizándoles su plena autonomía. A su turno, el artículo 19 N° 15 asegura a todas las personas el derecho de asociarse sin permiso previo, en la medida que dichas asociaciones no contravengan la moral, el orden público y la seguridad del Estado.

De esta forma, las asociaciones formales, es decir, aquellas que constituyéndose en conformidad a la ley gozan de personalidad jurídica, son el producto del ejercicio del derecho constitucional de asociación, y son llamadas personas jurídicas o morales, por cuanto tienen una existencia ideal, y poseen personalidad jurídica, es decir, se encuentran situados en la categoría de sujetos de derecho.

El artículo 545 del nuestro Código Civil define a la persona jurídica como un ente ficticio capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser representada judicial y extrajudicialmente. De esta forma, las asociaciones formales son capaces de adquirir derechos y contraer obligaciones, lo que equivale decir que gozan de patrimonio propio, en el sentido clásico de su acepción, y constituyen entidades distintas de los miembros que la componen.

### **PARA EXPLICAR LA PERSONALIDAD JURÍDICA DE LAS SOCIEDADES, SE HAN ESTABLECIDO DISTINTAS TEORÍAS.**

#### **a) La Teoría de la ficción:**

Sostiene que la persona jurídica no es más que una creación legal. El ordenamiento jurídico conceptúa a la unión de personas o a los bienes destinados a un fin benéfico como si fuera un sujeto de derecho, una persona. Esta teoría fue popularizada por Savigny, quien es su representante más ilustre.

Para Savigny las personas jurídicas son seres creados artificialmente, que no existen como tales sino para el cumplimiento de un fin jurídico y para el cual son capaces de tener un patrimonio.

**b) Teoría de la realidad objetiva (teoría antropomórfica u orgánica)**

Concibe a la persona moral como un organismo natural al igual que el hombre, con una voluntad propia y un propio interés, distintos de la voluntad e interés de las personas físicas de sus miembros. La subjetividad jurídica de tales entes deriva de su comportamiento en la realidad de manera semejante al hombre, y de ahí que el derecho no les conceda propiamente la personalidad, sino que se limita a reconocerla.

**c) Teoría de la realidad técnica (teoría formalista de Ferrara)**

Para esta teoría no existe ninguna imposibilidad en concebir derechos que pertenezcan a otros seres que no sean los individuos humanos. Más aún, la naturaleza de las cosas impone a menudo esta concepción. No se puede concebir sin derechos propios al Estado, ni a muchas sociedades, asociaciones o establecimientos. El hecho de ser sujetos de derecho, lejos de ser una ficción, es una realidad lógica y a veces necesaria.

Mediante esta teoría se concilia el pensamiento que está en la base de la teoría de la ficción, con la idea de que ello no impide que sea técnicamente útil a los hombres y en su interés mismo, crear seres sobre los cuales harán descansar derechos destinados, a fin de cuentas, a beneficiar a los individuos. La personalidad jurídica no es más que un instrumento creado por el Dº al servicio de los intereses de la economía.

**LA SOCIEDAD DE HECHO.**

Art. 2057. Es aquella a la que faltó alguno de los requisitos establecidos por la ley. La restitución de los aportes deberá realizarse en tal caso conforme a las normas del cuasicontrato de comunidad. Además, debe tenerse presente la norma del Art. 2058 que protege a los terceros de buena fe, por cuanto establece la inoponibilidad de la nulidad de la sociedad. (Es un caso más de recepción normativa de la teoría de la apariencia)

**13.4 TIPOS DE SOCIEDADES.**

**1) Sociedades Civiles y Sociedades Comerciales.**

Depende esta clasificación de los negocios a los que se dedique las sociedades. (Art. 2059) Debe atenderse al objeto o giro social y no a la calidad de las personas que constituyen la sociedad.

Se pueden estipular sociedades civiles y hacerle aplicables las reglas del Código de Comercio, es decir que queden regidas por el Código de Comercio. En todo caso, las

sociedades comerciales se rigen por el C. de Comercio y en lo no previsto ahí, como supletorio, por el C.C. (Art. 2º del C. de Comercio)

En general, todas las sociedades pueden ser de una u otra forma salvo las sociedades anónimas que por disposición legal expresa del Art. 1º de la Ley de Sociedades Anónimas siempre serán sociedades comerciales, aun cuando su giro sea civil. (2064 C.C.)

## **2) Sociedad Colectiva, De Responsabilidad Limitada, En Comandita y Anónima.**

Art. 2061 CC

### **A) SOCIEDAD COLECTIVA.**

Se define en el Art. 2061 Inc 2º CC. Se caracteriza por que la sociedad es administrada por todos los socios por sí o por un mandatario elegido de común acuerdo. Los socios responden de las deudas de la sociedad con todo su patrimonio personal.

- En la sociedad colectiva civil a prorrata de sus respectivos aportes
- y en la sociedad colectiva comercial solidariamente (por lo tanto no se protege el patrimonio personal de los socios y esto hace que sean muy pocas las sociedades colectivas).

La razón social (nombre) en las sociedades colectivas se forma con el nombre de alguno de los socios o de todos los socios y la palabra "y compañía".

### **B) SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.**

La responsabilidad de los socios se limita al monto de sus respectivos aportes y no se puede perseguir los patrimonios personales de los socios, salvo que los socios se constituyan en codeudores solidarios o fiadores en las obligaciones sociales.

El nombre de la sociedad de responsabilidad limitada se conforma de 2 maneras posibles:

§ Con el nombre de 1 o más de los socios y la agregación de palabra "Limitada".

§ Por una referencia a el objeto social más la agregación de palabra "Limitada". En lo demás, este tipo de sociedad se rige por las reglas de sociedad colectiva.

### **C) SOCIEDAD ANÓNIMA.**

Es una sociedad de capitales y se define en el Art. 2061 inc. 4º y en el Art. 1 de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas.

Se caracteriza por ser un fondo de capital.

Se administra mediante 2 órganos:

- 1) La Junta de Accionistas, que es la reunión de todos los accionistas para la deliberación de las materias propias de la junta de accionistas; y
- 2) El Directorio que está formado por un conjunto de personas elegidos por la junta de accionistas para la administración de la sociedad. Lo normal es que el Directorio delegue parte de sus facultades en el Gerente de la Sociedad Anónima.

La responsabilidad de los accionistas se limita al monto de los aportes, sin perjuicio de las reglas especiales contenidas en la Ley 18.046. Art. 2097 y 2061 CC.  
El nombre de la S.A. se regula en el Art 8 de la Ley de S.A. y es la referencia al objeto social más la expresión "S.A".

#### **D) SOCIEDAD EN COMANDITA.**

Hay 2 tipos de socios (es una mezcla de sociedad de capital con sociedad de personas):

§ Los socios gestores: aquellos que administran la sociedad y que responden como socios colectivos es decir ilimitadamente. Art. 2061 CC.

§ Los socios comanditarios: solo aportan capital y no pueden participar en la administración de la sociedad. Responden hasta el monto de sus aportes a la sociedad. Art 2097 y 2063 CC.

El nombre de la sociedad se forma con la palabra en comandita más el nombre de los socios gestores (existe prohibición de incluir el nombre de los socios comanditarios)

Esta sociedad puede ser:

1. Sociedad comandita simple (se forma y prueba como la sociedad colectiva)

2. Sociedad comandita por acciones: los derechos en esta sociedad se dividen en acciones y el nombre se forma por la sigla C.P.A.

Se suelen hacer sociedades en comanditas en que el socio gestor es un socio colectivo. P/Ej. Soc. Minera Pudahuel LTDA. CPA.

### **13.5 SOCIEDAD COLECTIVA CIVIL**

#### **1. LA ADMINISTRACIÓN:**

Art. 2061 incº 2 CC señala que la administración es efectuada por todos los socios por sí o por un mandatario designado de común acuerdo, por lo tanto hay que distinguir:

Art. 2071-2072-2073 CC.

a) Si se ha designado administrador por los socios.

i) Se designó en el pacto social: Se trata de un mandatario estatutario y es condición esencial de la existencia de la sociedad. Consecuencias que emanan de esto:

- El administrador no puede renunciar si no es por causa contemplada en los estatutos o unánimemente aceptada por los demás socios.
- No puede ser removido, sino por causa grave o por causa contemplada en los estatutos.
- En caso de renuncia o remoción justificada pueden continuar los socios con la sociedad en los términos del Art. 2073 CC.

ii) Se designo en acto posterior: En este caso rigen las reglas del mandato. Art 2074 y siguientes.

b) Si no se ha designado administrador por los socios, ni en el acto constitutivo ni el acto posterior: administran todos los socios conjuntamente. Art 2081 CC.

### **Formas de Administración.**

a. Administración por un sólo administrador: En el evento de que la administración sea conferida a un socio administrador este puede ejecutar los actos según le parezca con las restricciones legales del caso. Pese a esto la mayoría de los socios podrá oponerse a los actos que no hayan producido efectos legales. (Es decir, que no estén consumados) Art. 2075

b. Administración por varios administradores: Si la administración es conferida a varios socios o administradores pueden ejecutar por sí solo y por separado los actos de administración salvo que se les haya prohibido actuar separadamente en cuyo caso no podrán hacerlo ni aun a pretexto de urgencia. (2076)

c. Administración por todos los socios: Respecto de la Administración efectuada por todos los socios, hay que estarse a las reglas del Art. 2081 CC. Se entiende en este caso que cada uno de los socios ha recibido de los otros el poder de administrar con las limitaciones señaladas en esa disposición que son:

- Cualquier socio tiene derecho a oponerse a los actos administrativos del otro antes de su ejecución.
- Cada socio puede servirse de las cosas de la sociedad para su uso personal siempre que las emplee para su destino ordinario.
- Hacer concurrir a los demás socios a la conservación de las cosas.
- No hacer innovaciones en los inmuebles sociales sin el consentimiento de los otros socios.

### **Facultades de la Administración.**

Son las del mandato. Solo las del giro ordinario, a falta de facultad expresa. En consecuencia, será el objeto social la que determine las atribuciones del administrador (Art. 2077 y 2078).

Igual que en el mandato el administrador puede en caso urgente convertirse en agente oficioso.

### **Efectos de la Administración.**

Si el administrador actúa dentro del giro ordinario de la sociedad y de sus facultades obliga a la sociedad, si se excede en los límites de sus facultades sólo él quedara obligado. (Art. 2079)

## **2. OBLIGACIONES DE LOS SOCIOS:**

**a)** Efectuar el aporte a que está obligado en tiempo y forma (Art 2055 y 2087 CC). El riesgo de la cosa pertenece a la sociedad si ha sido aportada en propiedad. El

riesgo de la cosa pertenece al socio si la cosa se ha aportado en usufructo. (Art 2084 CC.). Si se trata de un cuasiusufructo, el riesgo es de la sociedad (2084 inc. 3º)

En caso de incumplimiento del socio de su obligación de aporte, es responsable de los perjuicios que su retardo haya ocasionado a la sociedad (2083) y, además, da derecho a los restantes socios para pedir la resolución, con indemnización de perjuicios. En verdad, la resolución opera aquí como causal de disolución de la sociedad. (Art. 2101)

**b)** Tienen la obligación de sanear el aporte en los términos del Art 2085 CC.

**c)** Los socios tienen la obligación de cuidar los intereses sociales respondiendo hasta de la culpa leve. Manifestaciones de este principio las encontramos en los Art. 2091; 2092; 2093 y 2094 del CC.

**d)** Tratándose de una sociedad colectiva comercial, los socios tienen una serie de prohibiciones (Art. 404 del C. de Comercio). Así, por ejemplo:

- No puede extraer del fondo común mayor cantidad de la asignada para sus gastos particulares, ni usar en sus negocios particulares la razón social.
- Ceder a cualquier título su interés en la sociedad (requiere del consentimiento de sus consocios)
- Explotar por cuenta propia el giro social.

La contravención a estas reglas le significa al socio cargar por sí solo con las pérdidas y abonar a la sociedad todas las ganancias.

### **3. OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD PARA CON LOS SOCIOS.**

**a)** Debe reembolsarle la suma que le hubiere adelantado el socio a la sociedad con conocimiento de ella para negocios de la sociedad o sociales. (2089, inc. 1º)

**b)** Además debe resarcirle los perjuicios que la gestión le hubiere ocasionado. (2089).

**c)** Estas indemnizaciones se pagan a prorrata por los socios y la cuota del socio insolvente grava a los demás, pero también a prorrata de sus derechos.

### **4. OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD RESPECTO DE 3º.**

**a)** El socio que contrata a nombre propio no obliga en ningún caso a la sociedad. Art. 2094 CC.

**b)** Cuando actúa a nombre de la sociedad debe hacerlo inequívocamente y en tal caso obliga a la sociedad frente a terceros. Art 2094 CC. En caso de duda se entenderá que contrata o actúa a nombre propio.

### Forma en que los socios responden de las deudas sociales:

Los contratos válidamente celebrados por algún socio o administrador en uso de sus facultades obligan a la sociedad y a los socios a prorrata de su interés social; con la característica que la cuota del deudor insolvente grava a los otros. Por lo tanto, hay responsabilidad ilimitada pero no solidaria en la sociedad colectiva civil (En la colectiva comercial, responden ilimitada y solidariamente).

En consecuencia, además del patrimonio social, los socios comprometen su propio patrimonio.

Si bien los acreedores de la sociedad tienen acción para perseguir sus créditos en el patrimonio de los socios, los acreedores personales de los socios no tienen acción para perseguir sus créditos en el patrimonio social; y sólo tienen derecho a hacer efectivos sus créditos sobre los beneficios que los socios obtengan de la sociedad. (Art. 2096. Las excepciones relativas a la hipoteca que consulta el inciso primero no son tales)

c) Si contrata a nombre de la sociedad, pero sin poder suficiente, se obliga personalmente el socio, y la sociedad sólo subsidiariamente y hasta concurrencia del beneficio que hubiere reportado del negocio.

### **13.5.1 DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD.**

Art. 2098 CC. Causales:

- a) Plazo o condición (Art. 2098). En caso de prórroga, debe pactarse antes del vencimiento del plazo y deben cumplirse las mismas formalidades que para la constitución (si bien es consensual, si se constituyó por escrito, la prórroga también debe constar por escrito)
- b) Terminación del negocio. (Art 2099 CC.)
- c) Por insolvencia de la sociedad. (Art 2100 CC.)
- d) Por la pérdida total de los bienes sociales. (Art 2100 y 2102 CC.)
- e) En el evento de que uno de los socios no efectúe su aporte y los demás decidan disolverla. (Art. 2101)
- f) Por la muerte de cualquiera de los socios con la excepción de que en el contrato se pacte que la sociedad puede continuar con los herederos del difunto o sin ellos. (2014)
- g) Por acuerdo entre las partes. Mutuo disenso (Art 2097). Es común que esto se haga como una reforma de estatutos en que se modifica la vigencia de la sociedad, debiendo terminar en una fecha cercana. Ello, por cuanto de esa forma se evita tener que insertar en la escritura de disolución un certificado de término de giro que debe otorgar el SII.
- h) Por renuncia de cualquiera de los socios. La renuncia, como acto unilateral de un socio que manifiesta su voluntad de retirarse solo constituye causal de terminación de las sociedades de duración indefinida. Los efectos de la renuncia se regulan en los Art 2108 y 2109 CC.

### **Efectos de la Disolución:**

- a) Si la sociedad es civil, se produce el término de la personalidad jurídica y debe procederse a su división en los términos del Art 2115 CC, esto es se aplica las reglas de la partición de los bienes hereditarios al caudal social.
- b) Si la sociedad es comercial, persiste la personalidad jurídica durante la liquidación de la sociedad y el haber y pasivo de la sociedad deben liquidarse conforme a los artículos 408 y siguientes del C. de Comercio.
- c) Termina la representación de sus administradores y mandatarios (por aplicación del N° 9 del art. 2163)
- d) Los derechos de los socios contra la sociedad "en liquidación" o contra la comunidad resultante de la disolución, son libremente transferibles por éstos.
- e) En cuanto a los terceros, la disolución de la sociedad sólo produce efecto en los siguientes 3 casos (Art. 2114):
  - Cuando la sociedad se disuelve por la llegada del plazo pactado para su vigencia.
  - Se puede oponer la disolución cuando se ha publicado este hecho por 3 veces en periódicos del dpto. de la capital de provincia.
  - Cuando haya prueba de que el 3º conoció oportunamente de la disolución de la sociedad.



## CAPÍTULO 14 CUASICONTRATOS

### 14.1 ASPECTOS GENERALES.

#### 1. Consagración y concepto de los cuasicontratos

Art. 1437 CC "...Las obligaciones nacen de un hecho voluntario de la persona que se obliga, como en la aceptación de una herencia o legado, y en todos los cuasicontratos..."

Art. 2284 CC. Las obligaciones que se contraen sin convención, nacen o de la ley, o del hecho voluntario de una de las partes. Las que nacen de la ley se expresan en ella.

Si el hecho de que nacen es lícito, constituye un cuasicontrato.

Si el hecho es ilícito, y cometido con intención de dañar, constituye un delito.

Si el hecho es culpable, pero cometido sin intención de dañar, constituye un cuasidelito. En este título se trata solamente de los cuasicontratos

De ambas disposiciones, se concibe que el CC entiende al **cuasicontrato** como (1) Un hecho voluntario, (2) no convencional y (3) lícito (4) que produce obligaciones.

- El cuasicontrato es una **acto voluntario** y se diferencia por este carácter de la ley como fuente las obligaciones. La ley impone obligaciones independientemente de la voluntad.
- Aún siendo voluntario, el cuasicontrato **no es el resultado de un acuerdo de voluntades**, circunstancia que lo diferencia de los contratos.
- El hecho que le da origen es lícito, por lo cual se diferencia de delito y cuasidelito, que son voluntarios pero ilícitos.

#### 2. Críticas a la noción de cuasicontrato.

Los juristas romanos decían que existían obligaciones nacidas de causas que no eran ni un contrato ni un delito, pero debían ser consideradas como si resultaran de algunas de ellas. Lo que ellos intentaron fue sólo justificar la fuerza obligatoria y el régimen al cual debían sujetarse estas obligaciones.

PLANIOL critica:

**1.** La expresión cuasicontrato sugiere la idea de que se trata una institución análoga al contrato, en circunstancias que las diferencias son radicales.

**2.** Niega que el cuasicontrato sea un hecho voluntario, porque la voluntad no genera la obligación que se impone al autor del acto, y porque suele resultar obligado quien no la ha expresado en modo alguno.

3. El cuasicontrato tampoco sería lícito. En todos los cuasicontratos se descubre como rasgo común, un enriquecimiento sin causa: ilicitud o injusticia.

4. En suma, las obligaciones que engendra estarían en la ley, con miras a reparar un enriquecimiento injusto.

### 3. Principales cuasicontratos.

Art. 2285 CC: hay 3 principales cuasicontratos:

- la agencia oficiosa,
- el pago de lo no debido y
- la comunidad.

La misma disposición pone de manifiesto la existencia de otros cuasicontratos:

1. 1437 CC: califica de cuasicontrato la aceptación de una herencia o legado;
2. 2238 CC: el depósito necesario de que se hace cargo un incapaz, que se encuentra en su sana razón, constituye un cuasicontrato que obliga al depositario sin la autorización de su representante legal.
3. 173 Código de Minería: tipo de sociedades que nacen de un hecho, constituyen cuasicontrato.

### 14.2 FUNDAMENTO: REPARACIÓN AL ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA

Gran parte de la doctrina encuentra el fundamento de las obligaciones nacidas de los cuasicontratos en el propósito de la ley de **impedir o reparar el enriquecimiento sin causa**, llegando incluso a ser considerado como una fuente de las obligaciones por ciertos sectores de la doctrina.

Generalmente una persona se enriquece en desmedro de otra, pero el incremento a costa del empobrecimiento, opera por un justo motivo.

No existiendo causa para el enriquecimiento, la víctima cuenta con la Acción de in rem verso para obtener la reparación.

Nuestro CC no contiene una norma que consagre en términos generales al enriquecimiento injustificado como fuente de las obligaciones. Además de la regulación de los cuasicontratos, el Código sólo se limita a la existencia de casos particulares, que se fundan en esta institución:

1) **Recompensas que se deben los cónyuges** (hoy existe la compensación económica);

2) **Prestaciones mutuas del reivindicante y del poseedor vencido;**

3) **Actos ejecutados por el marido**, dan acción a los acreedores sobre los bienes de la mujer, cuando el acto cede en utilidad personal de ésta y hasta concurrencia del beneficio que obtenga.

4) 1688 CC: **incapaz que se ha hecho más rico debe restituir.**

5) **Agencia oficiosa y pago de lo no debido.**

En otros países como Alemania y Suiza, se consagran formalmente el enriquecimiento sin causa como fuente de las obligaciones.

### **14.3 LA AGENCIA OFICIOSA O GESTIÓN DE NEGOCIOS AJENOS**

Art. 2286 CC: La *agencia oficiosa* o *gestión de negocios ajenos*, llamada comúnmente *gestión de negocios*, es un cuasicontrato por el cual el que administra sin mandato los negocios de alguna persona, se obliga para con ésta, y la obliga en ciertos casos.

Esta intrusión en un patrimonio ajeno se justifica por el fin altruista que la inspira.

- Quien la realiza se llama agente oficioso o gerente;
- la persona por cuya cuenta se verifica se denomina interesado.

#### **14.3.1 REQUISITOS.**

**1) La intrusión del gerente debe ser espontánea.** No debe mediar un mandato legal, como aquellas acciones que realiza el padre o la madre, los tutores o curadores.

**2) El gerente debe obrar sin mandato.** No constituye AO, las gestiones que se realicen a instancias del interesado. 2286 CC.

**3) El agente oficioso debe tener la intención de obligar al interesado.**

- 2123 CC: el encargo constitutivo del objeto del mandato puede hacerse aun por la aquiescencia tácita de una persona a la gestión de sus negocios por otra.
- La gestión del interesado supone, por cierto, conocimiento de la gestión. Pero el simple conocimiento del interesado no convertirá la AO en mandato. Es menester que haya podido manifestar su disconformidad y no la haya manifestado.
- El juez, deberá resolver cuándo hay AO y cuándo hay mandato, en atención a las circunstancias del caso.
- 2122 CC: el mandatario que ejecuta de buena fe un mandato nulo o que por una necesidad imperiosa sale de los límites de su mandato, se convierte en un agente oficioso.

Si la gestión se realiza sin la intención de obligar al interesado y de reembolsarse de los gastos que ocasione, los actos del gestor constituyen una **mera liberalidad**.

- Art. 2292 CC: una persona cree equivocadamente hacer su propio negocio y en verdad gestiona uno ajeno. No hay propiamente agencia oficiosa. Es parecido al caso en que media prohibición del interesado: se le otorga acción para reclamar aquello en que la gestión haya hecho más rico al interesado y con tal que subsista esta utilidad al tiempo de reclamar el reembolso.
- Existe agencia oficiosa si alguien cree gestionar los negocios de una persona y gestiona los de otra. Este error, carece de importancia, ya que el gestor ha tenido la intención de obligar y de que se le reembolse. Art. 2293 CC.

La gestión de un negocio ajeno, contra la expresa prohibición del interesado, **no constituye agencia oficiosa**.

En este caso, el gestor sólo puede reclamar aquello en que, gracias a su gestión, el interesado se haya hecho más rico, con tal que esta utilidad exista al momento de demandarle, según establece el art. 2291 CC. La ley otorga la acción in rem verso pero limitada a la utilidad existente al tiempo de la demanda. Ej. Extinción de una deuda, que sin ella hubiera tenido que pagar el interesado.

#### 4) La capacidad de las partes.

- Gerente: debe ser capaz.
- Interesado: no requiere ser capaz. No ejecuta ningún acto voluntario, sino que se obliga como consecuencia de los actos de otro.

#### La agencia oficiosa en juicio

En principio, no puede parecer en juicio por otra persona sino su mandatario. Sin embargo, es posible admitir la comparecencia de una persona que obre sin mandato a beneficio de otro. Para ello, es necesario que el compareciente ofrezca garantía de que el interesado aprobará lo que haya hecho en su nombre. Esta garantía se denomina fianza de rato. El juez calificará las circunstancias que justifican la comparecencia y la garantía ofrecida, y fijará un plazo para la ratificación del interesado. (6-3 CPC). El agente oficioso debe ser persona capaz de parecer en juicio.

#### 14.3.2 EFECTOS DE LA AGENCIA OFICIOSA.

Art. 2286 CC: destaca claramente que el agente siempre se obliga para con el interesado, pero que el interesado se obliga para con el agente sólo en ciertos casos.

#### 1. Obligaciones del agente

La agencia oficiosa está emparentada con el mandato. Art. 2287 CC: las obligaciones del agente oficioso o gerente son las mismas que las del mandatario.

**1.** El gerente, por regla general, debe **emplear en la gestión el cuidado de un buen padre de familia**; pero su responsabilidad puede ser mayor o menor, según las circunstancias en que se ha hecho cargo de la gestión. (2288-2).

**2.** El agente **debe hacerse cargo de todas las dependencias del negocio**. No puede limitar su gestión, sino que debe darle la amplitud que corresponde a la naturaleza del negocio administrado.

**3.** El gerente pudo no haber tomado a su cargo la gestión; pero una vez que la ha asumido, debe **continuarla hasta que el interesado pueda tomarla a su cuidado o encomendarla a otra persona**. Art. 2289 CC.

4. El gerente, siendo administrador de bienes ajenos, debe **rendir cuenta de su gestión**. Deberá hacerlo antes de ejercer cualquier acción contra el interesado. 2294 CC.

## 2. Obligaciones del interesado.

El interesado no siempre se obliga con la gestión.

Sus obligaciones para con el gerente se sujetan a una condición precisa: que el negocio haya sido bien administrado, es decir, **que la gestión haya sido ÚTIL**. La utilidad condiciona las obligaciones del interesado y limita los términos en que se obliga.

1. En dicho supuesto, **cumplirá el interesado las obligaciones que el gerente ha contraído en la gestión**. El gerente obligaría al interesado ante terceros.

2. Respecto del gerente, **el interesado se obliga a reembolsar las expensas útiles o necesarias que haya efectuado**.

3. **El interesado no está obligado a pagar ninguna remuneración al gerente**. En caso de haber sido mal administrado el negocio, no se obliga el interesado ni para con el agente ni para con terceros. El gerente es responsable de los perjuicios.

## LA AGENCIA OFICIOSA Y EL MANDATO.

Semejanzas: en ambos casos se obra en nombre de otro y no por cuenta propia.

|                                                 | MANDATO                                                                                                                                                                                                        | AGENCIA OFICIOSA                                                                                                            |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PODERES</b>                                  | Mandatario obre premunido de poderes.                                                                                                                                                                          | Agente carece de poderes                                                                                                    |
| <b>NAT. JDCA.</b>                               | Contrato                                                                                                                                                                                                       | Cuasicontrato                                                                                                               |
| <b>OBLIGACIÓN DEL MANDANTE Y DEL INTERESADO</b> | El mandante se obliga independientemente del beneficio que le reporten los actos del mandatario, ya que éste no se obliga al éxito, sino a hacer lo que esté de su parte para el buen resultado de su gestión. | El interesado sólo se obliga cuando la gestión le sea útil.                                                                 |
| <b>CAPACIDAD</b>                                | El mandante debe ser capaz.                                                                                                                                                                                    | El interesado se obliga con el agente aunque sea incapaz, puesto que las obligaciones que contrae son ajenas a su voluntad. |

#### **14.4 EL PAGO DE LO NO DEBIDO**

##### **1. Caso calificado de enriquecimiento sin causa.**

La obligación de restituir es impuesta por la ley para impedirlo. Frente a un error en el pago, se le otorga esta acción.

##### **2. Inaplicabilidad de las reglas del pago de lo no debido en caso de nulidad y resolución.**

Las normas del pago de lo no debido, no se aplican en todos los casos en que existan pagos indebidos. Anulado o resuelto el contrato, las prestaciones de las partes resultarán indebidas y éstas tendrán derechos a ser restituidas al estado anterior al acto. Pero las acciones encaminadas a este propósito se registrarán por:

- las normas de la nulidad (1687)
- y por las normas de la resolución (1487)

En ambos casos, no es el error lo que da fundamento a la repetición.

#### **14.4.1 REQUISITOS DEL PAGO DE LO NO DEBIDO.**

##### **1) Que no exista obligación.**

1. La obligación no se contrajo jamás.
2. La deuda se paga a una persona distinta del acreedor verdadero.
3. Se paga por otro que el verdadero deudor. Una persona paga una deuda ajena, creyéndola propia. Excepción: Art. 2295 inc. 2 CC. Supresión del título o cancelación.
4. Obligación condicional, subordinada a una condición suspensiva pendiente. Art. 1485 inc. 2. La facultad de repetir lo pagado puede ejercerse hasta antes del cumplimiento de la condición.

El pago de una obligación natural es debido. 2296 CC.

##### **2) Que el pago se haya hecho por error.**

La ley no asiste al que a sabiendas paga lo que no debe.

El error que determina al pago indebido, puede ser tanto de hecho como de derecho. Art. 2297 CC. El error de derecho no justifica la repetición cuando el que cumple una obligación natural lo hace en la equivocada creencia de que el acreedor podía exigirle el pago.

#### **PRUEBA DE LOS REQUISITOS DEL PAGO DE LO NO DEBIDO.**

Para intentar la acción hay que acreditar:

- 1. El hecho del pago**, sujetándose a la normativa probatoria general;
- 2. Acreditar que el pago era indebido.** Art. 2295 y 2298 CC.

**Prueba del error.** El error es indispensable para admitir la acción. ¿Quién debe probarlo?

- El pago a sabiendas de una deuda inexistente importa donación. Art. 1397 CC.
- El ánimo de donar no se presume (Art. 1393 y 2299 CC).
- Deberá probarse por quien pretende que hay donación.
- **Al demandado le corresponderá probar que no hubo error, sino cabal conocimiento por quien efectuó el pago.**

#### **14.4.2 EFECTOS DEL PAGO DE LO NO DEBIDO.**

**Obligación de restituir y alcance.** El pago de lo no debido genera la obligación de restituir lo indebidamente recibido. La cuantía de la obligación depende de su buena o mala fe.

- Buena fe del que recibió el pago:

- a) Si recibió dinero u otras cosas fungibles que no se le debían, es obligado a la restitución de otro tanto del mismo género y calidad;
- b) No es responsable de los deterioros o pérdidas de la especie que se le dio en el falso concepto de debérsele, aunque hayan sobrevenido por negligencia suya. Sólo responderá de la pérdida o deterioro cuando se haya hecho más rico.
- c) Si ha vendido la especie que se le dio como debida, es sólo obligado a restituir el precio de la venta, y a ceder las acciones que tenga contra el comprador que no le haya pagado íntegramente.

- Mala fe del que recibió el pago: recibe a sabiendas de que no se le debía.

- a) Si recibió dinero u otras cosas fungibles que no se le debían, es obligado a la restitución de otro tanto del mismo género y calidad, y los intereses corrientes;
- b) Si recibió una especie o cuerpo cierto, contrae todas las obligaciones del poseedor de mala fe. Responde de los deterioros que haya sufrido la cosa por un hecho o culpa suya, aunque no les haya aprovechado. Debe restituir los frutos y aún los que pudo percibir el solvens con mediana inteligencia y actividad.
- c) Si ha vendido la especie que se le dio como debida, es obligado como todo poseedor que dolosamente ha dejado de poseer.

**Acciones contra los terceros adquirentes.** El accipiens pudo enajenar lo recibido. La solución dependerá del título a que hayan adquirido y de la buena o mala fe.

**1. Adquirentes a título oneroso:**

- los adquirentes de buena fe, escapan de la persecución del que pagó erradamente.
- Si están de mala fe, el solvens puede accionar en su contra.

**2. Adquirentes a título gratuito: siempre tendrá acción y no importa la buena o mala fe del tercero. 2303-2301**

## 14.5 LA COMUNIDAD

### **1. Concepto.**

Es considerada en nuestro CC como un cuasicontrato, una fuente de las obligaciones y derechos recíprocos de los comuneros.

Art. 2304 CC. La *comunidad* de una cosa universal o singular, entre dos o más personas sin que ninguna de ellas haya contratado sociedad o celebrado otra convención relativa a la misma cosa, es una especie de cuasicontrato.

El cuasicontrato de comunidad supone ciertamente una comunidad. Sin embargo, no toda comunidad constituye un cuasicontrato.

El cuasicontrato de comunidad supone, que los comuneros no hayan convenido la manera como debe administrarse la cosa común. La ley, en tal caso, establece cómo debe realizarse esta administración y cuáles serán los derechos y obligaciones de los partícipes.

### **2. Origen de la comunidad**

Generalmente se produce sin que exista contrato (herederos por ejemplo). También puede tener origen contractual: varias personas compran una cosa en común.

El origen de la comunidad es indiferente. La circunstancia de que exista un contrato en el origen, no le quita el carácter de cuasicontrato, si los contratantes no dictaron las normas a que se sujetarán en sus relaciones recíprocas.

La comunidad **no es persona jurídica**. Los bienes comunes pertenecen a los comuneros pro indiviso; carece de patrimonio propio. El derecho de los comuneros en la cosa **debe ser de la misma naturaleza**. El derecho de cada uno de ellos está limitado por el de los demás. De ahí surgen los derechos y obligaciones recíprocos, sin necesidad de un convenio especial.

#### 14.5.1 DERECHOS DE LOS COMUNEROS EN LA COMUNIDAD.

Art. 2305 CC. El derecho de cada uno de los comuneros sobre la cosa común es el mismo que el de los socios en el haber social.

No puede entenderse en el sentido literal, porque contradice la naturaleza misma de la comunidad: los bienes pertenecen pro indiviso. El legislador lo que quiso fue referirse a las facultades de los comuneros de usar y gozar de los bienes comunes y a su administración. Se remitiría al Art. 2081 CC.

#### **1. Derecho de uso de las cosas comunes**

Puede usarlas en su uso personal, con tal que las emplee según su uso ordinario, y sin perjuicio del justo uso de los otros. Se limita: (1) uso ordinario; y (2) derecho



que le corresponde a los demás. 655 CPC

## **2. Gastos de conservación**

Cada comunero tiene derecho a obligar a los otros a que hagan con él los gastos necesarios para la conservación de las cosas comunes. Benefician a todos los comuneros y deben financiarlas de consuno. Sin esto, el diligente se vería complicado por la repetición que debería practicar.

## **3. Innovaciones en los bienes comunes**

Ninguno de los comuneros puede hacer innovaciones en los bienes comunes, sin el consentimiento de los otros.

## **4. Derecho de oponerse un comunero a los actos administrativos de los otros**

Cualquier comunero puede oponerse a los actos de administración de los otros. La oposición de 1, hace que el acto no se ejecute, pese a la voluntad en contrario de la mayoría. Éste es uno de los inconvenientes de la comunidad.

## **5. Administración pro indiviso**

El CPC previó la designación de un administrador pro indiviso. Esta designación le corresponde a la justicia ordinaria mientras no se ha constituido el juicio de partición o cuando falta el árbitro, y a éste en caso contrario (653 CPC). Ver 654 CPC normas procesales.

## **6. Contribución de los comuneros a las cargas y participación en los beneficios.**

Los comuneros participan de los beneficios de las cosas comunes y soportan las cargas de la comunidad en **proporción a sus cuotas**. Art. 2309 y 2310 CC.

Por lo anterior, es de suma importancia conocer **la cuota de cada comunero**. Nuestro CC es silente. No habiendo solución, se entienden que se dividen en partes iguales.

## **7. Deudas contraídas por un comunero.**

La comunidad no es una persona jurídica. Los comuneros no representan a la comunidad ni viceversa. Las deudas que contrae un comunero, en interés de la comunidad, gravitan exclusivamente en él. Tendrá acción contra los demás comuneros. Art. 2307 CC.

## **8. Deudas contraídas por los comuneros colectivamente.**

En principio, se dividen por partes iguales, salvo estipulación de solidaridad u otra forma de división.

El que paga más de lo que debe, tiene acción de reembolso contra los otros. Art.

2307 inc. 2 CC.

### **9. Responsabilidad de los comuneros y compensaciones debidas a la comunidad.**

En la administración de los bienes comunes, el comunero debe conducirse como un buen padre de familia y emplear una mediana diligencia. Art. 2308 CC culpa leve. Adeudará a la comunidad lo que saque de ella y deberá pagar intereses corrientes cuando tome dineros comunes para negocios particulares.

### **10. La cuota del comunero insolvente grava a los demás.**

Art. 2311 CC: se refiere a las prestaciones que se deben los comuneros entre sí. Difiere por ello del Art. 2095 CC.

### **11. Derecho del comunero para enajenar su cuota.**

El comunero puede enajenar su cuota, aún sin consentimiento de los restantes comuneros. Art. 1812 y 1312 CC.

### **12. Situación de los acreedores del comunero.**

Los bienes comunes pertenecen a los comuneros pro indiviso. Los acreedores del comunero sólo pueden perseguir la cuota que le corresponde al comunero que es deudor.

### **14.5.2. TERMINACIÓN DE LA COMUNIDAD. (Art. 2312 CC).**

- 1.** Por la **reunión de las cuotas de todos los comuneros en una sola persona**;
- 2.** Por la **destrucción de la cosa común**;
- 3.** Por la **división del haber común**. Se sujeta a las mismas reglas que la partición de la herencia (Art. 2313 CC).

### **Acción de partición**

La ley mira con malos ojos a la comunidad. Art. 1317 CC: nadie está obligado a permanecer en la indivisión. La división de la cosa común puede pedirse siempre, a menos que se haya convenido lo contrario, convención cuyos efectos no durarán más de 5 años.

Por ello, se dice que la acción de partición es **imprescriptible**. La prescripción no puede servir para establecer un estado permanente de indivisión.

La acción de partición acompaña siempre a la comunidad, pero no puede sobrevivirla. La comunidad puede terminar porque un comunero o un tercero adquieren por prescripción el dominio exclusivo. La acción de partición se extinguirá por vía consecencial.

## CAPÍTULO 15 CONTRATOS ALEATORIOS

### 15.1 ASPECTOS GENERALES

#### 1. Contratos onerosos

Los contratos onerosos se clasifican en:

**1. Conmutativos:** las prestaciones de las partes se miran como equivalentes, esto es, el beneficio que cada una recibe se reputa proporcionado al gravamen que soporta.

**2. Aleatorios:** un acontecimiento de ocurrencia incierta, dependiente del azar, hace que los contratantes corran un riesgo de ganancia o pérdida.

**El contrato es aleatorio para ambas partes.** La perspectiva de ganancia para una parte constituye una posibilidad de pérdida para la otra.

#### 2. Principales contratos aleatorios.

**Art. 2258 CC:**

1. Contrato de seguros;
2. Juego;
3. Apuesta;
4. Constitución de renta vitalicia; y
5. Constitución de censo vitalicio.

El CC sólo se ocupa de los cuatro últimos. El seguro y el juego, están regidos por el Ccom y por leyes especiales.

#### 3. Someras ideas acerca del contrato de seguro.

Art. 512 Ccom: el seguro es un contrato bilateral, condicional y aleatorio por el cual una persona natural o jurídica toma sobre sí por un determinado tiempo todos o algunos de los riesgos de pérdida o deterioro que corren ciertos objetos pertenecientes a otra persona, obligándose, mediante una retribución convenida, a indemnizarle la pérdida o cualquier otro daño estimable que sufran los objetos asegurados.

Se afirma por algunos que **no sería aleatorio**.

1. Es un contrato de indemnización meramente. Nunca puede ser causa de ganancia.
2. Se puede analizar de forma distinta, sea considerándolo en particular o tomando en cuenta un cúmulo de asegurados. Las primas, hoy por hoy, se calculan sobre bases científicas y las aseguradoras a su vez se reaseguran y efectúan reservas. Lo único aleatorio sería la ocurrencia del siniestro.

#### 4. Otros contratos aleatorios.

El CC sólo menciona los principales. El contrato es aleatorio, cada vez que en las prestaciones de las partes se encierra una contingencia incierta de ganancia o pérdida.

- a) Es aleatoria la cesión de derechos litigiosos;
- b) Venta de la suerte o la venta en que se libere al vendedor de toda obligación de garantía;
- c) Venta de la nuda propiedad en cuanto es incierto el momento en que el comprador percibirá las ventajas de la cosa comprada.

### 15.2 EL JUEGO Y LA APUESTA

#### 1. Concepto

El CC no los definió. El juego y la apuesta son contratos diferentes.

- **Juego:** contrato por el cual las partes, entregadas a un juego, se obligan a pagar al ganador una determinada suma de dinero o a realizar otra prestación.

- **Apuesta:** es un contrato en que las partes, en desacuerdo acerca de un acontecimiento cualquiera, convienen en que aquella cuya opinión resulte infundada pagará a la otra una suma de dinero o realizará otra prestación en su favor.

Ambos contratos difieren en el rol atribuido a las partes, activo en el juego y pasivo en la apuesta.

#### 2. Reglas aplicables al juego y la apuesta.

El Art. 2263 CC sólo se refiere al juego. El Art. 2261 CC sólo es aplicable a la apuesta. Las restantes disposiciones son comunes a ambos contratos.

#### A) El Juego

##### 1) Clasificación.

Juegos lícitos:

- a) juegos de inteligencia;
- b) juegos de destreza física o corporal.

Juegos ilícitos o de azar.

##### 2) Juegos ilícitos o de azar.

El legislador declara ilícito los juegos de azar: dependientes de la suerte. Objeto ilícito en las deudas contraídas en juegos de azar (Art. 1466 CC).

- El ganador no puede demandar el cumplimiento de las obligaciones que

derivan de este juego;

- el perdedor puede rehusarse al pago por medio de la excepción de nulidad.
- Pero una vez satisfecha la deuda de juego, el deudor carece de acción para recobrar lo que se haya dado o pagado por un objeto o causa ilícita a sabiendas.

El Código Penal considera ilícitos los juegos de azar que se practican en casa de juego de suerte, envite o azar.

Para Meza Barros son civilmente ilícitos incluso los autorizados. Sólo se abstendrían de la sanción penal. Vial opina en contrario.

### **3) Juegos lícitos con predominio de la inteligencia.**

No repudia la ley este tipo de juegos, pero no cree prudente darles plena eficacia a las obligaciones que derivan de ellos.

Art. 2260 CC. El juego y la apuesta no producen acción, sino solamente excepción. Así, en los juegos lícitos en que predomina el esfuerzo intelectual, se generan obligaciones meramente naturales.

### **4) Condiciones para que no pueda repetirse lo pagado.**

1. El que paga debe tener la libre administración de sus bienes (Art. 2262 y 1470 inc. final CC); y
2. Que no se haya ganado con dolo: trampa para obtener situación favorable.

### **5) Juegos de destreza física o corporal.**

Art. 2263 CC: producirán acción los juegos de fuerza o destreza corporal (...) con tal que en ellos no se contravenga a las leyes o a los reglamentos de policía.

Estos juegos, generan obligaciones civiles perfectas, siempre que se encuentren cumpliendo con las leyes y reglamentos policiales.

La contravención de estas normas genera que el juez desechará la demanda en todo (Art. 2263 inc. 2 CC).

## **B) La apuesta**

### **Clasificación.**

**1) Apuesta lícita:** no dan acción sino sólo excepción. Se rigen por las mismas normas que el juego en relación a la repetición.

Art. 2261 CC. Concepto peculiar del dolo: Hay dolo en el que hace la apuesta, si sabe de cierto que se ha de verificar o se ha verificado el hecho de que se trata.

Los terceros que vinculan una prestación a las resultas de un juego de destreza o fuerza corporal, igualmente serán apostadores, por lo que carecerán de acción.

**2) Apuesta ilícita:** incide en los juegos de envite o azar. Hay objeto ilícito en toda obligación contraída en juegos de azar, sea las que contraiga el jugador o un tercero apostador.

### **15.3 LA RENTA VITALICIA.**

#### **1) Concepto.**

Art. 2264 CC: La *constitución de renta vitalicia* es un contrato aleatorio en que una persona se obliga, a título oneroso, a pagar a otra una *renta* o pensión periódica, durante la vida natural de cualquiera de estas dos personas o de un tercero.

#### **2) Caracteres.**

- 1. Unilateral:** es una característica propia de los reales. Solamente se obliga quien debe pagar la pensión vitalicia. La prestación de la contraparte no es obligación, sino requisito del contrato.
- 2. Oneroso:** el obligado a pagar la renta contrae el compromiso a cambio de una contraprestación.
- 3. Aleatorio:** envuelve una contingencia incierta de ganancia o pérdida. Dependerá del azar, de la duración de la vida del acreedor o de un tercero.
- 4. Solemne:** debe otorgarse por escritura pública.
- 5. Real:** no se perfecciona, sino por la entrega del precio. No es perfecto, mientras el acreedor no realiza previamente la prestación a cambio de la cual se le deberá la renta o pensión.

#### **3) Renta vitalicia a título gratuito.**

Las características anteriores son las del contrato regulado por el CC. Pero suele tener caracteres diferentes.

- a) La renta puede no tener un origen contractual, sino en un testamento: legado;
- b) Puede constituirse, a título gratuito, por acto entre vivos: donación;
- c) No sería necesariamente aleatoria, por lo recién mencionado. 2278: cuando se constituye una renta vitalicia gratuitamente, no hay contrato aleatorio. Es una clasificación propia de los onerosos.
- d) La constitución de una renta vitalicia gratuita no es un contrato real: no es necesario la entrega de ningún precio que deba entregarse a cambio de la pensión.
- e) Se sujetará a las formas de los testamentos y de las donaciones.

#### **4) Precio de la renta vitalicia.**

La persona que ha contratado la renta, debe suministrar de antemano la prestación al futuro deudor.

2267: el precio de la renta vitalicia, o lo que se paga por el derecho de percibirla, puede consistir en dinero o en cosas raíces o muebles.

La renta o pensión. Mientras que el precio puede consistir en dinero u otros bienes, la pensión no podrá ser sino en dinero (Art. 2267 inc. 2 CC).

La renta representa, en parte, los intereses del capital que el constituyente enajena a fondo perdido. Sin embargo, la ley no limita el monto de la pensión en relación con el capital (Art. 2268 CC). Se diferencia con el mutuo, por el carácter aleatorio.

### **5) Beneficiario de la renta.**

Generalmente se constituye a favor de la persona que paga el precio.

Puede constituirse a favor de varias personas para que gocen de ella simultánea o sucesivamente.

Para impedir que la duración de la renta se extienda excesivamente, la ley exige que las personas que deben gozar de la renta **existan al tiempo del contrato** (2265).

Cuando se pacta a favor de un tercero, estamos frente a una estipulación a favor de otro.

### **6) Duración de la renta.**

La renta vitalicia se constituye, prácticamente, durante la vida de quien paga el precio. Su objetivo es asegurarle subsistencia mientras viva.

Pero también puede estipularse que se deba durante la vida del otro contratante o de un tercero ajeno al contrato.

### **7) Caso en que la renta se constituye por la vida de un tercero.**

Puede suceder que el tercero sobreviva a la persona que goza de ella. La renta subsiste y el derecho de percibirla corresponde a los sucesores.

### **8) Condiciones que debe reunir la persona de quien depende la duración de la renta.**

Es indispensable que esta persona exista al tiempo de la celebración. Art. 2266 y 2270 CC.

### **9) Efectos del contrato.**

#### **Obligaciones del deudor de la renta.**

#### **1. Pagar la renta.**

- 1) Se puede estipular que las rentas se paguen por períodos anticipados;

- 2) El deudor puede exigir en cada pago que se acredite la supervivencia de la persona de cuya existencia depende su duración (2275);
- 3) La renta, fruto civil, se devenga día a día (2276). Sin embargo, en caso de convenio de pago de renta anticipadamente, se deberá todo el año corriente, porque el deudor ya adquirió derecho de reclamarla.

Consecuencias de la falta de pago de la renta. Tiene derecho el acreedor para compeler al deudor a cumplir. 2272.

También goza del derecho para obligar al deudor moroso a prestar seguridades para el pago futuro.

Carece del derecho de pedir la resolución por falta de pago. El deudor tampoco puede pedir que se deje sin efecto, aún ofreciendo restituir el precio.

Las partes pueden modificar las reglas precedentes (2271).

**2. Suministrar las seguridades estipuladas.** Art. 2273 CC: el deudor se obliga a rendir caución de que cumplirá su obligación de pagar la renta.

### **10) Extinción de la renta vitalicia.**

1. Muerte de la persona de quien depende la duración de la renta: modo natural;
2. Resolución del contrato en caso de que el deudor no preste seguridades estipuladas; y
3. Prescripción. Art. 2277 CC: dejó de percibirse y demandarse por más de 5 años continuos.

## **15.4 EL CENSO VITALICIO.**

### **1) Concepto.**

Art. 2279 CC: La renta vitalicia se llama *censo vitalicio*, cuando se constituye sobre una finca dada que haya de pasar con esta carga a todo el que la posea.

El censo vitalicio, se diferencia de la renta, en que la obligación de pagar la renta o pensión no pesa sólo en la persona que se obliga, sino sobre todo aquél que adquiera la finca sobre la cual se ha impuesto el gravamen.

Se rige por las normas de la renta vitalicia y del censo. Art. 2283 y 2279 inc. 2 CC.



### **DIFERENCIAS DEL CENSO VITALICIO CON EL CENSO ORDINARIO.**

| <b>CENSO ORDINARIO</b>                                                                             | <b>CENSO VITALICIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perpetuo.                                                                                          | Temporal. Se puede estipular que el censo se deba durante la vida natural de varias personas que se designen, cesando con la del último sobreviviente. No valdrá para este objeto la designación de persona alguna que no exista al tiempo de fallecer el testador (cuando se constituyó por testamento), o de otorgarse la donación, o de perfeccionarse el contrato. |
| Es redimible: liberarse la propiedad, consignando el capital correspondiente.                      | Irredimible.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Divisible, cuando la finca acensuada se divida por causa de muerte.                                | Indivisible.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Puede reducirse cuando el valor de la finca excede considerablemente al valor del capital impuesto | No es susceptible de reducción.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

**Beneficiario del censo vitalicio.** Puede constituirse a favor de dos o más personas que lo gocen sucesiva o simultáneamente.

El beneficiario, en todo caso, debe existir al tiempo de fallecer el testador, al aceptarse la donación, o al perfeccionarse el contrato, según sea el caso.

## CAPÍTULO 16. CONTRATOS MODERNOS

### 16.1 ASPECTOS GENERALES

Las particularidades del tráfico económico moderno han obligado al mundo del derecho a reaccionar, generando un marco jurídico que se haga cargo de su nueva fisonomía y necesidades. Uno de los aspectos en que esto se hace especialmente patente es en la llamada contratación moderna, es decir en el cúmulo de nuevas figuras contractuales (ya sea originales o derivadas de figuras típicas) destinadas a organizar, disciplinar y brindar seguridad jurídica a la actividad mercantil.

Todas estas figuras que han encontrado su fuente en la práctica, básicamente comercial, no encuentran un tratamiento orgánico en nuestra legislación, tratándose, en su gran mayoría de contratos atípicos, siendo por tanto necesario determinar la naturaleza jurídica que cada una de estas figuras presenta para así identificar las normas especiales o comunes aplicables a ellas.

Ante la insuficiencia de la legislación interna en la regulación de estos contratos, el aporte del derecho internacional se presenta como determinante, tanto en su faceta de *lex mercatoria*, como en la elaboración de tratados y convenios sobre la materia, buscando establecer un derecho uniforme que regule el comercio internacional, destacando el aporte de UNCITRAL (Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional), la ICC (Cámara internacional de Comercio) y la UNIDROIT (Instituto para la Unificación del Derecho Privado)

podemos distinguir entre contratos de transporte, la compraventa mercantil, contratos de seguro, el leasing, electrónicos, bancarios y financieros, de transferencia tecnológica, de colaboración, etc.

### 16.2 EL FACTORING

#### **1. Concepto.**

*Complejo articulado* de servicios interdependientes y variables en el que destacan tres *funciones básicas*, denominadas gestión o prestación de servicios, garantía o asunción de riesgo y financiamiento, siendo esencial sólo la primera de estas funciones.

Se trata de un convenio de efectos permanentes entre la empresa de factoring o factor y su cliente, por medio del cual este último transfiere o se obliga a transferir todos o algunos de sus créditos al primero para que este efectúe su cobro; a su vez el factor puede asumir otras obligaciones como el riesgo del cobro, servicios complementarios de contabilidad y estudio de mercado, financiamiento, etc.

Si bien la única función propia del factoring es la gestión, este ha sido caracterizado en función de sus otras características, como una actividad financiera y de colaboración, ya que si bien no es esencial que el factor asuma el riesgo o financie a su cliente, estos son los rasgos que han permitido el crecimiento de esta institución,

toda vez que quienes recurren a esta figura lo hacen generalmente para obtener liquidez y simplificar su contabilidad.

El factoring nace en el derecho anglosajón y a través de su desarrollo y adaptación a las diferentes realidades ha ido adoptando diversas formas, así se distingue según su alcance entre old line factoring y new style factoring; según su ejecución entre aquel con o sin notificación; y según el financiamiento que otorgue entre factoring al vencimiento y con plazo.

## 2. Sujetos

En el contrato de factoring intervienen directamente sus partes, es decir el factor y el cliente, pero también debe considerarse a los deudores de este último que en virtud del factoring ven modificado su acreedor.

## 3. Objeto

La cesión de crédito puede recaer sobre uno o más créditos actuales con pago diferido, o bien sobre la cartera de créditos de un determinado cliente tanto presentes como futuros.

## 4. Regulación jurídica

**a.- Naturaleza jurídica:** Si bien no existe mayor preocupación doctrinaria sobre la materia, las principales proposiciones consideran al factoring como un contrato atípico, un negocio indirecto o bien como un contrato de colaboración empresarial.

**b.- Marco normativo:** El factoring es un contrato atípico por lo que su regulación queda entregada a la voluntad de las partes en todo aquello que no sea contra la ley, el orden público o las buenas costumbres, cabe destacar que se presenta por regla general como un contrato de adhesión en que el proponente es la empresa de factoring, por lo que deberá determinarse si es aplicable la normativa de protección al consumidor y en caso contrario (que será la regla general) aplicar en la interpretación contractual todas las normas de protección establecidas en el Código Civil.

Cuando la regulación convencional resulte insuficiente deberán llenarse los vacíos por medio de la analogía, es decir intentando reconducir las diversas operaciones que derivan del factoring a algún contrato tipificado en nuestro ordenamiento, así por ejemplo la cesión de créditos, el mutuo, prestación de servicios, etc. En todo caso no es extraño que sean las mismas partes al contratar quienes efectúen expresamente esta remisión.

## 5. El Factoring en Chile

En Chile el factoring se estructura sobre la base de la celebración de un contrato de factoring, en el cual se estipulan las normas generales por las cuales se han de regir

las partes, y se establecen sus obligaciones, con un plazo generalmente de un año prorrogable. El cliente se obliga a transferir los créditos provenientes de las ventas de productos y/o prestaciones de servicios de su giro que consten en los títulos respectivos, el factor a su turno se obliga a adquirir los mismos de conformidad a las condiciones generales que fija el mismo contrato.

La transferencia de los créditos se formalizará con posterioridad, a través de sucesivos actos traslativos, en los cuales se establece la posibilidad de que parte del valor de los créditos se pague al cliente anticipadamente.

Se establece así una relación contractual a plazo que permite al cliente transformar sus cuentas por cobrar en recursos líquidos, sin perjuicio de que el factor no asume el riesgo de la insolvencia de los terceros deudores.

El cliente antes de celebrar el contrato de factoring deberá presentar sus antecedentes tanto legales como financiero contables y tributarios al factor, junto con un detalle sobre quiénes son los terceros con los cuales contrata (cartera de clientes). Sobre la base de esta información el factor efectúa un estudio del cliente y sus deudores estableciendo su viabilidad y solvencia, y determinando la conveniencia del negocio.

Aceptado el negocio se celebra el contrato y se establece una "línea de financiamiento" a favor del cliente, esta lo faculta para transferir un monto anual de créditos al factor, y en ella la cartera de clientes se clasifica y cualifica, lo que se traduce en que del monto total asignado, podrá el cliente transferir un porcentaje por cada cliente.

El factor no asume el riesgo de la insolvencia de los terceros, es por esto que la línea de financiamiento es caucionada por medio de una garantía personal del cliente, representada por un pagaré extendido a la vista a favor del factor por el monto total de la línea.

Una vez realizado todo lo anterior la operación comenzará a materializarse por medio de una serie de transferencias sucesivas (no existe una cesión futura y global), seguidas de sus respectivas notificaciones. Para el caso que la cesión de alguno de los créditos no se formalice frente a terceros se incluye en el contrato de cesión un mandato especial e irrevocable de cobro a favor del cliente, a objeto de que recaude el crédito del factor.

### **16.3. CONTRATOS DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA**

Con el objetivo de competir en el mundo moderno las empresas intentan invertir en investigación y desarrollo, creando la tecnología adecuada para responder a las necesidades del mercado. Las empresas una vez que obtienen estos conocimientos buscan su protección jurídica, al respecto valga destacar, en primer lugar que opera a su respecto la protección al derecho de propiedad y en cuanto creación del intelecto humano se le aplica también la normativa especial de propiedad industrial.

Así quienes desarrollan esta tecnología pueden optar entre obtener a su respecto una patente, registro de una marca, modelo o diseño industrial, o bien, tratándose de conocimientos que prefieren mantener en secreto no registrarlos disponiendo de ellos simplemente conforme al régimen general de la propiedad.

Las empresas que poseen estos activos intangibles pueden interesarse en transferirlos a otras a cambio de una contraprestación.

Como el mero régimen clásico de protección de la propiedad industrial con los avances quedó obsoleto, se han ido configurando diversas figuras jurídicas para llevar a cabo el traspaso, a saber: los contratos de licencia, know-how y engineering.

## **A) LICENCIA**

### **1. Concepto.**

“Existe contrato de licencia o royalty, cuando el titular o dueño de un privilegio industrial otorga a otra persona el uso y/o goce temporal de ella por una prestación en dinero u otros bienes. Esta remuneración también se acostumbra denominarla royalty o regalía” (Álvaro Puelma)

### **2. Elementos de la definición.**

- Titular o dueño de un privilegio industrial: El privilegio industrial comprende los derechos derivados de las marcas comerciales, patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales.
- Uso y/o goce temporal: La extensión del contrato dependerá de los fines que busquen las partes y la forma que adopte el contrato. Es esencialmente temporal porque la protección registral lo es.
- Contraprestación: Si bien la licencia puede ser gratuita es de escasísima ocurrencia que así sea, por lo que lo general será pactar un royalty o regalía, que equivale al precio que se paga por el uso y/o goce del privilegio y que puede corresponder a una suma única, un porcentaje de las utilidades del licenciataria, una cantidad fija pagadera a intervalos periódicos, etc.

## **B) KNOW-HOW**

### **1. Concepto**

Existe know-how cuando un proveedor se compromete a transmitir un conocimiento técnico más o menos secreto, consistente en un conjunto de invenciones, procesos, fórmulas o diseños no patentados o no patentables que incluyen experiencia y habilidad técnica acumulada, a un receptor que gozará de sus beneficios y quien se obliga a pagar un precio o royalty y no revelar el conocimiento a terceros.

### **2. Elementos de la definición**

- Proveedor que transmite un conjunto de conocimientos técnicos
- El conocimiento debe revestir el carácter de secreto o al menos reservado.

- El conocimiento transmitido puede consistir en toda clase de conocimientos de carácter reservados, ya sea relativos al proceso de producción, de comercialización, propaganda, organización empresarial, computacional, y en general todo aquellos destinado a hacer posible el éxito de la actividad de que se trate.
- El receptor debe adquirir una utilidad comercial del know-how celebrado.

#### **16.4 CONTRATOS DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL**

El éxito de una empresa no se mide hoy simplemente en virtud de la ganancia que pueda obtener comparando sus costos de producción v/s precio de venta de sus bienes o servicios, el concepto imperante actualmente es el de eficiencia, la que se logra básicamente potenciando las propias fortalezas y buscando asociarse con terceros que se hagan cargo de aquellas áreas cuyo desarrollo importa una significativa pérdida de recursos y tiempo a la empresa y que sin embargo constituyen el giro de estos terceros, por lo que no solamente podrán desarrollarlos a un menor costo, sino también en forma más profesional. Estos objetivos se logran a través de los contratos de colaboración empresarial.

Estas figuras se denominan contratos de colaboración empresarial toda vez que a través de ellas se persigue una utilidad para todas las partes contratantes, existiendo, por regla general, entre ellas un vínculo de igualdad.

Estas colaboraciones pueden consistir en servicios destinados a buscar clientes, determinación de funciones reciprocas determinadas a llegar en forma más eficiente al consumidor final, finalmente pueden consistir en estrategias económicas de reemplazo de la competencia.

### **FRANQUICIA**

#### **1. Concepto.**

La franquicia es un acuerdo entre dos o más personas por el cual a una parte, denominada franquiciado, se le concede el derecho de ingresar en el negocio de ofrecer, vender o distribuir bienes o servicios bajo el plan de mercadeo o sistema prescrito o sugerido en parte sustancial por la otra parte, el franquiciante, y la operación del negocio del franquiciado de acuerdo con este plan o sistema, está materialmente asociada con la marca del franquiciante, su nombre comercial, logotipo, publicidad o cualquier otro símbolo de este o alguna de sus afiliadas, y la persona a quien se le concede el derecho de ingresar a dicho negocio se le requiere a pagar directa o indirectamente una suma o franquicia.

Se trata por lo tanto de una operación que involucra una serie de actos jurídicos que lo integran o le sirven de soporte, destinado a que el franquiciado explote comercialmente bajo su riesgo empresarial pero bajo las directrices del franquiciante los bienes o servicios objeto del acuerdo.

## **JOINT VENTURE**

### **1. Concepto.**

El joint venture puede definirse según sus rasgos definitorios como una figura jurídica de asociación que puede dar origen o no a una nueva entidad constituida entre empresas, instituciones o entidades que conservan su autonomía como tales, con la finalidad de llevar a cabo un negocio único o varios proyectos relacionados entre sí.

### **2. Características.**

Esta definición resulta de la sistematización de los rasgos que definen la institución, que le confieren una individualidad e identidad jurídica única e independiente. Estos rasgos son:

- Se trata de una figura encuadrable dentro del género de las asociaciones, toda vez que al convenir un joint venture, las partes buscan dar nacimiento a una asociación en el sentido amplio del término, esto es, formar una agrupación de personas dotada de una cierta organización, que tiene por objeto llevar a cabo un emprendimiento común.
- Tiene naturaleza contractual y dentro de los contratos es uno de colaboración empresarial, ya que crea vínculos entre empresas independientes, generando una especie de integración parcial, pero manteniendo la autonomía económica y jurídica de cada parte. Es un instrumento para unir capacidades empresariales en un plano de igualdad con el objetivo de obtener mayor éxito en la consecución de ciertas metas predeterminadas, por medio de una organización común.
- Constituye una empresa en el sentido económico del término, es decir, se crea una nueva capacidad de producción, de tecnología o de elaboración de nuevos productos o servicios. Organiza diversos factores productivos, aportados por las distintas partes para la explotación o desarrollo de una actividad conjunta, generalmente, aunque no necesariamente, de naturaleza económica.
- Naturaleza *siu generis*, es por un lado una entidad asociativa no societaria y por el otro una forma contractual de colaboración.

## ANEXOS

### ANEXO: PARALELO OBLIGACIÓN DINERARIO Y OBLIGACIÓN DE CRÉDITO O DINERO.

|                                                                                                                                                                                                           | Obligación dineraria.                                                                                                                               | Operaciones de crédito de dinero                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Reajustabilidad</b>                                                                                                                                                                                    | Pueden las partes acordar cláusulas de reajustabilidad, adoptando al efecto las que juzguen adecuadas (UF, IPC, etc.)                               | La Ley 18.010 ha dejado entregado este aspecto a lo que acuerden las partes contratantes, pudiendo pactar la fórmula que estimen conveniente. Pero si en estas deudas interviene un banco, institución financiera o cooperativa de ahorro y crédito, el sistema de reajuste debe autorizarlo el Banco Central. |
| <b>Prepago</b>                                                                                                                                                                                            | El prepago sólo se permite cuando no se han convenido intereses.                                                                                    | <b>El deudor de una operación de crédito de dinero puede anticipar su pago</b> Así lo establece el Art. 10 Ley 18.010, lo que es una excepción a la regla establecida para el mutuo en el Art. 2204 CC. La facultad de prepagar es irrenunciable.                                                              |
| <b>Forma de pago de los intereses</b> Interés: toda suma de dinero que el acreedor recibe o tiene derecho a recibir por sobre el capital o el capital reajustado en su caso/ Renta que produce un capital | Se pueden pactar en dinero o cosas fungibles (Art. 2205 CC),                                                                                        | En las operaciones reguladas por la Ley 18.010 sólo pueden pactarse en dinero (Art. 11 inc. 1º Ley 18.010).                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Naturaleza de la obligación de pagar intereses:</b><br><b>No se relaciona con la presunción de</b>                                                                                                     | <b>Accidentales (se presume gratuidad)</b> Las simples obligaciones de dinero <u>sólo generan intereses cuando las partes lo convienen o la ley</u> | En las operaciones de crédito de dinero, la regla se invierte: <b>no se presume la gratuidad</b> , y salvo disposición de ley o pacto en contrario, devengan                                                                                                                                                   |



|                                   |                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>gratuidad.</b>                 | <u>lo establece.</u> Pero si son pagados sin estar estipulados, no pueden repetirse (Art. 2209 CC).                                                                                                                         | interés corriente (Art. 12 Ley 18.010).             |
| <b>Anatocismo</b>                 | No prohibido                                                                                                                                                                                                                | Expresamente permitido                              |
| <b>Sanción al interés usurero</b> | Intereses de la obligación principal: 2206 (Reducción al interés corriente)<br>Intereses pactados por la mora: 1544 aplicable a la cláusula penal (el interés moratorio se reduce al máximo de interés permitido estipular) | Art. 8 Ley 18.010 (Reducción al interés corriente). |